CONFORME novo CPC

Cristiano Chaves de Farias
Nelson Rosenvald

CURSO DE DIREITO CIVIL

Parte Geral e LINDB

De acordo com o Novo CPC e o Estatuto da Pessoa com Deficiência

EDITORA JusPODIVM
www.editorajuspodivm.com.br

15ª EDIÇÃO
revista, ampliada e atualizada

1

Cristiano Chaves de Farias
Nelson Rosenvald

CURSO DE DIREITO CIVIL

Parte Geral e LINDB

CONFORME NOVO CPC

15ª EDIÇÃO

revista, ampliada e atualizada

1

2017

EDITORA JusPODIVM
www.editorajuspodivm.com.br

EDITORA
*Jus*PODIVM
www.editorajuspodivm.com.br

Rua Mato Grosso, 175 – Pituba, CEP: 41830-151 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3363-8617 / Fax: (71) 3363-5050
• E-mail: fale@editorajuspodivm.com.br

Copyright: Edições *Jus*PODIVM

Conselho Editorial: Eduardo Viana Portela Neves, Dirley da Cunha Jr., Leonardo de Medeiros Garcia, Fredie Didier Jr., José Henrique Mouta, José Marcelo Vigliar, Marcos Ehrhardt Júnior, Nestor Távora, Robrio Nunes Filho, Roberval Rocha Ferreira Filho, Rodolfo Pamplona Filho, Rodrigo Reis Mazzei e Rogério Sanches Cunha.

Capa: Rene Bueno e Daniela Jardim *(www.buenojardim.com.br)*

F224c Farias, Cristiano Chaves de
Curso de direito civil: parte geral e LINDB / Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald – 15. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.
880 p.

Bibliografia.
ISBN 978-85-442-1102-1.

1. Direito civil. 2. Parte geral. I. Título.

CDD 342.11

Todos os direitos desta edição reservados a Edições *Jus*PODIVM.

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor e da Edições *Jus*PODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis.

CAPÍTULO III

A Personalidade Jurídica e os Direitos da Personalidade

Sumário • 1. A Dignidade da Pessoa Humana como Valor Fundamental do Ordenamento Jurídico Brasileiro; 2. A Pessoa; 2.1 Generalidades; 2.2 Espécies de pessoas; 3. A Personalidade Jurídica; 4. Os Direitos da Personalidade; 4.1 Breve escorço histórico; 4.2 Noções conceituais: das velhas definições ao dogma fundamental do Direito Civil-Constitucional; 4.3 Fontes; 4.4 Características; 4.5 As liberdades públicas e os direitos da personalidade; 4.6 A possibilidade de colisão entre os direitos da personalidade e a *liberdade de imprensa*, ou a *liberdade de expressão*, e o critério de solução adequado (inadmissibilidade do *hate speech*) e o direito de resposta; 4.7 A liberdade de expressão, os direitos da personalidade e a publicação das biografias não autorizadas; 4.8 O direito (da personalidade) ao esquecimento e a liberdade de imprensa; 4.9 A proteção dos direitos da personalidade e a insuficiência dos argumentos clássicos: a tutela avançada (preventiva e repressiva) dos direitos da personalidade; 4.10 A proteção da personalidade da pessoa morta e os lesados indiretos; 4.11 Classificação dos direitos da personalidade; 5. O Nome Civil; 5.1 Noções conceituais e características; 5.2 Elementos componentes do nome civil; 5.3 O princípio da inalterabilidade relativa e as hipóteses de alteração do nome civil; 5.4 Hipóteses controvertidas de mudança do nome civil; 5.5 O nome comercial; 5.6 A tutela jurídica do nome civil.

"Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é..."

***(Dom de iludir*, de Caetano Veloso)**

1. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO VALOR FUNDAMENTAL DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Em que pese ser da tradição dos clássicos (e importantes) "manuais" de Direito Civil, na literatura jurídica brasileira, introduzir o estudo do capítulo pertinente à personalidade jurídica com os conceitos fundamentais de pessoa e de personalidade jurídica, encarecemos vênia ao leitor para tecer relevantes considerações sobre o macroprincípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sem o qual a análise da teoria da personalidade e da proteção fundamental que dela decorre tornar-se-iam vazias, caindo em verdadeiro marasmo formalista, despido de significado concreto.

É que se apresenta imperiosa a projeção da personalidade humana em seus aspectos verdadeiros, a partir das múltiplas e variadas atividades desenvolvidas modernamente pelo ser humano em nossa sociedade - aberta, plural e multifacetada.

E o viés que permitirá a unificação da personalidade jurídica ao derredor de uma ideia central é exatamente o princípio maior, constitucionalmente afirmado: a *dignidade da pessoa humana*. Por isso, impende lembrar, nesse ponto, que o Direito Civil não pode, de forma alguma, distanciar-se da normatividade constitucional, impondo-se a estrita obediência às premissas fundamentais postas na Lei Fundamental, pois consistem nos valores mais relevantes da ordem jurídica brasileira.

Nessa trilha de raciocínio, repita-se à saciedade que o mais precioso valor da ordem jurídica brasileira, erigido como fundamental pela Constituição de 1988, é a *dignidade humana*, vinculando o conteúdo das regras acerca da personalidade jurídica. Assim, como consectário, impõe reconhecer a elevação do ser humano ao centro de todo o sistema jurídico, no sentido de que as normas são feitas para a pessoa e para a sua realização existencial, devendo garantir um mínimo de direitos fundamentais que sejam vocacionados para lhe proporcionar vida com dignidade.

Enfim, o postulado fundamental da ordem jurídica brasileira é a dignidade humana, enfeixando todos os valores e direitos que podem ser reconhecidos à pessoa humana, englobando a afirmação de sua integridade física, psíquica e intelectual, além de garantir a sua autonomia e livre desenvolvimento da personalidade.

Com Gustavo Tepedino, "a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, associada ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da marginalização, e de redução das desigualdades sociais, juntamente com a previsão do § 2° do art. 5°, no sentido da não exclusão de quaisquer direitos e garantias, mesmo que não expressos, desde que decorrentes dos princípios adotados pelo texto maior, configuram uma verdadeira *cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana*, tomada como valor máximo pelo ordenamento".[1]

1. TEPEDINO, Gustavo. *Temas de Direito Civil*, op. cit., p. 48. Elimar Szaniawski, a outro giro, denomina a dignidade humana com a expressão *direito-mãe*, por ser a fonte de inúmeros outros direitos, que se unem para a tutela avançada da personalidade jurídica. Cf. *Direitos de personalidade e sua tutela*, op. cit., p. 61.

Também a Constituição alemã trilha a mesma senda. Veja-se, a propósito, a redação do art. 1º da Lei Fundamental tedesca: "a dignidade do homem é inviolável".

Importante frisar que a dignidade humana não é criação da ordem constitucional, muito embora seja por ela tutelada. Note-se que a Constituição da República não criou a dignidade, apenas lhe atribuiu "o valor supremo de alicerce da ordem jurídica democrática", como percebe Maria Celina Bodin de Moraes,[2] passando o referido valor a permear todas as relações jurídicas entabuladas em nosso país.

Nessa ordem de ideias, a *dignidade da pessoa humana* serve como mola de propulsão da intangibilidade da vida humana, dela defluindo como consectários naturais: (*i*) *o respeito à integridade física e psíquica das pessoas*; (*ii*) *a admissão da existência de pressupostos materiais (patrimoniais, inclusive) mínimos para que se possa viver*; e (*iii*) *o respeito pelas condições fundamentais de liberdade e igualdade.*[3]

Enfim, é o valor máximo da ordem jurídica brasileira. É o centro de gravidade ao derredor do qual se posicionaram todas as normas jurídicas. Uma espécie de *Aleph*, imaginado pela pena sensível do literata argentino Jorge Luís Borges: um lugar onde tudo (o grande universo e suas muitas coisas) converge ao mesmo tempo e em um só ponto, fluindo e confluindo.[4]

Dessas ideias, exsurge lícita a conclusão de que o ordenamento jurídico não mais assegura, apenas, o direito à vida, mas, necessariamente, reconhece e tutela o direito a uma *vida digna.*[5]

Aliás, sobreleva sublinhar que a dignidade da pessoa humana, enquanto o valor jurídico máximo do sistema, traz consigo, naturalmente, uma dupla face: de um lado, tem uma eficácia positiva e, de outra banda, uma eficácia negativa. A eficácia positiva serve para vincular todo o tecido normativo infraconstitucional à afirmação da dignidade. Ou seja, são impostas obrigações ao Estado e aos particulares para a

2. MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à pessoa humana*, op. cit., p. 83.

3. Com esse pensar, Antônio Junqueira de Azevedo. "A caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana", op. cit., p. 3-24.

4. Fazendo múltiplas referências à obra de Jorge Luís Borges e ao *Aleph*, como esse grande ponto imaginário de confluência, vide a obra *O cantor de tango*, do romancista portenho Tomás Eloy Martinez. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. O protagonista do livro é um doutorando nova-iorquino que pesquisa as origens do tango, segundo Jorge Luis Borges. No início do século, o acadêmico toma conhecimento da existência de um cantor argentino à moda antiga, capaz de reviver o espírito original do gênero portenho. Como, no entanto, não há gravações dessa voz milagrosa, decide viajar a Buenos Aires apenas para ouvi-la. O livro é um registro da busca desse cantor dos cantores, que se vai revelando muito mais difícil, perturbadora e apaixonante do que seu protagonista pode num primeiro momento suspeitar. As peripécias do protagonista na pista do cantor vão oferecendo uma visão estranhada da Buenos Aires de hoje e servindo de vetor para uma série de narrações, fragmentos da memória da cidade, desde suas duas conflituosas fundações até os horrores da ditadura, passando por um rosário de pequenas e grandes tragédias. Uma viagem insólita por uma Buenos Aires não conhecida, uma cidade-esfinge tão bela e, paradoxalmente, desconhecida.

5. Gláucia Correa Retamozo Barcelos Alves, em texto dedicado à análise do tema e com aguçada sensibilidade, proclama que "a dignidade do homem reside no fato de ele ser indefinível. O homem é como é, porque reconhece essa dignidade em si mesmo e nos outros homens. Kant o disse de maneira maravilhosamente simples: nenhum homem pode ser, para outro, apenas meio; cada homem é um fim em si mesmo" ("Sobre a dignidade da pessoa", op. cit., p. 228).

afirmação da dignidade. A outro giro, a sua eficácia negativa serve como restrição, ao Poder Público e às pessoas como um todo, ao exercício de determinados direitos.

Bem por isso, o sistema jurídico de proteção da personalidade jurídica precisa estar antenado nesse objetivo constitucional de garantir a todos uma vida digna, através das suas eficácias positiva e negativa.

Em sendo assim, é particularmente feliz a colocação de Rafael Garcia Rodrigues no sentido de que "na experiência brasileira, a Constituição Federal é um marco, pois ancorou como fundamento da República a prioridade à dignidade da pessoa humana (art. 1º, I e III), de forma a orientar toda atividade legislativa, estatal ou privada à consecução do projeto de realização do indivíduo como interesse superior e primeiro. Logo, toda *a normativa civil deve não apenas ocupar-se do momento patológico do dano em indenização (responsabilidade civil), mas orientar-se no sentido de dirigir a atividade privada à concretização e efetivação da dignidade da pessoa humana*".[6]

Assim, o reconhecimento da fundamentalidade do princípio da dignidade da pessoa humana impõe uma nova postura aos civilistas modernos, que devem, na interpretação e aplicação de normas e conceitos jurídicos, assegurar a vida humana de forma integral e prioritária.

"A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que leva consigo a pretensão ao respeito por parte dos demais", como consignou o Tribunal Constitucional da Espanha.[7]

Exaurindo as inúmeras vertentes que decorrem da matéria, Ingo Wolfgang Sarlet estabelece que dignidade da pessoa humana é a "qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos".[8]

Dignidade da pessoa humana, nessa ordem de ideias, expressa uma gama de valores humanizadores e civilizatórios incorporados ao sistema jurídico brasileiro, com reflexos multidisciplinares.

Equivale a dizer: todas as normas jurídicas do Direito Civil (e, é claro, dos demais ramos da ciência jurídica) relativas à personalidade jurídica e aos direitos da personalidade precisam estar vocacionadas à dignidade do homem.

---

6. RODRIGUES, Rafael Garcia. "A pessoa e o ser humano no novo Código Civil", op. cit., p. 33.
7. ApudSARLET, Ingo Wolfgang. *Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais*, op. cit., p. 42.
8. SARLET, Ingo Wolfgang. *Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais*, op. cit., p. 60.

É preciso, porém, ir mais longe. Ultrapassando o caráter de mera pretensão abstrata ou de simples promessa do constituinte, já é chegada a hora de *efetivar* no caso concreto, no cotidiano jurídico, a dignidade humana. Equivale a dizer: impende exigir, contemporaneamente, que o valor fundamental do sistema jurídico, concretamente, permeie todo o tecido normativo do Direito Civil. Ou seja, é preciso funcionalizar os institutos privados aos valores constitucionais, fazendo com que a propriedade, a responsabilidade civil, os contratos, a família e a sucessão estejam parametrizados pela dignidade humana, servindo como mecanismos efetivos de sua materialização.[9]

Surge, pois, em razão dessa nova perspectiva jurídica proporcionada pela *Lex Mater*, um conceito contemporâneo de personalidade jurídica, desenhada a partir de um *"mínimo ético"* e de um *"mínimo existencial"*, que não podem ser violados nem pelo Poder Público, nem pelos demais membros da sociedade privada.[10] Portanto, a personalidade jurídica não mais pode estar represada na ideia pura e simples de aptidão para ser sujeito de direito. Muito mais do que isso, a personalidade jurídica, antenada no valor máximo da dignidade humana, diz respeito ao reconhecimento de um mínimo de garantias e de direitos fundamentais, reconhecidos à pessoa para que possa viver dignamente.[11]

Em quadro conclusivo, é lícito verberar que o reconhecimento da fundamentalidade da *dignidade da pessoa humana* produz como consectário lógico a reapreciação (em outras palavras, uma revisita) dos velhos institutos (e dogmas) civilísticos, dentre os quais, a personalidade jurídica, a autonomia da vontade, o patrimônio, o contrato, a propriedade e a família.[12]

---

9. No campo do Direito Penal, com esse espírito, o Pretório Excelso, julgando um *habeas corpus* impetrado em favor do gerente de uma entidade bancária estatal, buscou dar efetividade à dignidade humana. O caso dizia respeito à determinação de uma penhora sobre conta-corrente de um cliente do banco, vindo o gerente a promover o bloqueio do valor constante no mandado. Todavia, entendendo o Oficial de Justiça que a penhora deveria recair em metade do valor disponível na conta, deu ordem de prisão em flagrante ao gerente. O Ministro Gilmar Mendes, relator do *habeas corpus*, realçou que a *desproporcionalidade* entre a ordem de prisão e a conduta do gerente tornou-se ainda mais gritante quando considerado o postulado essencial da dignidade humana. Acrescentou que o princípio da dignidade da pessoa humana proíbe "o uso ou a transformação do ser humano em objeto de degradação dos processos e ações estatais, pois seria dever estatal respeitar e proteger o indivíduo contra diversos tipos de ofensas e humilhações" (STF, Ac. unân., 2a T., *HC* 82.969/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 4.10.03).

10. Sobre o assunto, com referências à obra de Hans Welzel, consulte-se Marcos de Campos Ludwig. "O direito ao livre desenvolvimento da personalidade na Alemanha e possibilidades de sua aplicação no direito privado brasileiro", op. cit., p. 287.

11. Vale registrar, inclusive, que, fulcrada nessa perspectiva de garantir o *mínimo existencial*, foi editada a Lei nº 11.346/06, que reconhece como um verdadeiro direito fundamental do ser humano a alimentação adequada (art. 2º), impondo-se, de um lado, ao Poder Público a adoção de providências cabíveis (ações afirmativas) para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população e, de outra banda, ao particular que preste alimentos a alguém a obrigação de fazê-lo adequadamente. Em outras palavras: as latitudes e longitudes do direito à vida digna garantem não apenas o direito a se alimentar, mas o direito de se alimentar adequadamente e com segurança.

12. Vale aqui a referência ao estudo de Alexandre dos Santos Cunha. "Dignidade da pessoa humana: conceito fundamental de Direito Civil", op. cit., p. 261.

Avulta, assim, um novo comportamento nos juristas (normalmente refratários a mudanças), garantindo a utilidade social da ciência jurídica. Até porque, como bem adverte Daniel Sarmento, "a realização concreta do valor da pessoa humana não depende só do Direito. *Depende muito mais da consolidação, nos corações e mentes, de uma ética altruísta, voltada para 'o outro'*".[13]

Talvez se justifique nessa ambiência o vaticínio de Luís Roberto Barroso, no sentido de que a efetividade dos valores constitucionais resulta na "volta aos valores, na reaproximação entre ética e Direito",[14] deixando antever a necessidade premente de uma nova perspectiva e compromisso do profissional da ciência jurídica.

O Direito Civil, assim, assume importantíssimo papel na promoção da valorização da pessoa humana e, consequentemente, na construção de uma sociedade mais solidária e justa, o que passa pela compreensão correta do alcance da personalidade jurídica e dos fundamentais direitos da personalidade, conectados à legalidade constitucional, em especial à afirmação da dignidade da pessoa humana.

2. A PESSOA

2.1 Generalidades

É certo afirmar que *pessoa* é todo aquele sujeito de direitos. É, enfim, aquele que titulariza relações jurídicas na órbita do Direito, podendo se apresentar como sujeito ativo ou como sujeito passivo, além de reclamar um mínimo de proteção necessária ao desempenho de suas atividades.

Em um primeiro raciocínio, poder-se-ia afirmar que pessoa é toda criatura humana.[15] Todavia, essa ideia não é completa por excluir os entes morais (pessoas jurídicas), a quem a lei, também, atribui personalidade para praticar atos da vida civil.

Ou seja, o vocábulo *pessoa* comporta diferentes signos. Tem um significado vulgar – reportando-se ao ser humano – e outro jurídico, mais amplo, agasalhando, além das pessoas humanas, também as pessoas jurídicas. No ponto, é relevante apresentar uma advertência: o conceito *jurídico de pessoa* não se confunde com a sua conceituação *antropológica, filosófica, biológica, psicológica...* A ciência jurídica parte de uma premissa distinta, estabelecendo como ponto fundante o referencial de que a pessoa é o *sujeito de direito*, aquele que pode titularizar relações jurídicas.

---

13. SARMENTO, Daniel. *Direitos fundamentais e relações privadas*, op. cit., p. 379.
14. BARROSO, Luís Roberto. "Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional Brasileiro", op. cit., p. 28.
15. Washington de Barros Monteiro percebe a origem do vocábulo *pessoa* na locução latina *persona*,oriunda da linguagem teatral, designando máscara e, em seguida, o papel, a atuação do ator. Daí concluir pela existência de três acepções da palavra: (*a*)uma *vulgar*, sinônimo de ser humano; (*b*)outra *filosófica*, designando o ente dotado de razão, realizando um fim consciente; (*c*) e, finalmente, uma acepção *jurídica*, designando o ente físico ou moral, susceptível de direitos e obrigações, sendo este último o conceito que interessa ao Direito. *Curso de Direito Civil*, op. cit., p. 56.

Assim, afigura-se mais completa a ideia de que pessoa é todo e qualquer ente físico ou coletivo susceptível de direitos e obrigações. Sinônimo de sujeito de direitos",[16] como salienta Maria Helena Diniz.

Nessa linha de intelecção, chega-se à conclusão de que pessoa é o ente capaz de exercer direitos e submeter-se a deveres, na órbita da ciência do Direito. Ou seja, é aquele que poderá se apresentar no polo ativo ou passivo de uma relação jurídica.

Não se pode ignorar, contudo, que, singrando os mares da constitucionalização do Direito Civil, é de se reconhecer que ser pessoa não pode significar, tão somente, a possibilidade de titularizar relações jurídicas. É preciso lembrar que a pessoa tem uma existência (que deve ser digna). Bem por isso, ser pessoa significa, em concreto, poder ser sujeito das inúmeras relações jurídicas, sempre dispondo de uma proteção básica e elementar, tendendo a promover a sua inexorável dignidade.

Pessoa, enfim, é o *sujeito das relações jurídicas* que traz consigo um mínimo de proteção fundamental, necessária para realizar tais atividades, compatível e adequada às suas características (que são os direitos da personalidade).

2.2 Espécies de pessoas

Invocando, uma vez mais, as sábias palavras de Washington de Barros Monteiro, "duas são as espécies de pessoas reconhecidas pela ordem jurídica: *a pessoa natural*, também chamada de física (o homem, ou melhor, o ente humano, o ser humano), e a *pessoa jurídica*, igualmente denominada pessoa moral ou pessoa coletiva (agrupamentos humanos visando a fins de interesse comum)".[17]

Desse modo, sobreleva afirmar o conceito de pessoa – enquanto sujeito de direito – abrangendo, a um só tempo, as *pessoas naturais* (também chamadas de *pessoas físicas*) e as *pessoas jurídicas* (também ditas *pessoas coletivas*), ambas podendo titularizar relações jurídicas, como sujeito ativo ou passivo, bem como tendo reconhecida uma proteção fundamental, consistente nos direitos da personalidade. E titularidade de um direito é, na visão sempre percuciente de Francisco Amaral, "a união do sujeito com esse direito", uma vez que "não há sujeitos sem direitos, como não há direitos sem titular".[18]

Pessoa natural e pessoa jurídica são, portanto, as duas diferentes espécies de pessoas – isto é, de potenciais sujeitos de direito, a quem se reconhece uma proteção fundamental.

De um lado, é fácil perceber que a *pessoa natural* (ou *pessoa física*) é o ente provido de estrutura biopsicológica, trazendo consigo uma complexa estrutura humana,

16. DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro*, op. cit., p. 115.
17. MONTEIRO, Washington de Barros. *Curso de Direito Civil*, op. cit., p. 57.
18. AMARAL, Francisco. *Direito Civil*:introdução,op. cit., p. 218.

composta de corpo, alma e intelecto. É, enfim, o ser humano nascido com vida. É a pessoa humana, criada à imagem e semelhança do Criador, como lembra o trecho bíblico. Veja-se, inclusive, não mais ser possível afirmar que a pessoa natural seria um ser necessariamente criado de modo biológico, em razão dos mecanismos científicos de concepção humana artificial, atualmente existentes, como a fertilização *in vitro* e a inseminação artificial.

Aliás, convém sublinhar que a compreensão da pessoa humana está indissociavelmente unida tanto à dimensão individual, quanto à dimensão social do ser humano. Impossível a análise da personalidade jurídica humana suprimindo qualquer dessas dimensões do ser. Bem oportuna, a propósito, a lembrança da narrativa literária de Machado de Assis, através do personagem Jacobina, na sua clássica obra *O espelho*,[19] esclarecendo que "cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro [...]; as duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades perde naturalmente metade da existência; e casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira".[20]

A outro giro, a *pessoa jurídica* é a entidade formada pela soma de esforços de pessoas naturais ou por uma destinação específica de patrimônio, visando, numa hipótese ou na outra, a consecução de uma finalidade específica e constituída na forma da lei. Em outras palavras, é um ente formado pelo conjunto de pessoas naturais ou por um acervo patrimonial afetado para uma finalidade, ganhando personalidade jurídica e patrimônio próprios, autônomos, distintos de seus instituidores.

A toda e qualquer pessoa, vale frisar, é reconhecida a potencialidade de ser sujeito de direitos e, além disso, uma proteção básica e fundamental, materializada em direitos elementares compatíveis com a sua estrutura.

3. A PERSONALIDADE JURÍDICA

A pessoa, enquanto sujeito de direito, prende-se, atrela-se, inexoravelmente, à ideia de personalidade.

19. Em *O Espelho*, inicialmente publicado na forma de um conto, na *Gazeta de Notícias*, em 1882, Machado de Assis demonstra o seu amadurecimento literário e a fina sensibilidade em relação à pessoa humana. Na obra, o imortal escritor esboça uma nova teoria da alma humana, subtítulo conferido ao texto, a partir de um estudo sobre o espírito contraditório do homem, simbolizado por um espelho. Trata-se de inteligente metáfora sobre a alma humana à luz do espelho, problematizando o dualismo entre a alma exterior e a interior, demonstrando as contradições humanas, entre o consciente e o inconsciente. Com a sua genialidade, o autor lança, então, uma insinuação de que o ser humano está dividido entre duas "almas": uma alma interna, que *"olha de dentro para fora"*, transmitindo seus anseios particulares e valorizando sua consciência individual; e uma alma externa, que "olha de fora para dentro", composta de valores alheios ao indivíduo, mas presentes em sua formação.

20. A referência também é compartilhada por Marcos de Campos Ludwig. "O direito ao livre desenvolvimento da personalidade na Alemanha e possibilidades de sua aplicação no direito privado brasileiro", op. cit., p. 271.

É que, sob o ponto de vista da ciência jurídica – afastadas as indagações de ordem filosófica, biológica, antropológica... –, o estudo das pessoas desperta o interesse jurídico pelo fato de ser titular de personalidade jurídica e, por igual, de direitos da personalidade.

Com isso, não é difícil perceber que a noção de personalidade jurídica é o cerne, a base, que sustenta, juridicamente, todas as pessoas, garantindo-lhes um mínimo de proteção fundamental.

É bem verdade que, historicamente, a personalidade jurídica foi compreendida, tão somente, como uma *aptidão genérica reconhecida a toda e qualquer pessoa para que possa titularizar relações jurídicas.* Ou seja, a personalidade jurídica sempre foi vista apenas como um atributo genérico reconhecido a uma pessoa para que viesse a ser admitida como um sujeito de direitos.

Todavia, não se pode olvidar que determinadas entidades ou grupos não personalizados (isto é, desprovidas de personalidade jurídica, existindo, apenas, pelo prisma fático), como, por exemplo, o condomínio edilício, a sociedade de fato ou a massa falida, podem titularizar diversas relações jurídicas, mesmo não possuindo personalidade. Veja-se, ilustrativamente, que um condomínio edilício, no plano concreto, trava inúmeras relações jurídicas, atuando como contratante, como empregador, como parte no processo e como contribuinte, dentre outras várias hipóteses. Ou seja, mesmo não dispondo de personalidade jurídica (que não lhes foi reconhecida pelo sistema jurídico), os entes despersonalizados podem ser sujeitos de direitos, titularizando, no polo ativo ou passivo, incontáveis relações jurídicas. Dessa forma, não se pode, efetivamente, atrelar a personalidade jurídica, simplesmente, à possibilidade de titularizar relações jurídicas. Não se pode, enfim, represar a ideia de personalidade jurídica, tão somente, na potencialidade de ser sujeito de direitos, afinal é possível sê-lo, independentemente dela.

Evidencia-se, pois, que a personalidade jurídica não pode estar aprisionada no conceito simplório de sujeito de direito. Há de ser mais do que isso.

De maneira mais realista e próxima da influência dos direitos fundamentais constitucionais, é possível (aliás, é necessário) perceber uma nova ideia de personalidade jurídica. Com esteio em avançada visão civil-constitucional, a personalidade jurídica é o atributo reconhecido a uma pessoa (natural ou jurídica) para que possa atuar no plano jurídico (titularizando as mais diversas relações) e *reclamar uma proteção jurídica mínima, básica, reconhecida pelos direitos da personalidade.*

A personalidade jurídica é, assim, muito mais do que, simplesmente, poder ser sujeito de direitos. Titularizar a personalidade jurídica significa, em concreto, ter uma tutela jurídica especial, consistente em reclamar direitos fundamentais, imprescindíveis ao exercício de uma vida digna.

Em necessária perspectiva civil-constitucional, a personalidade não se esgota, destarte, na possibilidade de alguém (o titular) ser sujeito de direitos, mas, por

igual, relaciona-se com o próprio ser humano, sendo a consequência mais relevante do princípio da dignidade da pessoa humana.[21]

Na lição de Gustavo Tepedino, promovendo a adequação da ordem civil ao novo colorido emanado da *Lex Legum*, "em respeito ao texto constitucional, parece lícito considerar a personalidade não como um novo reduto de poder do indivíduo, no âmbito do qual seria exercida a sua titularidade, mas como *valor máximo do ordenamento, modelador da autonomia privada, capaz de submeter toda a atividade econômica a novos critérios de validade*".[22]

Ora, a nova tábua axiomática preconizada pelo Texto Constitucional, ancorada na afirmação da *cidadania* e a *dignidade da pessoa humana* como valores supremos, confere novo conteúdo à legislação infraconstitucional, impondo uma nova compreensão da personalidade como lastro fundamental, esteio cimentado, da ordem jurídica, de modo a afirmar a primazia da pessoa humana.

Consoante a lição de Maria Helena Diniz, apoiada em Goffredo da Silva Teles, "a personalidade consiste no conjunto de caracteres da própria pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A personalidade é que apoia os direitos e deveres que dela irradiam, é objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o que é".[23]

Já é, aliás, o que deflui da simples leitura do art. 1º da Lei Civil, proclamando que "toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil".

Cuida-se de uma aptidão genericamente reconhecida: toda pessoa é dotada de personalidade. É a possibilidade de ser titular de relações jurídicas e de reclamar o exercício da *cidadania*, garantida constitucionalmente, que será implementada (dentre outras maneiras) através dos direitos da personalidade.

Nesse sentido, a personalidade é parte integrante da pessoa. É uma parte juridicamente intrínseca, permitindo que o titular venha a adquirir, exercitar, modificar, substituir, extinguir ou defender interesses. Buscando inspiração em Francisco Amaral, "a personalidade, mais do que qualificação formal, é um valor jurídico que se reconhece nos indivíduos e, por extensão, em grupos legalmente constituídos, materializando-se na capacidade jurídica ou de direito".[24]

---

21. Nesse sentido, Rafael Garcia Rodrigues sustenta, com acerto, ser imperativa uma "mudança dos paradigmas, a revisão de todas as categorias e conceitos jurídicos, a necessidade de forjar um novo direito civil, já não mais afeto exclusivamente às situações patrimoniais: o indivíduo, o ser humano é necessário afirmar como o centro referencial do ordenamento" ("A pessoa e o ser humano no novo Código Civil", op. cit., p. 2.
22. TEPEDINO, Gustavo. *Temas de Direito Civil*, op. cit., p. 47.
23. DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro*, op. cit., p. 81. Mantendo o mesmo raciocínio e com a sua visão simbólica, disparava San Tiago Dantas ser a personalidade jurídica uma "*ossatura destinada a ser revestida de direitos*". Cf. *Programa de Direito Civil*, op. cit., p. 192.
24. AMARAL, Francisco. *Direito Civil*: Introdução, op. cit., p. 220.

A personalidade jurídica, assim, é o conceito básico, elementar, do Direito Civil, estendendo-se a todas as pessoas, devendo ser vislumbrada na textura constitucional, servindo como valor máximo da ordem jurídica.

Enfim, além de servir como fonte de afirmação da aptidão genérica para titularizar relações jurídicas, a personalidade civil traduz o valor maior do ordenamento jurídico, servindo como órbita ao derredor da qual gravitará toda a legislação infraconstitucional. É valor ético, oriundo dos matizes constitucionais, especialmente a *dignidade da pessoa humana*.

Afirma-se, pois, "que a personalidade não se resume à possibilidade de ser titular de direitos e obrigações, ou seja, ao conceito abstrato de pessoa próprio do ideário oitocentista, importando o reconhecimento de direitos que tocam somente ao ser humano, expressão de sua própria existência", no dizer de Rafael Garcia Rodrigues.[25]

Conexo ao conceito de *personalidade*, porém sem que com ele se confunda, exsurge a ideia de *capacidade*. É que enquanto a *personalidade* tem alcance generalizante, dizendo respeito a um valor jurídico reconhecido a todos os seres humanos (e elastecido para alcançar também agrupamentos de pessoas), dizendo respeito a um valor jurídico reconhecido a todas as pessoas, a *capacidade jurídica* concerne à possibilidade de aqueles que são dotados de personalidade serem sujeitos de direito de relações patrimoniais.

Em síntese apertada, porém completa: enquanto que a personalidade *tende ao exercício das relações existenciais*, a capacidade diz respeito ao *exercício de relações patrimoniais*. Exemplificando, ter personalidade é titularizar os direitos da personalidade, enquanto ter capacidade é poder concretizar relações obrigacionais, como o crédito e o débito.

Nesse diapasão, exemplificando, uma criança ou adolescente tem personalidade (e, por conseguinte, direito a uma vida digna), mas não tem capacidade. Em sendo assim, poderá manifestar a sua vontade em relação à sua adoção por um terceiro, por exemplo, mas não lhe é reconhecido o direito de celebrar um contrato de doação ou de arrendamento. Ou seja, relações existenciais podem ser titularizadas por quem tem personalidade, mesmo que não tenha plena capacidade.

4. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

4.1 Breve escorço histórico

Os direitos da personalidade constituem construção jurídica relativamente recente, fruto do cuidado da doutrina germânica e francesa, especialmente após a Segunda Guerra Mundial.[26]

25. RODRIGUES, Rafael Garcia. "A pessoa e o ser humano no novo Código Civil", op. cit., p. 3.
26. Confira-se, nesse sentido, Inácio de Carvalho Neto e Érika Harumi Fugie. *Novo Código Civil Comparado e Comentado*, op. cit., p. 38.

Historicamente, o Direito Romano não cuidou dos direitos da personalidade nos moldes que são concebidos hodiernamente, apenas contemplando a chamada *actio injuriarum*, a ação contra a injúria, que foi elastecida para abranger qualquer atentado contra a pessoa.[27]

Também os gregos não estruturaram uma categoria jurídica específica para tutelar a personalidade. Existia, tão somente, uma ação denominada *dike kakegoric*, tendendo à punição de quem violava algum interesse físico ou moral.

Com o Cristianismo e a pregação de uma fraternidade universal, tem início um despertar para a proteção da personalidade humana.

A Carta Magna inglesa, de 1215, estabeleceu a proteção de aspectos fundamentais da personalidade humana, como a liberdade, vindo a reconhecer, implicitamente, os direitos da personalidade. Mais adiante, a Declaração dos Direitos do Homem, em 1789, valorizou a tutela da personalidade humana e a defesa de direitos individuais.

No entanto, somente após a Segunda Grande Guerra Mundial, consideradas as atrocidades praticadas pelo nazismo contra a individualidade da pessoa humana e contra a humanidade como um todo, sentiu-se a necessidade de proteção de uma categoria básica de direitos reconhecidos à pessoa humana. Era preciso assegurar uma tutela fundamental, elementar, em favor da personalidade humana, salvaguardando a própria raça. Nesse passo, em 1948, foi promulgada a Declaração Universal de Direitos do Homem.[28]

Naturalmente, os Códigos Civis, como um todo, não faziam menção aos direitos da personalidade. O Código Civil francês (*Code de France*), o alemão (*BGB*) e o italiano eram silentes, não possuindo qualquer referência, até porque a categoria ainda não era tutelada. Com o pós-guerra, os Códigos foram paulatinamente reformados, vindo a sua grande maioria, na atualidade, a proteger, expressa e amplamente, os direitos da personalidade. Importante colaboração adveio do Direito alemão, preocupado, após os lamentáveis episódios ali ocorridos, atentatórios contra a humanidade, em afirmar a relevância na proteção da pessoa humana e de sua integridade.

Entre nós, os direitos da personalidade foram admitidos após importantes contribuições doutrinárias, alçados à altitude legislativa por normas esparsas e consagrados pelo Texto Constitucional de 1988.[29] Antes disso, o Projeto de Código Civil elaborado pelo eterno mestre Orlando Gomes, na década de 1960, em 16 artigos, cuidava amplamente da matéria, inclusive emprestando disciplina mais profunda do que a legislação vigente.

---

27. Com o mesmo raciocínio, veja-se Elimar Szaniawski. *Os direitos da personalidade e sua tutela*, op. cit., p. 185-186.
28. Faz referência Arnaldo Rizzardoao fato de que, nos últimos anos, os direitos da personalidade aumentaram a sua importância, na medida em que "mais se valoriza a pessoa humana e se colocam em primeiro plano os seus direitos" (*Parte Geral do Código Civil*, op. cit., p. 146).
29. *Vide*, exemplificativamente, o art. 5º, incisos V, X e XLI, da Constituição da República, que fazem referência à proteção da personalidade humana.

Apesar do acanhamento (ficando aquém das expectativas doutrinárias e do próprio avanço jurisprudencial dos anos mais recentes), o Código Civil de 2002 reconheceu, expressamente, os direitos da personalidade nos arts. 11 a 21. Hodiernamente, contudo, entendem muitos ordenamentos jurídicos, almejando tornar mais efetiva a dignidade do homem, elevada ao *status* de princípio fundamental em muitos deles, que o melhor caminho legislativo a seguir é inscrever nos textos constitucionais os direitos da personalidade. Ganha corpo, dessa maneira, o movimento de constitucionalização da proteção ampla e irrestrita da personalidade humana,[30] como se percebe das experiências espanhola e italiana, além da necessária referência à ordem jurídica brasileira.

É bem verdade que existem divergências quanto à terminologia utilizada. Como resume Carlos Alberto Bittar, há uma divergência em relação à nomenclatura porque alguns autores inclinam-se por denominá-los *direitos essenciais da pessoa* (Tobeñas), enquanto outros optam pela expressão *direitos à personalidade* ou *direitos essenciais* (Ravà). Há, ainda, quem prefira designar como *direitos pessoais* (Bruns) e, ainda, como *direitos personalíssimos* (Pugliati, Chiovenda e Rotondi). No entanto, malgrado a existência da confusão terminológica, a expressão dotada de maior técnica e consagrada na doutrina brasileira (Orlando Gomes, Rubens Limongi França e Antonio Chaves) e alienígena (Adriano de Cupis e Gierke) tem sido, realmente, *direitos da personalidade* – que está consagrada, inclusive, no Código Civil brasileiro.[31]

4.2 Noções conceituais: das velhas definições ao dogma fundamental do Direito Civil-Constitucional

Com o propósito de satisfazer as suas necessidades sociais, o homem pode adquirir direitos e assumir deveres, podendo ser sujeito ativo ou passivo dessas infindáveis relações pactuadas. O conjunto dessas situações jurídicas individuais, susceptíveis de apreciação econômica, é dito *patrimônio*. E, ao lado dessas situações patrimoniais (com vocação econômica), existem os chamados *direitos da personalidade*, enraizados na esfera mais íntima da pessoa e não mensuráveis economicamente, voltados à afirmação dos seus valores existenciais.

Em sendo assim, considerando que a personalidade é um conjunto de características pessoais, os direitos da personalidade constituem verdadeiros direitos subjetivos, atinentes à própria condição de pessoa. Enfim, no dizer de Inácio de Carvalho Neto e Érika Harumi Fugie, são eles, verdadeiramente, "a medula da personalidade".[32]

Nessa ordem de ideias, é possível asseverar serem os *direitos da personalidade* aquelas situações jurídicas reconhecidas à pessoa, tomada em si mesma e em suas necessárias projeções sociais. Isto é, são os direitos essenciais ao desenvolvimento

30. Esse é o pensamento de Gilberto Haddad Jabur. *Liberdade de pensamento e direito à vida privada*, op. cit., p. 123.
31. BITTAR, Carlos Alberto. *Os direitos da personalidade*, op. cit., p. 2.
32. CARVALHO NETO, Inácio; FUGIE, Érika Harumi. *Novo Código Civil Comparado e Comentado*, op. cit., p. 38.

da pessoa humana, em que se convertem as projeções físicas, psíquicas e intelectuais do seu titular, individualizando-o de modo a lhe emprestar segura e avançada tutela jurídica.[33]

Os direitos da personalidade, portanto, possibilitam a atuação na defesa da própria pessoa, considerada em seus múltiplos aspectos (físico, psíquico, intelectual...).

Compõem, em verdade, um conjunto de prerrogativas jurídicas reconhecidas à pessoa, atinentes aos seus diferentes aspectos em si mesma e às suas projeções e aos seus prolongamentos.[34]

Trata-se, sem a menor sombra de dúvida, de noção fluida, em constante e cotidiana evolução, tendo o escopo de assegurar uma categoria jurídica fundamental para a efetivação da dignidade humana. Aliás, forte na lição imorredoura de Orlando Gomes, nos direitos da personalidade estão compreendidos *os direitos essenciais à pessoa humana, a fim de resguardar a sua própria dignidade.*[35]

É preciso estampar em cores nítidas a ideia de que a matéria (direitos da personalidade) necessita ser enxergada, nos dias de hoje, sob a ótica civil-constitucional, em razão das importantes opções firmadas pela *Lex Legum*. A afirmação da *cidadania* e da *dignidade da pessoa humana* como princípios constitucionais (art. 1º, II e III), juntamente com a proclamação da igualdade e da liberdade, dão novo conteúdo aos direitos da personalidade, realçando a *pessoa humana como ponto central da ordem jurídica brasileira.*

Em síntese estreita: *os direitos da personalidade estão, inexoravelmente, unidos ao desenvolvimento da pessoa humana, caracterizando-se como garantia para a preservação de sua dignidade.*

A partir do novo contorno dogmático desenhado através dos novos valores e matizes constitucionais, é fácil depreender os direitos da personalidade como construção normativa que reconhece a proteção jurídica avançada da pessoa.[36]

Com essa perspectiva, os direitos da personalidade – ultrapassando a setorial distinção emanada da histórica dicotomia direito público e privado – derivam da

---

33. Em sentido semelhante, Orlando Gomes, citado por Gilberto Haddad Jabur. *Liberdade de pensamento e direito à vida privada*, op. cit., p. 89. Este último autor, aliás, propõe a compreensão dos direitos da personalidade como interesses "de conteúdo não patrimonial, mas com reflexo pecuniário, que possibilitam o desfrute das faculdades do corpo e do espírito, essenciais ao bem-estar, e que encerram, por isso, categoria autônoma, a ponto de não serem absolutamente disponíveis e de merecerem, sem intervenção humana, como nenhum outro direito merece, o predicado da inexpropriabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade" (*Liberdade de pensamento e direito à vida privada*, op. cit., p. 94).

34. Com idêntico pensar, Carlos Alberto Bittar. *Os direitos da personalidade*, op. cit., p. 6 ss, e Regina Sahm. *Direito à imagem no direito civil contemporâneo*, op. cit., p. 20.

35. GOMES, Orlando. *Introdução ao Direito Civil*,op. cit., p. 153.

36. Nesse diapasão, Francisco Amaral chega mesmo a afirmar, espancando qualquer dúvida porventura ainda existente, que "por terem guarida no texto constitucional, pode reconhecer-se que os direitos da personalidade são *o terreno de encontro privilegiado entre o direito privado, as liberdades públicas e o direito constitucional*" (*Direito Civil:* introdução, op. cit., p. 250-251).

própria dignidade reconhecida à pessoa humana para tutelar os valores mais significativos do indivíduo, seja perante outras pessoas, seja em relação ao Poder Público. Com as cores constitucionais, os direitos da personalidade passam a expressar o *minimum* necessário e imprescindível à vida com dignidade.

Passando em revista as ideias aqui coligidas: compreendidos à luz da legalidade constitucional, é possível vislumbrar os direitos da personalidade como *"os direitos atinentes à tutela da pessoa humana, considerados essenciais à sua dignidade e integridade"*, na síntese de Gustavo Tepedino.[37] Acatando essa relação implicacional entre os direitos da personalidade e a dignidade humana, afirmada constitucionalmente, sedimentou-se o Enunciado 274 da Jornada de Direito Civil: "Os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, III, da Constituição Federal".

4.3 Fontes

Discussão acirrada diz respeito à fonte dos direitos da personalidade.

Folgada maioria na doutrina brasileira e estrangeira busca em fontes suprajurídicas a justificativa dos direitos da personalidade. Salientam que se relacionam com atributos inerentes à própria condição humana, motivo pelo qual entendem decorrer do chamado *direito natural*. Para essa corrente, os direitos da personalidade manteriam estreito laço com uma concepção religiosa do Direito, sendo emanação divina.

Exemplo utilizado para ilustrar diz respeito ao julgamento de Nuremberg,[38] quando se condenaram atrocidades cometidas durante o período nazista, na Alemanha, sob o pretexto de estar sendo cumprida a lei.

Essa é a posição, seguramente, majoritária em sede doutrinária.[39]

Não parece a melhor solução. Efetivamente, embora em posição minoritária, entendemos assistir razão aos *positivistas*, que vislumbram a fonte precípua dos direitos da personalidade no próprio ordenamento jurídico. Ou seja, é a ordem jurídica que reconhece os direitos da personalidade, viabilizando o seu exercício.

Com efeito, há evidente equívoco na escola jusnaturalista, que entende os direitos da personalidade como inatos ao homem, ou seja, afirmam decorrer de uma

37. TEPEDINO, Gustavo. *Temas de Direito Civil*, op. cit., p. 24.

38. Bela (e fria) cidade situada no norte do Estado da Baviera, na Alemanha, Nuremberg sediou uma série de tribunais militares, constituídos pelas Forças Aliadas vitoriosas na Segunda Grande Guerra Mundial, constituídos para o julgamento de oficiais nazistas e membros da liderança política, militar e econômica da Alemanha Nazista. Os julgamentos ocorreram entre 20.11.45 e 1.10.46.

39. Corroborando desse entendimento, Maria Helena Diniz. *Curso de Direito Civil Brasileiro*, op. cit., p. 83; Gilberto Haddad Jabur. *Liberdade de pensamento e direito à vida privada*, op. cit., p. 87; e Carlos Alberto Bittar, para quem "esses direitos existem antes e independentemente do direito positivo, como inerentes ao próprio homem, considerado em si e em suas manifestações" (*Os direitos da personalidade*, op. cit., p. 7-8).

ordem jurídica previamente constituída, por confundir o direito natural (dever ser) com a experiência talhada, construída culturalmente, no plano do direito positivo (do ser). Por isso, mereceu de Pietro Perlingieri a lúcida advertência de que os direitos da personalidade "devem encontrar o seu fundamento na norma positiva", de modo a garantir sua adequada tutela.

É que "no estado de direito, a ordem jurídica serve exatamente para evitar os abusos de poder cometidos por quem, com base em valores supralegislativos, ainda que em nome de interesses aparentemente humanistas, viesse a violar garantias individuais e sociais estabelecidas, através da representação popular, pelo direito positivo", nas palavras de Gustavo Tepedino.[40]

Equivale a dizer que a garantia de uma proteção mínima à personalidade é fruto da preocupação afirmada pelo avanço cultural do ser humano que, atualmente, repele toda e qualquer ideia que possa comprometer sua plena integridade. Assim, está no terreno da cultura (e a lei é um fato cultural) o reconhecimento dos direitos da personalidade e não em ordens jurídicas preestabelecidas.

Orlando Gomes, com habitual percuciência, esclarece a decorrência histórica dos direitos da personalidade, fruto de uma necessidade social, em face do menosprezo e do desapreço à dignidade humana por parte do Estado, somados à multiplicação dos atentados perpetrados contra a personalidade por particulares em razão dos progressos técnicos da era moderna. Assim, foram incentivados os tribunais germânicos, no pós-guerra, a agir em proteção da pessoa humana, através do reconhecimento de direitos da personalidade.[41]

Resulta, assim, demasiadamente difícil aos jusnaturalistas explicar a aplicação de direitos da personalidade (garantidores da proteção humana) de forma inata em situações ainda hoje existentes, nas quais queda inerte a tutela humana, como nos países muçulmanos com suas penas corporais, nos países africanos com suas cirurgias de mutilação dos órgãos sexuais femininos e nos países que admitem a pena de morte. Se decorrem do direito natural (se são inatos), onde estariam escondidos os direitos da personalidade em tais situações? Tudo isso sem questionar os países que admitem a escravidão.

Outro exemplo eloquente diz respeito aos direitos autorais que, embora classificados como direitos da personalidade, não são, às escâncaras, inatos, destruindo a tese jusnaturalista.

Enfim, como afirmou Hannah Arendt, em passagem eloquente e célebre, "os direitos humanos não são um dado, mas um construído".

Por esse fio condutor, Edson Ferreira da Silva, corroborando das ideias positivistas, invoca Pontes de Miranda, para sustentar que "os direitos da personalidade não

40. TEPEDINO, Gustavo. *Temas de Direito Civil*, op. cit., p. 40.
41. GOMES, Orlando. *Novos temas de Direito Civil*, op. cit., p. 251.

são impostos por ordem sobrenatural, ou natural, aos sistemas jurídicos; são efeitos de fatos jurídicos, que se produziram nos sistemas jurídicos, quando a certo grau de evolução a pressão política fez os sistemas jurídicos darem entrada a suportes fáticos que antes ficavam de fora, na dimensão moral ou na dimensão religiosa".[42]

Não é demais alertar que a *dignidade da pessoa humana* não pode ser reduzida apenas a um valor inato à natureza humana (algo inerente à sua própria natureza), sendo induvidoso um sentido cultural na acepção da expressão, sendo fruto do aperfeiçoamento da espécie humana.[43] Já teve oportunidade o Tribunal Constitucional de Portugal de afirmar que "a ideia de dignidade da pessoa humana, no seu conteúdo concreto – nas exigências ou corolários em que se desmultiplica – não é algo puramente apriorístico, mas que necessariamente tem de concretizar-se histórico-culturalmente" (Acórdão 90-105-2, de 29.3.1990, Rel. Bravo Serra).

4.4 Características

A partir da percepção do art. 11 do Código Civil, as características precípuas dos direitos da personalidade são a sua intransmissibilidade e a sua inalienabilidade. Equivale a dizer, os direitos da personalidade são indisponíveis, na medida em que não admitem transmissão (em vida ou por morte) ou alienação (a título oneroso ou gratuito).

Essa indisponibilidade dos direitos da personalidade, no entanto, deve ser compreendida em perspectiva relativizada, apenas impedindo que o titular possa deles dispor em caráter permanente ou total, sem que se dele retire a possibilidade de prática de um certo nível de disponibilidade, como no exemplo da cessão de imagem ou da doação de órgãos humanos.

Dessa maneira, muito embora os direitos da personalidade sejam indisponíveis ao seu titular, admite-se, eventualmente, uma cessão do seu exercício, em determinadas situações e dentro de certos limites. Significa, pois, a existência da possibilidade de ato de disposição, ainda que em caráter relativo, não sacrificando a dignidade do titular.

Nesse passo, inclusive, a própria dicção do art. 11 do Código de 2002 é de clareza solar ao dispor que "*com exceção dos casos previstos em lei*, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis", permitindo antever o seu caráter indisponível relativamente.

É dizer: em casos específicos (não em todos!), o titular pode ceder o exercício de alguns dos seus direitos da personalidade, dês que não seja em caráter permanente ou genérico e que não importe em violação de sua fundamental dignidade. É

42. SILVA, Edson Ferreira da. *Direito à intimidade*, op. cit., p. 14.

43. Em sentido inverso, Rizzatto Nunes afirma que "a dignidade nasce com a pessoa. É-lhe inata. Inerente à sua existência" (*O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana*, op. cit., p. 49).

o exemplo da cessão do exercício do direito de imagem, que pode se caracterizar de maneira onerosa ou gratuita, durante determinado lapso temporal.

Não foi por outro motivo que se consolidou o entendimento, através do Enunciado 4, aprovado na Jornada de Direito Civil. Confira-se:

> Enunciado 4, Jornada de Direito Civil:
> "O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral".

Na trilha desse entendimento, é admissível a limitação voluntária a direito da personalidade, desde que não seja em caráter absoluto e genérico. Ou, noutras palavras, o ato de disposição de um direito da personalidade há de ser transitório (limitado no tempo) e específico (afinal, ninguém pode abrir mão de toda a sua personalidade).

Exemplificativamente: é possível ceder o uso da imagem para a edição específica de uma revista, mas não é possível autorizar o uso indeterminado da imagem, sem limites temporais.[44] Por isso, nenhuma cessão de imagem, por exemplo, pode ser permanente, sendo lícito ao titular, após o prazo máximo de cinco anos (se outro prazo menor não foi convencionado, conforme o sistema da Lei nº 9.610/98), reclamar a proteção de sua personalidade. Noutro caso, é possível a uma celebridade conceder uma entrevista a um veículo de comunicação revelando particularidades de sua vida privada, sem que se autorize, com isso, a publicação de fatos que não foram espontaneamente apresentados.

Outrossim, admite-se a cessão de direitos autorais e a doação de órgãos humanos duplos ou regeneráveis, denotando a relatividade da indisponibilidade que caracteriza tais direitos.

E mais: além de não poder ser permanente, nem genérico, o ato de disposição não pode violar a dignidade do titular. Com isso, mesmo que alguém manifeste, expressamente, a sua vontade, não será possível ceder o exercício de um direito da personalidade com afronta à sua dignidade (mínimo existencial). Seria o exemplo de uma pessoa que consente em participar de um programa de televisão em que a sua integridade física é aviltada. No caso, a sua aquiescência é irrelevante, pois atenta contra a sua dignidade. Por óbvio, há uma grande dificuldade em conceituar qual seria o limite da violação da dignidade do titular. Em se tratando de um conceito plástico, aberto, aquilo que representa afronta à dignidade para uma pessoa, pode não representar para outra. A nós, parece que a *autonomia privada* tem de ser preservada, na medida em que cabe, basicamente, ao próprio titular indicar os limites e as possibilidades de flexibilização do que se lhe caracteriza como uma *vida digna*. Ninguém mais do que ele mesmo tem como fazê-lo. Todavia, existem casos nos quais

44. Ilustra Leoni Lopes de Oliveira que "uma pessoa não pode ser fotografada, por exemplo, despida e publicadas as fotos sem sua autorização. Mas nada impede que uma mulher celebre com uma revista um contrato de um trabalho fotográfico em que posará despida" (*Novo Código Civil Anotado*, op. cit., p. 47).

uma pessoa pode permitir uma mitigação da proteção de sua personalidade por comprometimento de sua *liberdade de manifestação de vontade*, como na hipótese de uma pessoa que esteja submetida a privações, torturas ou necessidades vitais. Se for perguntado a alguém que está a passar fome, com a sua família, se violaria sua dignidade vender um rim, certamente a resposta seria negativa. Afinal de contas, a pessoa já se encontra em situação indigna. Ao nosso viso, por conseguinte, a proteção da dignidade do titular deve ser verificada casuisticamente, somente se limitando a autonomia privada em casos muito específicos, de claro comprometimento da vontade.

Há uma interessante situação a respeito do tema, a merecer uma problematização. Trata-se de um julgamento do Conselho Constitucional da França no célebre caso do "arremesso de anões". Sem dúvida, é um importante precedente da jurisprudência francesa, cuidando de um estranho jogo, no qual anões eram lançados a distância, com o auxílio de um canhão de pressão. Insurgindo-se contra decretos das prefeituras dos locais onde o jogo era praticado, proibindo a diversão pública, os promotores do jogo ingressaram com medidas judiciais tendendo à liberação do certame. E *Manuel Wackenheim*, um anão com pouco mais de um metro e quatorze centímetros de altura, se habilitou como litisconsorte na demanda. Confirmando a vedação administrativa, a Casa Judicial francesa reconheceu que o "respeito à dignidade humana, conceito absoluto que é, não poderia cercar-se de quaisquer concessões em função de apreciações subjetivas que cada um possa ter a seu próprio respeito. Por sua natureza mesma, a dignidade da pessoa humana está fora do comércio". A questão nos defronta com um curioso conflito: considerando que o nanismo restringe bastante as chances de emprego de algumas pessoas, justificar-se-ia uma flexibilização de sua personalidade? O tema é, de fato, inspirador e precisa ser visto com olhares mais largos, não se restringindo a uma visão simplória do conceito de integridade física. Indubitavelmente, *é preciso refletir sobre a extensão da interferência da ordem jurídica na vida das pessoas humanas, sem descurar sobre a amplitude do conceito de vida digna.*

Ademais, vale o destaque de que o ato de disposição de um direito da personalidade pode decorrer da lei ou da autonomia privada, através de manifestação do próprio titular, como no exemplo da cessão de imagem ou da doação de órgãos dúplices ou regeneráveis.

Além da característica da *indisponibilidade relativa*, reconhecida expressamente pelo Código Civil em seu art. 11, os direitos da personalidade trazem consigo outras marcas registradas. Em que pese não constarem expressamente do texto legal, são, também, características dos direitos da personalidade: o caráter *absoluto*, a *impres-critibilidade*, a *extrapatrimonialidade* e a *vitaliciedade*. Vejamos então.

Os direitos da personalidade são *absolutos* porque possuem eficácia contra todos (ou seja, são oponíveis *erga omnes*), impondo-se à coletividade, e aos particulares individualmente considerados, o dever de respeitá-los. É um verdadeiro dever geral de abstenção, dirigido a todos.

Por outro lado, a *imprescritibilidade* impede que a lesão a um direito da personalidade venha a convalescer com o passar do tempo, obstando a pretensão de assegurar o livre exercício do direito da personalidade. Inexiste, portanto, prazo extintivo para que seja exercido um direito da personalidade. Advirta-se, porém, que a pretensão indenizatória decorrente de um eventual dano à personalidade está submetida aos prazos prescricionais. Nesse caso, a pretensão reparatória de obter indenização pelos danos sofridos prescreve, em conformidade com a regra geral, no prazo de três anos, inclusive na hipótese de um dano decorrente de violação aos direitos da personalidade (CC, art. 206, § 3º, V).[45] Imprescritível, assim, é a pretensão de garantir o exercício do direito, mas não a de reparar pecuniariamente um eventual dano sofrido.[46] Exemplificando: se alguém, indevidamente, utiliza-se da imagem de outrem, a pretensão de impedir que a pessoa continue se valendo daquela imagem não sofre limitação temporal, podendo ser exercida a qualquer tempo, porém, em três anos prescreverá a pretensão de reparação pecuniária do dano causado à imagem.

Há exceção, porém, no que diz respeito à regra geral da prescritibilidade das pretensões patrimoniais.. No que tange às ações tendentes à reparação de danos causados por prisão ou tortura, durante o regime militar de exceção, pelo qual passamos durante tristes épocas, vem afirmando o Superior Tribunal de Justiça a sua imprescritibilidade, seguindo a trilha do art. 14 da Lei nº 9.140/95. Veja-se a respeito:

> "São imprescritíveis as ações de reparação de dano ajuizadas em decorrência de perseguição, tortura e prisão, por motivos políticos, durante o Regime Militar, afastando, por conseguinte, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32. Isso, porque as referidas ações referem-se a período em que a ordem jurídica foi desconsiderada, com legislação de exceção, havendo, sem dúvida, incontáveis abusos e violações dos direitos fundamentais, mormente do direito à dignidade da pessoa humana" (STJ, Ac. unân., 1ª T., AgRg 970.753/MG, Rel. Min. Denise Arruda, j. 21.10.08, *DJU* 12.11.08).

Já a *extrapatrimonialidade* consiste na insuscetibilidade de apreciação econômica dos direitos da personalidade, ainda que a eventual lesão possa produzir consequências monetárias (na hipótese, a indenização por dano extrapatrimonial, comumente chamado de dano moral). O tema exige esclarecimentos. É certo e incontroverso que a honra, a privacidade e demais bens jurídicos personalíssimos de uma pessoa não comportam avaliação pecuniária. São valores existenciais e, por conseguinte, não são susceptíveis de aferição monetária, de um valor patrimonial. Entretanto, uma vez ocorrendo uma violação a esses valores da personalidade, independentemente de causar prejuízo material,[47] surge a possibilidade de reparação do dano moral

45. No mesmo sentido: GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito Civil Brasileiro*, op. cit., p. 158.
46. Em sentido inverso, minoritariamente, Flávio Tartuce apregoa a inexistência de "qualquer prazo prescricional, por envolver matéria de ordem pública", sustentando que a pretensão indenizatória decorrente de violação a um direito da personalidade, embora de natureza patrimonial (e não existencial) também seria imprescritível (*Direito Civil*, op. cit., p. 47).
47. OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. *Novo Código Civil Anotado*, op. cit., p. 49.

aracterizado, como forma de compensar o prejuízo imposto à vítima e sancionar o sante, inclusive com o caráter educativo (preventivo) de impedir novos atentados.

Releva assinalar que decorre do caráter *extrapatrimonial* dos direitos da personalidade a sua *impenhorabilidade*, não sendo possível servir como objeto de penhora.

Finalmente, não se pode esquecer que os direitos da personalidade são *vitalícios*, ctinguindo-se, naturalmente, com a morte do titular, confirmando o seu caráter intransmissível. Falecendo, pois, o titular de um direito da personalidade, não haverá ansmissão, extinguindo-se, automaticamente, a relação jurídica personalíssima. Não e esqueça, de qualquer forma, que se reconhece, como um direito da personalidade a pessoa humana (viva), a proteção aos valores jurídicos da personalidade de algum familiar que já morreu, como assinala o parágrafo único do art. 12 do Estatuto ubstantivo. São os chamados *lesados indiretos*, que estão legitimados para reclamar, m nome próprio, a proteção aos seus direitos da personalidade (próprios), consubstanciados na defesa de valores personalíssimos do seu cônjuge ou companheiro lecido, bem como de seus parentes (mortos), em linha reta ou colateral até o quarto rau. Nesse caso, o dano ocorre depois da morte da pessoa, atingindo, diretamente, o morto (que não mais tem personalidade), e, por igual, indiretamente aos seus arentes e cônjuge ou companheiro vivos. Por isso, são designados *lesados indiretos*.

É de se destacar, portanto, que os direitos da personalidade são, de fato, intransmissíveis. Todavia, malgrado essa intransmissibilidade (CC, art. 11), é possível ue que os seus reflexos patrimoniais sejam transmitidos para o espólio (sucessores) falecido. Assim sendo, é reconhecida a transmissão do direito (patrimonial) de digir uma reparação pecuniária pela violação de direitos (patrimoniais ou existenciais) uma pessoa morta, conforme previsto no art. 943 do Código Civil.[48] Aqui, o que transmite é o *direito indenizatório, de natureza marcantemente patrimonial*. Ou ja, é o direito de exigir a reparação de um dano sofrido, através do recebimento uma indenização a que o morto faria jus se tivesse proposto a ação, ou a obrigação de prestá-la, quando o falecido causou um dano e morreu sem repará-lo. Não i, efetivamente, transmissão de algum direito personalíssimo violado, até porque, mo visto, o direito da personalidade é intransmissível. Nessa linha de intelecção, rpetrado um dano contra a personalidade de alguém, surge uma pretensão reparatória por dano moral, que se transmite aos herdeiros, juntamente com a herança. é por isso que, mesmo falecendo o ofendido sem promover a ação reparatória, os us herdeiros podem fazê-lo, dentro do prazo prescricional previsto em lei.[49]

48. Art. 943, Código Civil: "O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança".

49. A jurisprudência é simpática ao entendimento: "O herdeiro não sucede no sofrimento da vítima. Não seria razoável admitir-se que o sofrimento do ofendido se prolongasse ou se estendesse ao herdeiro e este, fazendo sua a dor do morto, demandasse o responsável, a fim de ser indenizado da dor alheia. Mas é irrecusável que o herdeiro sucede no direito de ação que o morto, quando ainda vivo, tinha contra o autor do dano. Se o sofrimento é algo entranhadamente pessoal, o direito de ação de indenização do dano moral

Também não se confunde com a hipótese contida no art. 110 do Código de Processo Civil de 2015, que trata de *sucessão processual necessária*. Depois de promovida uma ação, ocorrendo o óbito de qualquer das partes, autor ou réu, o seu espólio ou sucessores sucedem o morto, assumindo o polo processual da demanda, mesmo que se trate de uma ação promovida para reclamar danos à personalidade.[50] A natureza do instituto é, às escâncaras, processual.

4.5 As liberdades públicas e os direitos da personalidade

Convém, por questões didáticas e teóricas, distinguir os direitos da personalidade das chamadas liberdades públicas.

Os direitos da personalidade são estudados sob a ótica do direito privado, considerados como a garantia mínima da pessoa humana para as suas atividades internas e para as suas projeções ou exteriorizações para a sociedade. Por isso, impõem à coletividade uma conduta negativa, evitando embaraço ao seu exercício.

De outro lado, as liberdades públicas "são condutas individuais ou coletivas realizadas de forma autodeterminada, em face da autorização expressa ou implícita, conferida pelo Estado", como pondera Roberto Senise Lisboa.[51] Disso não discrepa Gilberto Haddad Jabur, esclarecendo que "as liberdades públicas surgem quando o Estado consagra os direitos individuais ou fundamentais".[52]

Ora, enquanto os direitos da personalidade são percebidos pela ótica privatista, afirmando a tutela da pessoa humana, as liberdades públicas, descortinadas na esfera pública, correspondem a imposições para assegurar aqueles direitos.

Em outras palavras, enquanto os direitos da personalidade afirmam a proteção avançada da pessoa humana, estabelecendo condutas negativas da coletividade (*obrigação de não fazer*, isto é, não violar a personalidade de outrem), as liberdades públicas funcionam a partir de garantias constitucionais impondo condutas positivas ao Estado para que estejam assegurados os direitos da personalidade.

4.6 A possibilidade de colisão entre os direitos da personalidade e a *liberdade de imprensa*, ou a *liberdade de expressão*, e o critério de solução adequado (inadmissibilidade do *hate speech*) e o direito de resposta

Assegura a Carta Constitucional de 1988 (arts. 5º, IX, e 220, § 1º) a liberdade de imprensa, sem prévia censura, como consectário da própria liberdade de

---

é de natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores" (STJ, Ac. 1ª T., REsp. 324.886, Rel. Min. José Delgado, *RSTJ* 151: 157).

50. Assim: "Na ação de reparação por danos morais, podem os herdeiros da vítima prosseguirem no polo ativo da demanda por ela proposta" (STJ, Ac. 3ª T., REsp. 577.787/RJ, Rel. Min. Castro Filho, *DJU* 20.9.04, p. 290).

51. LISBOA, Roberto Senise. *Manual Elementar de Direito Civil*, op. cit., p. 176.

52. JABUR, Gilberto Haddad. *Liberdade de pensamento e direito à vida privada*, op. cit., p. 77.

pensamento e de expressão (art. 5º, IV). Cuida-se, em mais palavras, do direito de livre manifestação de pensamento pela imprensa, assegurada a informação pelos seus variados e diversos órgãos.

É mister destacar que na sociedade contemporânea – aberta, plural, multifacetária e globalizada –, a expressão *imprensa* ganha contornos mais amplos, abrangendo diferentes meios de comunicação ou informação, tais como jornais, revistas, televisão, rádio e a *Internet*.

Pois bem, no estado democrático de direito, a *liberdade de imprensa* não pode estar submetida à prévia censura e, a outro giro, os direitos da personalidade também mereceram especial proteção constitucional, alçados à altitude de cláusulas pétreas.

Dessa maneira, o exercício do direito de informação não pode ser admitido em caráter absoluto, ilimitado, sendo imperioso estabelecer limites ao direito de informar, a partir da proteção dos direitos da personalidade (imagem, vida privada, honra...), especialmente com base na tutela fundamental da dignidade da pessoa humana, também alçada ao *status* constitucional (CF, art. 1º, III).[53]

É dizer: na perspectiva dos direitos fundamentais consagrados pela Carta de 5 de outubro, há uma induvidosa força normativa que impede atentados contra a dignidade da pessoa humana e os interesses sociais coletivos. Por isso, embora a liberdade de imprensa também mereça proteção especial e diferenciada, protegida com o *status* de direito fundamental constitucional, não pode o seu exercício ultrapassar o limite bem definido das demais garantias constitucionais. Até porque, como diz o sábio ditado popular, o direito de um termina quando começa o do outro...

Bem por isso, encontram-se, comumente, em nosso cotidiano conflitos de interesses estabelecidos entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade.

Em casos tais (colisão de direitos da personalidade e liberdade de imprensa), é certa e incontroversa a inexistência de qualquer hierarquia, merecendo, ambas as figuras, uma proteção constitucional, como direito fundamental. Impõe-se, então, o uso da técnica de ponderação dos interesses, buscando averiguar, no caso concreto, qual o interesse que sobrepuja, na proteção da dignidade humana. Impõe-se investigar qual o direito que possui maior amplitude casuisticamente.[54]

---

53. Apontando entendimento exatamente nesse sentido, Cláudio Luiz Bueno de Godoy. *A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade*, op. cit., p. 64, e OduvaldoDonninie Rogério Ferraz Donnini. *Imprensa livre, dano moral dano à imagem, e sua quantificação à luz do novo Código Civil*, op. cit., p. 54.

54. Para ilustrar a assertiva, veja-se que a jurisprudência admite o critério da solução casuística, em decisões de conteúdo distintos: "O Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos, entendeu pela prática de ilícito consubstanciado no *abuso de direito de informar, ao se veicular notícia em programa de rádio que desvirtuou a realidade dos fatos, induzindo a opinião pública a uma visão distorcida deles*, causando danos à parte envolvida, violando o direito à integridade moral" (STJ, Ac. Unân., 4ª T., AgRg no Ag 1.335.108/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 25.10.11, *DJe* 4.11.11). E, de outra lado: "1. A publicação, desacompanhada de opiniões e comentários depreciativos do jornal, de série de reportagens relativas ao fato de investigação dos órgãos superiores do Ministério Público a respeito de alegada divulgação de questões do Concurso de Ingresso na carreira pelo autor, então integrante da Comissão Examinadora, não configura dano moral ao

Interessante hipótese é formulada por Gustavo Tepedino, inspirado em Stefano Rodotá, lembrando do político que professa um exacerbado moralismo e, posteriormente, é surpreendido, pela imprensa, em situação que contradiz as ideias pregadas. Conclui ser possível veicular a notícia nesse caso, a bem do interesse público.[55] Identicamente, a divulgação de fatos que envolvem sonegação fiscal comprovada não atenta contra os direitos da personalidade,[56] bem assim como não caracteriza abuso a veiculação normal de informação sobre eventuais apurações procedidas no âmbito de inquérito policial.[57] Incorporando esse entendimento, a jurisprudência já afirmou que a veiculação de fatos, inseridos em matéria jornalística, baseada em fatos de interesse público, sem extrapolar o direito de crítica, em casos que ostentam gravidade e ampla repercussão social, não caracteriza dano moral indenizável (STJ, Ac. 4ª T., REsp. 801.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.6.12). Significa, portanto, que toda publicação jornalística traz consigo uma *cláusula de modicidade*, permitindo um temperamento para a compreensão dos efeitos sobre terceiros dela decorrentes quando se tratar de um agente público envolvido em um fato público.[58]

Por outro turno, se a informação veiculada pela imprensa vulnera a privacidade ou a imagem de alguém, estará desvirtuando o exercício do direito à notícia,

---

autor, cuja honorabilidade restou intacta, proclamada, inclusive, por testemunhos pessoais de julgadores no Acórdão recorrido. 2. Inexistência de violação ao direito à intimidade e a sigilo do ocorrido. 3. *Atos que se inseriram na estrita liberdade de imprensa, constitucionalmente assegurada*" (STJ, Ac. Unân., 3ª T., REsp. 959.330/ES, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 9.3.10, *DJe* 16.11.10).

55. TEPEDINO, Gustavo. *Temas de Direito Civil*, op. cit., p. 474.

56. "Ao divulgar fatos de sonegação fiscal em que se trata de notícia verdadeira, reportagem comum, mero repasse de informações obtidas de forma lícita, não cabe indenização por dano moral, pois nenhum ilícito cometeu a empresa jornalística" (TJ/SP, Ac. Unân., 2ª Câm. Cív., Ap. Cív. 274.956-1, Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani, j. 19.2.97, *RT* 740: 296).

57. OduvaldobDonnini e Rogério Ferraz Donnini percebem que "não constitui abuso no exercício de direito de informar, quando a notícia jornalística se limita a reproduzir fatos insertos no inquérito policial" (*Imprensa livre, dano moral dano à imagem, e sua quantificação à luz do novo Código Civil*, op. cit., p. 111-112). No mesmo diapasão: "Não constitui abuso no exercício do direito de informação a reportagem jornalística que se limita a reproduzir fatos constantes de inquérito policial, embora tenha aludido a 'furto' e 'roubo', quando se trataria de apuração de 'apropriação indébita'" (TJ/SP, Ac. Unân., 2ª Câm. Direito Privado, Ap. Cív. 75.900-4 – Comarca de São Paulo, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 29.6.99, *Lex-JTJ* 220: 88).

58. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a presença implícita da cláusula de modicidade como um mecanismo de harmonização entre a liberdade de imprensa e de expressão e os direitos da personalidade. Veja-se: "5. Proporcionalidade entre liberdade de imprensa e responsabilidade civil por danos morais e materiais. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão *latosensu* para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. *Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania.* E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos" (STF, Ac. Tribunal Pleno, ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 30.4.09, *DJe* 6.11.09, *RTJ* 213: 20).

caracterizando verdadeiro abuso de direito, prontamente reparável. É o caso da veiculação de notícia fazendo referência desabonatória a alguém, sem qualquer cunho jornalístico.[59] De igual maneira, afronta os direitos da personalidade o sensacionalismo promovido pelo órgão de imprensa, lesando a dignidade humana, mesmo que os fatos veiculados estejam, realmente, sendo apurados pela Polícia ou pelo Ministério Público.[60] Não se pode tolerar que a imprensa venha a se valer de seu prestígio e alcance para impor prejuízo aos direitos da personalidade de qualquer pessoa, atentando contra a sua honra, imagem ou intimidade.

Em arremate, afirma-se a inexistência de hierarquia valorativa entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade, impondo uma solução casuística de eventual conflito, com o uso da técnica de ponderação de interesses. Somente no caso concreto será possível descobrir se prevalece a liberdade de imprensa ou a proteção da personalidade.

Reconhecida, eventual e casuisticamente, a responsabilidade civil por dano à personalidade causado pelo exercício da liberdade de imprensa, é imperioso evidenciar que a Súmula 221 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dever de indenizar é imposto tanto do autor do escrito, quanto do proprietário do veículo de divulgação:

> Súmula 221, Superior Tribunal de Justiça:
>
> "São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação".

Cuida-se de entendimento elogiável por facilitar a reparação do dano sofrido pela vítima, que poderá acionar o órgão de imprensa ou o autor do ato atentatório à personalidade alheia.

Sob o prisma da reparação de danos, a vítima de uma ofensa por meio da imprensa pode optar entre uma tutela preventiva ou reparatória, na forma da legislação processual.

Em meio à vastidão de mecanismos processuais de tutela preventiva (dentre os quais, a fixação de multa ou a restrição de direitos), merece destaque o exercício do direito de resposta, a partir da parametrização estabelecida pela Lei nº13.188/15. Efetivamente, "ao ofendido, em matéria divulgada, publicada ou transmitida por

59. "A expressa referência em jornal a nome do magistrado, sem nenhuma relevância jornalística ou mesmo de cunho informativo aos seus leitores, quando feita em reportagem policial e veiculada em jornal com circulação em todo o Estado, caracteriza violação à honra daquele, ensejando-lhe, com isso, pleitear indenização por danos morais contra o seu ofensor" (TJ/MT, Ac. Unân., 2ª Câm. Cív., Ap. Cív. 17.557 – Comarca de Cuiabá, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 17.12.96, *RT* 741: 357).

60. Veja-se, a respeito, um didático precedente jurisprudencial: *"Detectado que a par de se originar a notícia veiculada em jornal de fonte oficial do Ministério Público, o cunho sensacionalista pelo emprego de expressão chula dado aos fatos causou ofensa de ordem moral, devida a indenização reparadora que deve, todavia, ser fixada sem excessos, a fim de evitar enriquecimento sem causa"* (STJ, Ac. Unân., 4ª T., REsp. 448.604/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 6.11.03, *DJU* 25.2.04, p. 180).

veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo" (art. 2°). Assim, qualquer notícia ou reportagem veiculada por meio da imprensa, em seu sentido mais amplo possível (abrangendo, inclusive, a internet), atentatória à personalidade alheia (honra, imagem, vida privada, intimidade...) pode ensejar o direito de resposta da pessoa agravada, como mecanismo de preservação de sua personalidade. Não se abarca no conceito de imprensa, entrementes, os comentários realizados por usuários das redes sociais, como o facebook, o instagram, o periscope e o twitter. A relevância do direito de resposta é a própria isonomia constitucionalmente assegurada. Por isso, uma eventual retratação espontânea não obsta o exercício do direito de resposta pela vítima, de modo a externar a sua versão e impressões sobre o fato. Muito menos impedirá uma eventual ação reparatória.

O direito de resposta, ou de retificação, deve ser exercido no prazo decadencial de sessenta dias, a partir da data da divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva (art. 3°)). Ao nosso viso, porém, parece mais razoável estabelecer que a fluência do prazo se inicia a partir do momento do conhecimento da lesão à personalidade, invocando a chamada teoria da actio nata. Isso porque na data da violação da personalidade, o ofendido não necessariamente tem conhecimento da lesão. Esse direito de resposta deve ser dirigido diretamente ao veículo de comunicação causador da ofensa ou, não havendo pessoa jurídica constituída, ao responsável pela publicação. No caso de divulgação por mais de um veículo, todos podem ser provocados. Se, no prazo de sete dias, contados do recebimento do pedido, não houver resposta,[61] com divulgação, publicação ou transmissão do conteúdo a ser retificado, evidencia-se o interesse jurídico da vítima para a propositura de uma judicial, na qual pode formular o pedido de resposta (art. 5 °). A ação deve ser ajuizada no foro do domicílio do ofendido ou, à sua escolha, no lugar em que a ofensa tenha tido maior repercussão. Trata-se, a toda evidência, de competência territorial/relativa, podendo ser alterada pela vontade dos interessados. Processado em rito mais célere e abreviado, o pedido de resposta será despachado pelo juiz cível, em vinte e quatro horas, mandando citar o responsável pelo veículo de comunicação para que, em igual prazo, apresente as razões pelas quais não divulgou a resposta ou, em três dias, ofereça contestação.

61. Nos termos do art. 4o do citado Diploma Legal, "a resposta ou retificação atenderá, quanto à forma e à duração, ao seguinte: I - praticado o agravo em mídia escrita ou na internet, terá a resposta ou retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a dimensão da matéria que a ensejou; II - praticado o agravo em mídia televisiva, terá a resposta ou retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a duração da matéria que a ensejou; III - praticado o agravo em mídia radiofônica, terá a resposta ou retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a duração da matéria que a ensejou. § 1o Se o agravo tiver sido divulgado, publicado, republicado, transmitido ou retransmitido em mídia escrita ou em cadeia de rádio ou televisão para mais de um Município ou Estado, será conferido proporcional alcance à divulgação da resposta ou retificação. § 2o O ofendido poderá requerer que a resposta ou retificação seja divulgada, publicada ou transmitida nos mesmos espaço, dia da semana e horário do agravo. § 3o A resposta ou retificação cuja divulgação, publicação ou transmissão não obedeça ao disposto nesta Lei é considerada inexistente. § 4o Na delimitação do agravo, deverá ser considerado o contexto da informação ou matéria que gerou a ofensa."

Deferindo, ou não, o eventual pedido de liminar, após a instrução do processo, será prolatada sentença no prazo máximo de trinta dias, contados do ajuizamento da demanda, salvo se o pedido for convertido em perdas e danos.

A outro giro, pode o ofendido optar, de acordo com a sua conveniência, por um requerimento indenizatório, pleiteando uma reparação pelo dano extrapatrimonial causado. A respeito do valor da indenização a ser fixado pelo juiz, vale destacar a impossibilidade de estar adstrito aos limites previamente tarifados em diplomas legais, uma vez que a *Lex Fundamentallis* agasalhou a indenização por dano moral de forma ampla e irrestrita, sendo incompatível com a Carta Maior qualquer limitação indenizatória.[62] Outrora, a Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67), editada durante a ditadura militar, estabelecia limites tarifários para a indenização por danos causados pela imprensa – o que é, a toda evidência, incompatível com o sistema de reparação integral consagrado constitucionalmente. Aliás, o Pretório Excelso já solidificou o entendimento de que a Lei de Imprensa é incompatível com a norma constitucional (em linguagem técnica, *não foi recepcionada* ou *não foi novada* pelo Texto Constitucional), afastando, em definitivo, qualquer tabelamento na fixação do *quantum* reparatório.[63]

Ressalte-se, de passagem, que a eventual mitigação da liberdade de imprensa não implica em repristinar, em trazer de volta, a lamentável prática da censura. O que se tem, em concreto, é que a democracia e as liberdades constitucionais podem

62. A Súmula 281 do Superior Tribunal de Justiça já havia consagrado: "A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa".

63. Colhe-se da decisão: "Óbice lógico à confecção de uma lei de imprensa que se orne de compleição estatutária ou orgânica. A própria Constituição, quando o quis, convocou o legislador de segundo escalão para o aporte regratório da parte restante de seus dispositivos (art. 29, art. 93 e § 5º do art. 128). São irregulamentáveis os bens de personalidade que se põem como o próprio conteúdo ou substrato da liberdade de informação jornalística, por se tratar de bens jurídicos que têm na própria interdição da prévia interferência do Estado o seu modo natural, cabal e ininterrupto de incidir. Vontade normativa que, em tema elementarmente de imprensa, surge e se exaure no próprio texto da Lei Suprema. 10.2. Incompatibilidade material insuperável entre a Lei nº 5.250/67 e a Constituição de 1988. Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo material ou de substância (vertical), contamina toda a Lei de Imprensa: a) quanto ao seu entrelace de comandos, a serviço da prestidigitadora lógica de que para cada regra geral afirmativa da liberdade é aberto um leque de exceções que praticamente tudo desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além de um simples projeto de governo para alcançar a realização de um projeto de poder, este a se eternizar no tempo e a sufocar todo pensamento crítico no País. 10.3 São de todo imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da Lei 5.250/67 com a Constituição, seja mediante expurgo puro e simples de destacados dispositivos da lei, seja mediante o emprego dessa refinada técnica de controle de constitucionalidade que atende pelo nome de 'interpretação conforme a Constituição'. A técnica da interpretação conforme não pode artificializar ou forçar a descontaminação da parte restante do diploma legal interpretado, pena de descabido incursionamento do intérprete em legiferação por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo, de fins e de viés semântico (linhas e entrelinhas) do texto interpretado. Caso-limite de interpretação necessariamente conglobante ou por arrastamento teleológico, a pré-excluir do intérprete/aplicador do Direito qualquer possibilidade da declaração de inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei sindicada, mas permanecendo incólume uma parte sobejante que já não tem significado autônomo. Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um todo *pro indiviso*" (STF, Ac. Tribunal Pleno, ADPF 130, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 30.4.09, *DJU* 6.11.09).

impor uma relativização no exercício de todo e qualquer direito, inclusive no que tange à liberdade de expressão e de imprensa, quando colidir com outros valores, também constitucionais, de proteção da pessoa humana. Em comentário esclarecedor, bem registra Edílsom Farias não ser possível "confundir censura com controle jurisdicional da legalidade no exercício da liberdade de comunicação social, que é função reservada aos juízes e tribunais na democracia constitucional[...] Isto é, *não constituem censura as medidas judiciais decretadas para apurar a responsabilidade dos meios de comunicação social no exercício de sua atividade informativa*".[64]

O certo é que a regra geral é a liberdade de imprensa. Entrementes, essa ampla divulgação e manifestação de fatos não é ilimitada ou absoluta, encontrando restrições, dentre outras hipóteses, nos direitos da personalidade, coibindo abusos na veiculação de notícias. Aliás, esse entendimento restou assentado na Corte Suprema, como se nota:

> "*Mecanismo constitucional de calibração de princípios*. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a 'livre' e 'plena' manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando *a posteriori*, infletem sobre as causas

64. FARIAS, Edílsom. *Liberdade de expressão e comunicação*: teoria e proteção constitucional, op. cit., p. 284. Nessa linha de intelecção, assegura o eminente e atuante Promotor de Justiça no estado do Piauí, que a *restrição à liberdade de expressão* "possui fundamento constitucional", enquanto a *censura* "é repelida pela Constituição. A restrição é medida necessária para harmonizar a expressão e a comunicação com os direitos de terceiros ou interesses coletivos protegidos pela Lei Fundamental, já a censura constitui determinação administrativa proveniente de órgãos públicos vinculados ao Poder Executivo" (p. 286).

para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa" (STF, Ac. Tribunal Pleno, ADPF 130, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 30.4.09, *DJU* 6.11.09).

Toda essa coerência de raciocínio também é aplicável à *liberdade de expressão*, permitindo antever a existência de limites ao seu exercício. Com isso, o chamado *hate speech* (consistente nas manifestações de pensamento ilimitadas, contendo declarações de ódio, desprezo ou intolerância, normalmente atreladas a etnia, religião, gênero ou orientação sexual) não é permitido pelo sistema jurídico brasileiro. Até porque a Constituição não vedou, tão só, ao Poder Público a prática de atos discriminatórios, impondo, por igual, a todo e qualquer cidadão ou pessoa jurídica tal conduta. Por isso, impor limites à liberdade de expressão é manter acesa a luz contra o preconceito e a intolerância – que atingem, em especial, as minorias sociais, étnicas e econômicas. Isso não permite, porém, como adverte Daniel Sarmento, que "o intérprete se engaje em abstrusas desconstruções dos atos expressivos, visando a encontrar preconceitos e mensagens discriminatórias ocultas, para assim fundamentar limitações às liberdades comunicativas".[65] Não se esqueça: a liberdade de expressão é a regra constitucional, apenas não sendo absoluta.

Em síntese conclusiva, infere-se que a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, consagradas constitucionalmente, não têm caráter absoluto, podendo sofrer flexibilização no caso concreto, quando algum direito fundamental, também assegurado constitucionalmente, reclame proteção privilegiada.[66]

4.7 A liberdade de expressão, os direitos da personalidade e a publicação das biografias não autorizadas

Ainda em relação à liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa (direito de comunicação social), constitucionalmente asseguradas, surge o interessante questionamento a respeito da publicação de biografias não autorizadas de pessoas públicas.

Pois bem, em se tratando de fatos notórios, que despertam o interesse da coletividade (ou, pelo menos, de setores dela), envolvendo a vida privada de pessoas (quase sempre, públicas), parece-nos bem razoável admitir a publicação de biografias, por conta da liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa – que são valores jurídicos afirmados constitucionalmente.

Isso porque entendemos que as latitudes e longitudes da liberdade de imprensa, comtemplada no Texto Magno, abrange não apenas o direito de informar, mas, na

65. SARMENTO, Daniel. "A liberdade de expressão e o problema do *hate speech*", op. cit., p. 94.

66. Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no rumoroso caso "Ellwanger", entendeu que a liberdade de expressão *"não é garantia constitucional absoluta"*, encontrando *"limites morais e jurídicos"*, e que o direito à livre expressão *"não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam em ilicitude penal"*, devendo prevalecer "os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica" (STF, Tribunal Pleno, *HC* 82.424-2/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 17.9.03).

mesma magnitude, o direito de ser informado. Notícias sobre acontecimentos envolvem um processo cultural de informação e de conhecimento, contribuindo decisivamente para evolução da sociedade. A própria conotação do vocábulo livre diz respeito ao que "forma" e ao que "informa", contribuindo para o pensamento (livre), a produção intelectual, artística e científica (livre) e a comunicação social (livre) sirvam como fonte de conhecimento.

E, certamente, disso derivam novas ideias e novas ações para uma sociedade mais justa, culta e solidária. Cultura é cidadania.

Perlustrando esse caminho seguro, conclui-se, com convicção e segurança, que a falta de autorização do biografado (ou dos seus herdeiros, no caso de uma biografia póstuma) não se mostra um empecilho à publicação de uma biografia (obra nitidamente cultural, de conteúdo informativo), em face do interesse social no conhecimento dos fatos.

Realmente, o direito à liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa, vocacionados à autorização de publicação de biografias não autorizadas, transpassa o solitário pensamento de um ser humano (o autor dos escritos), ganhando a leitura e a participação de terceiros e do mundo, como um todo. E, assim, se faz História da humanidade (com maiúscula, sim), entremeada pela comunicação entre as pessoas, pelas palavras (ditas e redigidas). Até porque a História se aperfeiçoa pelo que se conta, e não pelo que se deixou de dizer. E esse contexto, por óbvio, envolve também críticas, elogios, narrativas, exposições, relatos... *As palavras, enfim, ganham vida e se tornam a vida.*

Prospectando sobre essa importância dos escritos para a História, não se pode deixar de reconhecer que o Novo Testamento, por exemplo, é, de certo modo, a biografia não autorizada de Jesus Cristo.

Nessa linha de intelecção, toda e qualquer restrição à liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa constitui, em linhas gerais, uma prática inaceitável em um Estado constitucional de Direito e deve ser reprimida. Nessa esteira, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa,[67] já alertou para a circunstância de que o ordenamento constitucional brasileiro não admite a figura da censura prévia como mecanismo afirmador das democracias.

---

67. Significativo o trecho aqui transcrito da decisão do Pretório Excelso: "2. Regime constitucional da liberdade de imprensa como reforço das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão em sentido genérico, de modo a abarcar os direitos à produção intelectual, artística, científica e comunicacional. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome 'Da Comunicação Social' (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de 'atividades' ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota

Pensar em sentido contrário é estabelecer censura, que nada mais é do que o controle prévio das informações a serem levadas ao público. Exigir autorização prévia do biografado, ou dos seus familiares, seria, pois, um mecanismo de controle de informações que podem tocar ao interesse da coletividade, o que se mostra incompatível com o espírito constitucional. Como obstar, sem ferir o direito de ser informado, que se transcreva, por exemplo, a trajetória de um político envolvido em corrupção ou de uma pessoa com deficiência que se tornou um vitorioso esportista?

No entanto, em se tratando de detalhes particulares da vida privada de uma pessoa (inclusive das pessoas públicas, as chamadas celebridades), considerando que a liberdade de expressão não pode ser absoluta, é possível pensar na incidência dos instrumentos da responsabilidade civil, e também da penal, com vistas à proteção dos direitos da personalidade.

Essa utilização dos instrumentos do direito indenizatório, no que diz respeito às biografias não autorizadas, evidencia uma solução possível para a harmônica convivência entre a liberdade de expressão e a intimidade do biografado: conceder *precedência ao direito cujo exercício não anulará o outro, permitindo que posteriormente se corrijam os equívocos de origem*. Com isso, deve ser prestigiada a liberdade de expressão e de imprensa, cujo exercício abusivo pode desencadear instrumentos efetivos de proteção da personalidade. Ao revés, privilegiar os direitos da personalidade importaria em sacrificar, inteiramente, a liberdade de expressão.

Vislumbramos, no ponto, uma ponderação (balanceamento) dos interesses conflitantes, conduzindo ao entendimento de que biografar é uma descrição de coisas já acontecidas, é atividade de quem apenas descreve o modo pelo qual o biografado viveu e já exteriorizou a sua intimidade e a sua vida privada. É informação de fatos de alcance e interesse social. Noutros termos, o ato de biografar não se traduz em interceptar escutas telefônicas, teleobjetivar recintos privados ou qualquer outra forma de obstruir o direito que assiste à pessoa humana de desfrutar de uma vida íntima e manter relações de natureza privada. Nada disso! Biografar é a descrição do que vem depois desse desfrute, materializado por um modo a que o biógrafo teve acesso.

E é exatamente por isso que, *prima facie*, se nos afigura merecedor de proteção jurídica o direito à liberdade de expressão, com a efetiva possibilidade de publicação de biografias, mesmo não autorizadas pelo biografado ou pelos seus herdeiros.

Por outro turno, não se olvide que se a biografia não autorizada descambar para o campo da invencionice ou da distorção dos fatos, com violação da personalidade do biografado, será cabível a utilização dos mecanismos reparatórios do Direito Civil, sem prejuízo de eventual responsabilização penal, por crime contra a honra. Aliás,

---

de potencial emancipatório de mentes e espíritos. *O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização*" (STF, Ac. Tribunal Pleno, ADPF 130, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 30.4.09, *DJU* 6.11.09).

vislumbramos nessa arquitetura, inclusive, um profícuo espaço para um debate sobre a *indenização punitiva* (pena civil), como mecanismo de coibir publicações ofensivas à personalidade alheia. Seguramente, esse é o equacionamento da tensão entre as liberdades comunicativas e os direitos da personalidade. Enfim, supondo que, concretamente, ao lado de biografias sérias e embasadas em ampla e consistente pesquisa fática, o mercado editorial também disponibilize trabalhos que beiram a leviandade, vislumbramos que somente as primeiras constituam trabalhos legitimamente merecedores de tutela jurídica.

A jurisprudência que vinha se concebendo sobre o tema terminava por se inclinar para o campo da proibição da publicação das biografias não autorizadas. Exemplificativamente, o cantor *Roberto Carlos* obteve uma autorização judicial para a apreensão dos exemplares de uma biografia não autorizada que revelava situações relativas à sua vida (TJ/RJ, Ac. unân. 18ª Câm. Cív., Agr. Instr. 2007.002.06253, rel. Des. Pedro Freire Raguenet, j. 3.5.07). Noutro episódio, o Poder Judiciário de Sergipe suspendeu a publicação da obra *Lampião – O Mata Sete*, que levantava suspeitas sobre a suposta condição homossexual do famoso cangaceiro, a requerimento de sua filha.[68,69]

Todavia, em visível e oportuna mudança (corretiva) de rumo do entendimento jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4815/DF, proposta pela *Associação Nacional dos Editores de Livros* – ANEL, determinou a interpretação conforme a Constituição dos arts. 20 e 21 do Código Civil, afastando do ordenamento jurídico brasileiro a necessidade do consentimento da pessoa biografada (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas) para a publicação ou veiculação de obras biográficas referentes a "pessoas públicas ou envolvidas em acontecimentos de interesse coletivo".[70] A decisão da Corte Excelsa, com relatoria da culta Ministra Cármem Lúcia, corretamente, ao invés de declarar a inconstitucionalidade dos citados dispositivos do Código Civil, estabeleceu que se promova uma interpretação deles conforme a Constituição, de modo a concluir que o sistema jurídico brasileiro admite a publicação de biografias não autorizadas. Veja-se o arremate do *decisum*:

---

68. A decisão do Juiz de Direito *Aldo Albuquerque de Mello* (Processo n. 2011.10701579), da 7ª Vara Cível de Aracaju (SE), afirma: "Entre evitar eventual prejuízo financeiro do requerido, com a proibição da publicação do seu livro e evitar a ofensa à honra da requerente e de seus pais, deve o Judiciário, por óbvio, ficar com a segunda opção e proteger a honra e a intimidade da requerente e seus genitores".

69. Para aprofundamento sobre o tema, veja-se: GARCIA, Rebeca, "Biografias não autorizadas: liberdade de expressão e privacidade na história da vida privada", op. cit., especialmente p. 66-67.

70. É particularmente pertinente um trecho da fundamentada decisão: "Não se alegue estar-se diante de circunstâncias que respeitam sempre a quem exerce cargo do povo, pelo que este deve dele saber, não se podendo escusar de deixar que a plena luz entre sobre todos os setores de sua vida. Primeiro, porque há sempre um espaço de indevassabilidade e segredo que compõe o íntimo de uma pessoa e que é de parco ou nenhum conhecimento dos outros. Segundo, porque quem faz a sua vida e profissão na praça pública, com a presença e a confiança do povo e angaria o prestígio que o qualifica e enaltece não há de pretender esquivar-se deste mesmo público segundo o seu voluntarismo, como se a praça fosse um mecanismo virtual, com botão de liga/desliga ao sabor do capricho daquele que buscou e fez-se notório."

"Os arts. 20 e 21 do Código Civil do Brasil contemplam, em sua leitura direta, a exigência de autorização prévia para divulgação de escritos, transmissão da palavra, ou publicação, exposição ou utilização da imagem de uma pessoa sem o que poderão ser proibidas, a do interessado requerimento ou, em se tratando de morto ou de ausente, do cônjuge, ascendentes ou descendentes, sem prejuízo da indenização cabível, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Essa interpretação, pretensamente protetiva do direito à intangibilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa, não pode ser adotada relativamente à produção de obra biográfica, pela circunstância de não se conter exceção expressa a esse gênero no dispositivo legal.

E assim não pode porque a liberdade de pensamento, de expressão, de produção artística, cultural, científica estaria comprometida e a censura particular seria a forma de se impor o silêncio à história da comunidade e, em algumas ocasiões, a história dos fatos que ultrapassam fronteiras e gerações. (...)

Pelo exposto, julgo procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas". (STF, Ac. unân. Tribunal Pleno, ADIn 4815/DF, rel. Min. Cármem Lúcia, j. 10.6.15)

Em lapidar trecho, destacou a Corte Excelsa que exigir prévia autorização para a publicação de biografias importaria em verdadeira "censura e censura é uma forma de cala-boca".

Obtempere-se, de qualquer maneira, que a decisão do Tribunal Supremo deixa claro que "a bisbilhotice e o incômodo do olhar obsessivo do outro sobre a vida de uma pessoa" podem ser punidos, na forma do sistema de responsabilidades. Isso E, assim, restou reafirmado "o direito à inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa, nos termos do inc. X do art. 5º da Constituição da República, cuja transgressão haverá de se reparar mediante indenização".

Isso porque a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da imagem, da honra... enfim, da personalidade digna de uma pessoa humana não foi atingida pelo entendimento aqui defendido. Trata-se, tão só, de um afastamento, com o uso da técnica de ponderação de interesses, de um juízo preliminar de censura. É possível publicar, sim, exercendo a liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa. Contudo, havendo afronta à personalidade alheia incidem os instrumentos da responsabilidade civil e penal, com vistas a impor ao agente causador do dano sanção correspondente à gravidade do ato praticado.

Sob o prisma processual, é possível imaginar mecanismos de reparação do dano (indenização por dano moral, por exemplo) e de prevenção de danos (através das técnicas de tutela específica).

4.8 O direito (da personalidade) ao esquecimento e a liberdade de imprensa

Interessante discussão travada em nossa doutrina, com repercussão nos Tribunais, diz respeito ao direito da personalidade ao *esquecimento*.

O ser humano é inacabado, encontrando-se, certamente, em eterno processo de amadurecimento e evolução (mental, intelectual...). O escritor uruguaio Eduardo Galeano chegou mesmo a afirmar que "somos o que fazemos, mas somos, principalmente, o que fazemos para mudar o que somos". Bem por isso, toda pessoa humana tem o direito de arrepender-se de fatos passados, mantendo a sua caminhada rumo ao melhor.

Até mesmo porque existem certos fatos pretéritos que, se não matam fisicamente, causam profunda corrosão na alma e no espírito. É nesse quadrante que se concebe o *direito ao esquecimento* ou, como se diz na Itália, *diritto all'oblio*.

Em linhas gerais, o direito ao esquecimento não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou de reescrever a história – ainda que seja a própria história. Em verdade, trata-se da possibilidade reconhecida a todas as pessoas de restringir o uso de fatos pretéritos ligados a si, mais especificamente no que tange ao modo e à finalidade com que são lembrados esses fatos passados.[71]

Mais ainda: é o direito de impedir que dados e fatos pessoais de outrora sejam revividos, repristinados, no presente ou no futuro de maneira descontextualizada.

Enfim, é uma garantia contra o que vem se denominando de *superinformacionismo*.

Embora sem invocar, expressamente, o direito ao esquecimento, a apresentadora de televisão *Maria da Graça Xuxa Meneghel*, em 1987, requereu em juízo o direito ao esquecimento em relação à sua participação no filme *Amor, Estranho Amor*, de Wálter Hugo Khouri, de 1982, no qual participou de uma cena em que apareceu nua, na cama, com um garoto de 12 anos de idade. Considerando o seu posterior perfil profissional infanto-juvenil, sustentou o direito ao arrependimento da participação cinematográfica-erótica. Foi vencedora da ação, tendo sido reconhecido o seu direito de "apagar uma imagem pretérita incompatível com uma imagem atual, como hoje é permitido aos autores de obras literárias que pretendam renegar trabalhos que consideram imperfeitos ou menos dignos" (TJ/RJ, Ap. Cív. 3819/91, Rel. Des. Thiago Ribas Filho).

Para além disso, independentemente de um arrependimento pessoal, certos fatos íntimos revelados podem gerar no titular a vontade de retirá-los da pauta do dia, deixando serem esquecidos por terceiros e pela coletividade.[72]

---

71. SCHREIBER, Anderson. *Direitos da personalidade*, op. cit., p. 171.

72. A título de ilustração, lembra-se que uma jornalista, no Paraná, perdeu o emprego por conta da publicação de fotos suas nuas por um ex-namorado. As imagens chegaram a ser propagadas em mais de sete milhões de *sites* pornográficos pelo mundo.

É bem verdade que nessa ambiência do direito ao esquecimento, surgem curiosas dagações: qual é o espectro de incidência do direito ao esquecimento? Abrangeria alquer fato ocorrido no passado e que vem a incomodar o titular? O assunto fica oibido de ser reavivado por qualquer membro da sociedade? Qual é o lapso temporal cessário para se pleitear o respeito ao direito de esquecer?

Todas essas indagações não podem ser respondidas aprioristicamente, exigindo, n cada caso, um cuidadoso balanceamento dos valores jurídicos em apreço, atra-s da técnica de ponderação de interesses. Somente à luz de cada hipótese fática ncreta é que será possível esclarecer qual a abrangência do fato a ser esquecido e tempo razoável para que um fato não mais deva reverberar, com vistas à proteção o titular da personalidade.

O simples reconhecimento da existência efetiva de um *direito ao esquecimento* ão conduz, por si só, ao imperativo dever de abster da informação (ou de indenizar informação já publicada). Até mesmo porque existem fatos que estão enraizados na ida e na história de uma sociedade, prendendo-se, muita vez, ao próprio processo de ormação da identidade cultural de um povo. Estes não serão apagados e, tampouco, squecidos. É preciso, pois, ponderar os interesses em conflito (personalidade, de m lado, liberdade de imprensa, do outro) para que se possa, caso a caso, deliberar melhor solução.

Esse balanceamento de interesses, inclusive, foi posto à prova em um julgado, em que o Superior Tribunal de Justiça analisou o pedido dos familiares de *Aida Curi*, uma jovem brutalmente assassinada aos 18 anos de idade, em 1958, no Rio de Janeiro. A vítima foi levada à força por dois rapazes (ajudados pelo porteiro de um prédio) ao topo de um edifício na Avenida Atlântica, abusada sexualmente e, após a queda do terraço no 12º andar, veio a falecer. A história desse crime foi apresentada no programa *Linha Direta*, da Rede Globo de Televisão, com a divulgação do nome da vítima e dos fatos reais ocorridos. Segundo os seus familiares, a veiculação televisiva trouxe a lembrança do crime e todo sofrimento que o envolve. No julgamento, a Corte Superior de Justiça entendeu que, nesse caso, o crime era indissociável do nome da vítima e, por isso, não seria possível à emissora retratar a história com omissão do nome da vítima, a exemplo do que ocorre em outros trágicos crimes, como os que envolveram a missionária *Dorothy Stang* e o jornalista *Vladimir Herzog*. Vale a pena acompanhar trechos da substanciosa decisão, da lavra do culto Ministro Luís Felipe Salomão:

> "(...) 2. Nos presentes autos, o cerne da controvérsia passa pela ausência de contemporaneidade da notícia de fatos passados, a qual, segundo o entendimento dos autores, reabriu antigas feridas já superadas quanto à morte de sua irmã, Aida Curi, no distante ano de 1958. Buscam a proclamação do seu direito ao esquecimento, de não ter revivida, contra a vontade deles, a dor antes experimentada por ocasião da morte de Aida Curi, assim também pela publicidade conferida ao caso décadas passadas.
>
> 3. Assim como os condenados que cumpriram pena e os absolvidos que se envolveram em processo-crime (REsp. nº 1.334/097/RJ), as vítimas de crimes

e seus familiares têm direito ao esquecimento – se assim desejarem –, direito esse consistente em não se submeterem a desnecessárias lembranças de fatos passados que lhes causaram, por si, inesquecíveis feridas. Caso contrário, chegar-se-ia à antipática e desumana solução de reconhecer esse direito ao ofensor (que está relacionado com sua ressocialização) e retirá-lo dos ofendidos, permitindo que os canais de informação se enriqueçam mediante a indefinida exploração das desgraças privadas pelas quais passaram.

4. Não obstante isso, assim como o direito ao esquecimento do ofensor – condenado e já penalizado – deve ser ponderado pela questão da historicidade do fato narrado, assim também o direito dos ofendidos deve observar esse mesmo parâmetro. Em um crime de repercussão nacional, a vítima – por torpeza do destino – frequentemente se torna elemento indissociável do delito, circunstância que, na generalidade das vezes, inviabiliza a narrativa do crime caso se pretenda omitir a figura do ofendido.

5. Com efeito, *o direito ao esquecimento que ora se reconhece para todos, ofensor e ofendidos, não alcança o caso dos autos, em que se reviveu, décadas depois do crime, acontecimento que entrou para o domínio público, de modo que se tornaria impraticável a atividade da imprensa para o desiderato de retratar o caso Aida Curi, sem Aida Curi.*

6. *É evidente ser possível, caso a caso, a ponderação acerca de como o crime tornou-se histórico, podendo o julgador reconhecer que, desde sempre, o que houve foi uma exacerbada exploração midiática, e permitir novamente essa exploração significaria conformar-se com um segundo abuso só porque o primeiro já ocorrera.* Porém, no caso em exame, não ficou reconhecida essa artificiosidade ou o abuso antecedente na cobertura do crime, inserindo-se, portanto, nas exceções decorrentes da ampla publicidade a que podem se sujeitar alguns delitos.

7. *Não fosse por isso, o reconhecimento, em tese, de um direito de esquecimento não conduz necessariamente ao dever de indenizar.* Em matéria de responsabilidade civil, a violação de direitos encontra-se na seara da ilicitude, cuja existência não dispensa também a ocorrência de dano, com nexo causal, para chegar-se, finalmente, ao dever de indenizar. No caso de familiares de vítimas de crimes passados, que só querem esquecer a dor pela qual passaram em determinado momento da vida, há uma infeliz constatação: na medida em que o tempo passa e vai se adquirindo um 'direito ao esquecimento', na contramão, a dor vai diminuindo, de modo que,

relembrar o fato trágico da vida, a depender do tempo transcorrido, embora possa gerar desconforto, não causa o mesmo abalo de antes.

8. A reportagem contra a qual se insurgiram os autores foi ao ar 50 (cinquenta) anos depois da morte de Aida Curi, circunstância da qual se conclui não ter havido abalo moral apto a gerar responsabilidade civil. *Nesse particular, fazendo-se a indispensável ponderação de valores, o acolhimento do direito ao esquecimento, no caso, com a consequente indenização, consubstancia desproporcional corte à liberdade de imprensa, se comparado ao desconforto gerado pela lembrança*" (STJ, Ac. 4ª T., REsp. 1.335.153/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 28.5.13, *DJe* 10.9.13).

De fato, em situações como essa, na medida em que o tempo passa, as dores vão diminuindo (até porque, como diz o ditado, *o tempo é o senhor da razão*), de modo que, relembrar o fato trágico da vida, a depender do tempo transcorrido, embora possa gerar desconforto, não causa o mesmo abalo de antes.

Com lastro em outros fatos concretos, porém, a solução, por igual, pode apontar noutro sentido.

O próprio Superior Tribunal de Justiça teve oportunidade, no mesmo dia, de deliberar sobre o direito ao esquecimento de uma outra maneira. O caso que ficou conhecido, mundialmente, como *Chacina da Candelária*, no Rio de Janeiro, foi reapresentado pela Rede Globo de Televisão. Um dos acusados pelo bárbaro crime, que foi absolvido por unanimidade no julgamento penal pelo Tribunal do Júri, ajuizou, então, uma ação ressarcitória contra a emissora, pleiteando indenização porque teve violado o seu direito ao esquecimento, máxime por ter sido absolvido judicialmente. Deliberando sobre a causa, a Corte Superior entendeu que, nesse caso, a fatídica história poderia ter sido veiculada de forma fidedigna, sem qualquer menção ao nome e à imagem daquela pessoa – que já tinha sido, repita-se, absolvido criminalmente. Até porque veicular o seu nome e imagem em rede nacional não reforçou uma visão de *inocentado*, mas sim de *indiciado*. Nesse julgado, diferentemente, concluiu-se pela proteção do direito ao esquecimento, com imputação de ressarcimento à emissora de televisão:

> "9. Não há dúvida de que a história da sociedade é patrimônio imaterial do povo e nela se inserem os mais variados acontecimentos e personagens capazes de revelar, para o futuro, os traços políticos, sociais ou culturais de determinada época. Todavia, a historicidade da notícia jornalística, em se tratando de jornalismo policial, há de ser vista com cautela. Há, de fato, crimes históricos e criminosos famosos; mas também há crimes e criminosos que se tornaram artificialmente históricos e famosos, obra da exploração midiática exacerbada e de um populismo penal satisfativo dos prazeres primários das multidões, que simplifica o fenômeno criminal às estigmatizadas figuras do 'bandido' vs. 'cidadão de bem'.
>
> 10. É que a historicidade de determinados crimes por vezes é edificada à custa de vários desvios de legalidade, por isso não deve constituir óbice em si intransponível ao reconhecimento de direitos como o vindicado nos presentes autos. Na verdade, a permissão ampla e irrestrita a que um crime e as pessoas nele envolvidas sejam retratados indefinidamente no tempo – a pretexto da historicidade do fato – pode significar permissão de um segundo abuso à dignidade humana, simplesmente porque o primeiro já fora cometido no passado. *Por isso, nesses casos, o reconhecimento do 'direito ao esquecimento' pode significar um corretivo – tardio, mas possível – das vicissitudes do passado, seja de inquéritos policiais ou processos judiciais pirotécnicos e injustos, seja da exploração* populista da mídia.
>
> 11. É evidente o legítimo interesse público em que seja dada publicidade da resposta estatal ao fenômeno criminal. Não obstante, é imperioso também ressaltar que o interesse público – além de ser conceito de significação fluida – não coincide com o interesse do público, que é guiado, no mais das vezes, por sentimento de execração pública, praceamento da pessoa humana, condenação sumária e vingança continuada.
>
> 12. Assim como é acolhido no direito estrangeiro, é imperiosa a aplicabilidade do direito ao esquecimento no cenário interno, com base não só na principiologia decorrente dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, mas também diretamente do direito positivo infraconstitucional.

A assertiva de que uma notícia lícita não se transforma em ilícita com o simples passar do tempo não tem nenhuma base jurídica. O ordenamento é repleto de previsões em que a significação conferida pelo Direito à passagem do tempo é exatamente o esquecimento e a estabilização do passado, mostrando-se ilícito sim reagitar o que a lei pretende sepultar. Precedentes de direito comparado.

13. Nesse passo, o Direito estabiliza o passado e confere previsibilidade ao futuro por institutos bem conhecidos de todos: prescrição, decadência, perdão, anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, prazo máximo para que o nome de inadimplentes figure em cadastros restritivos de crédito, reabilitação penal e o direito ao sigilo quanto à folha de antecedentes daqueles que já cumpriram pena (art. 93 do Código Penal, art. 748 do Código de Processo Penal e art. 202 da Lei de Execuções Penais). Doutrina e precedentes.

14. Se os condenados que já cumpriram a pena têm direito ao sigilo da folha de antecedentes, assim também a exclusão dos registros da condenação no Instituto de Identificação, por maiores e melhores razões aqueles que foram absolvidos não podem permanecer com esse estigma, conferindo-lhes a lei o mesmo direito de serem esquecidos.

15. Ao crime, por si só, subjaz um natural interesse público, caso contrário nem seria crime, e eventuais violações de direito resolver-se-iam nos domínios da responsabilidade civil. E esse interesse público, que é, em alguma medida, satisfeito pela publicidade do processo penal, finca raízes essencialmente na fiscalização social da resposta estatal que será dada ao fato. Se é assim, o interesse público que orbita o fenômeno criminal tende a desaparecer na medida em que também se esgota a resposta penal conferida ao fato criminoso, a qual, certamente, encontra seu último suspiro, com a extinção da pena ou com a absolvição, ambas consumadas irreversivelmente. E é nesse interregno temporal que se perfaz também a vida útil da informação criminal, ou seja, enquanto durar a causa que a legitimava. Após essa vida útil da informação seu uso só pode ambicionar, ou um interesse histórico, ou uma pretensão subalterna, estigmatizante, tendente a perpetuar no tempo as misérias humanas.

16. Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados que cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em processo criminal, além de sinalizar uma evolução cultural da sociedade, *confere concretude a um ordenamento jurídico que, entre a memória – que é a conexão do presente com o passado – e a esperança – que é o vínculo do futuro com o presente –, fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, pois afirma-se, na verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia com a presunção* legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana.

17. Ressalvam-se do direito ao esquecimento os fatos genuinamente históricos – historicidade essa que deve ser analisada em concreto –, cujo interesse público e social deve sobreviver à passagem do tempo, desde que a narrativa desvinculada dos envolvidos se fizer impraticável.

18. No caso concreto, a despeito de a Chacina da Candelária ter se tornado – com muita razão – um fato histórico, que expôs as chagas do País ao mundo, tornando-se símbolo da precária proteção estatal conferida aos direitos humanos da criança e do adolescente em situação de risco, o certo é que a fatídica história seria bem contada e de forma fidedigna sem que

> para isso a imagem e o nome do autor precisassem ser expostos em rede nacional. Nem a liberdade de imprensa seria tolhida, nem a honra do autor seria maculada, caso se ocultassem o nome e a fisionomia do recorrido, ponderação de valores que, no caso, seria a melhor solução ao conflito.
>
> 19. Muito embora tenham as instâncias ordinárias reconhecido que a reportagem se mostrou fidedigna com a realidade, a receptividade do homem médio brasileiro a noticiários desse jaez é apta a reacender a desconfiança geral acerca da índole do autor, o qual, certamente, não teve reforçada sua imagem de inocentado, mas sim a de indiciado. No caso, permitir nova veiculação do fato, com a indicação precisa do nome e imagem do autor, significaria a permissão de uma segunda ofensa à sua dignidade, só porque a primeira já ocorrera no passado, uma vez que, como bem reconheceu o acórdão recorrido, além do crime em si, o inquérito policial consubstanciou uma reconhecida 'vergonha' nacional à parte" (STJ, Ac. Unân., 4ª T., REsp. 1.334.097/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 28.5.13, *DJe* 10.9.13).

Realmente, mesmo quem cometeu um crime, depois de determinado tempo, tem o direito de ver apagadas todas as consequências penais do seu ato, considerados o direito à reabilitação, afastando-se a possibilidade de considerar o fato para fins de reincidência, apagando-o de todos os registros criminais e processuais públicos. Se assim é até mesmo em relação à esfera penal, não parece razoável que os atos da vida privada, uma vez divulgados, possam permanecer indefinidamente nos meios de informação, em casos tais.

Acresça-se a tudo isso que no universo da *Internet* o direito ao esquecimento ganha contornos ainda mais difíceis, na medida em que a superexposição pode obstar, de algum modo, o direito ao esquecimento.

4.9 A proteção dos direitos da personalidade e a insuficiência dos argumentos clássicos: a tutela avançada (preventiva e repressiva) dos direitos da personalidade

A tutela dos direitos da personalidade conta com diferentes mecanismos de efetivação em nosso ordenamento jurídico.

Perfilhando-se à regra já insculpida no art. 5º, X, da Constituição Federal e nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil de 2015 (para a tutela jurisdicional individual) e 84 do Código de Defesa do Consumidor (para a tutela jurisdicional coletiva), veio o art. 12 do Texto Codificado a estabelecer a possibilidade de tutela (proteção) preventiva e repressiva (compensatória) para os direitos da personalidade.

Assim, está autorizada a concessão de provimentos judiciais reparatórios (compensatórios) e inibitórios (preventivos). Exemplificativamente, se houver uma indevida inserção do nome de um cliente no serviço de proteção ao crédito por um banco, abalando a sua honra objetiva e subjetiva, será possível à vítima requerer ao juiz a imediata retirada do seu nome do SPC e, no mesmo processo, uma compensação pelo dano sofrido, monetariamente.

Através do sistema de tutela preventiva (tutela específica dos direitos da personalidade) é possível a adoção, pelo juiz no caso concreto, de toda e qualquer providência tendente à integral proteção do bem jurídico personalíssimo, tais como a imposição de multa para que o agente se abstenha de alguma atividade. É permitida, inclusive, a adoção de medidas judiciais restritivas de direito, como o *mandado de distanciamento*, determinando-se ao agente que não se aproxime mais do que uma determinada distância da vítima. Será medida de grande utilidade, por exemplo, nas ações de separação de corpos, quando um dos cônjuges, eventualmente, tumultua a vida do outro, inclusive perseguindo por todo lugar. Infelizmente, não é incomum encontrar ex-cônjuges ou ex-companheiros que, após a ruptura da conjugalidade, terminam perseguindo e sufocando a pessoa com quem conviveram, atentando, muitas vezes, contra a sua privacidade e a sua dignidade como um todo. Em tais hipóteses, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinar o distanciamento, fixando um limite razoável para a abstenção da liberdade de locomoção. Por evidente, a distância variará em cada caso, dependendo da peculiaridade das pessoas e do lugar.

Para além do arsenal proposto pelo art. 12 da Lei Civil, não se olvide ainda da tutela privada (autotutela) da personalidade, inerente a qualquer ser humano, mediante a legítima defesa ou do exercício regular de um direito, desde que tal ato não ultrapasse o necessário à autotutela da personalidade.[73]

Sem dúvida, a violação dos direitos da personalidade acarreta graves consequências na órbita personalíssima, impondo danos de ordem extrapatrimonial (moral). Nesse passo, são previstas sanções jurídicas dirigidas a quem viola os direitos da personalidade de outrem, mediante a fixação de indenizações por danos não patrimoniais (reparação de danos), bem como através da adoção de providências de caráter inibitório (tutela específica), tendentes à obtenção do resultado equivalente, qual seja, o respeito aos direitos da personalidade.

No que concerne à caracterização dos danos não patrimoniais (chamados comumente de danos morais), sobreleva destacar a inexistência de qualquer necessidade de prova da dor, sofrimento, vexame, humilhação, tristeza ou qualquer sentimento negativo. Configura-se o dano moral pela simples e objetiva violação a direito da personalidade. Por isso, afirma-se que a prova desse dano moral, em certos casos, é *in re ipsa*, isto é, ínsita no próprio fato, caracterizada pela simples violação da personalidade e da dignidade do titular.[74]

---

73. Seria a conduta da apreensão de filme no qual foi indevidamente captada a imagem do ofendido, ou destruição de material gravado ilicitamente, que revelasse conversações mantidas com terceiros.

74. Essa compreensão está enraizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se pode notar: "I – O banco é responsável pelos danos morais causados por deficiência na prestação do serviço, consistente na inclusão indevida do nome de correntista nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe situação de desconforto e abalo psíquico. II – Em casos que tais, o dano é considerado *in reipsa*, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum" (STJ, Ac. unân., 3ª T., REsp. 786.239/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.4.09, *DJU* 13.5.09).

Até mesmo porque a dor, a vergonha, o desgosto, a aflição etc. é a eventual consequência do dano extrapatrimonial e não a sua essência, o seu conteúdo.[75]

Bem deliberou o Superior Tribunal de Justiça que, "no sistema jurídico atual, não se cogita da prova acerca da existência de dano decorrente da violação aos direitos da personalidade, dentre eles a intimidade, a imagem, a honra e reputação, já que, na espécie, o dano é presumido pela simples violação ao bem jurídico tutelado".[76]

Com isso, percebe-se que através da responsabilidade civil (reparação civil de danos) materializa-se, *também*, o objetivo precípuo do Direito Civil, que é a proteção avançada da pessoa humana e a afirmação de sua dignidade.

Em outras palavras: todo dano moral é decorrência de violação a direito da personalidade, caracterizado o prejuízo pelo simples atentado aos interesses jurídicos personalíssimos, independente da dor e sofrimento causados ao titular – que servirão para fins de fixação do *quantum* indenizatório. Lembre-se, aqui, oportunamente, que os direitos da personalidade não estão submetidos a um rol taxativo (*numerus clausus*), sendo aberta a sua previsão, a partir da cláusula geral protetiva da dignidade da pessoa humana.[77] Enfim, é a violação à imprescindível dignidade do homem.

Por isso, Maria Celina Bodin de Moraes propõe caracterizar-se o dano moral (ou melhor, extrapatrimonial) através da "injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição Federal".[78] Não discrepa Elimar Szaniawski, ponderando que o direito de personalidade tutela a integridade do indivíduo "garantindo e preservando a dignidade humana".[79]

Nessa ordem de ideias, o *dano moral* não se caracteriza, tão somente, em decorrência da violação da honra (o chamado *dano moral* específico). Também se consubstanciam os danos morais em decorrência da afronta à imagem, à privacidade

75. Vide, a respeito do tema, a lição de Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à pessoa humana, op. cit., p. 131.

76. STJ, Ac. unân., 4ª T., REsp. 506.437/SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 16.9.03. No mesmo sentido: "O dano moral, tido como lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às vezes de difícil constatação, por atingir os seus reflexos parte muito íntima do indivíduo – o seu interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação que o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral humano" (STJ, Ac. 4ª T., REsp. 121.757/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *DJU* 8.3.00).

77. Já deliberou o 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo sobre a indenizabilidade da violação à dignidade humana em caso no qual o correntista foi impedido de adentrar a agência bancária por conta da porta giratória, tendo sido atendido na rua, passando suas contas por baixo da porta: "Dano moral. Indenização. Banco. Cliente que foi impedido de entrar na agência bancária em virtude da existência de porta detectora de metais, mesmo depois de despojar-se de todos os seus pertences. Atendimento que se deu pelo lado de fora da agência, após o acionamento de forte esquema de segurança, sujeitando-se o usuário a passar por debaixo da porta os documentos para pagamento. Respeito à dignidade humana que não pode ser aviltada em nome da segurança. Instituições bancárias podem adotar meios não vexatórios para efetuar 'revista' em seus clientes e usuários" (1ºTACív. SP, Ac. 1ª Câm. de Férias, Ap. Cív. 943158-3, Rel. Juiz Plínio Tadeu do Amaral Malheiros, v. m., *RT* 789: 259).

78. MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à pessoa humana*, op. cit., p. 132.

79. SZANIAWSKI, Elimar. *Direitos de personalidade e sua tutela*, op. cit., p. 308.

ou à integridade física (nesse caso, apelidado de dano estético). Por isso, a nomenclatura não é, seguramente, a melhor, insinuar, indevidamente, que o dano moral seria uma violação a sentimentos negativos.

Aliás, não é despiciendo acrescentar que a cada violação de um direito da personalidade caberá uma reparação de dano autônoma e independente. Por isso, se houver violação da honra e da integridade física, haverá cumulação entre dano moral e dano estético, como, aliás, reconhece a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça:

> Súmula 387, Superior Tribunal de Justiça:
> "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Em suma: a cada direito da personalidade violado corresponderá uma reparação do dano causado, autônoma e independentemente. Por isso, é possível a cumulação de dano moral com outro dano moral. É o exemplo da cumulação do dano à honra com o dano à imagem ou do dano à privacidade com o dano à integridade física, dentre outras hipóteses.

Paradoxalmente, aprende-se a construir a defesa dos direitos da personalidade pela mesma lógica patrimonialista da tutela dos direitos de fundo econômico. Assim, se alguém ofende a propriedade ou os bens de terceiro, cabe ao titular pleitear uma importância pecuniária a título de ressarcimento. Da mesma forma, a lesão a um interesse não patrimonial resultará em resposta estritamente patrimonial. Trata-se de uma inversão de valores, pois se o dano é de natureza extrapatrimonial, não podemos persistir na reparação meramente financeira.

Assim, fortes na lição de Anderson Schreiber,[80] é hora de escaparmos de soluções míopes e propugnarmos pela "despatrimonialização, não já do dano, mas da reparação", através do alcance de meios não pecuniários que, sem substituir a compensação em dinheiro, associem-se a ela no sentido de efetivamente reparar ou aplacar o prejuízo moral.

Vale dizer, além da tutela preventiva e da tutela reparatória dos direitos da personalidade, sobreleva pontuar a possibilidade de tutela reintegratória, na forma específica, cujo objeto é reconstituir naturalmente a situação anterior ao ilícito já consumado, sem que o ofendido necessite se utilizar do mecanismo da reparação. A despecuniarização ou desmonetarização da reparação podem ser exemplificativamente apreciados no direito de resposta, quando o dano foi causado por algum veículo de comunicação, ou a retratação pública, ou mesmo a divulgação na imprensa da sentença condenatória. É de se registrar, de qualquer maneira, que a solução *in natura*, por si só, é insuficiente para a ampla e irrestrita proteção dos direitos da personalidade, não afastando os mecanismos preventivo e reparatório. Na verdade, apresenta-se o mecanismo de tutela específica como um *plus* na proteção da personalidade, que possui a interessante potencialidade de desestimular a conduta do ofensor (teoria do

80. SCHREIBER, Anderson. "Novas tendências da responsabilidade civil brasileira", op. cit., p. 65.

valor do desestímulo), sem a necessidade de se atribuir à vítima uma determinada quantia de natureza jurídica e estimativa duvidosas.

De fato, os provimentos reparatórios devem ser encarados como formas secundárias de tutelas, apenas manejáveis quando não se possa proteger o direito de maneira preventiva. Nessa seara, a tutela inibitória não se dirige contra o dano, mas à prevenção do ilícito. Ato ilícito e dano não são figuras umbilicalmente ligadas. O dano só se mostra necessário para fins de reparação, pois, mesmo sem a ocorrência de qualquer lesão, o ato ilícito já é um fato suficiente para se invocar a tutela jurisdicional. De forma irrefutável, Luiz Guilherme Marinoni[81] aduz que, "se o dano não é elemento constitutivo do ilícito, podendo este último existir independentemente do primeiro, não há razão para não se admitir uma tutela que leve em consideração apenas o ilícito, deixando de lado o dano".

De outra margem, é de se fazer referência à tutela dos direitos da personalidade na ótica penal, caracterizada pela tipificação de diferentes condutas espalhadas pela legislação penal, salvaguardando bens jurídicos de interesse público (como nos crimes contra a honra e contra a vida). Vale lembrar que a tutela penal não afasta a tutela civil e vice-versa, atuando em searas independentes.

Trilhando essas sendas, adverte Gustavo Tepedino[82] que a tutela da pessoa humana supera, no estágio atual do direito, a perspectiva setorial (direito público e privado) e não se satisfaz com técnicas ressarcitórias e repressivas (consubstanciadas no binômio lesão-sanção), exigindo instrumentos eficientes de promoção do ente humano a partir de sua integridade física.

Enfim, deve-se buscar a tutela da personalidade (natural ou jurídica) em sentido amplo, como especificação de um direito mais amplo: à vida, à saúde e à busca da satisfação social (constitucionalização dos direitos personalíssimos, socializados pela Carta Magna).

O sucesso da tutela inibitória independe ainda da afirmação da culpa do ofensor, sendo despicienda qualquer valoração subjetiva do seu comportamento ilícito. É suficiente a aferição da antijuridicidade do comportamento temido, a cuja abstenção se dirige a ordem judicial.

Historicamente, o Código Civil de 1916 não admitia a tutela inibitória da vida privada, pois, inspirado nas ideias liberais do século XIX, afastava a possibilidade de ordens judiciais ou de normas que impusessem obrigações de fazer ou de não fazer. A liberdade era um direito absoluto e insuscetível de ponderação.

Porém, a sociedade pós-moderna contribuiu sobremaneira para o agravamento da condição humana. O avanço das ciências é angustiante, pois insere o ser humano em estado de instrumentalização e total perda de referência de valores. Os danos se

81. MARINONI, Luiz Guilherme. *ATutela Inibitória*, op. cit., p. 37.
82. TEPEDINO, Gustavo. *Temas de Direito Civil*, op. cit., p. 23 ss.

proliferam e qualquer reparação se torna assimétrica diante do sacrifício aniquilador da personalidade. Muito mais importante que reparar o dano é a própria salvaguarda dos bens que integram a personalidade.

Quanto mais evoluído o Estado Democrático de Direito, mais amplos se tornam os instrumentos hábeis a inibir a materialização dos danos decorrentes, a partir da mera ameaça de lesão a direitos. Os direitos da personalidade quase sempre pressupõem interesses que colidem com situações de liberdade. Nessa tensão, caberá ao magistrado estabelecer uma prevalência axiológica de um bem diante do outro, de acordo com a concretude de cada contexto.

Para tanto, afirma o art. 12 do Diploma Substantivo que a tutela (proteção) jurídica dos direitos da personalidade, em sede civil (sem prejuízo da tutela penal), consubstanciar-se-á por meio de medidas repressivas – da chamada tutela clássica da personalidade – e, por igual, de medidas preventivas – a chamada tutela específica (que pode ser individual ou coletiva, reguladas, respectivamente, pelos arts. 497 do Código de Processo Civil e 84 do Código de Defesa do Consumidor). Assim, percebeu o legislador que a garantia dos direitos da personalidade exigia instrumentos mais eficazes do que simplesmente a possibilidade de reparar o prejuízo sofrido (através da indenização por dano extrapatrimonial). Apresentou-se necessária a adoção de medidas preventivas, que resguardassem o bem jurídico protegido contra investidas danosas.

Trata-se de medida semelhante ao *injunction* do Direito anglo-saxão, como ordem do tribunal da *common law* para o demandado adotar certo ato ou se abster de fazer algo, concedida a medida nos casos em que há um justo receio de ocorrência de efetiva ameaça de lesão a direito, através de dados objetivos e concretos. Muitas vezes, a medida restritiva se dirige a conhecida figura do perturbador. Aquela pessoa provocadora, contra quem devam ser impostos limites, em face da gravidade e urgência da interferência.

Ensina Elimar Szaniawski tratar-se "da hipótese em que terceira pessoa viola direito da personalidade de outrem sendo que o ato atentatório se protrai no tempo ou, em outras palavras, a execução do atentado não se exaure instantaneamente, mediante um só ato por parte do autor do atentado. A vítima terá por escopo obter por parte do judiciário, a cessação da execução da violação".[83]

Estabelece o art. 536 do Código de Processo Civil atual que, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente". Apesar de a norma utilizar o vocábulo *obrigações*, nada impede que o mecanismo da tutela específica seja ampliado para a proteção dos direitos da personalidade, como ressalta o §5º do citado art. 536 do Código

83. SZANIAWSKI, Elimar. *Direitos de Personalidade e sua Tutela*, op. cit., p. 248.

de Ritos.[84] Comentando, com propriedade, o tema, Sérgio Cruz Arenhart aduz que o citado dispositivo legal "elenca técnicas de coerção capazes de atuar na vontade do requerido, para impor-lhe a abstenção pretendida. Coteja, pois, o dispositivo com todas as carências da proteção à vida privada".[85]

A tutela inibitória, e os demais mecanismos de tutela específica como um todo, não se trata de espécie de medida cautelar, sendo ação de cognição exauriente, cuja finalidade dispensa eventual propositura de ação de reparação de danos. Destina-se a tutela inibitória à resolução definitiva da controvérsia, gerando coisa julgada material, como meio próprio e autônomo para excluir a ameaça da ocorrência do ilícito. Claro que nada impede que a parte cumule a pretensão inibitória com uma pretensão indenizatória, em razão de eventuais danos causados anteriormente.

De outro lado, a efetividade da tutela inibitória muitas vezes dependerá da possibilidade de sua antecipação, mesmo em caráter *inaudita altera pars*, isto é, independentemente da ouvida da parte contrária. Da efetividade da tutela decorre ainda a fungibilidade da medida, eis que o juiz não se vinculará ao pleito do autor, podendo dele se distanciar do pedido formulado pela parte para conceder o provimento mais adequado à resolução da pretensão. Aliás, nessa tocada, o § 1º do art. 536 do Código Instrumental é de alvejante ao utilizar a expressão *"entre outras"*, indicando, a toda evidência, a possibilidade de o magistrado conceder a medida que julgar mais adequada e pertinente ao caso em apreço.

Em cores nítidas, repetindo à exaustão: a tutela dos direitos da personalidade não se apresenta apenas repressiva (ressarcitória), ultrapassando a compreensão setorial (afirmada pela ideia de que a indenização era fruto do velho binômio *lesão-sanção*), para admitir uma imprescindível tutela preventiva, no sentido de inibir a prática do ilícito ou impedir que o dano se alastre, atuando no sentido de retirar a antijuridicidade. Exemplo bastante interessante e de largo interesse concreto é a possibilidade de ser deferido, como mecanismo de tutela preventiva (com fulcro no art. 536 do Código de Processo Civil), mandados de restrição de direitos, como, por exemplo, o mandado de distanciamento, impedindo que o ofensor se aproxime da vítima e, assim, atente contra a sua privacidade. Ao conceder a ordem de distanciamento, o magistrado poderá estabelecer uma distância genérica, em metros, não sendo necessário especificar os locais alcançados pela restrição.[86]

---

84. Explica Eduardo Talamini que a disposição processual "dá suporte a provimentos destinados a cessar ou impedir o início de condutas de afronta a qualquer direito da personalidade, ou, mais amplamente, a qualquer direito fundamental de primeira geração. Aí se inserem a integridade física e psicológica, a liberdade em suas inúmeras facetas, a igualdade, a honra, a imagem, a intimidade etc. – todos considerados em seus vários desdobramentos" (*Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer*, op. cit., p. 128).
85. ARENHART, Sérgio Cruz. *A Tutela Inibitória da Vida Privada*, op. cit., p. 11.
86. A respeito do tema: *"Poderá o Magistrado fixar, em metros, a distância a ser mantida pelo agressor da vítima* – tal como efetivamente fez o Juiz processante da causa –, *sendo, pois, desnecessário nominar quais os lugares a serem evitados*, uma vez que, se assim fosse, lhe resultaria burlar essa proibição e assediar a vítima em locais que não constam da lista de lugares previamente identificados" (STJ, Ac. unân., 5ª T., RHC 23.654/AP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 3.2.09, *DJe* 2.3.09).

No particular do mandado de distanciamento (restrição da liberdade locomotora), vislumbre-se a possibilidade de sua fixação não apenas para afastar pessoas de uma mesma família, como no conhecido caso da separação de corpos de cônjuges ou companheiros. É preciso realçar a possibilidade de sua fixação, também, em quaisquer outras hipóteses, em que a proteção da personalidade reclame impedir a aproximação. Seria o caso de um mero namoro, em que há indícios de violência.[87]

Nesse quadrante, o Enunciado 140 da Jornada de Direito Civil cimentou que "a primeira parte do art. 12 do Código Civil refere-se a técnicas de tutela específica, aplicáveis de ofício, enunciadas no art. 461 do Código de Processo Civil (no novo Código é o art. 536), devendo ser interpretada como resultado extensivo".

Desse modo, o ordenamento jurídico protege de forma mais ampla a personalidade, permitindo a utilização de medidas repressivas (reparação civil dos danos) e preventivas (tutela específica, através de multa diária, chamada de *astreintes*, ou de quaisquer outras providências que assegurem o resultado almejado). Conclui-se que, quanto maior a tutela da personalidade, menor se revelará o espaço para a responsabilidade civil.

Certamente, a tutela inibitória requer atuação concreta. A coerção requer a efetivação de meios de pressão capazes de influir na vontade do réu. A par da multa pecuniária (CPC, art. 536), apta a garantir a obediência da ordem judicial, poderá o magistrado, segundo critérios de conveniência, aplicar as medidas necessárias, tais como a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras, o impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial e de toda e qualquer outra medida que julgue adequada para garantir a obtenção do resultado útil almejado de proteção da personalidade (art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil).

O descumprimento da ordem judicial somente não poderá, como regra, implicar na prisão do réu renitente,[88] em razão da expressa vedação do art. 5º, LXVII, da Carta Constitucional, que veda a prisão civil por débito, salvo para o devedor de

87. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a Lei Maria da Penha, que estabelece proteção para a mulher, coibindo violência doméstica, é aplicável também em outras relações afetivas, como o namoro: "1. *Configura violência contra a mulher, ensejando a aplicação da Lei nº 11.340/06, a agressão cometida por ex-namorado que não se conformou com o fim de relação de namoro*, restando demonstrado nos autos o nexo causal entre a conduta agressiva do agente e a relação de intimidade que existia com a vítima. 2. *In casu*, a hipótese se amolda perfeitamente ao previsto no art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, já que caracterizada a relação íntima de afeto, em que o agressor conviveu com a ofendida por vinte e quatro anos, ainda que apenas como namorados, pois aludido dispositivo legal não exige a coabitação para a configuração da violência doméstica contra a mulher" (STJ, Ac. unân., 3ª Seção, CC 103.813/MG, rel. Min. Jorge Mussi, j. 24.6.09, *DJe* 3.8.09).

88. Veja-se a respeito: "Ordem judicial. Descumprimento. Prisão. Impossibilidade. Multa pecuniária. Magistrado. Poderes. Previsão legal. O descumprimento de ordem judicial caracteriza, em tese, crime de desobediência, devendo a prisão do representante legal da parte dar-se na esfera penal, com o envio das peças processuais necessárias ao Ministério Público, para as providências cabíveis. É facultado ao juiz a imposição, de ofício, de multa diária ao recalcitrante, se suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento da obrigação.I" (TA/MG, Ac. 8ª Câm. Civ., Agr. Instr. 2.0000.00.460397-4/000(1) – Comarca de Belo Horizonte, rel. Juiz José Amâncio, j. 4.2.05, *DJMG* 24.2.05).

alimentos. Somente em casos absolutamente excepcionais, quando o bem jurídico a ser protegido superar, valorativamente, a liberdade do devedor, é que se justificará a medida segregatória. A rigor, portanto, é descabido o uso da prisão civil como medida judicial de tutela específica (medida preventiva) de proteção dos direitos da personalidade, apenas se tolerando a sua determinação quando o bem a ser tutelado sobrepujar (em termos valorativos, de acordo com uma ponderação de interesses) a liberdade de locomoção do devedor. A dificuldade exemplificativa é evidente (e é bom que seja assim). Imaginamos, em linha de princípio, a possibilidade de determinação de prisão de um diretor de clínica ou hospital que se recuse à internação de um paciente em estado gravíssimo determinada judicialmente.

O objetivo principal da proteção da personalidade humana não é, simplesmente, atribuir dinheiro pela violação de um bem jurídico personalíssimo. Mais importante do que indenizar pecuniariamente é salvaguardar o próprio bem jurídico, impedindo que a lesão se alastre ou volte a ocorrer. Bem se manifestou a Corte Suprema de Justiça da Argentina sobre a matéria, esclarecendo a importância de transcender um caráter econômico na proteção da personalidade:

> "A consciência da própria dignidade não se silencia nem se satisfaz com indenizações pecuniárias, nem com publicações extemporâneas dispostas por sentenças inócuas, porque tardias. A crua noção anglo-saxônica de vindicar a honra *bygetting cash* já mostrou que é insatisfatória para muita gente decente".

De mais a mais, a proteção da personalidade depende de ordem judicial, podendo ocorrer de modo cumulativo, através de medidas que visem fazer cessar a violação ao direito da personalidade e, ao mesmo tempo, reparar o prejuízo já sofrido.[89] Interessante exemplo (de grande importância prática em tempos atuais) pode ser cogitado com o pedido formulado pelo correntista para que a sua Instituição Bancária retire o seu nome que foi indevidamente colocado no SPC ou SERASA (obrigação de fazer, garantida pela tutela específica), além de lhe indenizar os prejuízos já sofridos com a inclusão indevida de seu nome no cadastro de maus pagadores.[90]

Também importa alertar para a possibilidade de cumulação de pedidos de reparação por danos morais e materiais, como reza a Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça.

Importante enxergar que é amplíssimo o espectro de proteção da personalidade, servindo a norma estabelecida no art. 12 da Lei Civil como verdadeira cláusula geral de proteção, aplicável em qualquer caso de violação ou ameaça aos direitos da personalidade. Nesse sentido, assentou-se entendimento na Jornada de Direito Civil:

89. CARVALHO NETO, Inácio; FUGIE, Érika Harumi. *Novo Código Civil Comparado e Comentado*, op. cit., p. 39.

90. A respeito da matéria, vale apresentar a linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, garantindo que "o SPC deve indenizar pelo dano decorrente de indevida inscrição de inadimplência inexistente. Não se pode furtar da responsabilidade alegando não ser obrigado a comunicar. A comunicação do registro ao devedor é obrigação também do SPC, ainda que os seus estatutos imponham tal obrigação ao lojista" (STJ, Ac. 4ª T., REsp. 27.325-0/CE, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 7.12.00, *DJU* 19.2.01).

Enunciado 5, Jornada de Direito Civil:

> "As disposições do art. 12 têm caráter geral e aplicam-se inclusive às situações previstas no art. 20, excepcionados os casos expressos de legitimidade para requerer as medidas nele estabelecidas".

Prioriza-se a cidadania e a dignidade da pessoa humana, conferindo igualdade substancial e isonomia formal às relações jurídicas civis, além de garantia residual, dando maior amplitude aos direitos da personalidade, reconhecidos tanto às pessoas naturais, quanto às pessoas jurídicas (CC, art. 52), a partir de um verdadeiro *"atributo de elasticidade"*. Não se procura, aliás, proteger os direitos da personalidade das empresas com o fito de maximizar o desempenho econômico, mas sim como instrumento de tutela da realização das pessoas.

Louvável é o móvel do legislador, mas a norma em si é desnecessária, pois, se considerados os direitos da personalidade, como o faz a franca maioria da doutrina, como direitos subjetivos, independentemente de uma norma sancionatória, eles serão sempre objeto de tutela. Por isso, reconhecendo na estrutura dos direitos subjetivos uma ideia de *"direito ´ dever"*, há uma inescondível pretensão conferida ao titular. E, via de consequência, onde há a pretensão, há, por igual, a possibilidade de tutela jurídica do direito através da formulação de um pedido protetivo ao Poder Judiciário.

4.10 A proteção da personalidade da pessoa morta e os lesados indiretos

Perlustrando a linha de proteção ampla e avançada da personalidade, percebe-se que o parágrafo único do art. 12 do Código Civil confere tutela jurídica não apenas às pessoas que foram *lesadas diretamente* (referidas no *caput*), mas, por igual, às pessoas que foram *lesadas indiretamente*, indicadas no seu parágrafo único: o cônjuge sobrevivente (e, por evidente, o companheiro também), os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o quarto grau.[91]

É que quando uma ofensa é dirigida diretamente a uma pessoa já falecida, não produz qualquer efeito jurídico, na medida em que o morto não mais ostenta personalidade jurídica, por motivos óbvios. No entanto, ao atingir, diretamente, alguém que já faleceu o dano termina por reverberar sobre os seus familiares vivos, indiretamente. É dizer: o dano é diretamente dirigido ao falecido, mas atinge, obliquamente, pessoas que estavam atreladas afetivamente a ele. É o caso da inserção indevida do nome de um morto no sistema de proteção ao crédito (SPC e SERASA). Em relação ao falecido, não há qualquer repercussão jurídica, mas é possível afrontar a personalidade dos seus familiares vivos, por vias transversas.

---

91. Semelhante regra emana do art. 71 do Código Civil lusitano, dispondo que os direitos da personalidade gozam, igualmente, da proteção depois da morte do respectivo titular, cabendo as providências legais aos herdeiros legítimos ou ao cônjuge.

Trata-se, a toda evidência, de um dano por ricochete, reflexo. Isso porque atinge os familiares do falecido (cônjuge ou companheiro, hetero ou homoafetivo, ascendentes, descendentes ou colaterais até o quarto grau) de maneira resvalada, não direta.

Não se olvide, aliás, que em se tratando de uso indevida da imagem de pessoa morta, o Parágrafo Único do art. 20 do Código CIvil limita a legitimidade dos lesados indiretos, excluindo os colaterais do rol dos lesados indiretos. Assim, quando se tratar de uso irregular de imagem de pessoa falecida a lista dos lesados indiretos é mais restrita, apenas englobando o cônjuge supérstite (e o companheiro), os ascendentes e os descendentes, com exclusão dos colaterais.[92]

Defendemos, porém, uma compreensão exemplificativa, não taxativa, do rol apresentado pelos dispositivos legais. Isso porque, para nós, o fundamento da lista dos lesados indiretos é a afetividade, e não a Biologia. Com efeito, não se pode negar que o enteado ou o padrasto, um amigo querido, ou mesmo uma noiva ou namorada, podem sofrer, indiretamente, um dano decorrente da violação da personalidade do morto. O vínculo afetivo estabelecido pode ser igual ou ainda mais forte, razão pela qual entendemos ser exemplificativo o rol indicado no dispositivo legal. Em sendo assim, ao reconhecer o caráter exemplificativo desse rol, poderão estar abrangidos os colaterais, mesmo quando se tratar de dano causado à imagem de uma pessoa morta, se provada a relação afetiva entre o falecido e o seu parente colateral.

Nesse desenho, percebe-se que os *lesados indiretos* são as pessoas que têm legitimidade para requerer a medida de proteção (preventiva e/ou reparatória) quando o titular dos direitos da personalidade já estiver falecido.[93] Ou seja, pode a pessoa viva defender, em nome próprio, um direito próprio, seu, da personalidade, consubstanciado em resguardar a memória e a personalidade de alguém de sua família que já faleceu.[94] É a hipótese do filho que defende, judicialmente, a honra ou a imagem do pai falecido, indevidamente violados após o óbito. Nesse caso, insista-se, o titular defende um direito próprio, até porque o morto já não mais titulariza qualquer direito da personalidade.

Não se pode, todavia, cair na tentação de um raciocínio simplório e perfunctório afirmando a existência de direitos da personalidade do morto. A tutela jurídica concedida pelo parágrafo único do art. 12 da Lei Civil é dirigida às pessoas vivas, permitindo que sejam defendidos os direitos da personalidade do seu parente, cônjuge

92. O Enunciado 5 da Jornada de Direito Civil reconhece que se trata de disposição específica, afastando a regra geral dos lesados indiretos do parágrafo único do art. 12 do *Codex*: "As disposições do art. 12 têm caráter geral e aplicam-se inclusive às situações previstas no art. 20, excepcionados os casos expressos de legitimidade para requerer as medidas nele estabelecidas".

93. Identicamente, a Lei nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais, em seu art. 24, § 1º, reconhece legitimidade ativa aos herdeiros para defender os direitos personalíssimos do autor-morto no que disser respeito à paternidade, inédito, integridade e indicação do nome sobre criações intelectuais estéticas.

94. Anuindo ao que se sustenta no texto, Luiz Alberto David Araújo, inclusive mencionando ser também a posição prevalecente nas jurisprudências austríaca, suíça, italiana e francesa. Cf. *A proteção constitucional da própria imagem*, op. cit., p. 89.

ou companheiro já morto.[95] Nesse panorama, Elimar Szaniawski leciona que, em casos tais, o direito "respeita aos parentes do morto, tratando-se de um direito familiar", e não próprio.[96,97]

Trata-se, assim, de exercício de um direito próprio (de uma legitimidade autônoma para ajuizar uma ação) e não mera substituição processual.

Ou seja, é um direito reconhecido às pessoas vivas de ter salvaguardada a personalidade dos seus parentes (e do seu cônjuge ou companheiro) falecidos, sob pena de afronta à sua própria personalidade. Isso porque ao violar a honra, imagem, sepultura etc. de uma pessoa morta, atinge-se, obliquamente (*indiretamente*, na linguagem do Código Civil), os seus parentes (e o cônjuge ou companheiro) vivos.

Bem por isso, os lesados indiretos atuam *em nome próprio, defendendo um interesse próprio*,[98] consistente na defesa da personalidade de seus parentes (ou de seu cônjuge ou companheiro) falecidos. Agem, pois, por *legitimidade ordinária, autônoma*, e não em substituição processual.[99]

Com vistas a ilustrar a exposição, é possível lembrar as hipóteses de uso indevido de imagem e do nome de uma pessoa morta. Nesse caso, o dano atinge *diretamente o morto*, não podendo produzir efeitos, porque a sua personalidade já se extinguiu;[100]

---

95. Elucida qualquer dúvida o seguinte julgado: "Direito da personalidade. Violação. Com a morte da pessoa, seus parentes próximos podem se opor à divulgação da vida do extinto, não por transferência dos direitos da personalidade, mas por direito próprio" (TJ/RJ, Ac. Unân., 3ª Câm. Cív., Em Decl. Ap. Cív. 39.193, rel. Des. Wellington Moreira Pimentel, *RT* 619: 175).

96. SZANIAWSKI, Elimar. *Direitos de personalidade e sua tutela*, op. cit., p. 303.

97. Em sentido contrário, Alfredo Domingues Barbosa Migliore sustenta, em interessante trabalho, que a tutela jurídica referida seria dirigida ao próprio morto, caracterizando verdadeiros "direitos que vão além da vida corpórea", embora confesse, em seguida, que "racionalmente tem sido impossível explicá-lo". Cf. *Direito além da vida*: um ensaio sobre os direitos da personalidade *post mortem*, op. cit., p. 281.

98. O entendimento jurisprudencial, de há muito, já se solidificou nesse diapasão: "Um dos valores mais inalienáveis do patrimônio moral humano é a dignidade da vida e da morte. *O desprezo pelo ser humano após a sua morte gera dor profunda nos seus entes queridos que sofrem a perda da pessoa amada. O zelo para o corpo sepulto equipara-se ao constante velar pela alma da pessoa que se foi. Dor moral que se exacerba pela constatação da presença de outro cadáver na sepultura, mostrando-se improvável a localização do originário cadáver e a consectária impossibilidade de sua cremação*"(TJ/RJ, Ac. 10ª Câm. Cív., Ap. Cív. 14936/2001 (2001.001.14936), Rel. Des. Luiz Fux, j. 7.11.01).

99. Já teve oportunidade a jurisprudência de proclamar esse entendimento, como se pode notar: "Os direitos da personalidade, de que o direito à imagem é um deles, guardam como principal característica a sua intransmissibilidade. Nem por isso, contudo, deixa de merecer proteção a imagem de quem falece, como se fosse coisa de ninguém, porque ela permanece perenemente lembrada nas memórias, como bem imortal que se prolonga para muito além da vida, estando até acima desta, como sentenciou Ariosto. Daí por que não se pode subtrair da mãe o direito de defender a imagem de sua falecida filha". (STJ, Ac. Unân., 4a T., REsp. 26.866/RJ, Rel. Min. César Ásfor Rocha, j. 22.11.00, *DJU* 19.2.01, p. 179, RT 789: 201).

100. Exatamente porque a personalidade do falecido já se extinguiu, a viúva do célebre escritor *Humberto de Campos* não obteve êxito em demanda ajuizada contra o não menos festejado médium *Chico Xavier* e a *Federação Espírita Brasileira*, na qual pretendia condená-los por conta de obras psicografadas pelo espírito desencarnado do literata. A decisão, que remonta a 1944, afirmou que a existência da pessoa natural cessa com a morte e, assim, extingue-se a capacidade de adquirir direitos. Por isso, não poderia o falecido *Humberto de Campos* ter direitos autorais sobre um escrito posterior ao seu óbito, decorrente da intervenção de seu espírito. Para maior aprofundamento, veja-se: MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. *Direito além da vida*:um ensaio sobre os direitos da personalidade *post mortem*, op. cit., p. 62.

e, concomitantemente, atinge *indiretamente* o seu cônjuge ou companheiro e os seus familiares vivos. Estes terão legitimidade autônoma para defender, em nome próprio, um direito próprio, consistente em ver protegida a personalidade de seus familiares já falecidos.

É intuitivo, inclusive, que os lesados indiretos possuem legitimidade para requerer a reparação não somente na hipótese de morte real (natural) do seu cônjuge, companheiro ou parente, mas, também, na hipótese de morte presumida (declaração de ausência).

Ademais, convém pontuar a inaplicabilidade, na hipótese, da ordem de vocação hereditária do Direito das Sucessões, não havendo grau sucessivo para a legitimidade em exame. Assim, a legitimidade dos *lesados indiretos* é autônoma, possuindo cada um deles (cônjuge, companheiro ou parceiro homoafetivo sobrevivente, filhos, netos, pais, irmãos, tios...) legitimidade para reclamar o dano sofrido, em nome próprio e pleiteando uma indenização própria.[101]

Sobreleva ter cuidado para não confundir a legitimidade dos lesados indiretos com a situação mencionada no art. 943 do Código Civil, que trata da *transmissão do direito à reparação do dano causado a alguém que morreu, após sofrer a afronta.* A diferença é elementar: os lesados indiretos pleiteiam em nome próprio um dano causado aos seus parentes mortos, *depois do óbito deles*;a outro giro, se o ofendido morreu sem promover a ação reparatória, os seus parentes vivos podem fazê-lo, dentro do prazo prescricional. Note-se que, nesse segundo caso, os parentes receberam, por transmissão hereditária, o direito à reparação do dano, podendo pleitear o que caberia ao falecido, em nome dele. Na primeira hipótese, os parentes são as próprias vítimas, reclamando em seus próprios nomes.

4.11 Classificação dos direitos da personalidade

4.11.1 Noções gerais: não taxatividade dos direitos da personalidade

Os direitos da personalidade são tendentes a assegurar a integral proteção da pessoa humana, considerada em seus múltiplos aspectos (corpo, alma e intelecto). Logo, a classificação dos direitos da personalidade tem de corresponder à projeção da tutela jurídica em todas as searas em que atua o homem, considerados os seus múltiplos aspectos biopsicológicos.

Já se observou que os direitos da personalidade tendem à afirmação da plena integridade do seu titular. Enfim, da sua dignidade.

101. A tese vem sendo reconhecida jurisprudencialmente: "O art. 12, parágrafo único, do Código Civil, autoriza qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau, a pleitear indenização por danos morais, quando se tratar de reflexos de direitos da personalidade do morto, sendo que o dispositivo não condiciona o ajuizamento da ação à observância da ordem de vocação hereditária" (TJ/MG, Ac. 4ª Câm. Cív., Ap. Cív. 1.0699.07.071912-4/0021 – Comarca de Ubá, rel. Des. Moreira Diniz, j. 5.2.09, *DJMG* 27.2.09).

Em sendo assim, a classificação deve ter em conta os aspectos fundamentais d personalidade, que são: a *integridade física* (direito à vida, direito ao corpo, direi à saúde ou inteireza corporal, direito ao cadáver...), a *integridade intelectual* (direi à autoria científica ou literária, à liberdade religiosa e de expressão, dentre outr manifestações do intelecto) e a *integridade moral* ou *psíquica* (direito à privacidad ao nome, à imagem etc.).[102]

A toda evidência, essa classificação não exaure o rol dos direitos da personalidad

Não há dúvida quanto à impossibilidade de previsão taxativa (*numerus clausu* dos direitos da personalidade. Muito pelo contrário. Constituem uma *categoria elá tica*, compreendida ampla e concretamente, a partir do quadro evolutivo do homer integrado em suas mais variadas atividades (físicas, psíquicas, sociais, culturai intelectuais...).

É preciso, pois, compreendê-los a partir de uma cláusula geral que assegu proteção plena e eficaz à pessoa humana, permitindo que novos e eventuais v lores incorporados à personalidade não estejam carentes de tutela jurídica. Aliá na velocidade em que se operam as novas descobertas científicas e tecnológicas considerando o estágio evolutivo da ciência, é mister afirmar um *direito geral d personalidade*, de modo a salvaguardar a tutela da pessoa humana.

Nessa linha de ideias, a despeito da proteção específica dispensada ao nom (CC, arts. 16 a 19), à imagem (CC, art. 20), à privacidade (CC, art. 21), dentre outr direitos, há uma *cláusula geral de proteção da personalidade*, com o propósito d ampliar significativamente a tutela, impedindo o exaurimento das espécies de direit da personalidade,[103] que não podem ser esgotados, nem limitados. Na mesma direçã a vitoriosa experiência portuguesa, cujo Código Civil, em seu art. 70, estabelec uma tutela geral da personalidade, vindo, em seguida, a mencionar a proteção a nome (art. 72), à intimidade (art. 80), à imagem (art. 79), dentre outros. Tambén o Código Civil da Suíça contempla cláusula geral de proteção, insculpida no art. 2

Bem por isso, se consolidou no Enunciado 274 da Jornada de Direito Civil ess entendimento: "Os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiv pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana contida no art. 1º, III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana)

102. Também utiliza esse critério classificatório *tripartido*, Francisco Amaral. *Direito Civil*: introdução, op. ci p. 260. Vale registrar, de qualquer modo, que Orlando Gomes optou por uma classificação *bipartida*, di dindo os direitos da personalidade a partir de dois critérios: os direitos à *integridade física* e os direitos *integridade moral*. Cf. *Introdução ao Direito Civil*, op. cit., p. 153. Silenciou o mestre no que concerne a direitos da personalidade ligados à integridade intelectual, que, induvidosamente, são perceptíveis n pós-modernidade, como no referencial exemplo dos *direitos autorais*, deixando antever a necessidade d projeção dos direitos da personalidade também sob uma perspectiva *intelectual*.

103. Recente propaganda veiculada nas redes de televisão mencionava que "todo brasileiro tem direito a u *e-mail* grátis", insinuando tratar-se de um verdadeiro direito inalienável e essencial a toda e qualquer pess humana. O exemplo permite detectar que os direitos da personalidade são construídos concretamente, partir da realidade cultural viva e presente de cada momento histórico.

O festejado civilista italiano Alberto Trabucchi, com fina sensibilidade, reconhece um direito geral da personalidade, reportando-se ao art. 2º da Constituição italiana[104] como uma cláusula genérica cuja função é adequar as "várias garantias jurídicas às exigências sempre novas de tutela da pessoa".[105] Outra não foi a opção do constituinte brasileiro, estabelecendo cláusula geral protetiva logo no art. 1º, inciso III, da Lei Maior.

Importante esclarecer que a existência de uma cláusula geral de proteção da personalidade não é incompatível com a sua classificação tripartida. As fragmentações propendem a uma melhor compreensão sistemática da matéria, não exaurindo, entretanto, as espécies, permitindo a cláusula geral seu reconhecimento em qualquer situação concreta.

4.11.2 Cláusula geral de proteção da personalidade: o direito à vida (digna) como pressuposto dos direitos da personalidade

Esclarece lucidamente Roberto Senise Lisboa que "todos os direitos da personalidade decorrem da existência, ainda que pretérita, da vida",[106] permitindo antever a existência de um pressuposto lógico aos direitos da personalidade.

Assim sendo, é possível vislumbrar o direito à vida digna (dignidade da pessoa humana), a partir da intelecção do art. 1º, III, da Constituição da República, como o pressuposto lógico da personalidade humana e, consequentemente, dos próprios direitos da personalidade. Enfim, é verdadeira *cláusula geral de proteção da personalidade*, nos moldes da necessária proteção genérica da personalidade humana mencionada alhures e também encontrada no ordenamento português e no italiano.

Nessa linha de intelecção, Gustavo Tepedino percebe que as regras constitucionais "condicionam o intérprete e o legislador ordinário, modelando todo o tecido normativo infraconstitucional com a tábua axiológica eleita pelo constituinte", impondo uma nova leitura dos direitos da personalidade e marcando a presença de uma verdadeira *cláusula geral da personalidade* (a *dignidade da pessoa humana*).[107]

Ora, a despatrimonialização do direito privado e a necessária repersonalização do ser humanoconcorrem simultaneamente para o reconhecimento de um novo conteúdo, uma nova estrutura interna, do Direito Civil, que passa a estar vocacionado à tutela privilegiada e avançada da pessoa humana, projetada em suas múltiplas, variadas, complexas e multifacetadas atividades diárias.

---

104. Art. 2º, Constituição da Itália: "A República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, seja como sujeito singular ou considerado na formação social onde desenvolve sua personalidade e, por isso, requer a observância dos deveres inderrogáveis de solidariedade política, econômica e social".
105. TRABUCCHI, Alberto. *Istituzioni di diritto civile*, op. cit., p. 95.
106. LISBOA, Roberto Senise. *Manual Elementar de Direito Civil*, op. cit., p. 176.
107. TEPEDINO, Gustavo. *Temas de Direito Civil*, op. cit., p. 47.

A defesa da vida com dignidade é objetivo constitucionalmente assegurado Poder Público. Por isso, funciona como verdadeira cláusula geral, que serve c motor de impulsão de tudo o que vem expresso na ordem constitucional ou me infraconstitucional.

Importante, inclusive, observar uma certa vinculação entre a noção de direito personalidade à noção de direitos humanos, fazendo cair por terra a velha dicot que divorciava o direito público do direito privado, superando, definitivamen ultrapassada grande divisão do direito. Desse modo, a partir dos princípios cons cionais (que irradiam luzes para todos os ramos do direito, seja do direito púb seja do privado), fornecendo critérios de valor que vão inspirar toda a compree da norma infraconstitucional, é que se há de compreender a tutela da personali humana. Rompe-se a compreensão sectária da tutela da personalidade sob a publicista ou privatista, como se fosse possível emprestar uma proteção parc pessoa humana sem martirizar o comando constitucional.

Por isso mesmo, Elimar Szaniawski, invocando a lição primorosa de José Lama Corrêa de Oliveira e Francisco José Ferreira Muniz, defende o reconhecimento de cláusula geral de proteção da personalidade com o propósito de "fornecer a ba uma jurisprudência coerente, mas suficientemente sensível para a solução das variadas hipóteses de lesão aos direitos da personalidade".[108] Trocando em mi considerando a multiplicidade de situações a que se expõe a pessoa humana na modernidade, somente com o reconhecimento de uma cláusula geral de proteçã art. 1°, III), de conteúdo principiológico, a ser preenchido no caso concreto jurisprudência, auxiliada pela doutrina, é que se pode garantir, eficazmente, a t da pessoa humana, impedindo violações das mais variadas naturezas ao ser hum

Seja consentido salientar, finalmente, que, como a dignidade da pessoa hu é valor a ser preenchido concretamente, é possível chegar à ilação da existênc um direito à morte digna,[109] o que não significa, de nenhum modo, um dis favorável à eutanásia ou à ortotanásia.

4.11.3 Proteção da dignidade da pessoa humana e o combate ao bullying

Percebendo os deletérios efeitos que a prática de bullying pode ocasionar so dignidade de uma pessoa humana, editou-se a Lei n°13.185/15, instituindo um grama de combate à intimidação sistemática (*Bullying)* em todo o território naci

Caracteriza-se o *bullying* quando há violência física ou psicológica em at intimidação, humilhação ou discriminação (art. 2°) contra uma pessoa hum

108. SZANIAWSKI, Elimar. *Direitos de personalidade e sua tutela*, op. cit., p. 75.

109. Sobre o direito à morte digna, seja consentido remeter, em razão do maior aprofundamento e c sustentação desenvolvida, à obra de Anderson Röhe. *O paciente terminal e o direito de morrer*, especialmente p. 30 ss.

através de insultos, xingamentos, pilhérias, ataques, isolamento etc, causando uma diminuição do apreço ou da honra (objetiva ou subjetiva) de alguém. Lamentavelmente, é prática tolerada em inúmeros estabelecimentos no Brasil, sob o argumento (inadmissível) de que cada pessoa deve aprender a se defender.

Considerando que a preservação da dignidade humana é um pacto constitucional, direcionado não apenas ao Poder Público, mas, por igual, aos particulares, a citada norma legal estabeleceu ser "dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática (*bullying*)" (art. 5 º).

Em se tratando de intimação dirigida a criança ou adolescente a gravidade se amplia, até mesmo porque o art. 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente impõe ser "*dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor*".

Com isso, abre-se espaço para demandas (preventivas e/ou reparatórias) em desfavor de quem pratica a intimidação sistemática (por conduta comissiva) e, por igual, contra o estabelecimento que tolerou a prática, como escolas e faculdades (por conduta omissiva).[110]

4.11.4 Direito à integridade física

a) Noções gerais sobre a proteção da integridade física, o dano estético

O direito à *integridade física* concerne à proteção jurídica do corpo humano, isto é, à sua incolumidade corporal, incluída a tutela do corpo vivo e do corpo morto, além dos tecidos, órgãos e partes suscetíveis de separação e individualização.

Assim, o direito ao corpo diz respeito à proteção destinada à vida humana e à integridade física, englobando o corpo vivo, bem assim como o cadáver (direito ao corpo morto). Por isso, a violação da integridade física é suficiente para a caracterização do *dano estético*, independentemente da existência, ou não, de sequelas permanentes. Exatamente por isso, o Superior Tribunal de Justiça teve oportunidade de reconhecer o direito à indenização por conta de acidente em supermercado, em razão do desmoronamento de caixas mal empilhadas, sofrendo a vítima traumatismo na região da bacia, mesmo não gerando sequelas permanentes ou deformidades. É o reconhecimento da proteção à integridade física, independendo de sequelas graves (STJ, Ac. 4ª T., REsp. 575.576/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 13.4.04).

110. Já há interessante decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre o assunto: "Ação ordinária ajuizada por menor absolutamente incapaz, integrante do corpo discente do ora Apelado. Alegação de *bullying*, consubstanciado em sucessivas agressões ao Demandante por parte de outros alunos. Inércia da instituição de ensino. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Manifesto defeito na prestação do serviço, ante a falta de providências garantidoras da segurança do aluno nas dependências do colégio." (TJ/RJ, Ac. 11ª Câm. Civ., ApCív. 0031581-78.2011.8.19.0087, rel. Cláudio de Mello Tavares, j. 20.5.15).

Note-se que, violada a integridade física da pessoa humana, caracteriza-se o chamado *dano estético* – que, em linhas gerais, corresponde às lesões, permanentes ou transitórias, na integridade física de uma pessoa viva.[111]

Não se olvide, ademais, que a afronta à integridade física pode estar cumulada com a violação da honra ou de outro direito da personalidade, o que gera, na hipótese, uma possibilidade de cumulação da reparação de danos, como já reconhecido pela Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.[112]

Aliás, o Código Penal, tutelando a integridade física humana, pune, em seus arts. 121 a 128, as condutas contra a vida, tipificando criminalmente, como passíveis de censura, o homicídio, o auxílio, o induzimento e a instigação ao suicídio, o infanticídio e o aborto, além do delito de lesões corporais (art. 129).

A vida humana reclama, pois, especialíssima proteção, impondo a repulsa contra todo e qualquer risco contra a degradação ou destruição de sua integridade, especialmente em épocas de importantes descobertas científicas pela engenharia genética e de crescimento social e econômico constante (e, às vezes, desenfreado), não raro colocando em risco a integridade física do ser humano.

Historicamente, o tratamento jurídico dedicado ao corpo humano sofreu influências religiosas, chegando a se compreender o corpo humano como uma dádiva divina, impossibilitando qualquer intervenção pelo próprio titular. Por evidente, na contemporaneidade, a autonomia privada (liberdade do titular) alterou essa compreensão, admitindo-se um verdadeiro *direito ao corpo humano*.

O Código Civil dedicou proteção ao aspecto físico da personalidade nos arts. 13 a 15, aludindo à tutela jurídica do corpo vivo (art. 13) e do corpo morto (art. 14) e ao livre consentimento informado do paciente (art. 15).

Dispõe, expressamente, o art. 13 do *Codex* que "salvo por exigência médica, defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes". Cuida-se de visível proteção do corpo vivo, reconhecendo a possibilidade (ampla) do titular dele dispor, desde que não cause diminuição permanente da integridade física e não gere ofensa aos bons costumes.

Com isso, a prática de *body art* ou *body modification*, por si sós, não estão proibidas por não afetarem a dignidade do titular, uma vez que não lhe diminuem a integridade física.

---

111. Colhe-se interessante precedente jurisprudencial: "O dano estético cobre a ofensa ao natural, na imagem pessoal, o defeito, a sequela ou o aleijão que acomete a vítima. Logo, o dano estético é o dano moral que acomete aquele que sofre as consequências visíveis da lesão" (TRT-3a Região/MG, Ac. 6a T., I 368/2005.095.03.00-1, rel. Desa. Emília Facchini, *DJMG* 2.2.06, p. 8).

112. Súmula 387, Superior Tribunal de Justiça: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e da moral".

Acresça-se que a proteção dedicada à integridade física se inicia desde a concepção, permanecendo até a morte. Pode o titular, de toda sorte, dispor do seu corpo para depois da morte, gratuitamente, para fins altruísticos ou científicos, como facultado pelo art. 14 do *Codex*. É o chamado *direito ao cadáver*, que é, a toda evidência, um desdobramento do direito ao corpo humano.[113]

Advirta-se, porém, oportunamente, que não se confunde a disposição do cadáver, para depois da morte, com a retirada de órgãos humanos de pessoa morta para fins de transplantes. Com efeito, o art. 14 do Estatuto Civil regulamenta a disposição do cadáver pelo titular, por exemplo, com o propósito de deixá-lo para estudos em uma faculdade de Medicina. Diferentemente, as regras sobre retirada de órgãos de pessoa morta para fins de transplantes estão na Lei nº 9.434/97, notadamente em seu art. 4º, que exige o consentimento dos familiares para a extração de órgãos humanos de pessoas falecidas. O dispositivo legal aludido, inclusive, termina se colocando em rota de colisão frontal com o art. 14 do Texto Codificado que, por seu turno, estabelece ser "válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte". Exigir a anuência da família para a retirada de órgãos de um morto para transplantação em outrem, em momento tão doloroso, parece afrontar, diretamente, a autonomia privada quando o próprio titular, em vida, havia manifestado a sua vontade. Conquanto, sob o ponto de vista prático, venha prevalecendo o entendimento de que a solução deste (aparente) conflito normativo ocorreria pelo critério da *especialidade*, prevalecendo a norma legal específica dos transplantes, outro raciocínio merece ser levantado. Com efeito, considerando a autonomia privada e percebendo que o direito ao corpo morto pertence ao titular, ainda vivo, a solução que merece prestígio é a aplicação do regime da subsidiariedade. Assim sendo, *somente seria necessário o consentimento dos familiares para a extração de órgãos de pessoa morta para fins de transplantes* (art. 4º da Lei de Transplantes) *se o próprio titular, ainda vivo, não dispôs, expressamente, sobre o destino do seu cadáver* (art. 14 do Código Civil).[114]

Ainda a respeito do reconhecimento do *direito ao corpo morto como manifestação da própria personalidade*, convém sublinhar a necessidade de autorização judicial para exames, avaliações ou vistorias no cadáver, sob pena de responsabilização civil (é o exemplo da necessidade de produção de determinada prova pericial no cadáver, dentro de um processo, essencial ao esclarecimento de certos fatos).

A consequência disso, portanto, é a afirmação de que os humanos possuem direitos da personalidade sobre o próprio corpo (aspecto físico da personalidade). Por isso, não se poderia, em linha de princípio, vedar a realização de tratamentos

113. Também assim, Carlos Roberto Gonçalves. *Direito Civil Brasileiro*, op. cit., p. 162.

114. Nessa levada, inclusive, é de clareza meridiana a redação do Enunciado 277 da Jornada de Direito Civil: "O art. 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição gratuita do próprio corpo, com objetivo científico ou altruístico, para depois da morte, determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos em vida prevalece sobre a vontade dos familiares, portanto, a aplicação do art. 4º da Lei n. 9.434/97 ficou restrita à hipótese de silêncio do potencial doador".

terapêuticos e científicos. De qualquer maneira, é imperativo advertir que o profis da Medicina tem de atuar em conjunto com o paciente, orientando amplament coagir e sem menosprezar a sua vontade. É o chamado *consentimento inform* que, por sinal, traz a reboque a necessidade de o médico advertir, expressame seu paciente para todo e qualquer efeito conhecido previamente do procedim ser adotado, permitindo-lhe exercer, com amplitude, a sua autonomia. Até po paciente é *sujeito*, e não *objeto*, do tratamento médico. Alguns hospitais e cl inclusive, mais cuidadosos e evitando discussões futuras, chegam a gravar a tência. Não ocorrendo a advertência expressa, caberá reparação do dano causac violação do dever de informação, corolário da boa-fé objetiva.[115] Sobre o dire livre consentimento informado, em obra pioneira, Hildeliza Lacerda Tinoco Bo Cabral explica, didaticamente, que *"o ser humano possui direito à informação*, u que somente mediante tais esclarecimentos, poderá se tornar livre e conscient a melhor escolha. Em face desse direito de informação de que goza a pessoa, para o médico *o dever de informar*. Esse dever tem sido cada vez mais respe tutelado e reclamado, o que se coaduna com a constitucionalização do Direito em franca sintonia com a atual perspectiva dos direitos da personalidade".[116]

Reconhecida a avançada proteção da *integridade física* como consequência de sua dignidade, impõe-se afirmar a absoluta excepcionalidade da *internaç çada*, contrária à vontade do paciente, por afrontar os seus valores mais esse Somente havendo motivo comprovado medicamente e com demonstração de recursos extra-hospitalares são insuficientes é que se pode admitir, em carát talmente excepcional, a internação forçada de uma pessoa humana.[117] E, ind longe, é preciso explicitar o interesse público justificável, como em casos de d transmissíveis ou de perigo evidente à convivência social.[118] A matéria está t entre nós, pela Lei nº 10.216/01, que estabelece condições para a internação f por determinação médica, a requerimento dos familiares e interessados (cham internação involuntária, que tem de ser comunicada ao Ministério Público no de setenta duas horas, conforme determina o § 1º do art. 8º do citado D

115. O entendimento pretoriano é este: "A despreocupação do facultativo em obter do paciente seu conse informado pode significar – nos casos mais graves – negligência no exercício profissional. As exigê princípio do consentimento informado devem ser atendidas com maior zelo na medida em que o risco ou o dano" (STJ, Ac. 4ª T., REsp. 436.827/SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar Jr., *RSTJ* 168: 40

116. CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat. *Consentimento informado no exercício da Medicina e t direitos existenciais*: uma visão interdisciplinar, op. cit., p. 101.

117. A nossa melhor jurisprudência caminha nessa trilha: "É incabível a internação forçada de pessoa capaz sem que haja justificativa proporcional e razoável para a constrição da paciente. Ainda q conheça o legítimo dever de cuidado e proteção dos pais em relação aos filhos, a internação com de filha maior e capaz, em clínica para tratamento psiquiátrico, sem que haja efetivamente dia nesse sentido, configura constrangimento ilegal" (STJ, Ac. 3a T., *HC* 35.301/RJ, rel. Min. Nancy Andr 13.9.04, p. 231).

118. "É admitida, com fundamento na Lei 10.216/01, em processo de interdição, da competência do Ju a determinação judicial da internação psiquiátrica compulsória do enfermo mental perigoso à co social, assim reconhecido por laudo técnico pericial, que conclui pela necessidade da internação." unân. 3ª T., HC 135.271/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.12.2013, DJe 4.2.2014).

Legal) ou do juiz (denominada internação compulsória, devendo o magistrado levar em conta "as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários" – art. 9º da legislação de regência). Vislumbra-se, assim, uma clara excepcionalidade na internação forçada, preservada a regra geral da liberdade.

No que diz respeito às pessoas atingidas pela hanseníase, a Lei nº 11.520/07, dedicando tratamento especial, reconhece a necessidade de internação compulsória e segregatória em hospital de dermatologia sanitária e, exatamente por isso, confere a elas o direito ao recebimento de uma pensão especial.

b) A proibição de prática pelo titular de ato de disposição que importe em diminuição permanente da integridade física

A regra geral do sistema jurídico é a possibilidade de prática de ato de disposição dos direitos da personalidade quando não gerar diminuição permanente da integridade física. Ou seja, o titular cuida livremente de sua integridade corporal, apenas não podendo exceder os limites toleráveis. Enfim, *a autonomia privada da pessoa está presente no âmbito dos direitos da personalidade, devendo-se reconhecer a esses direitos, de forma geral, uma certa liberdade jurídica de exercício, não apenas na forma negativa, como tradicionalmente se pensava, mas também ativa ou positiva.* É o que se pode chamar *"admissão da disponibilidade limitada dos direitos da personalidade"*, na feliz expressão de Leonardo Estevam de Assis Zanini.[119]

Pois bem, com essas diretrizes e seguindo as pegadas do art. 13 do Código Reale, nota-se que a tutela jurídica da integridade física do corpo vivo, malgrado admita como regra atos de disposição pelo titular, impede a prática de condutas que gerem diminuição permanente da integridade física, salvo quando houver uma exigência médica.

> Art. 13, Código Civil:
> "Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes".

A fórmula utilizada pelo citado dispositivo legal indica que, não havendo redução permanente da integridade física, é possível a prática de diferentes atos de disposição corporal – como decorrência da autonomia privada.

Exemplificativamente, nota-se a possibilidade de utilização de tatuagens, *piercings* e do chamado *bodyart*,conforme a manifestação cultural e estética de cada pessoa. Por motivos ligados ao padrão interno de beleza, por homenagem a determinadas pessoas, por maneira de expressão de posicionamentos pessoais..., enfim por qualquer razão é possível ao ser humano se tatuar ou colocar *piercings*. Aliás, não se olvide que diversas tribos indígenas, de há muito, conferiam alto valor às tatuagens.

119. ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. *Direitos da personalidade*, op. cit., p. 268.

É preciso apresentar uma justificada crítica ao trecho do dispositivo legal refer (CC, art. 13) que se veda o ato de disposição do corpo se violar os "bons costum De um lado, a expressão *"bons costumes"* é um conceito vago, impreciso, não ser crível que sirva de elemento moderador da disposição do próprio corpo.[120] Trata-se verdadeiro conceito jurídico indeterminado, por não se saber o conteúdo, embora se conheça o efeito: proibição de prática de ato de disposição corporal que afro os "bons costumes".

A outro giro, não parece razoável que o titular somente possa diminuir perm nentemente a sua integridade física quando houver autorização médica. Vale, ac a lembrança de que a pessoa que se dedica aos esportes marciais, como o U enfrentando golpes certeiros em seu corpo, pode sofrer (e, ordinariamente, sofr diminuição permanente da integridade física, sem qualquer exigência médica. Nou exemplo, a pessoa que se submete a uma cirurgia plástica estética, retirando u costela, para fins exclusivamente de embelezamento, também diminuiu a sua in gridade física sem necessidade terapêutica. Outrossim, já se encontram mulheres q amputam o dedo mínimo do pé para que possam usar salto alto, sem desconforto Para além de tudo isso, o inverso também reclama uma cuidadosa reflexão. A prá ca ilimitada de atos de disposição corporal *não reducionistas, permanentemente, integridade física* não pode estar simplesmente autorizada pelo sistema, como cheque em branco entregue ao titular, como decorre da leitura do texto legal. C efeito, há de se indagar da legitimidade do ato em relação à dignidade do titular, n se levando em conta, apenas, a duração temporal da intervenção no corpo huma Bastaria imaginar o caso da implantação de microchips subcutâneos para controle

120. Também criticando o dispositivo legal, Anderson Schreiber lembra o caso da estudante de artes plást Priscilla Davanzo que tatuou o corpo com manchas pretas, imitando o couro de uma vaca holandesa projeto corporal atendeu, segundo Priscilla, à necessidade de protestar contra a incapacidade digestiva ser humano: 'não digerimos bem as ideias que recebemos de filmes, livros, jornais', as vacas, ao contrá 'digerem o bolo alimentar duas vezes'. A atitude de Priscilla pode ser considerada excêntrica. Mentes m tradicionais não hesitariam em classificá-la como contrária aos bons costumes. 'É que no direito e vida, a noção de bons costumes afigura-se tão ampla e vaga que pode abarcar qualquer atitude que desvie um pouco mais do padrão habitual de comportamento [...] Pode-se pensar o que quiser da atit de Priscilla Davanzo. Não há dúvida, contudo, de que o conjunto de tatuagens a que se submeteu constitui intervenção física grave o bastante para atrair a proibição jurídica do ato" (SCHREIBER, Ander *Direitos da personalidade*, op. cit., p. 35).

121. Consta de informação jornalística: "Uma intervenção cirúrgica polêmica tem se tornado comum nos Esta Unidos por prometer acabar com o desconforto de usar alguns tipos de sapatos femininos. Trata-se *amputação de dedinhos inferiores, solução encontrada por algumas norte-americanas para diminuir a exten da ponta dos pés* e, com isso, eliminar calos e deformações decorrentes do uso contínuo de sapatos c salto alto de bico fino. Esse tipo de cirurgia plástica é um dos três procedimentos mais procurados p acabar com o desconforto dos calçados. Os outros dois são diminuir o tamanho de algum dedo ou inj colágeno na parte da sola do pé perto deles, na tentativa de deixar a sola mais acolchoada. Segund Associação Americana de Podologia Médica, cerca de 87% das estadunidenses sofrem algum problema pé decorrente de calçados desconfortáveis. É o caso de *Susan Deming*, amante de sapatos de salto alto sempre teve muitos calos no pé esquerdo, pelo fato de alguns dedos serem maiores que os outros. P acabar com isso, ela diminuiu um centímetro do dedão do pé, e espera que, a partir de agora, camin deixe de ser um martírio" (Disponível em: <http://www.metro1.com.br/portal/?varSession=noticia&var torialId=8&varId=24063>. Acesso em: 26.12.12).

empregados. Certamente, para quem precisa do emprego não viola a sua dignidade, mas não é preciso grandes reflexões para que se perceba uma certa ilegitimidade da conduta por permitir um controle absoluto da pessoa do empregado pelo empregador. Conquanto a intervenção física não seja permanente, não nos parece legítima, devendo ser obstada.[122] Em sendo assim, *demonstra-se a impropriedade do dispositivo legal em referência, ao impor a exigência médica como um fator necessário para o ato de disposição permanente da integridade física, permitindo-se ao titular qualquer outra limitação corporal, caso não importe em diminuição permanente da integridade física.*

A outro giro, também não é possível radicalizar a compreensão de que a diminuição da integridade física somente é autorizada por força de *exigência médica*. Efetivamente, a prática de cirurgias plásticas com finalidade embelezadora, puramente estética, vem demonstrando, largamente, que a intervenção no corpo humano não decorre, *somente*, de exigência médica. O cotidiano revela ser extremamente comum cirurgia plástica para levantamento ou aumento de mamas, através de silicone. Até porque, muita vez, a cirurgia embelezadora decorre de inúmeros fatores pessoais (vaidade, senso estético, autoestima etc.), *menos de uma necessidade médica...*

Ademais, bem lembra Anderson Schreiber que "no fim da década de 90, o cirurgião Robert Smith amputou as pernas de dois pacientes fisicamente saudáveis, em um hospital na Escócia, suscitando o furor da imprensa britânica. Pois Smith alegou atender à 'exigência médica' de encerrar o sofrimento daqueles pacientes que, segundo o cirurgião, se encontravam em um tal estado de desespero que seriam capazes de promover automutilação 'em uma linha de trem'[...], com sérios risco de vida para si e para terceiros. Vê-se que o critério da exigência médica, visto por juristas com certo temor reverencial, pode assumir, muitas vezes, contornos tão flexíveis quanto os que caracterizam uma eventual alusão à exigência médica, com interpretações e nuances tão múltiplas quanto as que decorrem das próprias normas que procuram regular a dramática questão da disposição do próprio corpo".[123]

De todo modo, a nós parece que a regra geral há de ser a autonomia privada e, consequentemente, o titular deve poder praticar atos de disposição corporal, salvo quando comprometer a própria dignidade. Não há, portanto, um interesse público a justificar a restrição à prática de atos de disposição da integridade física.

---

122. Outro curioso exemplo é pinçado da interessante obra de Anderson Schreiber: "Laila começou desinfetando a parte superior do meu braço, antes de aplicar um analgésico local para entorpecer a área onde o chip seria implantado. Com uma seringa na mão, ela testou o local, o que me fez hesitar. Aplicou outra dose de analgésico. Com meu braço amortecido, Laila inseriu o microchip entre a minha pele e a camada de gordura do meu braço. Ela pressionou a seringa e ali estava: meu próprio número de dez dígitos instalado seguramente no meu corpo'. O relato produzido acima não provém de mente criativa de algum escritor de ficção científica, mas da experiência real vivida pelo jornalista *Simon Morton* na boate *Baja Beach Club*, em Barcelona. O estabelecimento oferece aos seus clientes a possibilidade de terem inserido sob a pele um microchip emissor de ondas de radiofrequência, que, além de assegurar livre acesso à área VIP da boate, funciona como uma espécie de cartão de consumação" (SCHREIBER, Anderson. *Direitos da personalidade*, op. cit., p. 31).

123. SCHREIBER, Anderson. "Os direitos da personalidade e o Código Civil de 2002", op. cit., p. 246.

c) A questão dos transplantes e a proteção da integridade física

As partes do corpo humano, vivo ou morto, integram a personalidade hu caracterizando coisa *extra commercium*, vedando-se, por conseguinte, todo e quer ato de disposição a título oneroso, como bem deliberou o Texto Constitu (CF/88, art. 199, § 4º, e Lei nº 9.434/97, art. 1º). Entretanto, são admitido de disposição de partes do corpo humano, vivo ou morto, a título gratuito, s causar prejuízo ao titular e tendo em vista um fim terapêutico, altruístico ou tífico (CC, arts. 13 e 14).

Fixando didaticamente, "é possível juridicamente a disposição gratuita de destacáveis do corpo humano, renováveis (leite, sangue, medula óssea, pele, esperma, fígado) ou não, para salvar a vida ou preservar a saúde do interessado terceiro ou para fins científicos ou terapêuticos", consoante a lição de Maria H Diniz,[124] e desde que o ato seja praticado a título gratuito, dentro das limit impostas por lei.

Urge diferençar o transplante de órgãos humanos entre pessoas vivas e o plante de órgãos *post mortem*, de modo a perceber as peculiaridades de cada das possibilidades.

O art. 9º da Lei nº 9.434/97 permite à pessoa maior e capaz dispor, em de tecidos, órgãos e partes do corpo vivo, dês que *gratuitamente*,[125] para finali terapêuticas ou para transplantes. O referido ato de disposição do corpo some permitido, obviamente, se não importar risco para a vida ou saúde do titular. Por somente as partes renováveis ou órgãos duplos podem ser objeto de doação em

Naturalmente, o transplante entre pessoas vivas depende de expresso co timento do titular e, tratando-se de ato de vontade, é plenamente revogável outro lado, em se tratando de incapaz, será mister autorização judicial, ouv Ministério Público, de modo a preservar os interesses do incapaz.

Em vida, a dação de órgãos pode ser feita livremente pelo titular, por de exclusivamente sua. É o que ocorre no exemplo muito comum do transplante de É um verdadeiro gesto de solidariedade humana, necessariamente revestido de ca gratuito e, preferencialmente, escrito. Por evidente, o órgão ou tecido não dev necessário para a vida ou a saúde do doador.

Quando se tratar de transplantes entre pessoas vivas, permite-se ao dona (*rectius*, dador) escolher o beneficiário do transplante (o destinatário do órgão) que se trate de pessoa da própria família. Com isso, evita-se um eventual ca pecuniário do ato, obstando um comércio de órgãos humanos. Aliás, é exata te por isso que se exige do médico, antes de realizar o transplante entre viv comunicação da realização do procedimento ao Promotor de Justiça da com

124. DINIZ, Maria Helena. *O estado atual do Biodireito*, op. cit., p. 250.

125. A comercialização de órgãos humanos está vedada pela Constituição Federal, notadamente no art. 19

do domicílio do doador. Ciente do procedimento, o Ministério Público, então, irá instaurar um procedimento administrativo investigatório para confirmar o respeito aos requisitos legais (Decreto nº 2.668/97, arts. 20 e 25, II). Havendo alguma irregularidade, deve o Promotor de Justiça adotar providências judiciais para impedir o transplante e obstar a formação de um comércio de órgãos humanos. Não se tratando de pessoas da mesma família, exige o art. 9º da Lei nº 9.434/97 uma autorização judicial, após a apuração da inexistência de interesse econômico, exceto quando se tratar de transplante de medula óssea (que, por conta da sua dinâmica, é permitido entre pessoas que não pertencem a um mesmo núcleo familiar).

Bem diverso é o tratamento emprestado pelo legislador ao transplante de órgãos *post mortem*.

No transplante após a morte veda-se que se escolha o beneficiário, delineando um caráter altruístico[126] ao ato, impondo-se obediência à fila de espera criada por lei (Lei nº 9.434/97, art. 2º e parágrafo único, e Decreto nº 2.268/97, art. 24), com o escopo de garantir a universalização da saúde e a igualdade de chances (CF/88, arts. 3º, 5º e 196), mantidas pelas Centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos – CNCDOs, nos diferentes estados da federação. Assim, comprovada a morte encefálica, mediante declaração médica da cessação da atividade cerebral,[127] e havendo consentimento da família da pessoa falecida, através de documento escrito (art. 4º da lei que disciplina a matéria), poderá ser providenciada a retirada de órgãos ou tecidos da pessoa morta, comunicando-se, de imediato, às CNCDOs (Decreto nº 2.268/97, art. 18), para que se possa atender àqueles inscritos na lista, de acordo com a ordem de prioridade e urgência de cada caso.

Sistematizando a *rotina dos transplantes* após a morte do doador: (*i*) ocorrendo morte encefálica de um paciente, comunica-se o óbito às CNCDOs; (*ii*) a equipe de captação dirige-se até o nosocômio para realizar exames; (*iii*) a equipe informa à central as características do paciente-doador; (*iv*) a partir do perfil do doador, a central realiza levantamento nos candidatos inscritos na lista de espera para a escolha do receptor que necessitar com maior urgência; (*v*) são realizados exames periciais no receptor para averiguar a compatibilidade e, *in continenti*, realiza-se o transplante.[128]

Importantes discussões estão sendo travadas no que respeita ao momento da morte. Conquanto o Conselho Federal de Medicina, através da Resolução nº 1.480/97, tenha deliberado que a morte se materializa (e, por conseguinte, autoriza-se a cessão de órgãos) com a morte encefálica (seguindo entendimento do Comitê da Universidade de Harvard, datado de 1968), há, hodiernamente, forte resistência na comunidade

126. Adverte Fábio Ulhoa Coelho que o beneficiário da doação de órgãos *post mortem*, por não se admitir escolha, pode ser, até mesmo, um desafeto da pessoa morta.Cf. *Curso de Direito Civil*, op. cit., p. 202.

127. Exige-se que os prontuários médicos contendo os resultados ou laudos dos exames relacionados aos diagnósticos que concluíram pela morte encefálica, bem como detalhando os procedimentos e atos cirúrgicos relativos ao transplante, sejam mantidos em arquivos da instituição pelo prazo mínimo de cinco anos.

128. Assim, SauweneHryniewicz. *Direito "in vitro"*: da Bioética ao Biodireito, op. cit., p. 142.

médica e em geral. Exemplificando a necessidade de compreensão da matéria po outros prismas, Regina Fiúza Sauwene Severo Hryniewicz lembram o caso da esquia dora norueguesa que, em março de 1999, após permanecer durante uma hora e mei soterrada no gelo, foi declarada clinicamente morta, afirmada sua morte encefálica vindo, posteriormente, por insistência do chefe da equipe médica, a ser reanimada conseguindo, inclusive, voltar a esquiar.[129]

Um outro relevante problema atinente aos transplantes por morte diz respeito validade e eficácia da manifestação de vontade do titular, ainda vivo, acerca da su condição de doador de órgãos. Pois bem, trazendo uma nova dicção para o art. 4º d Lei nº 9.434/97 e modificando a regra inicialmente estabelecida, a Lei nº 10.211/0 não mais admitiu a chamada doação presumida[130] de órgãos e tecidos *post morten* passando a exigir, para a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo humano d pessoas falecidas, a autorização do cônjuge (ou, por evidente, do companheiro) o do parente próximo. Ou seja, segundo o texto legal, a realização de transplante *pos mortem* depende da *autorização dos familiares do falecido*.

Diferentemente, porém, o art. 14 do Código Civil estabelece ser "válida, co objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo o em parte, para depois da morte". Evidencia, portanto, que a disposição do corpo pa depois da morte depende, basicamente, da *manifestação de vontade do próprio titular* e não de seus familiares. Por isso, Fábio Ulhoa Coelho asseverou que "qualquer pesso em vida, pode manifestar a expressa vontade de *não ser doadora*, hipótese em que retirada de órgãos, tecidos ou partes não se realizará nem mesmo com a autorizaçã do familiar. A lei reconhece plena eficácia a esse ato, *apesar do egoísmo ímpar*".[131]

Como se nota, as normas estão em aparente rota de colisão.

Pois bem, procurando harmonizar os citados dispositivos legais (o art. 4º da L de Transplantes e o art. 14 do Código Civil), conclui-se que, havendo manifestaçã de vontade do titular, ainda vivo, no sentido de ser, ou não, doador de órgãos, l de ser respeitada. Apenas na hipótese de o titular não ter declarado a sua vontad é que os familiares deliberam após o seu óbito. Essa solução foi abraçada, inclusiv pelo Enunciado 277 da Jornada de Direito Civil:

> Enunciado 277, Jornada de Direito Civil:
>
> "O art. 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição gratuita do próprio corpo, com objetivo científico ou altruístico, para depois da morte, determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos em vida prevalece sobre a vontade dos familiares, portanto, a aplicação do art. 4º da Lei n. 9.434/97 ficou restrita à hipótese de silêncio do potencial doador".

129. SAUWEN, Regina Fiúza; HRYNIEWICZ, Severo. *Direito "in vitro"*: da Bioética ao Biodireito, op. cit., p. 141

130. Continuam adotando o sistema da doação presumida de órgãos os ordenamentos jurídicos da Aust França, Polônia, Dinamarca e Suíça. O novo sistema brasileiro (consentimento presumido fraco ou cons timento *sui generis*) é o mesmo adotado na Espanha, Itália, Noruega e Suécia.

131. COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Civil*, op. cit., p. 199.

Demais de tudo isso, pontue-se a lógica possibilidade de revogação, a qualquer tempo, da vontade de dispor do corpo para depois da morte, como alude o parágrafo único do próprio art. 14 da Lei Civil.

Frise-se que não há que se confundir transplante com enxerto ou implante. Transplante é a amputação ou ablação de órgão, com função própria, de um organismo para ser instalado em outro, no qual atenderá às mesmas funções. É o exemplo do transplante de córnea ou coração de uma pessoa que morreu em outra. Já o enxerto é a retirada de uma porção orgânica para ser instalada no mesmo organismo ou em outro, com o propósito de atender a funções estéticas ou terapêuticas, sem exercer funções autônomas. A outro giro, o implante se caracteriza pela integração de tecidos mortos ou conservados no corpo de alguém. A norma legal acerca da matéria, contudo, não diferencia um de outro, submetendo todas as modalidades ao mesmo regramento.

Por derradeiro, anote-se que, em se tratando de falecimento de uma pessoa não identificada (indigente) por qualquer dos documentos elencados nos §§ 1º a 6º do art. 14 do Decreto nº 2.268/97, está vedada a retirada dos seus órgãos para fins de transplantes, conforme estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei nº 9.434/97, embora seja possível a sua utilização para fins de estudos e pesquisas científicas, em faculdades de Medicina, por exemplo.

d) A proteção da integridade física e a cirurgia de transgenitalização (mudança de sexo). O direito do transexual à mudança de seu registro civil de nascimento

Questão interessante diz respeito à possibilidade de realização, em transexuais, da cirurgia de redesignação de estado sexual, apelidada de cirurgia de "mudança de sexo".[132]

De saída, convém ressaltar que o transexual não pode ser confundido com o homossexual, o bissexual, o intersexual (também conhecido como hermafrodita) ou mesmo com o travesti.[133] O transexual é aquele que sofre uma dicotomia físico-psíquica, possuindo um sexo físico, distinto de sua conformação sexual psicológica. Nesse quadro, a cirurgia de mudança de sexo pode se apresentar como um modo necessário para a conformação do seu estado físico e psíquico.

A leitura fria da regra esculpida no art. 13 do Código Civil pode fazer crer que existe uma proibição de que se realize o citado ato cirúrgico de transgenitalização,

132. Em excelente opúsculo dedicado ao tema, o civilista paranaense Elimar Szaniawski esclarece que a técnica cirúrgica realizada no transexual pode ser resumida do seguinte modo: "O paciente masculino sofre a amputação de seu falo e testículos, sendo construído, no seu lugar, uma neovagina, mediante a utilização de pele escrotal. São-lhe criadas mamas de silicone, e os demais atributos femininos secundários são adquiridos mediante aplicação da terapia hormonal" (*Limites e possibilidades do direito de redesignação do estado sexual*, op. cit., p. 83).

133. Arnaldo Jabor, em crônica dedicada aos travestis, afirma achar "os travestis figuras shakespearianas, de grande dramaticidade, centauros urbanos, corajosos, encarnando duas vidas num corpo só", deixando antever uma evidente distinção com o transexual que, por seu turno, não utiliza duplamente o seu corpo. Cf. *Amor é prosa, sexo é poesia*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. p. 170.

muito embora essa suposta proibição violente a garantia da dignidade da humana, constitucionalmente assegurada.[134] Bem por isso, a leitura atenta positivo legal, à luz das garantias fundamentais constitucionais, conduz à co de que, sendo caso de *necessidade médica*, o sistema legal está permitindo a de mudança de sexo, nos casos de transexualismo.[135]

Ora, todo ser humano tem a sua dignidade afirmada constitucionalmente possuidor de um *direito à integridade física e psíquica.*[136] "Colocando na bal bens e interesses do transexual, em relação às vantagens ou desvantagens pela intervenção cirúrgica, na modificação de seu sexo morfológico, parece-m a mesma pende favoravelmente para as terapias de mudança de sexo, incl cirúrgica, pois será *somente através desta que o paciente transexual encontrará líbrio emocional, livrar-se-á das angústias e aflições e poderá desenvolver, livre sua personalidade*", como destaca Elimar Szaniawski.[137]

Interessante digressão é feita por Maria Berenice Dias, salientando que cesso transexual começa com o vestir-se como o outro sexo, passa por trat hormonal e terapêutico e termina com inúmeras cirurgias. *Não é um processo geiro. É a busca consistente de integração física, emocional, social, espiritual e conquistada com muito esforço e sacrifícios por pessoas que vivem infelizes e vezes depressivas quanto ao próprio sexo".*[138]

Exatamente por isso, o Conselho Federal de Medicina – CFM editou a Res nº 1.955/10, revogando a Resolução nº 1.652/02, permitindo, independentem autorização judicial, a realização de cirurgias de mudança de sexo (transgenitali em casos de transexualismo comprovado, fixando rígidos critérios: o pacient ser maior de 21 anos, não deve possuir características físicas inapropriadas cirurgia e deve ter diagnóstico médico de transgenitalismo, indicando o cab da cirurgia, após avaliação realizada por uma equipe multidisciplinar cons por psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social dur período mínimo de dois anos.

---

134. Entendendo que o art. 13 do Estatuto Civil proíbe a ablação de órgãos do corpo humano em tra Carlos Roberto Gonçalves. *Direito Civil Brasileiro*, op. cit., p. 164. Contrariamente, destacando, a ver acertadamente, não existir qualquer dúvida "quanto à legalidade da operação de mudança confira-se a lição de Fábio Ulhoa Coelho. *Curso de Direito Civil*, op. cit., p. 204.

135. Nessa tocada, afirma o Enunciado 276 da Jornada de Direito Civil: *"O art. 13 do Código Civil, ao p disposição do próprio corpo por exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização, em confo com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e a consequente alteração do e do sexo no Registro Civil".*

136. O Enunciado 6 da Jornada de Direito Civil emprestou interpretação razoável ao mencionado dis legal: *"A expressão* exigência médica *contida no art. 13 refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao b psíquico do disponente".*

137. SZANIAWSKI, Elimar. *Limites e possibilidades do direito de redesignação do estado sexual*, op. cit., p. 94 mesmo raciocínio, Ana Paula Ariston Barion Peres. *Transexualismo*:o Direito a uma nova identidade op. cit., p. 261 ss.

138. DIAS, Maria Berenice. *União homossexual*: o preconceito e a justiça, op. cit., p. 123.

Se a cirurgia for de adequação de fenótipo feminino para o masculino, só poderá ser praticada em hospitais universitários ou hospitais públicos adequados para a pesquisa. Entretanto, se pretende adequar o fenótipo masculino para o feminino, poderá ser realizada em hospitais públicos ou privados, independente da atividade de pesquisa, conforme as diretrizes da Resolução CFM nº 1.955/10. Em ambas as hipóteses, o procedimento cirúrgico *independerá de autorização judicial.*

De fato, havendo desvio psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição de fenótipo, há de se reconhecer, como o fez o órgão de classe médico, os benefícios da modificação do estado sexual, que exerce função terapêutica e respeita a dignidade humana.

Em outras palavras, o transexual tem direito (constitucionalmente garantido) à integridade física e psíquica e, por conta disso, poderá submeter-se à cirurgia de readequação sexual, independentemente de autorização judicial. Pensar de forma diversa seria negar-lhe o direito à própria felicidade, condenando a conviver com uma desconformidade físico-psíquica, que, sem dúvida, afeta o seu direito a uma vida digna.

Por isso, realizada a cirurgia de mudança de sexo, resta à Ciência Jurídica readequar o estado sexual registral e o nome do (ex)transexual, modificando o registro público respectivo. O pedido deve ser formulado através de um procedimento especial de jurisdição voluntária perante o juízo de Família[139] (por se tratar de questão de estado e não de mera retificação de registro). Em tal hipótese, a competência para processar e julgar o pedido é absoluta e pode ser declarada de ofício.

Superados os iniciais focos de resistência, felizmente ultrapassados, a orientação jurisprudencial que prevalece contemporaneamente é, sem dúvida, no sentido de permitir a redesignação do estado sexual e do nome, no caso de cirurgia de mudança de sexo (transgenitalização), sem qualquer referência ao *status* anterior da pessoa.[140] Já há algum tempo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seu entendimento

139. Também assim, Leoni Lopes de Oliveira esclarece não se tratar de "mera retificação de registro civil", dizendo respeito a verdadeira alteração do estado individual, afastando-se, por conseguinte, a competência da vara de registros públicos e fixando a competência (absoluta) da vara de família. Cf. *Novo Código Civil Anotado*, op. cit., p. 65.

140. Vejam-se, nessa tocada, importantes decisões das Cortes de Justiça fluminense e baiana sobre a matéria, confirmando a tese aqui esposada: "Passando, a pessoa portadora de transexualismo, por cirurgia de mudança de sexo, que importa a transmutação de suas características sexuais, é de ficar acolhida a pretensão de retificação do registro civil, para adequá-lo à realidade existente. A constituição morfológica do indivíduo e toda a sua aparência sendo de mulher, alterado que foi, cirurgicamente, o seu sexo, razoável que se retifique o dado de seu assento para 'feminino' no registro civil. O sexo da pessoa, já com o seu prenome mandado alterar para a forma feminina, no caso concreto considerado, que é irreversível, deve ficar adequado, no apontamento respectivo, evitando-se, para o interessado, constrangimentos individuais e perplexidade no meio social" (TJ/RJ, Ac. 16ª Câm. Cív., Ap. Cív. 16591/2002, Rel. Des. Ronald Valladares, *DORJ* 12.6.03, *Revista Jurídica* 309: 139). "Alteração do nome e do sexo. Transexualismo. Procedimento cirúrgico de transgenitalização realizado. É possível a alteração do registro de nascimento relativamente ao sexo e ao nome em virtude da realização da cirurgia de redesignação sexual" (TJ/BA, Ac. Unân., 3ª Câm. Cív., Ap. Cív. 31.844-5/06 – Comarca de Vitória da Conquista, Rel. Des. Sinésio Cabral Filho).

no sentido de admitir a mudança do nome e do estado sexual do transexual operad
O leading case, o caso que serviu de balizamento, foi uma homologação de senten
estrangeira, na qual um transexual havia obtido a modificação do nome e do est
do sexual junto à justiça italiana. Trata-se do Processo SE 1058 – Itália, Rel. Mi
Barros Monteiro, j. 16.8.06. Na oportunidade, destacou o Ministro relator – ap
citar precedentes dos Pretórios do Amapá, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Gran
do Sul e São Paulo – que o fundamento da mudança do sexo e do nome reside
tutela constitucional da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra
da imagem da pessoa humana.

Verticalizando o entendimento da Corte Superior, desdobrou-se, em seguic
que, operada a alteração no registro civil do transexual, não deve constar qualq
referência ao motivo da modificação, preservando a sua intimidade.[141]

Ressalte-se que o fundamento autorizador da permissão de mudança do esta
sexual no registro civil é de ordem constitucional, buscando assegurar a preservaç
da dignidade humana e da igualdade substancial, diretrizes da Carta Maior brasilei

Não é por outro motivo que o Comitê Olímpico Internacional – COI permi
que transexuais operados possam competir em modalidades esportivas olímpic
após a regularização jurídica de seu estado sexual e a realização de dois anos
terapia hormonal.[142]

Exige-se do jurista contemporâneo, para casos como esse, soluções que respeit
a dignidade humana, superando uma visão embaçada pelo preconceito, evitando
os direitos humanos possam ser negados.[143] Não se pode admitir que, sob o ma

141 "Sob a perspectiva dos princípios da Bioética – de beneficência, autonomia e justiça –, a dignidad
pessoa humana deve ser resguardada, em um âmbito de tolerância, para que a mitigação do sofrim
humano possa ser o sustentáculo de decisões judiciais, no sentido de salvaguardar o bem supremo e
principal do Direito: o ser humano em sua integridade física, psicológica, socioambiental e ético-espiritu
afirmação da identidade sexual, compreendida pela identidade humana, encerra a realização da dignic
no que tange à possibilidade de expressar todos os atributos e características do gênero imanente a
pessoa. Para o transexual, ter uma vida digna importa em ver reconhecida a sua identidade sexual, s
ótica psicossocial, a refletir a verdade real por ele vivenciada e que se reflete na sociedade...Conserv
'sexo masculino' no assento de nascimento do recorrente, em favor da realidade biológica e em detrim
das realidades psicológica e social, bem como morfológica, pois a aparência do transexual redesignado
tudo se assemelha ao sexo feminino, equivaleria a manter o recorrente em estado de anomalia, deix
de reconhecer seu direito de viver dignamente. (...) Assegurar ao transexual o exercício pleno de sua
dadeira identidade sexual consolida, sobretudo, o princípio constitucional da dignidade da pessoa hum
cuja tutela consiste em promover o desenvolvimento do ser humano sob todos os aspectos, garant
que ele não seja desrespeitado tampouco violentado em sua integridade psicofísica. Poderá, dessa fo
o redesignado exercer, em amplitude, seus direitos civis, sem restrições de cunho discriminatório o
intolerância, alçando sua autonomia privada em patamar de igualdade para com os demais integra
da vida civil. A liberdade se refletirá na seara doméstica, profissional e social do recorrente, que terá,
longos anos de sofrimentos, constrangimentos, frustrações e dissabores, enfim, uma vida plena e d
(STJ, Ac. unân., 3a T., REsp. 1.008.398/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.10.09, *DJU* 18.11.09).

142. A notícia foi veiculada pelo *Jornal do Brasil*, 18.5.04, p. C5.

143. Gustavo Tepedino relata o caso do transexual Juracy que, depois de mais de dez anos de vida con
na Dinamarca com um francês com quem convivia maritalmente, inclusive com filho adotado, veio v
seus familiares no interior da Bahia, decidindo, aqui no Brasil, adotar "à brasileira" um outro filho

protetivo da Carta de 5 de outubro de 1988, ainda possa existir discriminação a alguém somente pelo fato sexual. Isso importaria em subverter os próprios direitos humanos e negar as garantias fundamentais. Bem por isso, já se disse, em palavras candentes: "É preciso, inicialmente, dizer que homem e mulher pertencem à raça humana. Ninguém é superior. Sexo é uma contingência. Discriminar um homem é tão abominável como odiar um negro, um judeu, um palestino, um alemão ou um homossexual. As opções de cada pessoa, principalmente no campo sexual, hão de ser respeitadas [...] O direito à identidade pessoal é um dos direitos fundamentais da pessoa humana [...] é o direito que tem todo o sujeito de ser ele mesmo".[144]

Para além de tudo isso, vale o registro de que já se vem discutindo sobre a possibilidade de mudança do estado sexual e do nome pelo transexual não operado. A indagação é instigante: o transexual que, por vontade própria ou impossibilidade, não se submeteu à cirurgia de transgenitalização, também pode reclamar o direito de modificação de seu nome e estado sexual? O tema já se põe na agenda do dia da ciência jurídica.[145] De nossa parte, pensamos que o assunto deve ser refletido à luz da dignidade humana e da prova efetiva da situação fática do transexual. Sendo assim, nos posicionamento favoravelmente à alteração do estado sexual e do nome, mesmo que sem a intervenção cirúrgica, afinal de contas, não se pode reduzir o estado sexual de uma pessoa a um aspecto meramente genital. O estado sexual é composto por elementos mais complexos, transcendendo a simples referência à genitália de uma pessoa.

Merece registro, por derradeiro, um tormentoso problema que ocorrerá se o transexual, que obtiver a modificação em seu registro civil, eventualmente, tinha filhos ou tiver sido casado anteriormente. Nesse caso, nos registros civis de nascimento (de seus filhos) ou de casamento (com o seu ex-cônjuge) deve passar a constar a nova qualificação do transexual, em relação ao seu estado sexual e nome. Caso o filho, ou o ex-cônjuge, venha a se sentir afrontado em sua dignidade, por conta da mudança registral, terá de demandar uma solução pontual e casuística. A hipótese reclamará solução no caso concreto, a partir do uso da técnica de ponderação de interesses.[146]

---

menor abandonado em situação de miséria), que foi registrado como se filho do casal fosse. Juracy veio a ser presa no aeroporto do Rio de Janeiro e, absurdamente, conduzida ao pavilhão masculino do Presídio de Água Santa, onde permaneceu até que a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região veio a absolvê-la. A sua família, no entanto, já estava desestruturada e a sua intimidade devassada e exposta à mais degradante humilhação. Cf. *Temas de Direito Civil*, op. cit., p. 61-62.

144. Trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Ac. 3ª Câm. Cív., Ap. Cív. 593.110.547, Rel. Des. Luiz Gonzaga Pilla Hofmeister, j. 10.3.94.

145. Há um precedente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negando o pleito de mudança de nome e de estado sexual formulado por um transexual não operado: "o Apelante pleiteia alteração do nome e de sexo no registro civil, afirmando que desde tenra idade, apesar da conformação genital masculina, psicologicamente se sente mulher, fazendo-se tornar conhecido pelo prenome de Milena. Todavia, o recorrente ainda não se submeteu à cirurgia de mudança de sexo, o que não permite alteração do nome e do sexo em seu registro civil." (TJ/BA, Ac. 4a Câm. Cív., Ap. Cív. 03683226420128050001, rel. Des. José Olegário Monção Caldas, j. 15.10.13).

146. Considerando a dificuldade natural da hipótese, a legislação alemã e a sueca vedam a redesignação sexual quando a pessoa é casada ou tem filhos, como relata Maria Helena Diniz. Cf. *O estado atual do Biodireito*,

e) O princípio da autonomia do paciente e os seguidores da religião Testemu de Jeová

Ninguém pode ser compelido a submeter-se a tratamento médico de risco, dispõe o art. 15 do Código Civil, consagrando o princípio da autonomia do pac (consentimento informado), impondo aos profissionais de saúde que não atuem anterior autorização do próprio interessado.

Surge, então, um importante questionamento relativo à recusa a um trata to médico por motivações diversas. Seria possível ao paciente recusar determi tratamento médico por alguma convicção pessoal? Exemplificativamente, po alguém recusar uma cirurgia contra determinado mal por conta de um perig impotência sexual futura?

A questão vem assumindo enorme importância prática e despertando ap nados debates teóricos, não sendo raras as dramáticas situações vivenciadas pessoas que se recusam em submeter-se a procedimentos médicos por conta de convicções religiosas.

É o significativo e eloquente exemplo dos seguidores da Igreja Testemu de Jeová que, por força de crença religiosa (cuja liberdade é assegurada cons cionalmente como garantia fundamental), justificando a sua postura nas passa bíblicas do Gênesis (9, 3 a 5), Levítico (17, 10) e Atos (15, 20), não admit recebimento de transfusões de sangue.

Pois bem, a questão é extremamente intrincada, evolvendo direitos perso simos de fundamento constitucional: o direito à vida digna, o direito à integr física e a liberdade de crença.

Sem dúvidas, o debate envolve aspectos transcendentais, não podend restrito, em raciocínio simplório, à afirmação do direito à vida física, por env também, o direito (constitucionalmente assegurado) à liberdade de crença (c não ter crença) e de autodeterminação religiosa.

Sopesados, cuidadosamente, os valores presentes na questão, é de se recon a possibilidade de tal recusa à realização de procedimentos médicos que envolv prática de atos hematológicos. É que se explicita, no particular, um verdadeiro co de valores, impondo-se pesar na balança (técnica de ponderação dos interesses) descobrir qual o valor que sobrepuja, merecendo proteção acentuada.

É certo e incontroverso que o reconhecimento e o respeito às convicções giosas (ou à não convicção religiosa), sejam da maioria ou da minoria da popul é aspecto fundamental da personalidade,[147] protegida em sede constitucional amplitude do conceito de dignidade humana. Não é demais lembrar que do prin

op. cit., p. 247. Ainda assim, a dificuldade continua presente, pois seria possível objetar em tal hi o tratamento diferenciado, questionando se não haveria violação à igualdade substancial constitu

147. Promovendo uma detalhada e precisa análise da situação narrada, Gustavo Tepedino e Anderson Sch em artigo sobre as nuances dos direitos de minoria, sustentam a licitude da recusa, invocando fundar

da dignidade humana – vetor e ápice de todo o sistema jurídico brasileiro – defluem, além do inderrogável respeito à integridade física, as ideias de proteção à integridade psíquica e intelectual e às condições mínimas de liberdade e igualdade, denotando, com clareza meridiana, a necessária tutela à liberdade de credo, cuja violação significa, no final das contas, infringência ao próprio conceito de vida digna. Isto é, no conceito de dignidade humana encontra-se, sem dúvida, a liberdade de religião componente do conceito de vida digna – que, a toda evidência, não pode se restringir a aspectos meramente físicos.

Nessa hipótese específica, a solução que atende mais amplamente à dignidade humana, sem dúvida, deve ser, em linha de princípio, o respeito à liberdade religiosa, à convicção íntima, não sendo razoável uma interpretação literal da norma legal.[148]

Não é despiciendo registrar que a pessoa humana seguidora da orientação dos Testemunhas de Jeová pretende, tão somente, viver em paz consigo mesmo, com as demais pessoas e com o mundo, tendo respeitada a opção religiosa abraçada.[149]

Nesse passo, há o comovente relato de um caso em que o médico, no Paraná, promoveu a transfusão de sangue em determinada parturiente, contra a vontade dela e de seu marido, que recusavam o tratamento hematológico por motivos religiosos, vindo a paciente, após a alta médica, a sofrer o repúdio de sua comunidade, não sendo, sequer, aceita em seu lar pelo cônjuge, nem permitido que pudesse frequentar a sua Igreja.[150]

A questão, todavia, depende fundamentalmente do caso específico, não sendo possível estabelecer soluções apriorísticas. À luz da técnica de ponderação de interesses, é possível, então, apresentar importantes elementos conclusivos: se o paciente é maior e capaz e está em situação de absoluta normalidade (programando, por exemplo, um procedimento cirúrgico que deve ser realizado dentro de certo prazo, oportunidade em que ele não quer receber sangue), parece-nos que deve prevalecer a sua liberdade de crença. De nada adiantaria transfundir sangue e tornar a sua vida indigna, retirando dele a beleza de viver em paz consigo, com o mundo e com as suas convicções.

A mesma ponderação, contudo, pode se inclinar por soluções diversas. Em se tratando de pessoa incapaz (menor de idade, por exemplo) ou de pessoa em situação de emergência, já não se justifica a solução aqui preconizada. Ora, faltando maturidade suficiente para escolher uma opção religiosa, com todas as suas consequências, a

constitucionais, especialmente o direito à convicção religiosa como aspecto fundamental da personalidade humana. Cf. "Minorias no direito civil brasileiro", op. cit., p. 144.

148. Disso não discorda o magistrado pernambucano Sílvio Romero Beltrão, para quem "mesmo por razões religiosas, deve-se respeitar a autonomia do paciente. Não cabe ao leigo, mesmo que ele seja profissional da área de saúde, desconsiderar ou minimizar os valores de ordem religiosa do paciente, diante dos mais elevados interesses profissionais" (*Direitos da personalidade*, op. cit., p. 115).

149. Em trabalho dedicado ao tema, o saudoso constitucionalista Celso Ribeiro Bastos percebe a simples busca da realização pessoal na convicção religiosa dos que seguem a crença das Testemunhas de Jeová, concluindo ser de índole constitucional a sua recusa à transfusão de sangue. Cf. "Direito de recusa de pacientes submetidos a tratamento terapêutico às transfusões de sangue, por razões científicas e convicções religiosas", op. cit., p. 496.

150. A referência é de Miguel Kfouri Neto. *Responsabilidade civil do médico*, op. cit., p. 183.

solução já não pode ser a mesma. De outra banda, como adverte Gabriela Lopes Almeida, "em casos de emergência (nos quais não há possibilidade de manifestaç válida e livre de vontade) deverá ocorrer a intervenção médica", pois, nesse cas sobrepuja a manutenção da vida do paciente.[151] Aliás, a Resolução nº 1.021/80 Conselho Federal de Medicina e os arts. 46 e 56 do Código de Ética Médica autoriza os médicos a praticar a transfusão de sangue em seus pacientes, independentemer de consentimento, se houver iminente perigo de vida.

O debate, portanto, envolve a Bioética e a solução que deve vingar depen do caso concreto, não podendo prevalecer a ideia de que o direito à liberdade re giosa cede à indisponibilidade do direito ao corpo, apesar da induvidosa inclinaç jurisprudencial nesse sentido.[152]

Vale registrar, inclusive, que Tribunais norte-americanos e canadenses reconh cem o direito à convicção religiosa como suficiente para deliberar acerca do trat mento médico, entendendo que o direito constitucional à liberdade inclui o direi à crença religiosa.

E em nosso país, embora a jurisprudência majoritária – repita-se – se posicio em favor do procedimento transfusional forçado, já há decisões isoladas cuja mo vação se harmoniza, perfeitamente, com o que, aqui, é sustentado. Ilustrativament já se disse, em belo provimento judicial, que "detendo o paciente a capacidade ci e estando consciente das implicações e da gravidade da situação, entendo que recusa em se submeter à transfusão sanguínea em face de suas crenças religios *é um direito que lhe assiste, ainda que haja risco de morte. Isto porque a liberda de crença abrange não apenas a liberdade de cultos, alcançando também a possibi dade do indivíduo adepto a determinada religião orientar-se segundo as posições p ela estabelecidas. Vale ressaltar, entretanto, que quando a situação envolve menor de idade ou outros pacientes tidos como incapazes, a exemplo de uma pessoa e estado de inconsciência ou de uma pessoa detentora de alguma perturbação menta a questão ganha evidentemente outra conotação*" (decisão proferida pela Juíza F deral Luciana LaurentiGheller, em 18.2.09, nos autos da Ação Cautelar Inominad 2009.35.00.003277-7, Seção Judiciária do Estado de Goiás).

Com toda certeza, entender que a liberdade de religião (ou de não ter religiã deve ser sacrificada em respeito à intangibilidade do direito à vida e ao corpo humano *desconsiderar outro aspecto fundamental e igualmente indisponível da personalidade, q*

151. ALMEIDA, Gabriela Lopes de. "Direito de recusa a tratamento transfusional em face de convicção religic como garantia constitucional", op. cit., p. 169.

152. A posição ainda prevalecente em nossos Pretórios é no sentido de autorizar o procedimento transfusio em qualquer hipótese, mesmo existindo objeção por convicção religiosa do paciente-interessado. Veja- a respeito, a posição predominante: "Não há necessidade de intervenção judicial, pois o profissional saúde tem o dever de, havendo iminente perigo de vida, empreender todas as diligências necessárias tratamento da paciente, independentemente do consentimento dela ou de seus familiares" (TJ/RS, Ac. Câm. Cív., Ap. Cív. 70020868162 – Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Umberto GuaspariSudbrack, j. 22.8.(*DJ*/RS 29.8.07).

é a *liberdade de crença*, nas precisas palavras de Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber.[153] Daí a conclusão de Gabriela Lopes de Almeida: "Os seguidores da orientação das Testemunhas de Jeová, dês que maiores de idade e capazes (isto é, conscientes de seu ato), têm o direito de recusar tratamento que envolva transfusão de sangue, acaso não exista risco de vida, não podendo o médico intervir e impor tratamento transfusional. Ao revés, estar-se-ia negando, frontalmente, o direito constitucional à liberdade de crença e fé, impondo-lhes adequar-se à orientação da maioria da população".[154]

Não considerar esses relevantes aspectos seria desprezar uma compreensão mais elástica da personalidade, na qual se inclui, inexoravelmente, a intelectualidade humana, para represá-la apenas na dimensão física da pessoa.

Independentemente de qualquer outro aspecto, é certo que o paciente, seguidor da religião dos Testemunhas de Jeová, ao procurar assistência médica ou hospitalar busca, seguramente, minimizar a dor e o sofrimento que lhe aflige, obtendo cura para a sua patologia, mas sem qualquer afronta à sua dignidade e, seguramente, sem ter a obrigatoriedade de receber transfusão de sangue.

Bem por isso, mesmo para quem não acate integralmente a posição aqui esposada, é fundamental reconhecer que os Testemunhas de Jeová possuem o inescondível direito a um tratamento alternativo, sem o sistema transfusional, inclusive com componentes sanguíneos, impondo ao Poder Público ou aos planos/seguros de saúde a obrigatoriedade de fornecer possibilidade alternativa de cuidado e de cura. Nesse passo, lembra Sílvio Romero Beltrão que a posição dos seguidores dessa religião "*não proíbe de modo absoluto o uso de componentes sanguíneos com albumina e os preparativos para hemofílicos, além de circulação extracorpórea e a hemodiálise, cabendo a cada uma delas (testemunha) decidir individualmente se deve aceitar este tipo de tratamento*".[155]

f) A integridade física e a possibilidade de gestação em útero alheio ("barriga de aluguel")

Gestação em útero alheio ou gestação por outrem[156] (*surrogate mother* para os ingleses) é a técnica utilizada pela Ciência Médica para permitir que uma paciente, biologicamente impossibilitada de gestar ou de levar a gravidez até o final, possa ter um embrião – resultante de fecundação com o seu óvulo – gestado em útero de terceira pessoa. Enfim, é o procedimento que viabiliza a maternidade a determinadas pessoas, as quais a procriação natural não se mostra viável.

153. TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. "Minorias no direito civil brasileiro", op. cit., p. 144.

154. ALMEIDA, Gabriela Lopes de. "Direito de recusa a tratamento transfusional em face de convicção religiosa como garantia constitucional", op. cit., p. 175.

155. BELTRÃO, Sílvio Romero. *Direitos da personalidade*, op. cit., p. 115.

156. Estas são as expressões terminológicas mais utilizadas, embora também sejam encontradas outras designações como *maternidade por sub-rogação, mãe por procuração, maternidade por substituição, cessão de útero* e *mãe por comissão*, além da famosa expressão *barriga de aluguel* ou *mãe de aluguel*, menos próprias em face do caráter econômico que indicam.

Apesar das contundentes objeções da Igreja Católica,[157] o Conselho Federal Medicina – CFM, de há muito, vem admitindo a utilização da aludida técnica repro tiva. Revogando as Resoluções precedentes e aprimorando a normatividade do te foi editada a Resolução n. 2.121/15, autorizando o profissional médico a reali a gestação de substituição "desde que exista um problema médico que impeça contraindique a gestação na doadora genética ou em caso de união homoafetiva

A partir da parametrização estabelecida na citada Resolução é possível extrair requisitos exigidos para a gestação em útero alheio: *i)* a maternidade por substitui deverá efetuar-se entre parentes até o quarto grau (mãe e filha, avó e neta, irmãs, mas), devendo os demais casos ser submetidos à prévia anuência do Conselho Regio de Medicina; *ii)* a cessão de útero terá, imperativamente, caráter gratuito,[158] vedad remuneração pelo ato (afastando-se, assim, os nebulosos exemplos de aluguel do co humano); e *iii)* que tenha finalidade médica a sua aplicação, ou seja, somente é p mitida a utilização da técnica por pessoas que, realmente, não podem gestar, afasta os casos em que a mulher não quer ficar grávida por questões estéticas, por exemplo

Chama a atenção a evidente repulsa do ato normativo a um eventual cará oneroso da cessão de útero, somente permitindo a utilização desta técnica como recurso para pessoas que não podem levar a termo uma gestação. De todo mo abstraídos os debates sobre a violação, ou não, à Bioética na cobrança pelo út substituto, não se olvide que a mãe hospedeira faz jus aos alimentos gravídicos, co reza a Lei nº 11.804/08, uma vez que o art. 1º do aludido Diploma Legal reconhe expressamente, que tais alimentos são devidos à mulher gestante, durante a ges ção. Assim, podem ser demandados os pais biológicos ou socioafetivos, a depen do caso, por serem os legítimos interessados na reprodução assistida. Até porque alimentos gravídicos se destinam à manutenção material durante o período gestac nal. Tal pensionamento será devido desde a concepção, consoante a normatividad da matéria, somente cessando antes do parto em caso de interrupção da gravide

157. A Instrução *Donum vitae* (O Dom da Vida), exteriorizada em 22 de fevereiro de 1987, com a aprova do Papa João Paulo II, evidencia a rejeição eclesiástica às técnicas de fertilização medicamente assist reputando imprescindíveis para a gestação a existência de relações sexuais entre homem e mulher casa entre si. E, na hipótese de esterilidade, a única solução cabível seria a adoção. Parece, entretanto, que vem olvidando que o Velho Testamento já fazia referência às mães por substituição, no livro do Gên (30-3), narrando o drama de Raquel, em razão de sua infertilidade, descrevendo com minúcias a solu do problema, por meio da colaboração de outra mulher para o nascimento do filho de Jacó: "Raquel di a Jacó: – 'Aqui tens a minha serva (...), vai ter com ela. Que dê à luz sobre os meus joelhos; assim por eu também terei filhos'" *apud* MEIRELLES, Jussara. *Gestação por outrem e determinação da maternidad* "mãe de aluguel", op. cit., , p. 51 e ss.

158. Ponderam, lucidamente, Regina Fiúza Sauwen e Severo Hryniewicz que "comerciar bebês, mesmo os 'p duzidos' nas mais luxuosas clínicas, segundo as mais sofisticadas técnicas da biomedicina, é um atenta contra a dignidade humana". Cf. SAUWEN, Regina Fiúza; HRYNIEWICZ, Severo. *O direito "in vitro":* da Bioét ao Biodireito. op. cit.,, p. 113.

159. "Não se aceita, portanto, a utilização desse método apenas por vaidade da mulher que não quer submeter aos desconfortos da gestação ou em razão de suas atividades profissionais", como esclarec OLIVEIRA, Deborah Ciocci Alvarez de; BORGES JÚNIOR, Edson. *Reprodução assistida:* até onde poder chegar? – Compreendendo a ética e a lei. op. cit., p. 52.

Outro aspecto relevante é que, malgrado a gratuidade do ato, a mãe-gestacional fará jus a assistência médica e psicológica, custeada pelos interessados na gestação, a partir do referencial da boa-fé objetiva (CC, art. 422). Isso porque, em se tratando de negócio jurídico celebrado no interesse de quem pretende exercer a filiação, mostra-se absolutamente razoável impor eventual responsabilidade civil para arcar com despesas decorrentes de tratamentos médicos e psicológicos decorrentes da gestação em relação à mãe-hospedeira.[160]

Atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina, é de se conferir juridicidade à maternidade por substituição.

Os critérios definidos pela entidade de classe devem ser seguidos no caso concreto, evitando um verdadeiro "comércio de órgãos humanos". Vale aqui a referência ao caso *Baby M.* Em Nova Jersey (EUA), o casal Elizabeth e William Stern, não querendo levar adiante uma gravidez que poderia prejudicá-la profissionalmente, contratou Mary Beth Whitehead para que, fecundada artificialmente com o sêmen dele, lhes entregasse a criança concebida, após o nascimento. Em contrapartida, receberia uma remuneração de dez mil dólares. Aceitando o procedimento em face de sua situação financeira, Mary Beth, contudo, recusou-se a entregar a criança quando do seu nascimento, alegando que, quando da celebração do contrato, não era capaz de prever o vínculo afetivo que manteria com ela. Levado o caso à Suprema Corte de Nova Jersey, o Tribunal considerou que o contrato sob remuneração, nesse caso, era, evidentemente, ilegal, reconhecendo o direito da gestante de, a qualquer tempo, mudar de ideia e manter consigo o seu filho, embora tenha mantido a guarda do menor com o pai, reconhecido o direito de visita à "mãe hospedeira". Assim, deliberou que não haveria de se cogitar de eventual direito daquela cuja participação estava restrita a "fazer a encomenda". A mãe, portanto, em hipóteses marcadas pela retribuição econômica, é a que gestou o bebê,[161] rejeitando a comercialização do corpo humano e reconhecendo a ilicitude do negócio eventualmente celebrado.

Aliás, é importante a fixação de requisitos necessários para a validade do ato inclusive para fins de responsabilização civil das partes, evitando que, eventualmente, as partes envolvidas repudiem, por motivos diversos, a filiação estabelecida. Narram Deborah Ciocci Alvarez de Oliveira e Edson Borges Júnior que, em Michigan (EUA), em 1983, houve o caso de um bebê nascido com microcefalia que foi rejeitado, a um só tempo, pela mãe hospedeira e pelos genitores biológicos.[162] Por isso, respeitadas

160. Com a mesma preocupação, consta do item 3.4 da Resolução 2.121/15 do Conselho Federal de Medicina que as clínicas devem estabelecer *"garantia, por parte dos pacientes contratantes de serviços de reprodução assistida, de tratamento e acompanhamento médico, inclusive por equipes multidisciplinares, se necessário, à mãe que doará temporariamente o útero, até o puerpério"*.

161. Sobre o assunto, com mais profundidade e chegando à mesma conclusão, consulte-se Carlos Nelson Konder. "Elementos de uma interpretação constitucional dos contratos de reprodução assistida", op. cit., p. 261.

162. OLIVEIRA, Deborah Ciocci Alvarez de; BORGES JÚNIOR, Edson. *Reprodução assistida:* até onde podemos chegar? – Compreendendo a ética e a lei. São Paulo: Gaia, 2000, p. 53 e ss.

as exigências do Conselho de Medicina, é de se conferir a maternidade do nascituro àquela que cedeu o material genético.

Bem por isso, louvando-se, a toda evidência, do propósito de impedir problemas de conteúdo ético em relação ao tema, o item 3.3 da citada Resolução do Conselho Federal de Medicina exige que a clínica de reprodução assistida providencie um *"termo de Compromisso entre os pacientes e a doadora temporária do útero (que receberá o embrião em seu útero), estabelecendo claramente a questão da filiação da criança"*, evitando discussões posteriores.

Por derradeiro, mas não menos importante em relação ao tema, deve ser feita alusão à questão relativa ao *registro civil de nascimento* da criança nascida por meio de gestação em substituição. Não haverá dificuldade se o parto foi realizado pelo mesmo médico que cuidou do procedimento de fertilização. Neste caso, deverá ser procedido regularmente o registro de nascimento com base na declaração fornecida pelo médico, que inscreverá na declaração de nascido vivo (exigida pelo art. 46 da Lei n. 6.015/73) o nome da mãe biológica ou social.[163] Todavia, se o médico que realizar o parto não for o mesmo que promoveu a fertilização em útero alheio, somente poderá aquele que fez o parto registrar na declaração de nascido vivo o nome da parturiente (mãe hospedeira). Nesse caso, o interessado (a mãe biológica, o pai, o Ministério Público...) ou o próprio Oficial do Registro Civil suscitará procedimento de dúvida (art. 296 c/c os arts. 198 a 204 da Lei n. 6.015/73) ao juiz da Vara de Registros Públicos, que, com o auxílio da prova pericial (DNA) e ouvido o *Parquet* como fiscal da ordem jurídica (*custos juris*), determinará a inscrição do nome da mãe biológica no registro de nascimento.

Com evidente preocupação em relação ao tema, o item 3.5 da Resolução 2.121/15 do Órgão de classe da Medicina impõe à clínica de reprodução humana a obrigação de impor aos interessados a *"garantia do registro civil da criança pelos pacientes (pais genéticos), devendo esta documentação ser providenciada durante a gravidez"*. Procura-se evitar, com razoabilidade, problemas futuros relativos ao registro civil de nascimento.

Estas orientações, de qualquer sorte, possuem cunho administrativo, não havendo diploma legal acerca da matéria, conquanto a realidade viva reclame regulamentação legislativa, como fizeram inúmeros ordenamentos alienígenas.

g) A tutela jurídica do corpo humano e a procriação medicamente assistida (reprodução assistida)

A reprodução medicamente assistida é o gênero do qual podem derivar duas espécies: a *inseminação artificial* e a *fertilização na proveta* (também chamada de fertilização *in vitro* – *FIV*).

163. Com o mesmo pensamento, OLIVEIRA, Deborah Ciocci Alvarez de; BORGES JÚNIOR, Edson. *Reprodução assistida:* até onde podemos chegar? – Compreendendo a ética e a lei. São Paulo: Gaia, 2000, p. 55.

A *inseminação artificial* é o procedimento em que se realiza a concepção *in vivo*, no próprio corpo da mulher. O médico, portanto, prepara o material genético para implantar no corpo da mulher, onde ocorrerá a fecundação. De outra banda, na *fertilização na proveta* a concepção é laboratorial, realizada fora do corpo feminino, apenas ocorrendo a implantação de embriões já fecundados.

Ambas as modalidades técnicas podem se concretizar de forma *homóloga* ou *heteróloga*. Naquela (*homóloga*), utiliza-se de material genético do próprio cônjuge ou companheiro, com a sua expressa anuência. Nesta (*heteróloga*), o sêmen é de terceiro.

Assim, a fertilização assistida homóloga é caracterizada pela intervenção médica, facilitando casais que têm dificuldade em engravidar e levar a gestação a termo. Trabalha-se com o material genético do próprio casal, não gerando maiores dificuldades.

Na procriação assistida heteróloga, tem-se a participação de terceiro(s), sempre a título *gratuito* (Resolução nº 2.121/15, CFM). O médico trabalhará com sêmen (e/ou óvulo) de terceira pessoa, realizando a fecundação em laboratório para, em seguida, implantar o embrião no corpo da mulher. Respeitando o modelo de família monoparental (de mãe e filho, por exemplo), protegida constitucionalmente, é possível a fertilização, inclusive, em mulheres solteiras, viúvas ou divorciadas, independentemente de sua orientação sexual. Porém, havendo expressa autorização de uma outra pessoa para o procedimento de inseminação médica (do marido ou companheiro, por exemplo), decorrerá uma presunção de paternidade, recaindo sobre quem anuiu, como se se tratasse de verdadeiro reconhecimento prévio de filho.

Por outro turno, registre-se que o doador de sêmen, assim como a doadora de óvulo, está acobertado pelo sigilo (anonimato), não podendo ser identificado, por conta de uma opção visivelmente ética. No caso, não poderá o filho, posteriormente, se valer, sequer, de uma ação de reconhecimento de origem genética.

Apresente-se, no ponto, uma curiosa indagação: seria possível responsabilizar civilmente a clínica ou hospital por eventuais deficiências ou patologias congênitas na criança nascida da fertilização medicamente assistida? *Prima facie*, convém afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto à caracterização de vício ou defeito do produto (CDC, arts. 12 e 18), obstando uma "coisificação" da pessoa humana,[164] que não pode ser compreendida como um mero "objeto de contrato". De qualquer maneira, a Resolução CFM nº 2.121/15 estabelece a responsabilidade das clínicas pelo controle de doenças infectocontagiosas, coleta, manuseio, conservação, distribuição e transferência de material biológico humano. E, além disso, é possível cogitar da incidência do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, no que respeita à responsabilidade civil do profissional liberal, em face da atuação culposa do médico, eventualmente faltando com o necessário zelo profissional. Importante

164. Também com esse entendimento, Carlos Nelson Konder. "Elementos de uma interpretação constitucional dos contratos de reprodução assistida", op. cit., p. 252.

registrar que não se trata de vício em produto, mas de defeito na obrigação r de prestação de serviços.

De todo modo, é mister chamar a atenção para a necessidade de estab limites à atividade científica, dentro de uma expectativa ética. Não é à toa preclaro escritor baiano, de Itaparica, João Ubaldo Ribeiro, em seu *O Sorr Lagarto*, de 1989,[165] relatava os pesadelos e problemas que afligiam o protago por conta de experimentações biológicas, alertando para o fato de que o ser hu não pode ser reduzido a uma parte de biomassa, utilizando a tecnologia em seu e exclusivo benefício.

Talvez seja melhor esclarecer, como bem faz Sérgio Ferraz, que "nem tudo é cientificamente possível pode ser autorizado",[166] realçando a necessidade d sejam impostos limites éticos à atividade científica, obstando que a pessoa hu possa ter aviltada a sua imprescindível dignidade.

h) A proteção da integridade física e a situação dos ***wannabes*** (ou apotèmn

Diversos atos de disposição do corpo, como tatuagens e *piercings*, afig -se como manifestações de livre desenvolvimento da personalidade humana, de opções pessoais e culturais, já arraigadas a diferentes civilizações, como anteriormente. Não se poderia esquecer o exemplo clássico da circuncisão ju Em tais hipóteses, imaginar a intervenção do Poder Estatal reprimindo esse dispositivos constituiria induvidosa violação da dignidade humana,[167] caracte pela intromissão indevida do Estado na convicção particular do cidadão.

É possível, então, indagar a respeito da possibilidade de atos de disp do corpo humano mais violentos, como a autolesão (*self-injury*) ou a mutilaç partes do corpo, caracterizando verdadeira patologia clínica.

A questão foi tratada de maneira simplória pelo Código Civil, submetida à di na dos arts. 13 e 15 do Código Civil e do direito ao desenvolvimento da persona e identidade física e psíquica, exigindo solução que assegure a *dignidade hum*

Aqui reside o problema dos chamados *wannabes* (apotemnófilos ou *am es-by-choice*), que são aquelas pessoas portadoras de uma incontrolável comp

165. O próprio João Ubaldo Ribeiro afirma a respeito dessa festejada obra: "O título é uma metáfora, pois é c não há prova científica de que existem lagartos que sorriem. Um canadense, cientista, chegou a me p pensando que eu escrevia uma história sobre a evolução dos dinossauros. [...] Mas, *O Sorriso do Lago* se refere necessariamente a uma vingança dos dinossauros e lagartos. E no romance o protagonista o lagarto. *O Sorriso do Lagarto* é um livro que lida com a má administração do tempo que a hum passa na Terra. Acho que escrevi, sim, um romance sobre o mal, que fica transparente na atitude grande parte da classe dominante brasileira – ela detesta nosso país, ela detesta o que nós somos e a todas as violências: a mortalidade infantil, a violência nas cidades, a miséria. Quis escrever um livro adversário que existe em cada um de nós, sobre a figura de Satanás" (Leia, dez. 1989).

166. FERRAZ, Sérgio. *Manipulações biológicas e princípios constitucionais*: uma introdução, op. cit., p. 76.

167. Com idêntico raciocínio, importante fazer referência ao inexcedível texto de Carlos Nelson Kor consentimento no Biodireito: os casos dos transexuais e dos *wannabes*", op. cit., p. 63.

pela amputação de um membro específico de seu corpo, em razão do desconforto de estarem presos em um corpo que não corresponde à verdadeira identidade física que gostariam de ter.[168]

Na História, há o exemplo dos *eunucos* chineses que praticavam a ablação do órgão genital, com vistas a servir, de maneira integral, sem qualquer outro pensamento, ao Imperador.[169] Mais recentemente, encontra-se o caso de mulheres (em especial, nos Estados Unidos) que amputam o dedo mínimo do pé para que possam usar salto alto, sem desconforto.[170]

A hipótese não se confunde com o caso dos transexuais. É que em relação ao transexual, as pesquisas médicas já demonstram a finalidade terapêutica da cirurgia de adequação do estado físico e psíquico, enquanto a causa e o tratamento para os *wannabes* não são de ordem patológica.

O simples fato de não se tratar de questão terapêutica, dizendo respeito basicamente à autonomia privada, não justificaria, por si só, a intervenção proibitiva

168. Já se registra a existência de listas na Internet com mais de três mil e oitocentas pessoas partilhando essa condição. Cf.: KONDER, Carlos Nelson. "O consentimento no Biodireito: os casos dos transexuais e dos *wannabes*", op. cit., p. 65.

169. O processo de castração dos eunucos chineses é contado, em meio a um interessante romance policial, no livro *A Tumba do Imperador* (BERRY, Steve, *A Tumba do Imperador*. São Paulo: Record, 2012), em que problematiza situações a respeito da China e dos mistérios que gravitam ao derredor de sua conformação política e social: "O homem parou ereto. Ele parecia ter uns trinta e poucos anos, seus traços eram mais mongóis do que chineses, cabelos pretos presos em um penteado frouxo. Ele usava um robe branco com mangas largas, com detalhes em verde-claro no colarinho. Outros três homens, usando calças pretas e longas vestes cinzentas por baixo de curtos paletós azuis, o cercavam. O homem tirou o robe. Estava nu, o corpo pálido musculoso. Dois dos assistentes começaram a enfaixar seu abdome e suas coxas com bandagens brancas. Depois que a tarefa foi concluída, o homem ficou imóvel enquanto oterceiro criado lavava seu pênis e saco escrotal, que estavam expostos. A limpeza foi feita três vezes. O homem sentou-se em uma cadeira em uma posição semirreclinada, enquanto dois criados seguravam firmemente suas pernas. O terceiro participante aproximou-se de uma mesa laqueada e tirou de uma bandeja uma faca encurvada com um cabo rachado de osso[...] O homem permaneceu na mesma posição enquanto considerava a pergunta – vai se arrepender ou não? – e balançou a cabeça negativamente, sem a menor demonstração de medo ou incerteza. O assistente assentiu. Então, com dois rápidos golpes com a faca, cortou o pênis e saco escrotal do homem, o corte foi feito bem próximo ao corpo, sem deixar nada exposto. Nenhum som foi emitido. Os dois assistentes seguravam as pernas trêmulas do homem com firmeza. Sangue jorrou, mas o terceiro assistente cuidou do ferimento, obviamente causando dor ao homem sentado. Ainda assim, nenhum som foi emitido. A agonia tomava conta de seu rosto, mas o paciente pareceu recobrar o controle e equilibrou-se" (p. 62-63).

170. Consta de informação jornalística: "Uma intervenção cirúrgica polêmica tem se tornado comum nos Estados Unidos por prometer acabar com o desconforto de usar alguns tipos de sapatos femininos. Trata-se da *amputação de dedinhos inferiores, solução encontrada por algumas norte-americanas para diminuir a extensão da ponta dos pés* e, com isso, eliminar calos e deformações decorrentes do uso contínuo de sapatos com salto alto de bico fino. Esse tipo de cirurgia plástica é um dos três procedimentos mais procurados para acabar com o desconforto dos calçados. Os outros dois são diminuir o tamanho de algum dedo ou injetar colágeno na parte da sola do pé perto deles, na tentativa de deixar a sola mais acolchoada. Segundo a Associação Americana de Podologia Médica, cerca de 87% das estadunidenses sofrem algum problema no pé decorrente de calçados desconfortáveis. É o caso de *Susan Deming*, amante de sapatos de salto alto que sempre teve muitos calos no pé esquerdo, pelo fato de alguns dedos serem maiores que os outros. Para acabar com isso, ela diminuiu um centímetro do dedão do pé, e espera que, a partir de agora, caminhar deixe de ser um martírio" (Disponível em: <http://www.metro1.com.br/portal/?varSession=noticia&varEditoriaId=8&varId=24063>. Acesso em: 26.12.2012).

do Estado. A regra geral é a *liberdade de autodeterminação*, embora não absoluta. Por isso, parece mais prudente analisar cada caso concreto, sem estabelecer critérios apriorísticos precipitados. A extração do dedo mínimo para dar conforto aos pés teria o condão de afrontar a dignidade do seu titular? Parece-nos que a resposta negativa explicita a sensibilidade do tema.

O caso dos *wannabes* conduz, seguramente, a uma necessária compreensão do consentimento do titular, no Direito Civil contemporâneo, a partir de princípios constitucionais, com o fito de preservar a dignidade da pessoa humana, construindo soluções casuísticas.

i) A integridade física, a esterilização humana e os seus limites

A esterilização humana artificialmente determinada é resultado do emprego de técnicas específicas, em pessoa do sexo masculino ou feminino, para obstar a ocorrência de fecundação e procriação.[171]

As origens ancestrais da esterilização são as mais diversas possíveis, podendo lembrar referências demográficas, eugênicas, sociais, religiosas, econômicas e terapêuticas. Relata-se, por exemplo, que os adolescentes que integravam o coro da Capela Sistina, na Itália, para manter o tom contralto de suas vozes, eram castrados, com o propósito de não produzirem hormônios e não sofrerem modificações na voz. O cantor Carlo Broschi, inclusive, com sua melodiosa voz, teria curado a melancolia de Felipe V, da Espanha.[172] Na mitologia grega, há notícia de que a Rainha Semíramis, de Nínive, determinou que doentes incuráveis de seu reino fossem castrados, impedindo a degeneração da espécie.[173]

Admite-se, entre nós, a esterilização cirúrgica como método contraceptivo através da *laqueadura tubária*, *vasectomia* ou outro método aceito cientificamente, vedada a histerectomia (retirada do útero) ou ooforectomia (retirada dos ovários), exceto por exigência médica, como reza a Lei nº 9.263/96, notadamente em seus arts. 10, § 4º, e 15.

O citado diploma legal, regulamentando a paternidade responsável determinada constitucionalmente, admite a esterilização voluntária para fins de planejamento familiar, em homens e mulheres com plena capacidade civil, desde que maiores de 25 anos de idade ou que tenham, pelo menos, dois filhos vivos, observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade (por escrito) e o ato cirúrgico, durante o qual o interessado deverá ser conduzido ao serviço de controle de natalidade para desencorajar a esterilização,[174] através da recomendação de outros mecanismos contraceptivos.

171. Esse é, outrossim, o entendimento de Maria Helena Diniz. *O estado atual do Biodireito*, op. cit., p. 142.

172. DINIZ, Maria Helena. *O estado atual do Biodireito*, op. cit., p. 142.

173. Quem menciona a hipótese é Antônio Chaves. *Direito à vida e ao próprio corpo*, op. cit., p. 117.

174. COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Civil*, op. cit., p. 203.

Não se admite, por atentar contra a dignidade humana, a esterilização de criminosos sexuais (de quem pratica estupro, por exemplo), ainda que a origem delitógena seja um desvio de sexualidade.

Responde civilmente, por danos materiais e extrapatrimoniais (morais), quem realizar esterilização não autorizada legalmente, bem como a empresa que obriga suas empregadas a submeterem-se à esterilização, evitando, assim, o gozo de licença-maternidade.

j) A tutela jurídica da integridade física e as experiências científicas em pessoas humanas

Relatou o *Journalof Experimental Medicine*, em 1941, experiências científicas em que se introduzia em um bebê, com um ano de idade, o vírus do herpes com o propósito de estudar a doença. A situação toma cores mais nítidas na atualidade, considerando situações concretas em que a pessoa humana é tomada como objeto de ensaios clínicos, permitindo pesquisas em sua estrutura física (corpo humano).

A indagação é, pois, inexorável: a pessoa humana pode ser objeto de experimentações científicas?

Entende-se que as experiências científicas somente são possíveis pressupondo o *consentimento livre e informado*, com finalidade terapêutica e caráter gratuito, além de não produzir qualquer potencialidade de prejuízo à pessoa, respeitando os princípios da beneficência e não maleficência, proclamados como diretrizes da Bioética.

A comunidade internacional adotou *Diretrizes éticas internacionais para a pesquisa envolvendo seres humanos – Council for InternationalOrganizationsof Medical Siences*(CIOMS), em colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1993, na cidade de Genebra.

Entre nós, a Lei nº 8.974/95 estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados (OGM's). Na sua trilha, foi editada a Resolução nº 196/96 pelo Conselho Nacional de Saúde, fixando diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.

Quando se tratar de incapaz, o seu consentimento pode ser obtido através de seus representantes ou assistentes ou do juiz, se houver conflito entre eles.

De qualquer sorte, é preciso sopesar as vantagens da experimentação, salvaguardando a dignidade do interessado, a partir da ponderação dos riscos[175] e benefícios. Por isso, Elida Séguin, em obra específica, exige, ainda, que a experiência em seres humanos seja precedida por experimentos em animais.[176]

175. O risco admitido em tais procedimentos é tão só o risco habitual das rotinas médicas, não sendo possível agravar a situação do paciente, em face do acolhimento do princípio da não maleficência.

176. SÉGUIN, Elida. *Biodireito*, op. cit., p. 68.

A título exemplificativo, anote-se que a lei portuguesa (Decreto-lei nº 97/94) somente permite a participação de pessoas sãs em ensaios clínicos (experimentações científicas) quando não houver qualquer risco previsível para a sua integridade física e psíquica.

Registre-se que, como no direito luso (Código de Deontologia da Ordem dos Médicos em Portugal), deve ser proibida a prática de experiências científicas em "pessoas privadas da liberdade" (presos), em razão da impossibilidade de obtenção do livre consentimento e informação, por conta da peculiar situação em que se encontram, por conta da privação de liberdade.[177] Trata-se, sem dúvida, de importante ponderação ética, considerando que os presos constituem um grupo mais vulnerável à realização de ensaios médicos.

Vale sublinhar, demais disso tudo, que a Lei nº 11.105/05, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGMs, reconhece a possibilidade de pesquisa científica, com manipulação de organismos vivos (dentre os quais, as chamadas células-tronco), tendendo ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial (art. 2º).

k) Direito da personalidade ao corpo de outrem?

Estabelece o art. 1.566 do Código Civil ser dever dos cônjuges, na relação matrimonial, a *coabitação*. Historicamente, se pretendeu afirmar que o significado dessa coabitação (necessária ao casamento) seria dúplice, dizendo respeito, a um só tempo, à obrigação de vida em comum no domicílio conjugal (sentido objetivo) e de manutenção de relações sexuais habituais, convivendo intimamente (sentido subjetivo).

Nessa esteira, buscando inspiração nos léxicos e promovendo a exegese construtiva da norma legal, tem-se que a coabitação representa o relacionamento íntimo, afetivo e sexual, entre pessoas que vivem em comum, maritalmente.[178] É o chamado *débito conjugal* (expressão nitidamente criticável por conta de seu conteúdo preconceituoso e desvirtuado).

Ora, considerando que a coabitação é um dever imposto por lei às pessoas casadas, surge, então, interessante questionamento: há um direito da personalidade (sob o aspecto físico, evidentemente) ao corpo de outrem? Isto é, os cônjuges possuem um direito da personalidade de exigir relações sexuais entre si?

Conquanto parcela da doutrina[179] propugne pelo reconhecimento de um direito da personalidade sobre o corpo do cônjuge, a partir da reciprocidade da *prestação*

177. É de triste memória a experiência levada a termo pelo médico Sigmund Rascher, em campo de concentração de Dachau, pela qual submergiam corpos de presos em tanques de água com temperatura variando entre 2 e 15 graus centígrados, por longos lapsos de tempo, visando ao estudo da hipotermia, de modo a salvar pilotos nazistas que caíssem em águas geladas.

178. No ponto, vale conferir o texto de Cláudia HaidamusPerri. "Direito ao débito conjugal – um direito da personalidade", op. cit., p. 170.

179. Na mesma linha de pensamento, já se teve oportunidade, lamentavelmente, de afirmar, em sede jurisprudencial, que a prática de relações sexuais seria um dever de vida entre os cônjuges, transformando

do dever sexual no casamento,[180] essa não é a posição que deve prevalecer. É que a manifestação sexual (inclusive entre cônjuges e companheiros) é pura expressão de afeto, é materialização de sentimento, não sendo crível, nem admissível, que pudesse ser tratada pela ótica jurídica como uma obrigação imposta a uma pessoa humana.[181]

Pensar no débito conjugal como direito da personalidade é violar a dignidade humana, aviltando a sua liberdade afetiva e sexual. Nas palavras sensíveis e pertinentes do eminente Rodrigo da Cunha Pereira, "é claro que o sexo é um ingrediente importante do casamento e inclusive o vitaliza. Mas não se pode empobrecer a noção de sexo e de afeto e trazê-los assim para o Direito"[182] como uma prática imposta e obrigatória, desatrelado de seu conteúdo personalíssimo, como forma de realização e plenitude da personalidade humana.

Ademais, tratando o *debitum conjugale* como direito da personalidade, seria forçoso concluir que a sua eventual violação implicaria responsabilização civil do "cônjuge-devedor", que deveria reparar pecuniariamente (entregando dinheiro) a falta de afeto e carinho. Seria materializar o afeto – que é expressão típica da personalidade humana.

Por isso, há de se repudiar, *ex radice*, o enquadramento do débito conjugal como direito da personalidade e, por conseguinte, negar toda e qualquer indenização pela negativa da prática sexual entre os cônjuges, compreendendo-as como materialização do afeto.[183]

4.11.5 Direito à integridade psíquica (moral)

a) Noções gerais

O direito à integridade moral concerne à proteção conferida aos atributos psicológicos relacionados à pessoa, tais como a sua honra, a liberdade, o recato, a imagem, a vida privada e o nome. Tutela, pois, a higidez psíquica da pessoa, sempre à luz da necessária dignidade humana.

---

em obrigação jurídica o que tem caráter afetivo: "Anulação de casamento. Procedência. Mulher que tem aversão ao ato sexual, negando-se, terminantemente, ao *debitum conjugale*. Descumprimento de *dever de vida em comum*. Existência de causa inibitória para o congresso sexual, por motivos de ordem psicológica diagnosticado na requerida. [...] O *dever* de vida em comum dos esposos, no domicílio conjugal, exige comunhão total, notadamente de natureza íntima" (TJ/PR, Ac. 2ª Câm. Cív., Rnec 11033, Rel. Des. Nasser de Mello, *DJPR* 10.4.95).

180. Defendendo esse posicionamento, Cláudia HaidamusPerri. "Direito ao débito conjugal – um direito da personalidade", op. cit., p. 174 ss, alinhando-se à mesma opinião de Álvaro Villaça Azevedo e Rubens Limongi França.

181. Se tivesse, realmente, natureza obrigacional, sendo dever de um cônjuge, estaria legitimado o estupro entre cônjuges, acobertado pelo exercício regular de um direito.

182. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. "O débito e o crédito conjugal", op. cit., p. 7.

183. A título de esclarecimento, convém destacar que não se nega a possibilidade de responsabilidade civil decorrente de dano causado em uma relação matrimonial – ou em uma relação familiar qualquer. Essa reparação de danos, no entanto, é consequência da prática de um ato ilícito, não dizendo respeito à eventual recusa do afeto.

São atributos relacionados à incolumidade moral, destinados à preservação do conjunto psicológico da estrutura humana. São as emanações da alma, essencialmente incorpóreas, distintas das projeções físicas do indivíduo.[184]

Assim, seja por ações diretas ou indiretas, seja por conta de situações naturais ou provocadas, impõe-se a cada pessoa – e à coletividade como um todo, inclusive ao Poder Público – respeitar a integridade psicológica de toda e qualquer pessoa, abstendo-se de interferir no aspecto interior da personalidade. Por isso, como esclarece Carlos Alberto Bittar, "são vedadas pelo ordenamento jurídico todas as práticas tendentes ao aprisionamento da mente ou a intimidação pelo medo, ou pela dor, enfim, obnubiladoras do discernimento psíquico",[185] afastando-se internações forçadas em clínicas e *spas* (salvo por necessidade terapêutica), lavagens cerebrais etc.

A título ilustrativo, podem ser alinhados como direitos da personalidade no âmbito psíquico: (*i*)a imagem; (*ii*) a privacidade; (*iii*) a honra; (*iv*) o nome civil, dentre outros. O Código Civil, em seus arts. 20 e 21, apresentou contornos gerais para a tutela jurídica da imagem e da vida privada.

b) O direito à imagem

b.1) A proteção jurídica da imagem e a sua trilogia conceitual (imagem-retrato, imagem-atributo e imagem-voz)

A importância da imagem na história da humanidade não é recente. Ao revés, data de priscas eras. Só para ilustrar, vale lembrar o célebre caso do orador grego *Hipérides* que conseguiu obter a absolvição da cortesã *Frineia* sem utilizar de nenhuma palavra sequer em sua defesa, apenas apresentando aos julgadores a imagem dela nua, conseguindo convencê-los da sua inocência.[186]

Também as palavras bíblicas relatam que o homem representa a imagem e semelhança do Criador.

Em precedentes judiciais, relata-se que a primeira decisão protetiva do direito à imagem teria sido lavrada na França, em 1855, quando o Tribunal Civil de la Seine proibiu a exposição pública de um quadro representando a diretora de uma congregação religiosa.

No mundo pós-moderno, marcado pelo avanço tecnológico, pelo uso da *Internet* e pela facilitação na captação de imagens, representada por equipamentos eletrônicos e digitais, a preocupação com a tutela da imagem é evidente, saltando aos olhos.

184. Sobre o tema, chegando a observar que os componentes físicos e morais da personalidade são apenas o ponto de partida, "dentro dos quais deverão ser montados quadros não herméticos, capazes de admitir posteriores incursões, fruto da perene evolução do homem", faça-se referência à obra de Gilberto Haddad Jabur. *Liberdade de pensamento e direito à vida privada*, op. cit., p. 108.

185. BITTAR, Carlos Alberto. *Os direitos da personalidade*, op. cit., p. 116-117.

186. A referência é de Jacqueline Sarmento Dias. *O direito à imagem*, op. cit., p. 65.

A massificação no uso da imagem permite uma fácil e veloz exploração da imagem das pessoas.

Pois bem, o direito à imagem é de grande elasticidade, cuidando da proteção conferida à pessoa em relação à sua forma plástica e aos respectivos componentes identificadores (rosto, olhos, perfil, busto, voz, características fisionômicas etc.) que a individualizam na coletividade, deixando antever um amplo espectro, formado por um conjunto de características que permitem a sua identificação no meio social.

Trata-se de um direito exclusivo e excludente de alguém ser identificado e proteger a sua identificação na sociedade em que vive.

Efetivamente, a imagem corresponde à exteriorização da personalidade, englobando, a um só tempo, a reprodução fisionômica do titular e as sensações, bem assim como as características comportamentais que o tornam particular, destacado, nas relações sociais.[187]

Essa elasticidade conceitual, decorrente da proteção constitucional da imagem (CF, art. 5º, incisos V e X), faz compreender, no conceito de imagem, diferentes aspectos: a *imagem-retrato*, a *imagem-atributo* e a *imagem-voz*.

A *imagem-retrato* refere-se às características fisionômicas do titular, à representação de uma pessoa pelo seu aspecto visual, enfim, é o seu pôster, a sua fotografia,[188] encarada tanto no aspecto estático – uma pintura –, quanto no dinâmico – um filme –, conforme proteção dedicada pelo art. 5º, X, da Constituição da República. Noutro quadrante, a *imagem-atributo* é o consectário natural da vida em sociedade, consistindo no conjunto de características peculiares da apresentação e da identificação social de uma pessoa. Diz respeito, assim, aos seus qualificativos sociais, aos seus comportamentos reiterados que permitem identificá-la.[189] Não se confunde com a imagem exterior, cuidando, na verdade,

187. É também o que sustenta Carlos Affonso Pereira de Souza. "Contornos atuais do direito à imagem", op. cit., p. 38.

188. Há interessante precedente jurisprudencial cuidando do direito à imagem-retrato: "A publicação de fotografia em jornal com fins publicitários cedida por terceiro sem autorização expressa do fotografado constitui violação ao direito relativo à própria imagem, cabendo ao lesado indenização por danos morais, conforme inteligência do art. 5º, V e X, da CF" (TJ/AC, Ap. Cív. 97.0093-6, Rel. Des. Jersey Nunes, j. 23.9.97, *RT* 748: 310).

189. Excelente exemplo de imagem-atributo é trazido da jurisprudência. A conhecida apresentadora de programas infantis Xuxa ingressou com pedido em juízo de proibição da comercialização de fitas de vídeo do filme *Amor, estranho amor*,em que aparece em cenas de conteúdo erótico, rodado antes da construção de sua (incontroversa) imagem-atributo junto ao público infantil. Alegou que as cenas da película atentavam contra a imagem social que formou posteriormente. Deliberou a Corte fluminense: "Após o lançamento da fita (no cinema), ocorrido em 1982, a Autora (Xuxa) se projetou, nacional e internacionalmente, com programas infantis na televisão, criando uma imagem que muito justamente não quer ver atingida, cuja vulgarização atingiria não só ela própria como as crianças que são o seu público, ao qual se apresenta como símbolo da liberdade infantil, de bons hábitos e costumes, e da responsabilidade das pessoas" (TJ/RJ, Ap. Cív. 3819/91, Rel. Des. Thiago Ribas Filho, j. 27.2.92). A referência consta do belo trabalho de Carlos Affonso Pereira de Souza. "Contornos atuais do direito à imagem", op. cit., p. 43.

de seu retrato moral.[190] Já a *imagem-voz* concerne à identificação de uma pessoa através de seu timbre sonoro. Aliás, sem dúvida, a personalidade de alguém não se evidencia menos na voz que nas características fisionômicas.[191]

É importante deixar claro que o direito à imagem é um só, apenas projetando-se em diferentes aspectos. Significa dizer que não existem três diferentes direitos, mas um único direito, protegido constitucionalmente em sua tridimensionalidade.

Sublinhe-se, outrossim, que o direito à imagem é autônomo e independente, não estando submetido à honra ou privacidade e, sequer, à exploração econômica. Aliás, não se olvide, inclusive, que a autonomia conceitual do direito à imagem foi reconhecida em sede constitucional, dentre os direitos e garantias fundamentais (CF, art. 5º, V e X), merecendo proteção específica, independentemente de afronta à honra ou à privacidade.

Bem por isso, inclusive, partindo dessa autonomia conceitual, impõe-se disparar contundente crítica ao art. 20 do Código Civil que, indevidamente, amesquinhou o direito à imagem, afirmando que a sua proteção somente seria possível quando existir uma violação da honra ou exploração econômica. Reza, *in litteris*, o aludido dispositivo legal:

> Art. 20, Código Civil:
>
> "Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa *poderão ser proibidas*, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, *se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais*."

Como se percebe, o texto codificado incorreu em lamentável equívoco ao condicionar a proteção da imagem à violação da honra e boa fama ou à exploração comercial. Da forma com que ficou redigido o artigo, se alguém tiver a sua imagem veiculada, sem a sua autorização, mas sem exploração comercial e sem lhe atingir a honra, não haveria ato ilícito – o que se apresenta absurdo, por afrontar a tutela jurídica da imagem.

Por óbvio, exige-se uma interpretação conforme a Constituição do aludido art. 20 da Codificação de 2002. Em sendo assim, reconhecida a autonomia conceitual e a proteção fundamental da imagem, a simples utilização indevida da imagem de uma pessoa, mesmo sem afronta à sua honra e sem exploração comercial, já impõe a reparação por dano, a partir do garantismo constitucional (CF, art. 5º, L e X).

---

190. É o que afirma Luiz Alberto David Araújo, em obra especificamente dedicada ao tema. *A proteção constitucional da própria imagem*, op. cit., p. 32 ss. A respeito do tema, imperdível a leitura do interessante trabalho de Luiz Roberto Curado Moreira. "A problemática do dano à imagem", op. cit., bem como da obra de Regina Sahm. *Direito à imagem no direito civil contemporâneo*, op. cit., p. 42 ss.

191. Com absoluta razão, Alcides Leopoldo e Silva Júnior percebe que o som da voz é tão identificador da pessoa quanto seu próprio rosto. E lembra uma famosa propaganda de televisão de xampu em que se dizia "a voz continua a mesma, mas os cabelos...". Cf. *A pessoa pública e o seu direito de imagem*, op. cit., p. 14.

Aproveitando, de qualquer sorte, a redação do dispositivo codificado, se houver *exploração comercial da imagem alheia*, presume-se a violação do direito da personalidade, como, inclusive, cimentou entendimento a jurisprudência superior, consoante a redação da Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça:

> Súmula 403, Superior Tribunal de Justiça:
>
> "Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais."

Em sendo assim, o uso indevido da imagem de alguém, por si só, já induz a ocorrência de dano indenizável, independentemente da qualidade da imagem ou da existência de referências positivas. Ilustrando a matéria, vale recordar o caso de uma famosa atriz que teve uma fotografia desnuda veiculada, indevidamente, sem a sua anuência, por um jornal no Rio de Janeiro. Embora a Corte Estadual, incorrendo em lapso, tenha negado a indenização, baseado na beleza da modelo e da fotografia,[192] o Superior Tribunal de Justiça, corretamente, reconheceu o direito à reparação do dano, em face da *autonomia do direito à imagem*, que não se subordina à existência de afronta à honra, podendo estar cumulado com o dano moral puro (dano à honra).[193]

Noutra oportunidade, asseverou, didaticamente, a Corte Superior:

> "Em se tratando de direito à imagem, a obrigação de reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da prova da existência de prejuízo ou dano. O *dano é a própria utilização indevida da imagem*, não sendo necessária a demonstração do prejuízo material ou moral" (STJ, Ac. 4ª T., REsp. 267.529/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 3.10.00, *DJU* 18.12.00, p. 208).

---

192. Naquela oportunidade, o Tribunal do Rio de Janeiro negou a possibilidade de cumular o dano à imagem com o dano moral afirmando: "Fosse a autora uma mulher feia, gorda, cheia de estrias, de celulite, de culote e de pelancas, a publicação de sua fotografia desnuda – ou quase – em jornal de grande circulação, certamente lhe acarretaria um grande vexame, muita humilhação, constrangimento enorme, sofrimentos sem conta, a justificar – aí sim – o seu pedido de indenização de dano moral, a lhe servir de lenitivo para o mal sofrido. Tratando-se, porém, de uma das mulheres mais lindas do Brasil, nada justifica pedido dessa natureza, exatamente pela inexistência, aqui, de dano moral a ser indenizado" (TJ/RJ, Ac. II Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Des. Wilson Marques, j. 29.9.99, *Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro*, 41: 184-187).

193. "Publicação não autorizada de foto integrante de ensaio fotográfico contratado com revista especializada. Dano moral. Configuração. É possível a concretização do dano moral independentemente da conotação média de moral, posto que a honra subjetiva tem termômetro próprio inerente a cada indivíduo. É o decoro, é o sentimento de autoestima, de avaliação própria que possuem valoração individual, não se podendo negar esta dor de acordo com sentimentos alheios. Tem o condão de violar o decoro, a exibição de imagem nua em publicação diversa daquela com quem se contratou, acarretando alcance também diverso, quando a vontade da pessoa que teve sua imagem exposta era a de exibi-la em ensaio fotográfico publicado em revista especializada, destinada a público seleto. A publicação desautorizada de imagem exclusivamente destinada a certa revista, em veículo diverso do pretendido, atinge a honorabilidade da pessoa exposta, na medida em que experimenta o vexame de descumprir contrato em que se obrigou à exclusividade das fotos. A publicação de imagem sem a exclusividade necessária ou em produto jornalístico que não é próprio para o contexto, acarreta a depreciação da imagem e, em razão de tal depreciação, a proprietária da imagem experimenta dor e sofrimento" (STJ, Ac. 3ªT., REsp. 270.730/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.00, *DJU* 7.5.01, p. 139).

Em síntese: o direito à imagem é autônomo e independente, sendo inerente à própria personalidade e merecendo tutela jurídica específica.

E bem por isso, reconhecida a autonomia do direito à imagem, é preciso sublinhar que a utilização da imagem do empregado não integra a dimensão do contrato de trabalho, sendo vedado ao patrão explorar a imagem do seu trabalhador, salvo disposição em contrário.[194]

Aliás, por conta da amplitude do direito à imagem, a Lei nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais, além de tutelar o inventor, estende a proteção ao retratado e ao artista intérprete ou executante, também cuidando da proteção à imagem como um direito de autor, em linha de coerência com o inciso XXVIII do art. 5º da *Lex Legum*. Trata-se de projeção patrimonial do direito à imagem. Ao tutelar a imagem, a lei estabelece regras para a exibição e reprodução das conferências, alocuções, sermões, obras dramáticas e musicais, coreografias e pantomímicas, composições musicais, obras audiovisuais, fotográficas, de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética e ilustrações (art. 7º).

Também está protegido o chamado *direito de arena*, muito comum, por exemplo, em transmissões esportivas. Por óbvio, nas competições esportivas, a imagem do atleta pode ser utilizada mesmo sem a sua anuência expressa, pois é inerente ao exercício dessa profissão. Assim, a imagem de atletas termina sendo explorada, direta ou indiretamente, pelos seus clubes, por conta da transmissão de espetáculos dos quais participam diretamente. Bem por isso, o art. 42 da Lei nº 9.615/98 prevê que as entidades de prática desportiva possuem o direito de negociar, autorizar e proibir a fixação, a transmissão e retransmissão de imagem de espetáculos ou eventos desportivos dos quais participem, acrescentando que, salvo disposição contrária, o percentual mínimo de 20% do preço total da autorização será distribuído, em partes iguais, aos atletas profissionais participantes do evento. É o chamado *direito de arena*, consubstanciando um mecanismo de proteção da imagem do atleta, garantindo-lhe, inclusive, alguma retribuição por conta da sua utilização. Importante observar que a autorização para divulgação da imagem de um atleta, por consequência do direito de arena, não significa permissivo para a divulgação daquela imagem por outras formas, desviando a finalidade.[195]

194. Nessa esteira, há precedente pretoriano: "A utilização da imagem do empregado pelo empregador não pode ser subentendida como decorrente do contrato de trabalho, que não produz efeitos tão amplos, pena de gerar locupletamento ilícito; o uso da imagem pode ser ajustado, mas não deflui originariamente do contrato laboral; de maneira que frágil falar-se, na hipótese, de anuência presumida" (TRT – 15ª Região/Campinas, Ac. 3ª T., RO 1359/2002.066.15.00-4, Rel. Des. Francisco Alberto da Motta P. Giordani, *DJ* 20.4.06, p. 55).

195. Tanto que a jurisprudência já teve oportunidade de reconhecer que a transmissão de espetáculos esportivos não autorizava o uso da imagem dos atletas em álbuns de figurinhas: "O direito de arena que a lei atribuiu às entidades desportivas limita-se à fixação, transmissão e retransmissão do espetáculo desportivo público, mas não compreende o uso da imagem dos jogadores fora da situação específica do espetáculo, como na reprodução de fotografias para compor álbum de figurinhas" (STJ, Ac. 4a T., REsp. 46.420, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, *DJU* 5.12.94, p. 33.565).

De outro lado, o reconhecimento da tutela jurídica da imagem-atributo, inclusive em sede constitucional (CF, art. 5º, V), aponta para uma íntima relação com o direito de resposta.[196]

Lembre-se, ainda, que a pessoa jurídica também é titular do direito à imagem. É bem verdade que a ela não se pode reconhecer a integralidade da dimensão protetiva da imagem. Às pessoas jurídicas apenas se reconhece a titularidade do direito à *imagem-atributo*, através do conjunto de características que a particularizam socialmente. Em razão da ausência de estrutura biopsicológica, não possui, por evidente, a *imagem-retrato* e, muito menos, a *imagem-voz*.

b.2) A proteção da imagem como direito da personalidade

O enquadramento topológico do direito à imagem como um direito da personalidade (CC, art. 20) importa, como consequência lógica, na aplicação, em linhas gerais, das regras do próprio Código Civil sobre a proteção da personalidade – uma vez que possuem caráter geral.

Assim, basicamente, a proteção do direito à imagem se aperfeiçoa através de *tutela preventiva* (inibitória), com o escopo de impedir que o dano ocorra ou se alastre. Não afasta, de qualquer modo, a possibilidade de tutela repressiva, através de ação de indenização por danos extrapatrimoniais (comumente chamados de danos morais), quando o dano já se concretizou, independentemente de causar prejuízos materiais.[197] Ou seja, "o dano do lesado não se confunde com o lucro do infrator, que inclusive pode ter sofrido prejuízo com o negócio", como já deliberou o Superior Tribunal de Justiça.[198]

Vale destacar que a proteção concedida ao direito à imagem, pelo art. 20 do Livro Civil, não afasta a tutela geral do art. 12 da mesma lei, que tem caráter geral, apenas impondo uma limitação no que tange à legitimidade dos lesados indiretos, conforme o parágrafo único do citado art. 20 da Codificação. Nessa linha de entendimento, a Jornada de Direito Civil proclamou, no Enunciado 5, que:

> Enunciado 5, Jornada de Direito Civil:
>
> "1) as disposições do art. 12 têm caráter geral e aplicam-se inclusive às situações previstas no art. 20, excepcionados os casos expressos de legitimidade para requerer as medidas nele estabelecidas; 2) as disposições do art. 20 do novo Código Civil têm a finalidade específica de regrar a projeção dos bens personalíssimos nas situações nele enumeradas. Com exceção dos casos de

196. Assim, OduvaldoDonninie Rogério Ferraz Donnini. *Imprensa livre, dano moral, dano à imagem, e sua quantificação à luz do novo Código Civil*, op. cit., p. 71.

197. "Cuidando-se de direito à imagem, o ressarcimento se impõe pela só constatação de ter havido a utilização sem a devida autorização. O dano está na utilização indevida [...] O dano, neste caso, é a própria utilização para que a parte aufira lucro com a imagem não autorizada de outra pessoa" (STJ, Ac. 3ª T., REsp. 138.883, Rel. Min. Menezes Direito, j. 4.8.98, *RT* 760: 211).

198. STJ, Ac. 4ª T., REsp. 100.764/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 24.11.97, *RT* 752: 192.

> legitimação que se conformem com a tipificação preconizada nessa norma, a ela podem ser aplicadas subsidiariamente as regras instituídas no art. 12."

Reitere-se, por oportuno, que entendemos ser exemplificativo o rol dos lesado indiretos (CC, art. 12, parágrafo único), conforme exposto alhures. Por isso, concluímo que, havendo vinculação afetiva com o morto (cuja imagem foi indevidamente utili zada), o parente colateral até o quarto grau estará legitimado como *lesado indireto* podendo reclamar, em nome próprio, reparação do dano (preventiva e compensatória) apesar da restrição do parágrafo único do art. 20 do *Codex*.

b.3) Relativização do direito à imagem: consentimento do titular e lugare públicos

Considerando a máxima de que não há direitos absolutos em um sistema constitu cional de Direito, é de se concluir que o direito de imagem pode sofrer flexibilizaçõe sendo mitigado quando, eventualmente, se puser em rota de colisão com outros direitos

Primeiramente, o direito de imagem pode ser relativizado por manifestação d vontade, expressa ou tácita, do titular. Aliás, perlustrando o caminho pavimentad pelo art. 20 da Codificação, nota-se que a própria pessoa pode dispor de sua imagem consentindo, expressa ou tacitamente, com a utilização por terceiros.

Sem dúvida, revela-se de grande importância prática e teórica a questão d consentimento do titular para o uso da imagem por terceiro, especialmente er nossos dias, nos quais há uma facilidade de acesso aos meios de comunicação e à redes sociais e, com isso, uma fácil propagação da imagem das pessoas por meio d *Internet*, por exemplo.

Pois bem, o direito à imagem admite cessão – gratuita ou onerosa.

E mais: o consentimento para a utilização da imagem pode ser *expresso* o *tácito*. Expresso será o consentimento decorrente de uma declaração de vontade como na hipótese da celebração de um contrato pelo titular com uma revista, po exemplo, autorizando a veiculação de sua imagem. No mais das vezes, contudo, consentimento é tácito, como se nota das transmissões carnavalescas ou de jogo de futebol, quando pessoas diversas sorriem para as câmeras de televisão. Enfim, uma autorização comportamental.

Uma vez autorizada a utilização da imagem por outrem, está caracterizado ur verdadeiro ato de disposição (relativa) de direito, não sendo possível que se alegue posteriormente, dano ao direito e que se pretenda reparação civil. Com Luiz Alberto Davi Araújo, o consentimento "torna a utilização devida, correta, revestindo-a de legalidade".[19]

Considerando o caráter relativo desse ato de disposição de direito da perso nalidade, bem como a impossibilidade de disposição perpétua, não se admite un consentimento genérico, por demais abrangente, nem perpétuo, indeterminado.

199. ARAÚJO, Luiz Alberto David. *A proteção constitucional da própria imagem*, op. cit., p. 88.

Além disso, a anuência não precisa ser expressa, nem escrita. Apresenta-se perfeitamente possível que se conceda o uso da imagem de forma implícita, informal. É, inclusive, o modo mais comum, habitual. É a hipótese de alguém que se deixa fotografar ou filmar em eventos sabendo que a câmera que está registrando é de uma rede de televisão pela logomarca estampada ou pela identificação do fotógrafo de uma revista de variedades. Corretamente, inclusive, a jurisprudência vem admitindo o consentimento tácito.

Reconhecida a possibilidade de consentimento tácito (dedutível do próprio comportamento do titular), é de se exigir, por outra banda, prudência e razoabilidade na interpretação da vontade, evitando desvios de finalidade. Exemplificando: a autorização tácita de um modelo profissional, para ser exposta a sua imagem nua em uma galeria de artes, não pode ter uma extensão a permitir a utilização em outro local, desprovido de finalidade artística.[200]

Reclama alusão uma importante situação prática cotidiana: é que a autorização, expressa ou tácita, para ser fotografado nem sempre abrange a autorização para a publicação, em quaisquer meios, impresso, cibernético etc. Efetivamente, é comum encontrar situações nas quais a pessoa consente em ser fotografada para uso pessoal, afastada a intenção de dar publicidade àquela imagem captada. São hipóteses de imagens obtidas (por máquinas fotográficas ou de filmagens) para uso pessoal, exclusivamente, pela própria natureza da situação em que se encontra a pessoa. É o exemplo de casais de namorados que se permitem fotografar em situações de intimidade. Em tais casos, havendo exteriorização da imagem, por qualquer instrumento, haverá dever de reparação do dano à imagem, sem prejuízo de reparação de eventual dano à honra ou à privacidade, a depender da situação fática concreta. Isso porque apesar do consentimento para a captação da imagem, não há autorização para a sua publicação.

Por outro lado, é evidente que, não tendo consentido ou havendo indevida publicidade ou desvio de finalidade, o titular faz jus à indenização pelo uso indevido de sua imagem, inclusive lhe sendo lícito exigir de volta os originais do filme ou os negativos da fotografia. É que o consentimento engloba, não apenas a veiculação e exposição da imagem, mas, também, a sua simples captação.

E mais. Também haverá dano indenizável se o consentimento for desvirtuado ou se houver exploração econômica da imagem.[201] Assim, se um artista consente em posar para uma revista de cinema e sua foto é aproveitada em uma propaganda comercial de um produto medicinal, haverá dano reparável.[202] Também haverá dano

200. O exemplo foi talhado por Paulo José da Costa Júnor. *O direito de estar só*, op. cit., p. 60.

201. "Havendo permissão para utilização de imagens da edição de uma única obra, de índole científico-didática, e divulgados os retratos de parturiente, em plena atividade de dar à luz uma criança, fora da publicação nomeada na letra convencional, tal fato traduz agressão primária à tutela da intimidade moral, ferindo direito da personalidade, suscetível de indenização" (TJ/SP, Ac. 4ª Câm. Cív., Ap. Cív. 88.357-1, Rel. Des. Ney Almada, j. 17.9.87, *RT* 623: 61).

202. O exemplo é formulado por David Araújo, citando a obra de Santos Cifuentes. *A proteção constitucional da própria imagem*, op. cit., p. 89.

indenizável se a imagem de um jogador de futebol, captada durante a partida, serve, sem anuência do interessado, de mecanismo publicitário de um determinado produto. Um exemplo muito interessante pode ser lembrado com a condenação do canal de notícias *Globonews* por desvio de finalidade no uso da imagem de um dos envolvidos no lamentável episódio do naufrágio da Plataforma de petróleo P-36, da Petrobras. Aproveitando-se da imagem que havia sido captada para fins jornalísticos, a empresa passou a explorá-la comercialmente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, então, deliberou pela indenização, em face do desvio de finalidade:

> "Uso indevido da imagem. É a imagem direito constitucionalmente protegido e embora se admita sua veiculação no momento da divulgação do fato, há abuso e, portanto, ilícito se, passado o momento da notícia, ela é utilizada com fim comercial. Ação proposta por quem teve sua foto estampada em jornal e revistas em razão do episódio da tragédia do naufrágio da Plataforma P-36.
>
> Foto em que aparece o autor e que retrata acontecimento dramático de profundo interesse para o público, que na ocasião foi veiculada pela imprensa, mostrando momento dramático para todos os embarcados, que naquela ocasião foram tomados de profunda dor e acabrunhamento, tornando-se representativa da situação, passando a ser veiculada constantemente na imprensa. Houve uso indevido da imagem do autor, não obstante no primeiro momento se tratasse de mera divulgação do dramático episódio, o que, por si só, não causaria qualquer afronta ou dano ao autor, tanto mais que se tratava de garantir o direito à comunicação e à liberdade de imprensa; todavia, passado o momento da informação da ocorrência, a foto do autor, em estado de grande choque, passou a ser mero chamariz com cunho publicitário para a programação do canal, aproveitando-se a empresa de comunicação, a GloboNews, da imagem por ela colhida como atrativo na comercialização de seus produtos, sendo certo que nesses não mais se tratava de informar o fato ocorrido, mas tão somente de divulgar comercialmente a empresa como sendo a mais eficiente no mercado" (TJ/RJ, Ac. unân., 1ª Câm. Cív., Ap. Cív. 2004.001.34678, rel. Desa. Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, j. 21.6.05).

O fato de se encontrar o titular em lugar público também relativiza, mitiga, o direito à imagem.

É preciso, de qualquer forma, um cuidado especial com o uso da imagem de pessoas que estão em locais públicos, como praias e logradouros, bailes e desfiles carnavalescos,[203] estádios de futebol, passeatas, manifestações etc. É evidente que, estando em lugar público, há uma presunção de publicidade da imagem, em especial quando o fato for de interesse social e estiver sendo coberto jornalisticamente. No entanto, não se pode imaginar que, por estar em um local público, a imagem de uma pessoa deixou de merecer proteção jurídica. Assim sendo, se a imagem é captada e está inserida em um conjunto genérico, sem individualização, não há que se falar em dano, pois se refere a um evento público, aberto. É o exemplo da fotografia captada

203. "Direito à imagem. Violação. Requisitos de admissibilidade. Inocorre violação ao direito de imagem quando inexiste a finalidade comercial, e a foto foi feita em festa popular, na qual a fotografada, na qualidade de participante, se expunha à visão da multidão e dos meios de divulgação" (TJ/MG, Ap. Cív. 75.697/3 – Belo Horizonte, Rel. Des. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *IOB – Repertório de jurisprudência* 24, 88).

pelo jornal em uma praia, em dia de calor, para ilustrar reportagem sobre os efeitos do aquecimento global, mostrando inúmeras pessoas indistintamente, embora seja possível, até mesmo, identificar uma ou outra.[204] Entretanto, sendo focalizada em plano diferenciado a imagem de determinada pessoa que está em evento público, sem a sua autorização, estará, sem qualquer dúvida, caracterizada a violação ao direito de imagem. Resgatando o exemplo anterior, haverá dano reparável se a fotografia revela, em primeiro plano, as formas e silhueta de alguém que aproveitava o sol naquele dia. Trilhando o fio do exposto, infere-se, com certeza e tranquilidade, não ser possível invocar a publicidade do local para, com o uso da tecnologia, afrontar a imagem das pessoas. Por isso, mesmo estando em local público (insista-se no exemplo da praia ou de uma avenida de grande circulação), não se pode captar intimidades de um casal e explorar economicamente tais imagens.

Demais disso, também vale pontuar a absoluta nulidade das (abusivas) cláusulas inseridas em contratos de adesão (normalmente escritas em ingressos), nos casos de eventos particulares, como *shows* e espetáculos artísticos, informando que o evento está sendo gravado e que as imagens do público presente poderão ser utilizadas, a critério do promotor de evento. Trata-se de cláusula visivelmente ilícita e, por conseguinte, nula de pleno direito.

b.4) A função social da imagem

Tema dos mais importantes no âmbito do direito à imagem diz respeito à sua *função social*, proclamada pelo próprio comando do art. 20 da Lei Civil.

Com efeito, harmonizando os princípios constitucionais aplicáveis ao Direito Civil com a redação da própria Codificação, infere-se, com tranquilidade, a afirmação da *função social da imagem*. É que a proteção da imagem não é ilimitada ou absoluta, encontrando restrição no sistema jurídico, em razão da dinâmica da ciência jurídica.

Bem explica Sílvio Romero Beltrão que a tutela dispensada aos direitos da personalidade como um todo, e, particularmente, ao direito à imagem, "não pode significar uma liberdade arbitrária atribuída ao seu titular, devendo, pois, sofrer limitações do direito na própria lei que os instituiu [...], em face da conjugação com outras situações protegidas; deve sofrer limitações valoradas, objetivamente segundo os interesses e fins sociais da ordem jurídica".[205]

De fato, o exercício do direito à imagem não pode afrontar os interesses e a finalidade social do direito, não servindo para objetivos egoísticos, em detrimento da confiança despertada na coletividade. Por isso, a Codificação foi de clareza meridiana

204. A hipótese já foi amparada jurisprudencialmente: "Direito de imagem. *Topless* praticado em cenário público. Não se pode cometer o delírio de, em nome do direito de privacidade, estabelecer-se uma redoma protetora em torno de uma pessoa para torná-la imune de qualquer veiculação atinente a sua imagem. Se a demandante expõe sua imagem em cenário público, não é ilícita ou indevida sua reprodução pela imprensa, uma vez que a proteção à privacidade encontra limite na própria exposição realizada" (STJ, Ac. Unân., 4ª T., REsp. 595.600/SC, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 18.3.04, *DJU* 13.9.04, p. 259).

205. BELTRÃO, Sílvio Romero. *Direitos da personalidade*, op. cit., p. 31.

ao relativizar o direito à imagem, *independentemente do consentimento do titular*, em nome do interesse público (*rectius*, social). Veja-se:

> Art. 20, Código Civil:
>
> "Salvo se autorizadas, *ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública*, a divulgação de escritos,a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais".

Exemplo típico da mitigação da proteção à imagem pela preponderância do interesse público é o uso de imagem decorrente de investigação criminal, com a divulgação do retrato de um foragido em órgãos de imprensa e programas jornalísticos. Situação em que também sobrepuja o interesse coletivo é a utilização da imagem para fins históricos, como a construção de um monumento ou a veiculação em livros narrativos.

Outra hipótese bastante corriqueira de flexibilização da proteção da imagem é o exercício da liberdade de imprensa. Não é difícil encontrar situações nas quais a divulgação de informações ou escritos exige a veiculação da imagem alheia, a título jornalístico. Em tais casos, sobreleva uma *ponderação de interesses*, para, em cada caso, descobrir se prepondera o interesse social (na divulgação da imagem) ou se o fato não justifica o uso da imagem de terceiro. Como linha de orientação, é possível asseverar que somente se justifica a utilização da imagem de terceiro *quando se tratar de notícia ou fato de grande interesse coletivo e social, autorizando a relativização da imagem do titular.*

Efetivamente, a veiculação da imagem de uma pessoa pode ser necessária à ordem pública ou à administração da justiça, bastando lembrar, para tanto, um programa jornalístico que veicula imagens de foragidos da justiça ou de procurados pela polícia. Em tais casos, há uma mitigação da proteção à imagem em nome do interesse coletivo, concretizando a chamada *função social da imagem*.[206]

Não há, portanto, como definir soluções apriorísticas. Se é certo e incontroverso que a imagem está constitucionalmente tutelada, não menos certo é que merecem proteção, também, outros valores, como a liberdade de imprensa e de pensamento e o acesso à informação, quando presente o interesse social. Nessa linha de reflexão, somente na análise de cada caso concreto é que se pode configurar o uso indevido da imagem, ou não, a partir de uma ponderação dos valores em colisão, atentando para a veracidade do fato divulgado, a licitude na obtenção da imagem, a inexistência de desvio de finalidade, a natureza do fato etc.

---

206. Nessa esteira, editou-se o Enunciado 279 da Jornada de Direito Civil: "A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se medidas que não restrinjam a divulgação de informações".

É certo que a proteção da imagem não poderá exceder manifestamente os limites estabelecidos pela finalidade social e pelo bem comum.

b.5) A relativização do direito à imagem das pessoas públicas (celebridades)

É certo e incontroverso que não existem direitos absolutos, devendo, mesmo os direitos fundamentais, serem compreendidos em conjunto com o sistema jurídico, em juízo de ponderação de interesses. O direito à imagem não foge dessa regra.

Em determinadas circunstâncias, impõe-se, como visto alhures, uma flexibilização do direito à imagem em razão de interesses públicos ou de colisão com outros bens jurídicos. É a chamada *função social da imagem.*

São casos nos quais a preponderância do interesse social supera, valorativamente, a proteção individual da imagem, justificando a sua mitigação e a captação e divulgação.

Na mesma linha de entendimento, a imagem das pessoas públicas, as chamadas celebridades (artistas, esportistas, políticos, modelos, personagens históricos...), também sofre flexibilização, porque a projeção de sua personalidade extrapola os seus limites individuais, espalhando-se no interesse de toda a coletividade. Não é crível, nem admissível, portanto, que um conhecido artista de televisão ou um governante pudesse reclamar dano pelo uso da imagem em jornais, revistas, televisão etc. Máxime considerando o caráter jornalístico da utilização, no mais das vezes.

Serve como exemplo dessa mitigação da imagem das pessoas notórias, por conta de seu próprio ofício ou por uma opção de exposição midiática, o fato que envolveu a atriz e modelo *Juliana Paes*, em setembro de 2006, durante a divulgação de um produto de beleza na *Beauty Fair*, em São Paulo. Após um inofensivo rodopio, com um esvoaçante e exuberante vestido, a atriz foi flagrada sem calcinha.[207] Em casos tais, por óbvio, não há direito indenizatório, uma vez que a exposição da imagem de pessoa pública decorreu de sua própria opção midiática.

Comungando com esse entendimento, Paulo José da Costa Júnior esclarece que, de fato, o âmbito dos direitos da personalidade das pessoas notórias "haverá que reduzir-se, de forma sensível. E isto porque, no tocante às pessoas célebres, a coletividade tem maior interesse em conhecer-lhes a vida íntima, as reações que experimentam e as peculiaridades que oferecem".[208]

Não se imagine, porém, que as celebridades (mesmo a mais bela e midiática de todas) percam a proteção constitucional de sua imagem. Conservam, é claro, o direito (constitucionalmente assegurado) à imagem, apenas sofrendo uma flexibilização, *quando houver legítimo interesse na sua divulgação*, por força de seu ofício, profissão ou situação em que se encontre.

207. SCHREIBER, Anderson. "Os direitos da personalidade no Código Civil de 2002", op. cit., p. 232.
208. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. *O direito de estar só*, op. cit., p. 36-37.

Até mesmo porque as celebridades não podem ser consideradas *pessoas públicas durante todo o tempo*. Públicos serão determinados fatos ou acontecimentos que as envolvem, justificando estes a mitigação de sua imagem.

Endossando o argumento, Anderson Schreiber é preciso: "Públicos não são quaisquer episódios sobre os quais os leitores de jornais e revistas, os espectadores de TV, ou os internautas possam ter interesse. Público, no que concerne a atos envolvendo a imagem das pessoas, é apenas o evento sobre o qual recaia o interesse legítimo da informação".[209] De idêntica maneira, a jurisprudência vai acatando esse entendimento.[210]

Por isso, é possível que as pessoas públicas, eventualmente, sofram violação à sua imagem, com a utilização fora dos padrões sociais admitidos (como no exemplo da publicação, sem autorização, em um jornal da fotografia de uma famosa artista de televisão nua, tirada para integrar o ensaio para uma revista especializada[211]) ou fora do contexto jornalístico ou noticioso[212] (como na hipótese de uso da fotografia de um artista para fins de publicidade de determinado produto ou serviço).[213] Em célebre caso, de grande repercussão na França, o então Presidente *Georges Pompidou* teve uma fotografia sua veiculada pelo jornal *L'Express*, a bordo de um barco equipado com motor *Mercury*, na qual aparecia, com nitidez, a marca da empresa. Tempos depois, surgiu uma campanha publicitária da referida empresa, contendo a citada fotografia do presidente, com o texto "se durante dez anos nos esforçamos em ganhar todas as competições, o fazemos por sua segurança, Sr. Presidente". Promovida a ação reparatória por dano à imagem pelo Chefe do Executivo, alegou-se não ter ocorrido violação intolerável ao direito de imagem da pessoa. Entretanto,

209. SCHREIBER, Anderson. "Os direitos da personalidade no Código Civil de 2002", op. cit., p. 249-250.

210. "Ação indenizatória por danos morais. Existência de ilícito. Comprovação do dano e obrigação de indenizar. Pessoa pública. Artista de televisão. Limitação ao direito de imagem[...] Ator de TV, casado, fotografado em local aberto, sem autorização, beijando mulher que não era sua cônjuge. Publicação em diversas edições de revista de 'fofocas'; [...] Por ser ator de televisão que participou de inúmeras novelas (pessoa pública e/ou notória) e estar em local aberto (estacionamento de veículos), o recorrido possui direito de imagem mais restrito, mas não afastado. Na espécie, restou caracterizada a abusividade do uso da imagem do recorrido na reportagem, realizado com nítido propósito de incrementar as vendas da publicação. A simples publicação da revista atinge a imagem do recorrido, artista conhecido, até porque a fotografia o retrata beijando mulher que não era sua cônjuge" (STJ, Ac. 3ª T., REsp. 1.082.878/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.10.08, *DJU* 18.11.08).

211. "A publicação de imagem sem a exclusividade necessária ou em produto jornalístico que não é próprio para o contexto, acarreta a depreciação da imagem e, em razão de tal depreciação, a proprietária da imagem experimenta dor e sofrimento" (STJ, Ac. 3ª T., REsp. 270.730/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.00, *DJU* 7.5.01, p. 139).

212. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal admitiu a violação ao direito de imagem por um partido político que veiculou imagem de artista em entrevista que foi dada supondo tratar-se de reportagem com conteúdo jornalístico (TJ/DF, Ap. Cív. 4689997, *DJ* 15.4.1998, p. 59).

213. "Constitui ato ilícito, passível de reparação por transgressão ao direito de imagem, a publicação não autorizada de fotos de renomado ator de televisão em catálogo promocional de empresa de vestuário, mormente se ocorrida com a intenção de explorar e usufruir vantagem, ainda que tal divulgação não tenha sido desprestigiosa" (TJ/SP, Ac. 6ª Câm. Direito Privado, Ap. Cív. 91.030.4/2, rel. Des. Testa Marchi, j. 11.5.00, *RT* 782: 236).

a corte francesa reconheceu o dano à imagem, proibindo a veiculação do anúncio, deixando claro o desvio de utilização da imagem da pessoa pública.[214] Frise-se, à exaustão, que utilizada, indevidamente, a imagem de qualquer celebridade, o dever de reparar o dano decorrerá independentemente da prova do dano econômico, como reza a Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça.[215]Além disso, também é possível a violação do direito à privacidade das pessoas públicas quando se penetrar no refúgio íntimo da personalidade, o que ocorre no exemplo dos *papparazzis*, como ficaram conhecidos os fotógrafos e repórteres que perseguem as celebridades em busca de poses comprometedoras ou incomuns.

b.6) A possibilidade de responsabilização civil das celebridades que participam de publicidade ilícita

É bastante comum a participação de celebridades em campanhas publicitárias, influenciando, diretamente, o consumidor. São pessoas famosas que se utilizam do prestígio e credibilidade junto ao público para exercer influência sobre a escolha de produtos ou serviços, atestando as suas qualidades através da veiculação de sua imagem.

Às pessoas famosas associa o imaginário popular qualidades e características que compõem a sua imagem-atributo,[216] realçando a sua credibilidade. Ora, se a celebridade utiliza-se de sua imagem (que é protegida constitucionalmente) para transmitir confiança e segurança em determinado produto ou serviço, através do *marketing*, induzindo o consumidor, é natural que responda por eventuais danos ocasionados pelo produto quando endossar, ratificar, as suas vantagens.

Ilustrando a hipótese, a doutrina menciona a associação da imagem da atriz Maitê Proença ao anticoncepcional "Microvilar", que, por acidente de consumo em sua linha de produção, veio a ser comercializado com farinha em seu conteúdo, em lugar do medicamento.

Com mais contundência, Paulo Jorge Scartezzini Guimarães advoga a tese de que a celebridade assume, "diante do consumidor, uma posição de 'garante'".[217]

c) O direito à vida privada

É dificílima a delimitação do direito à vida privada, em razão da diferença cultural, das tradições e dos costumes entre os povos: se, por um lado, em um determinado país, certos comportamentos podem ser reputados ofensivos à vida privada, noutros países, o mesmo comportamento pode ser tolerado como normal.[218]

214. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. *O direito de estar só*, op. cit., p. 72.
215. Súmula 403, Superior Tribunal de Justiça: "Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais".
216. COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Civil*, op. cit., p. 209.
217. GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. *A publicidade ilícita e a responsabilidade civil das celebridades que dela participam*, op. cit., p. 155.
218. SZANIAWSKI, Elimar. *Direitos de personalidade e sua tutela*, op. cit., p. 119.

Bastaria imaginar a repulsa que causaria em alguns lugares o uso de ro (mínimas) de praia, o que, paradoxalmente, se mostra comum nos países tropic

Em linhas gerais, então, a *vida privada* é o refúgio impenetrável pela coletivid merecendo proteção. Ou seja, é o direito de viver a sua própria vida em isolame não sendo submetido à publicidade que não provocou, nem desejou. Consiste direito de obstar que a atividade de terceiro venha a conhecer, descobrir ou di gar as particularidades de uma pessoa. Exemplo de violação à vida privada pode apresentado com a quebra do segredo de correspondência ou com a violação inde do sigilo bancário, fiscal e telefônico.

Já se pode notar, assim, que o direito à vida privada é plástico, dinâmico, riando conforme a cultura e os valores de um lugar para outro. As suas latitud longitudes dependem, naturalmente, da compreensão de mundo e de vida de cada lu

No Brasil, a proteção da vida privada, como um bem jurídico integrante da sonalidade, funda-se no legítimo interesse de salvaguardar do conhecimento al (e da curiosidade indevida) tudo o que diz respeito à esfera íntima de uma pes A Constituição Federal, em seu art. 5º, tutelou a vida privada de modo genérico incisos V e X, mas também nos incisos XI, XII e LX de maneira mais direta.

Trata-se, pois, da vida pessoal do ser humano, perpassando de um asp interior ("que se leva quando vive detrás da sua porta fechada"),[219] incluindo as tos amoroso, sexual, religioso, familiar, sentimental de uma pessoa, até um asp externo, muito mais amplo. É que o direito à vida privada transcende o direit *estar só*. Não que esse aspecto lhe seja estranho, mas porque é mais do que is

Em verdade, o direito à privacidade se apresenta, também, como útil instrum para realizar a dignidade humana em perspectiva social e econômica. Assim, func como mecanismo de proteção da pessoa humana contra violências perpetradas à esfera individual no ambiente de trabalho, em hospitais e clínicas, em manicô e clínicas psiquiátricas, em escolas e estabelecimentos educacionais, em ban em estabelecimentos comerciais, em sistemas públicos prisionais etc. Não se p negligenciar, pois, uma dimensão coletiva da proteção da vida privada, rompe esquemas de opressão ao mais fraco imposta pelo detentor do poder econôm social ou político – ou mesmo de uma situação de vantagem. Com isso, há d coibir o procedimento agressivo e atentatório à privacidade de empresas que nego (emprestam, vendem...) bancos de dados de seus clientes a terceiros, causando- inescondível dano indenizável.

Reconhecendo essa emersão de um momento coletivo de proteção da privacid Stefano Rodotá, em obra pioneira, observa que, de discurso fechado, a privaci se projeta sobre a coletividade, recuperando sua carga vital e assumindo feições, então, desconhecidas.[220] No ponto, é conveniente lembrar que a tutela da privacid

219. A expressão é de Lucien Martin, apudSILVA, Edson Ferreira da. *Direito à intimidade*, op. cit., p. 52.
220. RODOTÁ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*, op. cit., p. 32.

nessa projeção coletiva, incumbe ao Ministério Público, a quem se conferiu a defesa dos interesses transindividuais (CF, art. 127).

Uma necessária perspectiva histórica e social do direito à privacidade gera, naturalmente, diferentes percepções dessa garantia constitucional. Assim, em épocas atuais, chama a atenção o fato de que as redes sociais da *Internet*, como, por exemplo, o *facebook* e o *twitter*, podem aviltar a privacidade alheia, independentemente da vontade do titular. Isso porque, afora as declarações espontâneas do interessado, o fluxo de informações pessoais da rede "contribui para a perda de privacidade", até porque a arquitetura da *web* forma "um sistema que, de jeito nenhum, foi projetado para proteger informações particulares", consoante a pertinente advertência de Carlos Alberto Goulart Ferreira.[221]

Sob o ponto de vista estrutural, *estão contidos no direito à vida privada, o direito à intimidade e o direito ao segredo (sigilo)*, compondo diferentes aspectos de um mesmo bem jurídico personalíssimo. É bem verdade que há certo dissenso terminológico, com parcela da doutrina optando por denominar o direito ao segredo como o direito à privacidade – o que termina por gerar uma espécie de jogo de palavras, pouco vantajoso didaticamente. Opta-se, assim, por prestigiar a cátedra de Gilberto Haddad Jabur, esclarecendo que "o direito à vida privada posiciona-se como gênero ao qual pertencem o direito à intimidade e o direito ao segredo. A vida privada é esfera que concentra, em escala decrescente, outros direitos relativos à restrição de vida pessoal de cada um".[222]

Destrinchando essa estruturação, nota-se que o direito à intimidade consiste em resguardar dos sentidos alheios as informações que dizem respeito, apenas, ao titular, ao passo que o direito ao segredo é fundado na não divulgação de fatos da vida de alguém. Eventualmente, o segredo pode tocar o interesse da coletividade ou do Estado, podendo ser flexibilizado, quando houver justa motivação. Isto é, pode ser mitigado o direito ao segredo quando um valor jurídico for mais denso, em ponderação de interesses.[223] A intimidade, ao revés, jamais manterá correlação com terceiros, sempre se enfeixando na personalidade do seu titular. Isso porque o direito à intimidade consiste "no fato de a pessoa viver uma parte de sua existência longe da interferência ou da influência de terceiros",[224] como esclarece Carlos Alberto Goulart Ferreira. E, convenhamos, na sociedade hipercomplexa, com altos níveis de exposição social, *a intimidade é um direito fundamental*, o direito ao recato, o direito de estar só e de preservar a si mesmo. Em sendo assim, a orientação sexual

221. FERREIRA, Carlos Alberto Goulart. *Espaço jurídico vazio e a tutela da intimidade*, op. cit., p. 423.
222. JABUR, Gilberto Haddad. *Liberdade de pensamento e direito à vida privada*, op. cit., p. 256.
223. É o que pensa a nossa jurisprudência: "Conquanto possível a quebra do sigilo fiscal de pessoa física ou jurídica no curso do processo, em homenagem ao preponderante interesse público, *constitui requisito essencial à higidez do ato judicial que a determina achar-se amparado em fundamentação consistente, por se cuidar de medida excepcional à regra geral da preservação da privacidade*, preconizada no art. 5º, X, da Carta Política" (STJ, Ac. Unân., 4ª T., REsp. 1.220.307/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 17.3.11, *DJe* 23.3.11).
224. FERREIRA, Carlos Alberto Goulart. *Espaço jurídico vazio e a tutela da intimidade*, op. cit., p. 457.

e religiosa estão compreendidas no âmbito da *intimidade*, enquanto a movimentação bancária e a declaração de tributos residem no âmbito do *segredo*.

Por isso, é possível concluir que *nem toda informação privada é íntima, embora toda intimidade seja privada*.

De qualquer sorte, considerada a autonomia conceitual da privacidade, repise-se a perfeita possibilidade de violação do direito à vida privada independentemente de resvalo à imagem ou à honra (boa fama) do titular. É que a intangibilidade da privacidade (decorrente de garantia constitucional e da redação do art. 21 do Código Civil) impõe proteção específica. Assim, é possível afrontar a privacidade de uma pessoa sem qualquer violação de sua honra ou de sua imagem. Acolhendo essa orientação, há interessante precedente jurisprudencial, tratando da inserção indevida, por uma companhia de telecomunicações, do nome da assinante nas páginas amarelas da lista telefônica, na seção de massagistas, apesar de ninguém, de seu ciclo social, ter tido conhecimento. Veja-se a pertinência dos argumentos do *decisum*:

> "Responsabilidade civil. Dano moral. Violação. Direitos da personalidade. Intimidade. Veiculação. Lista telefônica. Anúncio comercial equivocado. Serviços de massagem. 1. A conduta da prestadora de serviços telefônicos caracterizada pela veiculação não autorizada e equivocada de anúncio comercial na seção de serviços de massagens viola a intimidade da pessoa humana ao publicar telefone e endereços residenciais" (STJ, Ac. Unân., 4ª T., REsp. 506.437/SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 16.9.03).

Noutra oportunidade, a Corte Superior reconheceu a violação da privacidade por conta da afirmação contida em uma biografia de que o saudoso jogador de futebol *Garrincha* teria um órgão genital avantajado. Apesar da inexistência de afronta à imagem ou à honra, foi reconhecida a violação de sua privacidade e determinada a reparação do dano (STJ, REsp. 521.697/RJ, rel. Min. César Ásfor Rocha, j. 16.2.06, *DJU* 20.3.06, p. 276).

A outro giro, se a violação atinge, a um só tempo, a privacidade do titular e algum outro bem jurídico (como a honra ou a imagem), haverá uma dupla ilicitude e, por conseguinte, serão devidas tantas indenizações quantos sejam os bens jurídicos violados. Isso exatamente por conta da *autonomia do direito à privacidade*.

Merece registro o fato de que o próprio titular da personalidade pode, expressa ou tacitamente, relativizar a sua vida privada. É o exemplo comum das redes sociais, ambientes nos quais as pessoas, voluntariamente, expõem fatos íntimos ou secretos. Também seria a hipótese de uma entrevista jornalística em que o entrevistado, provocado ou não, revela sua intimidade. Em casos tais, o próprio titular conferiu publicidade ao fato, não havendo qualquer violação. Não poderá, contudo, envolver terceiros que, eventualmente, tenham interesse no fato, como na hipótese de relacionamentos afetivos ou sexuais. Envolvendo interesse de terceiro, haverá afronta à privacidade alheia e, consequentemente, direito à indenização.

No que tange ao direito à vida privada das pessoas públicas (celebridades), contrariamente ao que ocorre com o direito à imagem, não há uma relativização tão intensa da proteção dedicada pelo sistema. Se é certo, por um lado, que a privacidade das pessoas notórias se sujeita a um parâmetro de aferição "menos rígido do que os de vida estritamente privada. Isso decorre, naturalmente, da necessidade de autoexposição, de promoção pessoal ou do interesse público na transparência de determinadas condutas", como percebe Luís Roberto Barroso.[225] De outra banda, não menos certo é que isso não quer significar que as celebridades percam a proteção de sua privacidade. Em absoluto. O direito à vida privada lhes é garantido constitucionalmente e tem de ser tutelado. Apenas deve se ponderar a extensão do que se deve proteger da curiosidade do público em geral, no que toca às pessoas públicas.

Para além da flexibilização da privacidade das pessoas públicas, uma vez que o seu ofício ou profissão exige um certo volume de exposição de sua personalidade, como ocorre com um jogador de futebol ou um artista, é de se perceber que decorre da própria liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa, asseguradas constitucionalmente, a possibilidade de publicação de biografias, mesmo que não tenham sido autorizadas pelo biografado, ou pelos seus sucessores, se já falecido, no caso de uma biografia póstuma. A falta de anuência não se apresenta como um empecilho, em face da liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 4815/DF, inclusive determinou que se promovesse interpretação conforme a Constituição dos arts. 20 e 21 do Código Civil para:

> "Em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas)". (STF, Ac. unân. Tribunal Pleno, ADIn 4815/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.6.15)

De qualquer maneira, se a publicação de biografia não autorizada contiver violações à honra, imagem ou vida privada do biografado, ou de terceiros, responsabilizar-se-á civil e penalmente o autor da biografia, como cimentado pela aludida decisão da Corte Suprema ao *"reafirmar o direito à inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa, nos termos do inc. X do art. 5º da Constituição da República, cuja transgressão haverá de se reparar mediante indenização."*

Não se pense, entrementes, que uma celebridade sofre uma absoluta supressão de seu direito à vida privada. Apenas ocorre uma mitigação, relativização, por conta da exposição exigida pelo seu ofício ou profissão, sem uma perda completa. Por isso, a invasão de sua vida privada, em aspectos que não digam respeito à sua atividade profissional, ensejará a necessidade de proteção. A solução, sempre, dependerá de uma

225. BARROSO, Luís Roberto. "Liberdade expressão *versus* direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação", op. cit., p. 111.

avaliação do caso concreto, para se fixar as latitudes e longitudes dos fatos expostos e da atividade exercida pela pessoa pública. Demonstrando que uma pessoa notória mantém a proteção de sua privacidade, em certo nível, há um interessante caso, envolvendo a revelação de fatos secretos que respeitavam aos *affaires* amorosos de *Benito Mussolini* divulgados em um filme, teve um desfecho jurisprudencial protegendo a vida privada do ditador italiano: "Nem mesmo a pesquisa e a crítica histórica consentem o sacrifício do direito à intimidade, ainda que se trate de pessoas pertencentes à vida pública de um país, devendo-se respeitar o segredo de sua vida íntima".[226] Todavia, em outro caso com outros dados concretos, a solução pode não ser a mesma. Por isso, em demanda na qual se discutia se uma peça de teatro – que retratava a vida pessoal de personagens da História do Brasil (*Olga Benário* e *Luiz Carlos Prestes*) – feria, ou não, a privacidade de terceiros, entendeu a Corte de Justiça fluminense: "Tampouco se reconhece violação à privacidade, uma vez que os fatos mostrados são do conhecimento geral, ou pelo menos acessíveis a todos os interessados, por outros meios não excepcionais, como a leitura de livro para cuja redação ministrara informações o próprio titular do direito que se alega lesado" (TJ/RJ, Ap. Cív. 1988.001.03920, Rel. Des. Barbosa Moreira, j. 3.4.89).[227]

Igualmente relevante é a lembrança da inadmissibilidade da exceção da verdade em relação ao direito à privacidade. Com efeito, permitir que alguém prove que o fato (indevidamente propalado) é verdadeiro significa violar, novamente, a privacidade do titular. Por isso, em interessante passagem, reconheceu a melhor jurisprudência que "os fatos depressivos da vida estritamente privada do cidadão não devem ser propalados, ainda que verdadeiros, justamente porque, faltando interesse público não serviriam a outro propósito que o do escândalo e do desdouro".[228]

Caracterizado como um direito fundamental de matriz constitucional, a privacidade (intimidade e segredo) espraia relevantes consequências em outras áreas da ciência jurídica, vinculando determinadas situações.

No âmbito dos Direitos Reais, por exemplo, o amplo espectro de proteção da vida privada, resguardando os aspectos mais íntimos da pessoa humana, resulta na imposição de limitações ao direito de construir, impedindo, em qualquer situação que se abram janelas ou se façam eirados, terraços ou varandas a menos de um metro e meio do terreno vizinho,[229] bem como obstando a realização, na zona rural, de construções ou acréscimos a menos de três metros[230] do limite comum com o vizinho

226. JABUR, Gilberto Haddad. *Liberdade de pensamento e direito à vida privada*, op. cit., p. 256.

227. BARROSO, Luís Roberto. "Liberdade expressão *versus* direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação", op. cit., p. 112.

228. STJ, Ac. 4ª T., REsp. 58.101/SP, rel. Min. César Asfor Rocha, j. 16.9.97, *RSTJ* 104:326.

229. Art. 1.301, Código Civil: "É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. § 1º As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros. § 2º As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso".

230. Art. 1.303, Código Civil: "Na zona rural, não será permitido levantar edificações a menos de três metros do terreno vizinho".

Noutra perspectiva, no âmbito empresarial, já se prospecta o resguarde de informações privadas acerca de suas relações existenciais (como crença religiosa e orientação sexual) e, em certas situações, de sua remuneração. Ermiro Ferreira Neto, inclusive, advoga a necessidade de estabelecer limites às "exigências de transparência" nas empresas de capital aberto: "embora a transparência seja exigida no âmbito do mercado de capitais, tal circunstância não retira dos órgãos reguladores a responsabilidade pela adoção de travas que impeçam um avanço desmedido sobre a vida privada". Por isso, sustenta a possibilidade de se acobertar com o manto da privacidade informações relativas à remuneração de dirigentes de tais empresas.[231]

Já na esfera do Direito do Trabalho, dúvida inexiste de que a convivência no ambiente de trabalho implicará em uma ligeira mitigação da privacidade do trabalhador. Todavia, não é possível tolerar condutas do empregador que aniquilem a privacidade ou afrontem a dignidade do obreiro. Nessa trilha, a tutela jurídica constitucional da privacidade implica em reconhecer como abusivas algumas revistas íntimas em trabalhadores, promovidas por algumas empresas. Até porque, como pondera Floriano Barbosa Júnior, "o direito ao trabalho como direito humano de natureza social, atrai, como corolário, o direito à proteção da intimidade do trabalhador".[232] De fato, obrigar o empregado a expor partes íntimas de seu corpo é desarrazoado e atenta contra as suas garantias fundamentais.[233] E não se diga que, ao aceitar o emprego, o obreiro anuiu a essa situação porque, a toda evidência, a necessidade de ter um trabalho, em um país com tantas dificuldades como o nosso, impõe aceitar as imposições que vierem acessoriamente.[234] A jurisprudência trabalhista, inclusive, acata esse entendimento:

> "Revista íntima. A inserção do empregado no ambiente de trabalho não lhe retira os direitos da personalidade, dos quais o direito à intimidade constitui uma espécie. É certo que o empregado, ao ser submetido ao poder diretivo do empregador, sofre algumas limitações em seu direito à intimidade. Não se admite, contudo, que a ação do empregador se amplie a ponto de ferir a dignidade da pessoa humana. Caracteriza dano moral a circunstância de a empregadora ter convocado um reunião, para discutir com suas empregadas, questão relacionada à higiene dos sanitários utilizados no ambiente de trabalho, deixando o local antes do encerramento, quando então, por deliberação das próprias trabalhadoras, foi iniciada uma revista íntima de todas as presentes, com a anuência e participação das encarregadas, a fim de verificar quais empregadas se encontravam em período menstrual. O episódio evidenciou

231. FERREIRA NETO, Ermiro. *Privacidade e divulgação de remuneração no mercado de capitais*, op. cit., p. 135.
232. BARBOSA JÚNIOR, Floriano. *Direito à intimidade*:direito fundamental e humano na relação de emprego, op. cit., p. 110.
233. A própria Consolidação das Leis do Trabalho, no seu art. 373-A, inciso VI, em capítulo dedicado ao trabalho da mulher, proíbe a realização de revistas íntimas: "Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: [...] VI – proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias".
234. Indo mais longe, Edílton Meireles acrescenta que "essas mesmas conclusões se aplicam, ainda, à revista de natureza domiciliar ou sobre objetos e bens do empregado (veículos, bolsas etc.)" (*O novo Código Civil e o Direito do Trabalho*, op. cit., p. 19).

> afronta à intimidade das trabalhadoras, atraindo a obrigação de indenizar o dano moral perpetrado pela empresa" (TRT-3ª Região/MG, Ac. 2ª T., RO 6177/03 (1330-2002-039-03-00-5), Rel. Des. Fernando Guimarães A. Viegas Peixoto, *DJMG* 2.7.03, p. 13).

Não significa, porém, que toda e qualquer revista pessoal será ilícita. Se utilizada com *razoabilidade*, em atividades laborativas nas quais há riscos de subtração de produtos da empresa e sem afrontar a dignidade do trabalhador, a revista pessoal pode ser admitida.[235]

Outrossim, afronta a personalidade humana por violar a vida privada, a submissão do trabalhador a testes pré-admissionais e provas grafológicas em que tenha de revelar aspectos de sua intimidade, como aqueles ligados à sua sexualidade, ao uso de substâncias entorpecentes, doenças na família ou outras opções pessoais. Por isso, gera dano indenizável a simples submissão do empregado (ou mesmo do candidato ao emprego) ao teste de polígrafo (detector de mentiras ou *lie-detector*).[236]

Ainda na seara da privacidade do trabalhador, uma questão altamente polêmica diz respeito à possibilidade, ou não, de fiscalização do empregador do *e-mail corporativo* de seu empregado. Em linha de princípio, salvo uma ponderação mais robusta, não nos parece razoável permitir à empresa invadir a privacidade de seu empregado, tendo acesso ao que é escrito. Em especial, quando o empregador não permite ao seu obreiro o acesso ao *e-mail* particular, obrigando à utilização do *e-mail* corporativo. Parece que é prestigiar mais o patrimônio do que a personalidade. O ter, em lugar do ser. Aliás, bem reflete, sobre o tema, o emérito civilista italiano Stefano Rodotá considerando que "parece objetivamente atrasada a análise de quem se limita a sublinhar a existência de restrições materiais que impedem, a numerosos sujeitos, de usufruir da privacidade: uma análise deste tipo apenas espelha a postura da invocaçã

---

235. O entendimento pretoriano vai se fixando assim: "Dano moral. Afronta à honra e à imagem do empregad Não ocorrência. Reparação indevida. A revista feita diariamente na bolsa dos empregados e a instalação d câmeras nas dependências da empresa não evidenciam constrangimento capaz de afetar a honra e a bo fama deles, quando demonstrado que a revista era usual e abrangia todos os empregados e a implant ção de câmeras visava à segurança da empresa" (TRT – 12ª Região/SC, Ac. 3ª T., RO 4713.2005.050.12.00- Ac.17469/06, Rel. Desa. Lília Leonor Abreu, *DJ* 13.12.06, p. 11).

236. A jurisprudência já abraçou esse entendimento: "Dano moral. Teste do polígrafo (detector de mentira Direito à honra e à intimidade do trabalhador. O trabalhador, ao ingressar em uma empresa na qualidad de empregado, não se despe dos direitos e garantias fundamentais asseguradas pela Constituição República a todos os cidadãos, dentre os quais figura com destaque a inviolabilidade de sua intimidad de sua honra e de sua imagem (art. 5º, inciso X, do Texto Fundamental). Se é verdade que o empregad detém poderes de direção, fiscalização e disciplinamento em relação àqueles que lhe prestam serviç não menos certo que o exercício desse direito potestativo encontra limite em tais direitos e garant constitucionais. Quando o empregador obriga o seu empregado a se submeter ao teste do polígra equipamento de eficácia duvidosa e não adotado no ordenamento jurídico pátrio, extrapola os limi de atuação de seu poder diretivo e atinge a dignidade desse trabalhador, expondo a honra e intimida deste e submetendo-o a um constrangimento injustificado, apto a ensejar a reparação pelos danos mor causados" (TRT – 3ª Região/MG, Ac. 5ª T., RO 317-2003-092-03-00-9, Rel. Des. José Roberto Freire Pimen *DJMG* 5.6.04, p. 14).

abstrata da intangibilidade da esfera privada".[237] Contudo, a jurisprudência trabalhista vem se fixando em sentido inverso.[238-239]

d) O direito à honra

Enquanto a imagem diz respeito às características identificadoras de uma pessoa e a privacidade ao interesse de preservar do público a esfera íntima de atitudes, o direito à honra concerne ao prestígio social do seu titular.[240] Ou seja, apesar da estreita ligação com a privacidade, a honra com ela não se confunde. Se, de um lado, aquela resguarda o que, concreta e verdadeiramente, compõe a intimidade, de outra banda, esta protege a pessoa humana contra ataques que podem macular sua boa fama social.

Em sendo assim, a soma dos conceitos positivos que cada pessoa goza na vida em sociedade tem como resultado o que se convencionou chamar de honra. Noutras palavras, o direito à honra "tem pertinência com a *projeção social da respeitabilidade e estima conquistada* pelo indivíduo no seu ambiente e na sociedade".[241]

Trata-se da necessária defesa da reputação da pessoa, abrangendo o seu bom nome e a fama que desfruta na comunidade (seio social, familiar, profissional, empresarial...), bem como a proteção do seu sentimento interno de autoestima.[242]

---

237. RODOTÁ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância*, op. cit., p. 30-31.

238. "Prova ilícita. *E-mail* corporativo. Justa causa. Divulgação de material pornográfico. Os sacrossantos direitos do cidadão à privacidade e ao sigilo da correspondência, constitucionalmente assegurados, concernem à comunicação estritamente pessoal, ainda que virtual (*e-mail* particular). Assim, apenas o *e-mail* pessoal ou particular do empregado, socorrendo-se de provedor próprio, desfruta da proteção constitucional e legal da inviolabilidade. Solução diversa impõe-se em se tratando do chamado *e-mail* corporativo, instrumento de comunicação virtual mediante o qual o empregado louva-se de terminal de computador e de provedor da empresa, bem assim do próprio endereço eletrônico que lhe é disponibilizado pela empresa. Destina-se este a que nele trafeguem mensagens de cunho estritamente profissional. Em princípio, é de uso corporativo, salvo consentimento do empregador" (TST, Ac. 1ª T., RR 613/2000-013-10-00, rel. Min. João Oreste Dalazen, *DJU* 10.6.05).

239. Considerando que a jurisprudência vem admitindo o monitoramento do *e-mail* corporativo do trabalhador, Mauro Schiavi propõe a adoção de algumas cautelas, essenciais à preservação de sua dignidade, evitando uma afronta maior à sua personalidade. Afirma o magistrado: "Quando há monitoração, pelo empregador, do *e-mail* corporativo utilizado pelo empregado, devem ser tomadas algumas cautelas, pois o empregador não tem o direito irrestrito de monitoramento[...] De outro lado, em algumas hipóteses, a nosso ver, é possível esse monitoramento desde que presentes alguns requisitos, que passamos a elencar: a) fundada suspeita de utilização indevida do *e-mail* pelo empregado; b) indícios suficientes de que o empregado está desvirtuando a utilização do *e-mail*;c) que seja extremamente necessário, não havendo possibilidade de se provar o fato por outros meios; d) razoabilidade e boa-fé por parte do empregador" (*Ações de reparação por danos morais decorrentes da relação de trabalho*, op. cit., p. 103-104).

240. Elimar Szaniawski também distingue um do outro, aduzindo que, enquanto a vida privada resguarda a pessoa da ingerência alheia, "o direito à honra visa à proteção do valor moral e íntimo do homem, como a estima dos outros, ou a consideração social, o bom nome ou a boa fama" (*Direitos de personalidade e sua tutela*, op. cit., p. 129).

241. ALMEIDA, Luiz Antonio Freitas de. "Violação do direito à honra no mundo virtual: a (ir)reponsabilidade civil dos prestadores de serviços da *internet* por fato de terceiros", op. cit., p. 247.

242. Vide,a respeito: Bittar. *Os direitos da personalidade*, op. cit., p. 129. Com digressão semelhante, Adriano de Cupis pondera que, reconhecida como valor íntimo moral do homem, a honra constitui um "pressuposto indispensável para que ela possa progredir no meio social e conquistar um lugar adequado; e, por sua vez,

Vale notar que a extensão do direito à honra é ampla. E, por isso, prot titular contra fatos inverídicos desabonadores de sua personalidade em pr social e pessoal e, igualmente, contra fatos que, embora verdadeiros, não p ser demonstrados. Para além disso, consegue tutelar a pessoa, ainda, valo depreciativas acerca de sua personalidade.

Exatamente por conta dessa elasticidade estrutural, a honra pode ser marti de maneira direta (frontal) ou indireta (dissimulada), consistindo no abalo do co do titular na família, no trabalho, nas atividades estudantis etc. (daí se falar em política, artística, civil, científica etc.), produzindo um dano moral reparável. R D. Rabinovich-Berkman, renomado civilista argentino, aduz que a honra pode s sionada pela interferência no conceito que a vítima possui perante os outros, q alguém apresenta dados errôneos, provocando uma modificação da fama constru

Aliás, na clássica lição de Adriano de Cupis, já se percebia que "a honra sig tanto o valor moral íntimo do homem, como a estima dos outros, ou a conside social, o bom nome ou a boa fama, como, enfim, o sentimento, ou consciênc própria dignidade pessoal".[244]

Disso deflui, portanto, que a honra encerra dois diferentes aspectos: a *objetiva* e a *honra subjetiva*. Aquela (a objetiva) diz respeito à reputação que t ros (a coletividade) dedicam a alguém. É a chamada reputação.[245] Esta (subj tangencia o próprio juízo valorativo que determinada pessoa faz de si mesma autoestima, o sentimento de valorização pessoal, que toca a cada um.

Em resumo: a honra objetiva é o conceito externo, o que os outros pensa uma pessoa; a honra subjetiva é a sua estima pessoal, o que ela pensa de si próp

Admite-se a violação tanto da honra objetiva, quanto da subjetiva, propici em ambas as hipóteses, reparação por dano moral. Nesse passo, já reconheceu a m jurisprudência que é possível concretizar-se um dano à pessoa independenten da conotação média da moral social, "posto que a honra subjetiva tem termôr próprio, inerente a cada indivíduo. É o decoro, é o sentimento de autoestim avaliação própria que possuem valoração individual, não se podendo negar est de acordo com sentimentos alheios" (STJ, Ac. 3ª T., REsp. 270.730/RJ, rel. Min. N Andrighi, j. 19.12.00, *DJU* 7.5.01, p. 139).

A reparação do dano à honra exige cuidado especialíssimo do magistrad que não se pode olvidar a repercussão da lesão sobre a fama do ofendido. As

---

o sentimento, ou consciência, da própria dignidade pessoal representa uma fonte de elevada sati espiritual" (*Os direitos da personalidade*, op. cit., p. 122).

243. RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo D.. *Derecho Civil*:Parte General, op. cit., p. 397.

244. CUPIS, Adriano de. *Os direitos da personalidade*, op. cit., p. 121.

245. Com o mesmo pensar, Carlos Alberto Ghersi. *Derecho Civil*:Parte General, op. cit., p. 246.

246. Assim, também, Fábio Ulhoa Coelho, para quem "a honra subjetiva (a estima que cada pessoa nut si mesma) e a objetiva (a reputação de que goza cada pessoa entre os seus conhecidos) não pode prejudicadas por opiniões ou narrativas de outras pessoas" (*Curso de Direito Civil*, op. cit., p. 205).

as condições econômicas e pessoais (culturais, inclusive) dos envolvidos (lesante e lesado), além da propagação social do dano, têm de ser sopesadas pelo juiz no arbitramento do *quantum* indenizatório. Até porque a indenização por dano moral tem natureza compensatória, não servindo para, efetivamente, reparar o prejuízo sofrido (afinal, aquele dano não tem preço). E exige-se equilíbrio no arbitramento do valor indenizatório: não pode ser leve a ponto de não servir de desestímulo ao lesante, nem robusta de modo a propiciar o enriquecimento sem causa da vítima.

Nessa tocada, o art. 953 do Código Civil alude à indenização por injúria, difamação ou calúnia, consistindo "na reparação do dano que delas resulte ao ofendido".

De fato, a vida em sociedade impõe limites, de ordem ética e jurídica, para que as pessoas não sejam molestadas em sua reputação, por conta da liberdade de expressão alheia.

No mundo contemporâneo, a proteção da honra vai ganhando dimensões alarmantes. O espaço da *Internet* é ambiente fértil para afrontas à reputação social de pessoas humanas. Um exemplo disso é a inserção de perfil correlacionando alguém a um *site* de prostituição. Nesses casos, malgrado não possa se imputar ao servidor de hospedagem o absurdo dever jurídico de fiscalizar todas as publicações que são feitas a todo tempo, é possível afirmar que, uma vez comunicado da prática ilícita, deve imediatamente atuar, retirando as veiculações, sob pena de responsabilidade civil.[247]

De qualquer modo, não caracteriza violação à honra, no entanto, a difusão de fato que diz respeito ao interesse público, como a apuração de fatos criminosos, quando verdadeiros. É a conhecida *exceptioveritatis* (exceção da verdade), permitindo que se prove a veracidade dos fatos alegados. Lado outro, sendo falsos os fatos imputados, caracteriza-se dano ao titular.

247. O Superior Tribunal de Justiça já deliberou sobre o tema, endossando a tese aqui defendida: "3. A fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das informações postadas na *web* por cada usuário *não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso*, nos termos do art. 14 do CDC, o *site* que não examina e filtra os dados e imagens nele inseridos. 4. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no *site* pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de conteúdo, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02. 5. *Ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor agir de forma enérgica, retirando o material do ar imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.* 6. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários externem livremente sua opinião, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada. Sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, deve este adotar as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a individualização dos usuários do *site*, sob pena de responsabilização subjetiva por culpa *in omittendo*. 7. Ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de conteúdo que registra o número de protocolo (IP) na *internet* dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de serviço de *internet*" (STJ, Ac. Unân., 3ª T., REsp. 1.186.616/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.8.11).

Na esfera penal, o atentado à honra pode caracterizar crime contra a honra, em uma de suas modalidades: calúnia, injúria e difamação (CP, arts. 138 a 140).

Também o Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Interamericana de Direitos Humanos), subscrito pelo Brasil e vigendo em nosso país, reconhece a proteção à honra, no art. 11, dispondo que "toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade".

4.11.6 Direito à integridade intelectual

a) Noções gerais

Os direitos da personalidade no âmbito intelectual destinam-se à proteção conferida ao elemento criativo, típico da inteligência humana. São as criações, as manifestações do intelecto, como a liberdade de pensamento e o direito ao invento, além do contundente exemplo do direito autoral (regulamentado pela Lei nº 9.610/98).

Trata-se de proteção jurídica às obras da inteligência do homem, garantindo ao autor o direito de livremente publicar, motivo pelo qual mereceu de Francisco Amaral o comentário de que no âmbito intelectual, os direitos da personalidade constituem "a proteção jurídica às obras de inteligência" da pessoa humana.[248]

As criações podem ser destinadas à transmissão de conhecimento (obras estéticas, como livros, DVD's...) ou à aplicação industrial (obras utilitárias, valendo exemplificar com as marcas industriais, os logotipos, os emblemas e marcas empresariais etc.). As primeiras (obras estéticas) são criações submetidas à Lei nº 9.610/98, denominada Lei de Direitos Autorais; as segundas (obras utilitárias) são regidas pela Lei nº 9.279/96, denominado Código de Propriedade Industrial.[249] Fixando a compreensão da matéria: enquanto a Lei de Direitos Autorais protege a criação intelectual, o Código de Propriedade Intelectual tutela o invento que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e com aplicação industrial (Lei nº 9.279/96, art. 8º).

Outras hipóteses de direitos da personalidade enquadrados no âmbito intelectual podem ser trazidas à baila: a proteção da liberdade religiosa e sexual e a liberdade de pensamento.

Também há de ser feita menção ao direito de arena, reconhecido aos esportistas por conta da transmissão pela imprensa de espetáculos e competições em que atuem.[250] É o caso das transmissões pela televisão de jogos de futebol, vôlei e basquete em canais de televisão abertos ou fechados.

---

248. AMARAL, Francisco. *Direito Civil*: introdução, op. cit., p. 269.
249. Sobre o tema, remeta-se à leitura da obra de Carlos Alberto Bittar. *Os direitos da personalidade*, op. cit., p. 139.
250. Defendendo essa ideia, Limongi França, apud JABUR, Gilberto Haddad. *Liberdade de pensamento e direito à vida privada*, op. cit., p. 105.

É importante registrar que os direitos da personalidade no âmbito intelectual são incorpóreos e, via de consequência, insusceptíveis de apreensão material. Assim, descabe a utilização dos interditos (ações) possessórios na defesa dos direitos da personalidade relacionados à integridade intelectual, como os direitos autorais, conforme entendimento cimentado na Súmula 228 do Superior Tribunal de Justiça.

A proteção de tais direitos se consubstanciará por meio de tutela preventiva (tutela específica – art. 497 do Código de Processo Civil de 2015) ou de ação de reparação de danos. Aliás, convém salientar a desnecessidade de prova do prejuízo para a indenização por violação a direito moral de autor, uma vez que o dano se considera ínsito na própria conduta lesiva (*in reipsa*).[251]

b) O direito autoral e a sua feição de direito da personalidade

b.1) Noções conceituais

O direito autoral (ou direito do autor) vem merecendo proteção pela ordem jurídica desde a Convenção de Berlim, de 1908,[252] tendo merecido, em nosso sistema jurídico, tutela em sede constitucional (CF/88, art. 5º, XXVII, XXVIII e XXIX), garantindo aos autores, em geral, o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Aliás, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura que "toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais que lhes correspondam em razão de produções científicas, literárias ou artísticas de que seja autora" (art. 27 da Lei nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais).

Sem dúvida, a importância do tema é evidente, pois o direito autoral está presente em todas as atividades e setores da vida em sociedade, seja em produções industriais, seja em criações artísticas e culturais. Até mesmo na *Internet* percebe-se a importância do seu estudo, exigindo-se que a proteção jurídica das obras intelectuais esteja adequada ao avanço tecnológico dos meios de comunicação.[253]

Consiste o direito autoral na proteção conferida às obras intelectuais pela originalidade ou criatividade de forma, independentemente do meio físico em que se encontre (livro, CDs, DVDs, vídeos, *Internet*...).[254] Enfim, é a tutela da criação intelectual.[255]

---

251. BITTAR, Carlos Alberto. *Contornos atuais do direito do autor*, op. cit., p. 233.

252. Registra-se, de qualquer modo, que, muito antes, na Inglaterra, o direito autoral já tinha sido reconhecido formalmente através do *Copyright Act* da Rainha Ana, em 1709. Antes ainda, em 1662, o *LicensingAct* vedou a impressão de livros que não estivessem licenciados regularmente, conferindo proteção às obras literárias.

253. Tratando da matéria, vídeo elucidativo texto de Renato M. S. OpiceBlum e Juliana Canha Abrusio. "Direito autoral eletrônico", op. cit., p. 289 ss.

254. Até mesmo a obra fotográfica está protegida em lei: "Publicação de obra fotográfica sem indicação do autor caracteriza violação ao direito autoral, sendo a indenização devida. Não resta dúvida de que a obra fotográfica do autor está sob o amparo da Lei, como também da CF, no seu art. 5º, XXVII" (TJ/SP, Ac. 1ª Câm. Cív., Ap. Cív. 199.429-1/0, Rel. Des. Guimarães de Souza, v. u., *RT* 710: 51). Do mesmo modo, o crítico de arte também goza de tutela jurídica: "Reprodução não autorizada de texto de autoria de crítico de arte em catálogo para exposição e venda de quadros constitui violação de direito autoral e sujeita o infrator a pagamento de indenização" (TJ/RJ, Ac. Unân., 5ª Câm. Cív., Ap. Cív. 3277, Rel. Des. Narcizo Pinto, *DOERJ* 19.1.89).

255. Em sentido aproximado, Carlos Alberto Bittar enxerga o Direito Autoral como o ramo do Direito Privado que regula as relações advindas "da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e

A relação jurídica autoral é, a toda evidência, privada, baseada na própria *sonalidade humana*, somente merecendo proteção por conta do próprio *ato cria* representando, de certo modo, a própria pessoa do autor.

O *objeto* do direito autoral é a *criação*, seja uma obra literária, artíst científica, arquitetônica etc. Seja mesmo uma criação intelectual ou uma prod do espírito. Nesse passo, estão tuteladas as obras exteriorizadas pela palavra (uma conferência, palestra ou aula) ou escrita (um livro ou um artigo científi pelo gesto (mímica ou coreografia), por sinais ou traços identificadores (um m ou um desenho), pelos sons (uma melodia ou uma ópera), pela imagem (um fi ou uma novela), pelas figuras (uma obra arquitetônica ou uma escultura) ou m mo pela combinação de diferentes meios de expressão (como uma obra teatra cinematográfica).[256] Estão alcançados, inclusive, novas criações, descortinadas gênio humano. Igualmente, são tutelados os direitos do tradutor e os direitos s a criação de programas de informática (o chamado *software*).[257]

Todavia, por força das limitações da vida em sociedade, de conotações didát ou científicas ou mesmo da impossibilidade de se determinar a titularidade, o n sistema legal (Lei nº 9.610/98, art. 8º) excepciona algumas criações, que não ser de objeto de proteção legal. São as ideias, procedimentos normativos, sistemas, todos, projetos ou conceitos matemáticos; os esquemas, planos ou regras para real atos mentais, jogos ou negócios; os formulários em branco para serem preench por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; os texto tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais oficiais; as informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastro legendas; os nomes e títulos isolados; o aproveitamento industrial ou comercial ideias contidas nas obras. Realmente, não seria possível identificar o titular de ideia genérica, razão pela qual são justificáveis as exceções legais. Enfim, *não plágio de ideias* porque a proteção autoralista é deferida a uma ideia materializ concretizada pelo seu autor, até porque toda e qualquer pessoa humana é, inva velmente, resultado de um processo de formação cultural, recebendo a influênci

compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências" (*Direito de autor*, op. cit., p. 8).

256. Confirmando o amplo espectro de incidência do Direito Autoral, o art. 7º da lei de regência é de cl solar ao estabelecer proteção para as *criações do espírito de qualquer modo exteriorizadas*, através de já conhecido ou que se invente no futuro,tais como "I – os textos de obras literárias, artísticas ou cie cas; II – as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; III – as obras dramá e dramático-musicais; IV – as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por es ou por outra qualquer forma; V – as composições musicais, tenham ou não letra; VI – as obras audiovi sonorizadas ou não, inclusive cinematográficas; VII – as obras fotográficas e as produzidas por qual processo análogo ao da fotografia; VIII – as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e cinética; IX – as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; X – os projetos, esb e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenogra ciência; XI – as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como ção intelectual nova; XII – os programas de computador; XIII – as coletâneas ou compilações, antolo enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou dispo de conteúdo, constituam uma criação intelectual".

257. A Lei nº 9.609/98 regulamenta a proteção da propriedade intelectual de programas de computador.

meio em que está inserida.[258] Disso decorre a inexistência de direito autoral sobre um determinado estilo ou modo de fazer ou de se comportar, por mais criativo ou genial que seja. Não há uma propriedade sobre uma maneira comportamental. Aliás, se assim não fosse (ou seja, se existisse direito autoral sobre um estilo pessoal), "João Gilberto, por exemplo, poderia ter reivindicado, judicialmente, danos morais pelo uso – por tantos brasileiros e estrangeiros – de sua batida sincopada e de seu estilo de cantar baixinho, características marcantes do 'estilo Bossa Nova'", como muito bem lembrado por Rodrigo Moraes.[259]

O titular do direito autoral é, a toda evidência, o criador da obra intelectual, seja pessoa natural ou jurídica[260] (inclusive o Poder Público), por se tratar de quem concebeu e materializou a obra, através de seu engenho e criatividade. Originariamente, pois, o título jurídico que sustenta o Direito em apreço é a *criação*. Em se tratando de pessoa natural, não se exige a capacidade para o reconhecimento da qualidade de *autor*, apenas sofrendo as limitações impostas pela teoria das incapacidades (CC, arts. 3º e 4º) quanto ao exercício dos seus direitos, exigindo-se a presença do representante ou assistente.

A autoria pode ser *individual* ou *plúrima*, esta também chamada de *coautoria*, quando os esforços criativos são compartilhados por duas ou mais pessoas. A coautoria admite diferentes graus, podendo se apresentar em uma divisibilidade absoluta ou relativa ou, ainda, através de fusão das contribuições pessoais de cada autor. Pode se tratar, ainda, de autor estrangeiro, ficando sujeito à proteção prevista em acordos, convenções e tratados internacionais em vigor no Brasil, observada a regra da reciprocidade de tratamento (art. 2º da Lei nº 9.610/98).

De qualquer sorte, além do *autor originariamente reconhecido*, outras pessoas podem encartar-se no sistema de direito autoral, através de ato de transmissão *inter vivos* (por meio de um contrato celebrado pelo titular, transferindo direitos de exploração) ou *causa mortis* (como no caso dos herdeiros de um autor morto). Nessa hipótese, não se olvide que o ato translativo apenas opera a transferência dos efeitos patrimoniais do direito de autor, não havendo uma derivação plena. O titular da obra, normalmente, é identificado pelo seu nome civil, admitido o uso de pseudônimos ou de qualquer outro sinal identificatório (art. 12 da Lei de Direitos Autorais).

Situação especial e interessante concerne à *obra anônima*, aquela em que não se indica o nome do autor, por sua própria opção ou por se tratar de pessoa desconhecida.

258. "Obra intelectual. Proteção. Plágio não demonstrado. A simples ideia ou descoberta, enquanto não materializada, é patrimônio de todos, podendo ser utilizada por qualquer pessoa. Inexiste no Caderno 'Casa & Cia' trecho que comprove a existência de plágio da obra paradigma 'Espaço 21'" (TJ/RS, Ac. 9ª Câm. Cív., Ap. Cív. 70010335065 – Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, j. 31.8.05).

259. MORAES, Rodrigo. *Direitos morais do autor*:repersonalizando o Direito Autoral, op. cit., p. 89.

260. A título ilustrativo, convém observar que o art. 4º da Lei nº 9.609/98 – a chamada Lei do *Software* – reconhece proteção aos programas de computador dispondo pertencerem os direitos decorrentes dos programas desenvolvidos durante a vigência do contrato ou do vínculo estatutário ao empregador, contratante ou órgão público, salvo disposição em contrário.

Nesse caso, não serão alterados os contornos gerais do Direito Autoral, exceto no que tange aos efeitos patrimoniais, que pertencerão a quem publicar. Se, porém, o autor se apresentar ao público, assumirá os seus direitos (que lhe são reconhecidos por essência e natureza), ressalvados os direitos adquiridos por terceiros. Idêntica solução vem sendo acolhida pela jurisprudência no que concerne às obras espíritas psicografadas, reconhecendo a titularidade dos direitos autorais para a editora que publicá-las.[261]

De qualquer modo, hodiernamente, são reconhecidos os chamados *direitos conexos*, oriundos do avanço tecnológico, pelos quais se estende o conceito de autor também ao produtor de fonogramas, garantindo uma remuneração ao investimento realizado.

b.2) Espécies (classificação)

O direito autoral é um direito *sui generis*, possuindo uma evidente natureza híbrida, mista. É que, nos termos do art. 22 da Lei nº 9.610/98, a um só tempo, o direito de autor é direito da personalidade (pela ótica da criação intelectual, que decorre da inteligência humana) e, igualmente, é, também, direito real sobre bem imaterial. Equivale a dizer: o direito autoral é, concomitantemente, *direito da personalidade*,no que tange à criação (ao invento), e é, também, *direito real* (a chamada propriedade intelectual, quanto ao seu exercício).

Bipartem-se, pois, os direitos autorais em dois diferentes feixes, que estão, necessariamente, interligados, formando um todo, uno e indivisível: os direitos morais do autor (de essência personalíssima) e os direitos patrimoniais do autor (de índole material, produzindo efeitos na esfera dos direitos reais, por conta da caracterização de um modelo específico de propriedade). Exemplificando, são de ordem personalíssima o direito à paternidade e o direito à nominação da obra, dentre outros (art. 24), por não trazerem consigo caráter econômico. De outra sorte, têm natureza real, por conta do conteúdo patrimonial, o direito à exploração do direito autoral, bem como a prerrogativa de utilizar, fruir e dispor da obra (art. 28).[262]

Ademais, considerado o caráter patrimonial dos *direitos materiais de autor* (isto é, da parte patrimonial do direito autoral), é admitida a sua transmissão por ato *inter vivos* ou *causa mortis*. Naquela hipótese (transmissão em vida), a cessão é presumidamente onerosa e reconhece ao autor o direito irrenunciável à percepção de, no mínimo, 5% sobre o preço de comercialização da obra (Lei de Direitos Autorais,

261. Assim: "Direito autoral. Obra psicografada. [...] Indenização. Não se trata de resguardar direito autoral de alguma entidade espiritual, mas de uma empresa que publicou uma obra intelectual, singular, e que produziu resultado econômico bem palpável. Tendo havido lesão ao direito da empresa titular dos direitos autorais, cabível a indenização pelos prejuízos sofridos" (TJ/RS, Ac. 9ª Câm. Cív., Ap. Cív. 598101079 – Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 4.8.98).

262. Estabelece o art. 39 da Lei de Direitos Autorais que, salvo disposição em contrário através de pacto antenupcial, os direitos patrimoniais de autor não se comunicam ao cônjuge, excetuados os rendimentos resultantes da exploração do direito autoral. Aplica-se o dispositivo legal, também, às uniões estáveis, cujos efeitos patrimoniais são os mesmos do casamento, salvo disposição em contrário (CC, art. 1.725).

art. 38). É o exemplo do escritor que redige um livro, cedendo a exploração a uma editora. Nesta (transmissão por morte), o direito autoral é transmitido pelo prazo de 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor (Lei de Direitos Autorais, art. 41). Findo o referido período, a obra cai em domínio público. É o caso da grande maioria das músicas clássicas, executadas na espera dos cinemas por estarem no domínio público.

Outrossim, é intuitiva a possibilidade de desapropriação dos direitos autorais, no que diz respeito à sua porção patrimonial (propriedade intelectual, que, necessariamente, atendendo ao comando constitucional, tem de cumprir função social), mediante prévia e justa indenização. Bastaria imaginar um direito autoral que, por algum motivo, não esteja cumprindo a sua função social.

b.3) Direitos patrimoniais do autor

Explica Carlos Alberto Bittar que os direitos patrimoniais do autor "são aqueles referentes à utilização econômica da obra, por todos os processos técnicos possíveis. Consistem em um conjunto de prerrogativas de cunho pecuniário que, nascidas também com a criação da obra, manifestam-se, em concreto, com a sua comunicação ao público".[263]

Em síntese apertada, porém completa, os direitos patrimoniais do autor decorrem, naturalmente, da possibilidade de exploração da sua criação, traduzindo a possibilidade reconhecida ao autor de obter ganhos e vantagens de natureza pecuniária. Por óbvio, é faculdade de o próprio autor destinar, ou não, a sua obra à exploração econômica por ele mesmo ou por terceiro, através de uma cessão, gratuita ou onerosa.

Por conta desse aludido caráter econômico, a execução pública (com finalidade lucrativa, direta ou indireta) de obra musical, de algum autor, impõe a cobrança de valor destinado ao pagamento dos direitos do seu autor. Nesse âmbito musical, a cobrança será promovida pelo Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais – ECAD, que deverá repassar o valor ao autor, nos termos da legislação específica.

Em sentido inverso, não havendo intuito econômico, mas uma mera atividade de diversão pública, descabe a incidência dos direitos autorais. Bastaria lembrar a existência de inúmeras festas populares e folclóricas, pelo Brasil afora, promovidas pelo próprio Poder Público e franqueadas, gratuitamente, ao público em geral, como nas comemorações de emancipação política, festejos de São João, dentre outros momentos. Nessas hipóteses, não incidirá a cobrança do direito autoral, por se tratar de execução pública sem proveito econômico. A nossa jurisprudência já tem precedentes diversos nesse sentido.[264] É uma flexibilização do direito autoral, com esteio na função social da propriedade.

263. BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*, op. cit., p. 49.

264. "Direito Autoral. Festejos juninos organizados pela Municipalidade em logradouro público. Ausência de finalidade lucrativa, direta ou indireta. Tratando-se de festejo de cunho social e cultural, sem a cobrança de ingresso, nem a contratação de artistas e inexistente o proveito econômico, indevidos são os direitos

Vem entendendo a jurisprudência, além disso, ser devido o recolhimento da tax por retransmissão da execução de obras, mesmo quando essa retransmissão teve simples intenção de propiciar maior conforto, comodidade, a terceiros, através d por exemplo, uma *mera retransmissão radiofônica*. Ou seja, quem *retransmite* te obrigação de recolher a taxa devida. É o típico exemplo dos hotéis, motéis, pousa das e congêneres que possuam sistema de transmissão de rádio. Nesse diapasão, f editada a Súmula 63 do Superior Tribunal de Justiça:

> Súmula 63, Superior Tribunal de Justiça:
> "São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais".

Além disso, não se olvide que a transmissão *causa mortis* dos direitos patr moniais do autor tem regra específica, distinta do Código Civil. É que, conforme legislação específica, os aspectos materiais do direito autoral serão transmitid pelo prazo de 70 anos, a contar do dia 1 de janeiro do ano subsequente à morte d autor. No caso de coautoria, o prazo fluirá a partir do primeiro dia do ano seguinte morte do último dos coautores. Depois desse prazo, previsto em lei, a obra cairá e *domínio público*. Não é à toa, portanto, que diversos estabelecimento empresariai pelo Brasil afora, optam por tocar músicas clássicas antigas ou obras outras que j estejam em domínio público, evitando a incidência da taxa devida.

Importante frisar que a proteção e efeitos (inclusive patrimoniais) do direit autoral independem de qualquer registro. É que a simples menção de sua autoria suficiente para identificar a titularidade.[265] Por isso, a notoriedade da obra ou d invento já confere a proteção necessária ao direito autoral.

b.4) Direitos morais do autor

Ao lado dos direitos patrimoniais – com evidente índole econômica –, os direito autorais trazem consigo uma evidente *feição extrapatrimonial*. Cuida-se da multipl cidade de possibilidades conferidas ao autor, visando assegurar o exercício da ob em si mesma e em nome do próprio autor.

Como bem observa Rodrigo Morais, em obra dedicada ao tema e com precisã cirúrgica, "o direito moral de autor possui um duplo fundamento: tutela da pers nalidade do autor e tutela da obra como entidade própria".[266]

É evidente que os direitos morais do autor não seguem, em linhas gerais, a mesmas características dos direitos patrimoniais. Trata-se de situação jurídica pers nalíssima, que não admite cessão e que está, a toda evidência, a salvo de penhor ou atos de disposição. Enfim, é uma projeção da própria personalidade do autor.

---

autorais. Precedentes. Recurso especial não conhecido" (STJ, Ac. Unân., 4ª T., REsp. 514.082/SP, Rel. Mi Barros Monteiro, j. 11.11.03, *DJU* 16.2.04, p. 264).

265. Também com esse pensar, OpiceBlum e Abrusio: "Direito autoral eletrônico", op. cit., p. 292.

266. MORAES, Rodrigo. *Os direitos morais do autor*: repersonalizando o Direito Autoral, op. cit., p. 9.

Partindo da própria redação do texto legal (Lei nº 9.610/98), vale pontuar os direitos morais do autor: (*i*)direito à paternidade da obra; (*ii*)direto ao ineditismo da obra; (*iii*)direito à integridade da obra; (*iv*)direito à modificação da obra; (*v*) direito ao arrependimento da obra; (*vi*)direito ao acesso a exemplar único e raro da obra em poder de terceiro.

Alguns aspectos curiosos e relevantes merecem debate específico.[267] Vejamos.

De saída, é mister deixar patente que o *direito à paternidade da obra* é adquirido com a criação da obra e não com o registro dela. É que o nosso sistema jurídico, andando muito bem nesse ponto, adotou a facultatividade do registro da criação, protegendo, desse modo, a criação e o seu autor contra "registradores profissionais". A efetiva existência de um registro gera uma presunção relativa de autoria, admitindo, contudo, prova em contrário.

Quanto ao *direito ao ineditismo*, convém lembrar que somente ao autor compete deliberar sobre o momento adequado para dar conhecimento ao público de sua obra. Circunstâncias absolutamente íntimas, portanto, resguardam essa prerrogativa do autor de manter a sua obra inédita, aguardando um momento propício ou uma melhor maturação de seu invento. Bem por isso, o Superior Tribunal de Justiça condenou uma revista especializada que publicou, sem autorização prévia do autor, o final da novela *Ti TiTi*,exibida pela Rede Globo de Televisão:

> "Direitos Autorais. Novela. Desfecho antecipado por publicação em revista. Reprodução *ipsis litteris* de boa parte do *script* do último capítulo, inédito. Ausência de autorização do autor. Conduta que não encontra abrigo ou respaldo nos direitos de citação ou informação. Enriquecimento sem causa. Configuração. Indenização devida" (STJ, Ac. 4ª T., REsp. 23.746-8/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.3.1995, *DJU* 2.10.95).

Já o *direito à integridade da obra* tem largo espectro, dizendo respeito à garantia reconhecida ao criador de deixar a sua criatura a salvo de ingerências indevidas de terceiros. É um mero reflexo da própria criatividade do autor, em sua essência. Ou seja, quem criou a obra tem o direito de vê-la de maneira íntegra e completa. Exemplo contundente desse direito à integridade absoluta da obra advém do art. 621 do Código Civil, que garante ao arquiteto o direito de não ter a sua criação modificada pelo dono da obra, sem sua expressa e prévia autorização. É o caso dos inúmeros empreendimentos imobiliários, em todo o nosso país, que são vendidos a partir de um projeto arquitetônico de determinada pessoa (não raro, famosa e premiada) e que, depois de instalado o condomínio, aprova-se, em assembleia, a mudança na fachada ou na estrutura do imóvel, sem qualquer consulta àquele que idealizou todo o projeto. A redação do dispositivo é de clareza meridiana:

267. As referências feitas nesse tópico são baseadas, em linhas gerais, na belíssima obra do professor baiano Rodrigo Moraes, que, de forma pioneira, aprofunda o estudo dos aspectos personalíssimos do direito autoral e cuja leitura se recomenda, expressamente, nessa oportunidade, Cf. *Direitos morais do autor*: repersonalizando o Direito Autoral, op. cit., passim.

> Art. 621, Código Civil:
>
> "Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que, por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou a excessiva onerosidade de execução do projeto em sua forma originária".

Ainda tratando da *integridade da obra*, convém o registro de que o *ter não pode superar o ser*, como exaustivamente afirmado anteriormente. Ou seja, não se pode imaginar que *o direito à integridade da obra seja da obra em si mesma*, mas sim *um direito conferido ao seu autor*, por conta de todo o processo de criação. Trilhando essas pegadas, deflui-se que obras plásticas assinadas expressamente pelo seu criador, por exemplo, mesmo que cedidas, onera ou gratuitamente a terceiros, não podem ser modificadas sem a expressa anuência do autor. A questão já mereceu reconhecimento em nossa jurisprudência superior:

> "Destruição de obra de arte pertencente ao patrimônio público. Ato ilícito. Direito do autor. Indenização devida [...] Assim como o detrimento a bens materiais ocasiona prejuízo patrimonial, 'a agressão aos bens imateriais configura prejuízo moral'. Uma vez incontroversa a existência do dano e admitida a sua responsabilidade, decorre daí ser o mesmo indenizável, não pelo simples decurso do tempo ou pelo desgaste natural, mas justamente pela comprovada destruição da obra de arte, que é projeção da personalidade do autor"(STJ, Ac. 1ª T., REsp. 37.374-3/MG, Rel. Min. Hélio Mossimann, j. 28.9.94).

Com relação ao *direito à modificação da obra* reconhecido ao autor, convém registrar que o processo de criação traz a reboque, naturalmente, a possibilidade de mudança de sua estrutura, com vistas ao aprimoramento ou, simplesmente, à mudança da obra. Não há objeção à explicação de Rodrigo Moraes: "O direito moral de modificação corresponde à prerrogativa exclusiva que o criador tem de alterar o conteúdo de sua obra, antes ou depois de utilizada, seja por mudança de concepção estética, seja por quaisquer outros motivos de ordem tanto econômica, quanto religiosa ou moral, ressalvadas algumas hipóteses de direitos adquiridos por terceiros".[268] Aliás, considerada a natureza personalíssima do direito à modificação da obra, não é difícil concluir que os herdeiros do criador não podem, ao seu livre-arbítrio, promover mudanças estruturais na obra, porque tal prerrogativa não lhes foi conferida.[269]

Interessante refletir, ainda, que o *direito ao arrependimento* reconhecido ao autor nada mais é senão simples projeção da própria evolução humana, que vem, ao longo dos tempos, marcando os seres mais evoluídos. Um poético trecho de Chico Buarque de Hollanda já dizia: "*você que inventou a tristeza, ora, tenha a fineza de desinventar; você vai pagar, e é dobrado, cada lágrima rolada desse meu olhar*", explicitando a importância de evoluir e mudar de opinião, como um fenômeno típico do processo

268. MORAES, Rodrigo. *Os direitos morais do autor*:repersonalizando o Direito Autoral, Op. cit., p. 197.

269. Nessa esteira, veja-se o art. 35 da Lei nº 9.610/98: "quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra versão definitiva, não poderão os seus sucessores reproduzir versões anteriores".

de crescimento e aprendizado. Ao autor não pode ser diferente. Efetivamente, não se lhe pode subtrair o direito de se arrepender da criação e, simplesmente, vê-la retirada da exposição ao público, em respeito ao seu processo inventivo.[270]

E, finalmente, o *direito de acesso ao exemplar único e raro da obra em poder de terceiro* (art. 24, VII, da Lei de Direitos Autorais) nada mais é do que o reconhecimento de ter em mãos a própria criação. Cuida-se de explícita limitação ao direito de propriedade, reclamando dois requisitos: (*i*)que o exemplar seja raro e único;(*ii*) *que o exemplar esteja legitimamente em poder de outrem*. De mais a mais, tal direito deve ser exercido pelo autor da maneira menos gravosa para o proprietário, que será privado da sua titularidade. É, sem dúvida, uma manifestação da *função social da propriedade*, mitigando o direito do proprietário, para respeitar o direito do autor de ter consigo, ao menos, um exemplar de sua criação.

b.5) As ilicitudes contra o direito autoral e a sua proteção jurídica

A simples possibilidade de violação por terceiro justifica, tranquilamente, a proteção dedicada ao direito autoral. Máxime no mundo pós-moderno, no qual o desenvolvimento tecnológico e as descobertas científicas permitem, a cada instante, uma nova forma de comunicação, abrindo fronteiras nunca antes imaginadas.

A proteção do direito (moral ou patrimonial) do autor não depende de prévio registro da obra, pois, como visto alhures, tal providência administrativa é facultativa, adquirindo-se a proteção legal pelo simples ato de criação.

As figuras mais comuns de atentado ao direito autoral são o *plágio, a contrafação, a usurpação de nome ou pseudônimo alheio* e *a modificação não autorizada de obra de terceiro.*

O plágio é a imitação pueril e fraudulenta de obra alheia, com, ou sem, mecanismos dissimulatórios. É a reprodução indevida de trechos ou da inteireza de uma obra pertencente a terceiro, sem a sua devida referência. Cuida-se de conceito aberto, pela natural dificuldade de se delimitar a ocorrência da apropriação, no todo ou em parte, de elementos integrantes de uma outra criação. A dificuldade é ainda maior quando se recorda a inexistência de *plágio de ideias*.[271]

270. Rodrigo Moraes lembra interessantes episódios, envolvendo o direito ao arrependimento, recordando que a artista Xuxa Meneghel, no longínquo ano de 1982, estrelou um filme erótico, no qual o seu personagem era uma prostituta sedutora de um adolescente, quando ainda estava em início de carreira. Posteriormente, com a sua imagem, inexoravelmente, ligada ao público infanto-juvenil, teve reconhecido, judicialmente, o direito de não ter aquela película veiculada por meio de fitas de videocassetes, o que decorre da possibilidade, concreta e real, de arrependimento. cf. *Direitos morais do autor*:repersonalizando o Direito Autoral, op. cit., p. 237.

271. O Tribunal de Justiça bandeirante teve oportunidade de reconhecer a inexistência de plágio de ideias ao dirimir conflito entre duas emissoras de canais de televisão abertos, por conta da veiculação por uma delas de um programa no formato *reality show*, em moldes assemelhados ao programa já existente na emissora concorrente. Afirmou o Sodalício: "Direito Autoral. Imputação de plágio. Ausência de dados suficientes para convencer de sua caracterização. Audiovisual. Programa tipo *reality show*, sem roteiro, por não possuir conteúdo definido em um texto predeterminado. Ideia de circunscrever pessoas em recintos

A outro giro, a contrafação é a publicação ou reprodução abusivas de c alheias, sem a necessária aquiescência do autor, independentemente da destin (lucrativa ou não) e da finalidade.[272] Enfim, "é a cópia não autorizada de uma tangível",[273] como vem entendendo a jurisprudência.[274] Tais ilicitudes, como se notar, não se confundem com a usurpação de nome ou de pseudônimo, que se racteriza em atribuir uma obra estranha a outrem para indevido proveito, econô ou social, decorrente da condição de titular.

Em uma perspectiva pragmática, é possível afirmar que o plágio afronta o di moral do autor, enquanto a contrafação atenta contra o seu direito patrimonial

É certo, de qualquer modo, que outras ilicitudes são possíveis no âmbito Direitos Autorais, como hipóteses de alteração da obra sem prévia aquiescênci autor ou mesmo supressão de autoria.

Aliás, as práticas ilícitas contra os direitos autorais estão se ampliando co deravelmente por conta da internet, impondo ao sistema uma maior, e mais ef atuação. Até porque a banalização das cópias na internet pode comprometer o pr avanço intelectual da sociedade, através de uma limitação à procura em mecanis de buscas, como o Google. Com essa perspectiva, ponderam Poliana Policarpo e Brennand ser indiscutível "que a internet democratizou o acesso às informaçõ conhecimentos, conteúdos dos mais variados, além de permitir uma série de o tunidade e auxiliar na revelação de novos talentos. No entanto, deve-se ter cui com toda essa facilidade de 'copiar' para não se chegar a um estágio de estagn do conhecimento e criação, ou seja, do próprio pensamento".[276]

---

fechados e método operacional de realização, visando expor os comportamentos dos participante protegidos pelo Direito Autoral. Formato televisivo que não se confunde com assunto, argumento ou literária. Inexistência de tutela legal" (TJ/SP, Ac. 5ª Câmara de Direito Privado, AgReg. 228.409.4/6-0 Des. Marcus Andrade, j. 6.12.01).

272. Separando as figuras, Carlos Alberto Bittar promove interessante distinção: "Observa-se que, no plágio, a alheia é, simplesmente, apresentada pelo imitador como própria, ou sob graus diferentes de dissimulaç absorção de elementos fundamentais da estrutura da obra, atentando-se, pois, contra a personalidade do (frustração da paternidade). Na contrafação, há representação ou reprodução de obra alheia sem autor autoral, podendo ser total ou parcial. Inclui-se, em seu âmbito, a derivação sem consentimento (a adap ou a tradução ou a variação de tema), eis que sempre se via ao aproveitamento econômico indevido d (atentando contra o aspecto patrimonial, ou contra a obra em si)" (*Direito de autor*, op. cit., p. 149).

273. STJ, Ac. Unân., 3ª T., REsp. 979.379/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 218.08, *DJU* 5.9.08.

274. Noutro interessante julgado, a Corte Superior esclareceu, em tom didático: "Na contrafação, o consum enganado e vê subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor não consegue per quem lhe fornece o produto e, como consequência, também o fabricante não pode ser identificad boa parte de seu público-alvo. Assim, a contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidad fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabri de bens que circulam no mercado" (STJ, Ac. Unân., 3ª T., REsp. 1032014/RS, Rel. Min. Nancy Andri 26.5.09, *DJU* 4.6.09).

275. Incorporando tal pensamento, Simone Lahorgue Nunes explica que a contrafação é uma "reproduçã autorizada", enquanto o plágio não é uma cópia servil, mas a apropriação "da essência criadora da ocultando o nome do autor e "dando a si a autoria da obra". Cf. "Notas sobre o plágio de obra liter institutos afins", op. cit., p. 82.

276. POLICARPO, Poliana; BRENNAND, Edna. *Cibercrimes na E-democracia*, op. cit., p. 130.

Para toda e qualquer ilicitude o sistema protetivo dos direitos autorais é, seguramente, a *tutela específica*, através da providência que se apresentar, em cada caso, mais adequada, consoante indicação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil. Assim, em cada caso, deverá o magistrado adotar a providência que se mostrar mais eficiente (enfim, a tutela que se mostrar *específica*) para proteger de forma integral o direito autoral. Ilustrativamente, poderá o juiz determinar multa diária (*astreintes*), restrição de direitos, busca e apreensão de material etc.

O manejo da tutela específica, porém, não obsta a utilização, cumulativamente ou não, de tutela reparatória, através de indenização por danos morais ou materiais causados ao autor.

Em face do caráter intangível dos direitos autorais, relembre-se o descabimento de uso das medidas possessórias, consoante cimentou a Súmula 228 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 228, Superior Tribunal de Justiça:

"É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral".

c) Direito à liberdade de crença e autodeterminação religiosa como garantia da integridade intelectual da pessoa humana

É certo – e nisso não se põe dúvidas – que o direito à liberdade de crença (e não apenas o direito à liberdade de religião) está previsto em sede constitucional (art. 5º, VI, VIII e XVIII) e representa, incontroversamente, uma projeção da garantia de integridade intelectual da pessoa humana.

E mais: a Constituição, ao assegurar a liberdade de credo, não condicionou o seu exercício a qualquer autorização prévia de quem quer que seja.[277]

Extrai-se do art. 5º, VI, da norma constitucional: "é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias".

Assim sendo, é fácil perceber que o direito à liberdade de crença, mais do que simplesmente significar o direito de participar do culto religioso e a liberdade de expressão religiosa, tem estrutura interna (conteúdo) muito mais complexa. O direito à liberdade de crença, confirmando um estado laico, significa a possibilidade de autodeterminação, de poder se comportar de acordo com os seus próprios valores espirituais e morais e, sobretudo, pautar-se, em sua vida pessoal, de acordo com a sua própria religiosidade. Enfim, a partir da amplitude garantista do inciso VI do art. 5º da *Lex Fundamentallis*, está assegurada a todo e qualquer cidadão a liberdade de crer (ou de não crer) e de se autodeterminar conforme essa crença (ou não crença).

277. Sobre o tema, seja consentido remeter ao imperdível texto de João Batista Villela. "O novo Código Civil brasileiro e o direito à recusa de tratamento médico", op. cit., em especial, p. 63. Naquela sede, afirma o mestre mineiro que atentar contra a liberdade de crer e seguir uma religião revela um mal preparo para o exercício da medicina e do direito.

E, por isso, integra o âmbito da garantia constitucional fazer proselitismo e propagação de sua crença ou de sua descrença.

Nessa levada, Manoel Jorge e Silva Neto expõe: "A liberdade de crença, conjugada à de consciência, permite considerar que o indivíduo poderá crer no que quiser, e expressar publicamente a sua crença; mas não se lhe interdita, contudo, a liberdade de não crer em absolutamente nada, assim como de utilizar meios para a divulgação do seu agnosticismo".[278]

Com isso, releva defender a possibilidade de projeção de efeitos jurídicos concretos a partir da liberdade de crença, exigindo-se que o Estado, a sociedade privada e os particulares abstenham-se de toda e qualquer prática discriminatória, não só em abstrato, mas, efetivamente, em concreto, garantindo o direito à crença.

Aponte-se, por isso, que as manifestações decorrentes da liberdade de crença constituem expressão da personalidade das pessoas, apresentando-se como mecanismo de concretização de sua própria dignidade. Afetam, desse modo, somente o próprio titular e estão protegidas pela autonomia privada, que decorre do seu direito à autodeterminação. O próprio inciso VIII do art. 5º da Constituição da República é alvejante ao estabelecer que "ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei".

Dando contornos concretos ao direito fundamental à liberdade de crença, vale lembrar algumas manifestações católicas, toleradas juridicamente, como a autoflagelação com chicotes como ato de penitência para expurgar os pecados, além de lembrar e sentir o sofrimento de Cristo. Sobre o assunto, como não lembrar do personagem Silas, do festejado romance *O Código da Vinci*, de Dan Brown, que se impunha sacrifícios físicos dolorosos como meio de se penitenciar?

Ora, caro leitor, se em situações tais, o ordenamento jurídico confere juridicidade ao comportamento decorrente da liberdade de crença, não tem como tratar diferentemente outras religiões. Nessa linha de intelecção, considerando ainda que o Estado brasileiro é laico, não se pode aceitar que determinadas práticas religiosas sejam admitidas e outras práticas, manifestadas por grupos religiosos minoritários, sejam repugnadas ou proibidas, em nome de argumentos jurídicos. Assim, os seguidores do candomblé e do espiritismo, os Adventistas do Sétimo Dia e mesmo os Testemunhas de Jeová possuem, inexoravelmente, o mesmo direito de autodeterminação, comportando-se de acordo com a crença religiosa abraçada.

Lembra Roxana Cardoso Brasileiro Borges que, no candomblé, há um ritual de disposição do próprio corpo, através da "raspagem da cabeça do recém-iniciado (no candomblé), que tem o seu crânio cortado com navalha. Acredita-se que por esses

278. SILVA NETO, Manoel Jorge e. *Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa*, op. cit., p. 120-121.

cortes o orixá entrará no corpo da pessoa quando houver incorporação".[279] Trata-se, como se pode notar, de situação similar ao autoflagelo, decorrendo da liberdade de crença.

Também não se pode negar ao espírita a liberdade de crença. Por isso, a cerimônia de casamento celebrada por médium espírita há de produzir os mesmos e regulares efeitos decorrentes de uma cerimônia presidida por outra autoridade religiosa, como um padre ou um pastor. Aliás, convém o registro de que o Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento de um mandado de segurança impetrado contra o ato que indeferiu o registro de um matrimônio celebrado em centro espírita, deferiu a ordem requerida, reconhecendo a liberdade de crença como preceito constitucional (MS 34.739-8/05, Rel. Desa. Ruth Pondé Luz). Naquela oportunidade, o bem lançado parecer do Ministério Público baiano foi decisivo ao esclarecer que "a liberdade de religião enseja ao direito individual desdobramentos que asseguram a liberdade de crença, de culto e de organização. Na liberdade de credo, o que se preserva é a escolha da religião, o direito de aderir, mudar ou mesmo não adotar crença alguma". E mais adiante arremata com precisão cirúrgica: "a liberdade de culto é a proteção conferida à prática dos ritos, cerimônias, manifestações, reuniões, tradições e hábitos da religião escolhida".[280]

De igual sorte, não se pode negar ao Adventista do Sétimo Dia o direito de guardar o sábado, não praticando qualquer ato que implique em proveito pessoal. Aliás, o reconhecimento do direito (constitucional) à liberdade de crença faz com que o seguidor da orientação da Igreja Adventista do Sétimo Dia tenha o inescondível direito de que as provas e etapas de um *concurso público* não sejam marcadas para o dia de sábado. Trata-se de garantia constitucional e, como tal, constitui cláusula pétrea, materializando sua integridade intelectual e a sua própria dignidade. Com o mesmo sentir, Manoel Jorge e Silva Neto é enfático ao afirmar que "embora represente um custo maior para o órgão que disponibiliza as vagas a serem preenchidas por via de concurso público, o direito individual à liberdade religiosa do adventista não deve ceder espaço à comodidade da Administração Pública", defendendo, assim, o direito do adventista de ter respeitada a sua crença.[281]

---

279. BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. *Disponibilidade dos direitos da personalidade e autonomia privada*, op. cit., p. 194-195. Acresce, ainda, a eminente professora baiana que "a raspagem da cabeça e a abertura de incisões em diversas partes do corpo da pessoa são passos obrigatórios e têm o principal objetivo de inserir um preparado que, acredita-se, determinará a ancestralidade da entidade à qual o iniciado estará ligado".

280. O parecer do Ministério Público, que teve o número 7540/05, é da lavra dos Procuradores de Justiça José Edivaldo Rocha Rotondano e Carlos Frederico Brito dos Santos, datado de 31.10.05, chegando mesmo a afirmar, corretamente, que esse direito à liberdade de credo concerne "à possibilidade do estabelecimento e organização das igrejas e suas relações com o Estado".

281. SILVA NETO, Manoel Jorge e. *Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa*, op. cit., p. 142. No mesmo diapasão, o Tribunal mineiro vem reconhecendo o direito do seguidor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de realizar prova em concurso público em dia distinto: "Mandado de segurança. Concurso. Crença religiosa. Nova data para a realização do teste físico. Possibilidade. É garantido constitucionalmente o direito de mudança de data para realização de teste físico em concurso público, mormente por ser a liberdade de

De qualquer maneira, procurando conciliar o direito do Adventista co princípio da impessoalidade que norteia a Administração Pública, entende que, designada uma prova de concurso ou seleção pública para o sábado manhã, a solução que melhor atende às diretrizes constitucionais é garanti candidato adepto da religião Adventista do Sétimo Dia o direito de iniciar a prova às 18 h do sábado, devendo permanecer incomunicável até aquele mento, em sala localizada no local das provas, submetendo-se, então, à me avaliação que foi aplicada aos demais candidatos.[282] Desse modo, harmoniza o interesse público com o direito individual e fundamental de crença. Foi tamente por isso que o Supremo Tribunal Federal, em decisão coerente, já t oportunidade de indeferir um mandado de segurança impetrado pela União co objetivo de cassar uma decisão que garantiu a um candidato a concurso públ seguidor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o direito de realizar as provas outro horário, respeitando a sua liberdade, observada a sua incomunicabilid durante o período da prova (STF, SS2144/DF, decisão da lavra do Min. Ma Aurélio, j. 19.4.02).

No que concerne aos seguidores da Igreja dos Testemunhas de Jeová, o solução não se pode reconhecer. Não receber sangue, em transfusão, é dire do Testemunha de Jeová, como projeção de sua própria integridade intelect Impor-lhe sangue é violar a sua dignidade. Por isso, "o desprezo que médi

---

crença (Adventista do Sétimo Dia) um direito daqueles que professam a sua respectiva religião. Faz p da liberdade de culto assegurado pela Constituição da República o dia a este reservado" (TJ/MG Unân., 7a Câm. Cív., Reex. Nec. 1.0145.07.377345-2/001(1) – Comarca de Juiz de Fora, Rel. Des. Beli de Lacerda, j. 29.4.08, *DJMG* 5.6.08).

282. Propagando a mesma solução para o caso, veja-se a lição de Manoel Jorge e Silva Neto. *Proteção Co tucional à Liberdade Religiosa*, op. cit., p. 143. Em sede jurisprudencial, o Tribunal de Justiça do Estad Bahia já tem precedentes, acatando, como solução para o caso, o direito de realizar a prova em hor diferenciados ou, no caso de já estar matriculado, ter as faltas abonadas. Veja-se: "Agravo de instrume Mandado de segurança. Concessão de liminar, em favor de membro da Igreja Adventista do Sétimo *para determinar a realização de provas do vestibular em horários diferenciados.* Competência da Ju Comum Estadual. Preliminar insubsistente. Cabimento da tutela. A bem lançada argumentação quan *perspectiva de ofensa a direito líquido e certo do impetrante, com base no art. 5º, VI e VIII, da Magna Car* mais a data próxima para a realização dos exames, autorizam a concessão da liminar. Preliminar rejeit Agravo improvido" (TJ/BA, Ac. unân., 4ª Câm. Cív., Agr. Instr. 51-7/07 – Comarca de Salvador, Rel. Antonio Pessoa Cardoso, j. 25.4.07). "Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança. Crença religi Adventista do Sétimo Dia. Disciplinas ministradas sexta-feira à noite e sábado pela manhã. Decisão terminando que a Universidade-Agravante abonasse as faltas já existentes em nome do agravado, como, fosse apresentado um horário alternativo ou aplicada prestação alternativa, sempre compat com a crença religiosa do agravado. Inconformismo da Universidade-Agravante. Inacolhimento. [...] Dir à liberdade religiosa. Impossibilidade de restrição de direito em razão de crença religiosa. Direitos res tivamente previstos nos incisos VI e VIII da Constituição de 1988. Mecanismo para garantia de uma digna. *In casu*, os documentos atestam que o agravado é membro da Igreja Adventista do Sétimo 'Voluntários da Pátria'. Como cediço, a referida religião guarda o período que se inicia com o pôr-do da sexta-feira e se finda com o pôr-do-sol do sábado, reservando-o para o exercício de atividades cunho não particular. Em respeito ao direito constitucionalmente previsto, a instituição de ensino pode negar ao aluno regularmente aprovado em vestibular um meio alternativo para suprir as disciplí ministradas em horário incompatível com sua crença religiosa. Recurso improvido" (TJ/BA, Ac. Unân Câm. Cív., Agr. Instr. 26589-2/2009 – Comarca de Feira de Santana, rel. Desa. Maria do Socorro Bar Santiago, j. 6.10.09).

e juízes demonstram para com a opção não transfusionista das Testemunhas de Jeová revela bem até que ponto o suposto respeito pela vida alheia mascara visões autoritárias e invasivas", nas palavras certeiras de João Batista Villela.[283]

Com efeito, em todas as situações narradas, tem-se o traço comum do conteúdo da liberdade de crença, que significa (muito mais do que somente ter a liberdade de culto e de expressão) a possibilidade de autodeterminação conforme as próprias convicções religiosas, sem coação externa e sem atentados de terceiros. É o direito de viver e praticar o seu credo, através de atividades físicas, espirituais ou intelectuais, seja mediante a associação (voluntária) com terceiros, seja através de atos pessoais ou mesmo sociais.[284]

5. O NOME CIVIL

5.1 Noções conceituais e características

É certa e incontroversa a importância de cada pessoa ser identificada socialmente, individualizando-se e distinguindo-se em relação às demais. Aliás, data de priscas eras a importância conferida ao nome, percebendo-se até mesmo na Bíblia Sagrada que, entre os hebreus, emprestava-se nome individual aos recém-nascidos logo aos oito dias de vida, momento em que se dava a circuncisão, somente vindo a ser admitida a homonímia tempos depois, fruto do crescimento populacional.[285] Consta, também, que, em seus batismos, na Judeia, João designava as pessoas com um nome, para que se pudesse identificá-las.

Surge, assim, a partir dessa induvidosa necessidade de individualização da pessoa no seu grupo social respectivo, o *nome civil*, como um verdadeiro *atributo da personalidade*, consistente no direito à identificação (espécie dos direitos da personalidade).

Dúvida inexiste da importância do nome para uma pessoa humana. Identificação, referência, respeito, origens familiares e ancestrais.... Certamente, o nome confere sentimentos diversos a um ser humano, projetando-se como manifestação de sua própria dignidade.

Sobre essa importância do nome na vida das pessoas, a sensibilidade de William Shakespeare, no inesquecível *Romeu e Julieta*, até hoje imortalizado romanticamente

283. VILLELA, João Batista. "O novo Código Civil brasileiro e o direito à recusa de tratamento médico", op. cit., p. 63.

284. Exatamente por essa trilha de pensamento, a Suprema Corte norte-americana, no primeiro caso que envolveu a liberdade religiosa, julgou o caso "Gonzalesvs. Centro Espírita Beneficente União do Vegetal", deliberando pela licitude do uso do chá de ayahuasca nos cultos do Santo Daime. Por unanimidade, a Corte, presidida por John Roberts, entendeu que o chá faz parte do ritual de conexão com Deus para os seguidores daquela seita (que foi, lembre-se, fundada no Brasil). Por isso, os agentes federais não poderiam confiscar o vegetal utilizado para o chá. A notícia consta da *Revista Trimestral de Direito Civil* 26: 276. Em 21 de fevereiro de 2006, a Corte Suprema norte-americana decidiu em favor da Entidade, reconhecendo como lícito o uso do seu sacramento, a Hoasca.

285. Demonstrando a importância histórica do nome, com maior profundidade, em monografia dedicada ao tema, José Roberto Neves Amorim. *Direito ao nome da pessoa física*, op. cit., p. 2 ss.

nas agradáveis vilas de Verona, região do Vêneto, na Itália – batizada de "cidade dos namorados". Julieta, em seus arroubos, se declara para o amado, deixando claro que o seu sentimento independeria do sobrenome por ele ostentado e que impedia o relacionamento:

> "É só seu nome que é meu inimigo: mas você é você, não é Montéquio! O que é Montéquio? Não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem algum. Oh, chame-se outra coisa! O que há num nome? O que chamamos rosa teria o mesmo cheiro com outro nome; E assim, Romeu, chamado de outra coisa, continuaria sempre a ser perfeito, com outro nome. Mude-o, Romeu, e em troca dele, que não é você, fique comigo."

E mereceu de Romeu, em resposta, uma bela declaração:

> "Romeu, eu cobro essa jura! Se me chamar de amor, me rebatizo: e, de hoje em diante, eu não sou mais Romeu. Julieta, quem é que, assim, oculto pela noite, descobre o meu segredo? Pelo nome, não sei como dizer-lhe quem eu sou. Meu nome, cara santa, me traz ódio, porque, para você, é de inimigo".[286]

Nesse contexto, o *nome civil* é o sinal exterior pelo qual são reconhecidas e designadas as pessoas, no seio familiar e social. Na imagem simbólica de Josserand, "é a etiqueta colocada sobre cada um". Enfim, é *o elemento designativo da pessoa.*

Nessa linha de intelecção, Adriano de Cupis, com visão avançada, compreende o nome como elemento individualizador da pessoa, seja física ou jurídica, designando e distinguindo "todo o sujeito na sociedade civil".[287]

Indubitavelmente, o nome é um direito da personalidade (e não direito de propriedade, como já se quis afirmar doutrinariamente), pois toda e qualquer pessoa – natural ou jurídica – tem direito à identificação. É, portanto, um atributo reconhecido às pessoas como mecanismo de identificação, integrando a sua personalidade e merecendo especial proteção. Esclarece, corretamente, Pedro Henrique de Miranda Rosa que "o nome é um direito essencial da pessoa, pois é através dele que é conhecido na sociedade".[288]

De fato, o nome é um direito da personalidade, por servir como um sinal gráfico ou fonético tendente à identificação de uma pessoa (natural ou jurídica) na sociedade em que convive e atua. É, pois, um bem jurídico umbilical e imperativamente ligado às pessoas, superada, em definitivo, a antiga ideia de enquadramento do nome como um direito de propriedade ou como um direito público

Aliás, a própria legislação civil se coaduna com esse entendimento, cuidando do nome civil no capítulo dedicado aos direitos da personalidade (arts. 16 a 19, Capítulo II, do Título I, do Livro I), conferindo-lhe idêntica proteção (CC, art. 12).

---

286. SHAKESPEARE, William. *Romeu e Julieta*, op. cit., p. 45-46.

287. AMORIM, José Roberto Neves. *Direito ao nome da pessoa física*, op. cit., p. 6.

288. ROSA, Pedro Henrique de Miranda. *Direito Civil*:parte Geral e Teoria Geral das Obrigações, op. cit., p. 44.

Essa natureza personalíssima do nome civil inspira, a toda evidência, o art. 17 do Código de 2002, a proibir a *utilização do nome em publicações ou representações que exponham ao desprezo público o seu titular, ainda que sem intenção difamatória.* Pela mesma perspectiva, também é vedada a exploração comercial do nome de uma pessoa, sem a sua anuência, sob pena de responsabilização civil pelo dano causado. Inclusive, vale ressaltar, com esteio nas ponderações de Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo, ilustres civilistas baianos, que se trata "de hipótese de *responsabilidade objetiva*, pois independe da presença de culpa".[289-290]

Emoldurado, sem qualquer sombra de dúvidas, o nome civil como um direito da personalidade, inclusive pela Codificação brasileira, exsurgem, via de consequência, algumas características inerentes à sua natureza personalíssima, decorrentes de seu próprio enquadramento topológico. Bem por isso, é de se reconhecer que o direito ao *nome civil* é:

i) *absoluto* (produzindo efeitos *erga omnes*, sendo oponível a toda e qualquer pessoa, sem que isso impeça que duas pessoas naturais, eventualmente, tenham o mesmo nome – a chamada homonímia);

ii) *obrigatório* (e, nesse sentido, vale o comentário de que o art. 50 da Lei nº 6.015/73 – Lei de Registros Públicos proclama a necessidade de registro civil de todas as pessoas nascidas, inclusive os natimortos);

iii) *indisponível* (uma vez que não pode o *titular* ceder, alienar, renunciar, dentre outras formas de disposição);

iv) *exclusivo* (característica inerente, apenas, à pessoa jurídica, uma vez que impossível de ser aplicada à pessoa natural, a quem se permite a homonímia);

v) *imprescritível* (não sendo possível perder o nome pelo não uso);

vi) *inalienável* (reconhecida a impossibilidade de a pessoa humana vender ou dar o seu nome como decorrência lógica da própria impossibilidade de dispor da própria identificação pessoal. No entanto, não se olvide que a pessoa jurídica poderá dispor de seu *nome de fantasia*, que se trata de elemento componente de seu patrimônio);

vii) *incessível* (caráter privativo, também, da pessoa natural, inaplicável à pessoa jurídica);

289. FIGUEIREDO, Luciano; FIGUEIREDO, Roberto. *Direito Civil*: Parte Geral, op. cit., p. 253.

290. A jurisprudência superior já abraçou esse entendimento, como se nota de interessante caso:"(...) 4. *O nome é um dos atributos da personalidade, mediante o qual é reconhecido o seu portador, tanto no campo de sua esfera íntima quanto nos desdobramentos de suas relações sociais.* Ou seja, é através do nome que se personifica, individua e identifica exteriormente uma pessoa, de forma a impor-lhe direitos e obrigações. 5. *A inclusão equivocada dos nomes de médicos em 'Guia Orientador' de Plano de Saúde, sem expressa autorização, constitui dano presumido à imagem, gerador de direito à indenização, inexistindo necessidade de comprovação de qualquer prejuízo.* Vale dizer, o dano é a própria utilização indevida da imagem com fins lucrativos, sendo dispensável a demonstração do prejuízo material ou moral" (STJ, Ac. Unân., 4a T., REsp. 1.020.936/ES, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 17.2.11, *DJe* 22.2.11).

viii) *inexpropriável* (não sendo suscetível de desapropriação pelo Poder Públi salvo em se tratando de nome de pessoa jurídica, em face de seu conteú patrimonial);

ix) *irrenunciável* (salvo casos especiais, em que se admite o despojamento parte do nome);

x) *intransmissível* (consequência natural da indisponibilidade).

No sistema jurídico brasileiro, entretanto, a principal característica do nome a *imutabilidade (inalterabilidade) relativa*.

De fato, por estar intimamente ligado à identidade da pessoa, permitindo s identificação no meio social, além de gerar segurança jurídica e social, o nome civ como regra geral, deve estar submetido à inalterabilidade. Naturalmente, poré essa imutabilidade não pode ser absoluta, sendo possível a alteração do nome circunstâncias excepcionais, previstas em lei ou por decisão judicial, quando hou justa motivação, e desde que não imponha prejuízo para terceiros. É, por sinal, o q preconiza o art. 58 da Lei de Registros Públicos – LRP. Alguns exemplos, bastant comuns em nosso cotidiano, são a mudança de nome pelo casamento ou pela uni estável, pela dissolução do casamento ou da convivência, pela inclusão no progra de proteção à testemunha ou pela adoção.

Demais de tudo isso, o nome civil é matéria de ordem pública, já que to nascimento deve ser registrado no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais LRP, arts. 54 e 55.

O processo de aquisição do nome civil se inicia com a indicação (ainda caráter provisório) feita pelos pais ou responsáveis, quando do seu registro civil nascimento, no cartório. Aliás, concretizando o pacto constitucional que consa a igualdade entre o homem e a mulher, a Lei nº 13.112/15, incluiu um item 1º art. 52 da Lei de Registros Públicos para, de modo expresso, permitir que o pai a mãe, individualmente ou em conjunto, possa proceder ao registro civil de nas mento de seu filho. Dessa maneira, qualquer dos pais pode, em cartório, registra nascimento de seu filho, indicando-lhe um nome civil.

Por evidente, é vedada a indicação de nomes que exponham o titular ao ridícul causem vexame, humilhação, vergonha... Enfim, que violem a sua dignidade perant coletividade. Aliás, a propósito do tema, o art. 55 da Lei de Registros Públicos autori o oficial do cartório a recusar o registro de nomes que venham a ferir a dignidade titular.[291] Em casos tais, o oficial do cartório do registro civil pode (diríamos, até, deve se recusar a lavrar o registro. Naturalmente, se o interessado no registro discordar

291. Curiosa hipótese é narrada por José Roberto Neves Amorim relatando a história do motorista de táxi q recentemente, em São Paulo, pretendeu registrar o seu filho como Osama Bin Laden, tendo recorrido Judiciário, após a negativa do Oficial do Cartório do Registro Civil, vindo igualmente a ter rechaçad sua pretensão, com esteio no art. 55, parágrafo único, da Lei de Registros Públicos. Cf. *Direito ao nome pessoa física*, op. cit., p. 60.

recusa do oficial do cartório poderá demandar junto ao Poder Judiciário, defendendo os seus interesses. O meio processual adequado é um procedimento denominado de dúvida, previsto na Lei de Registros Públicos (art. 198). O procedimento é iniciado pelo próprio oficial, quando há discordância entre o seu entendimento e o interesse do particular, encaminhando para que o juiz delibere sobre a dúvida, após a oitiva do interessado. Se o próprio oficial não suscitar a dúvida, o particular pode fazê-lo por meio de petição dirigida ao magistrado – é a chamada dúvida inversa. O juiz, então, após o recebimento da dúvida, ou da dúvida inversa, e ouvido o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (*custos juris*), proferirá sentença, dirimindo-a. Contra a decisão, cabe recurso de apelação, que pode ser interposto pelo particular interessado ou pelo Promotor de Justiça.[292] Somente não pode recorrer da decisão o próprio oficial do cartório, uma vez que lhe faltará interesse recursal, na medida em que a sua pretensão, tão somente, era o esclarecimento da dúvida, sem ter o direito de divergir do magistrado, a quem competiu elucidar a questão controvertida.

Comprovando, de uma vez por todas, se tratar de um direito da personalidade, o nome indicado pelos pais, quando da lavratura do registro de nascimento, pode ser mantido, ou não, pelo titular ao adquirir a plena capacidade - aos dezoito anos de idade ou pela emancipação. A partir desse momento (aquisição da plena capacidade), inicia-se o prazo decadencial de um ano para o titular requerer uma mudança imotivada do seu próprio nome ao juiz, exercendo um direito potestativo, que é escolher a própria identificação. Nesse caso, o titular não precisa motivar o requerimento de alteração do nome, apenas indicando tratar-se de escolha própria da sua identificação – que lhe é atributo personalíssimo. A alteração imotivada pode alcançar o prenome e o sobrenome, dês que sem prejuízo à identificação da origem ancestral dos pais. Nota-se, pois, que a indicação feita pelos pais, quando do registro de nascimento, pode ter caráter temporário.

5.2 Elementos componentes do nome civil

O estudo do nome no direito estrangeiro revela a existência de diferentes sistemas de designação de pessoas: o árabe-eslavo (que traz no nome a indicação da qualidade e da origem do titular); o europeu genérico (no qual há obrigatoriedade de um único prenome e um único sobrenome); e o ibérico (exigindo a indicação de prenome, simples ou composto, e sobrenome duplo, referindo-se às origens paterna e materna).

Captando as nossas origens lusitanas, ao tratar expressamente dos elementos componentes do direito ao *nome*, o art. 16 da Codificação de 2002 afirma nele estarem compreendidos o *prenome* e o *sobrenome*, vindo, em seguida, a estender a proteção jurídica dedicada ao nome para alcançar também o *pseudônimo* (CC, art. 19).

292. Súmula 99, Superior Tribunal de Justiça: *"O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte."*

Ora, a partir da simples leitura dos referidos dispositivos legais, ressalta-se a importância capital de esclarecer os elementos constitutivos do nome civil, permitindo sua perfeita compreensão.

Destaque-se, preliminarmente, que, ao utilizar a expressão *nome*, o legislador não adotou uniformidade conceitual. Por vezes, "usa a expressão *nome*, significando o nome por inteiro, ora emprega os termos *nome* e *prenome*, ou, ainda, *nome* e *sobrenome*. O mesmo se diga da Lei de Registros Públicos, a qual ora adota o termo *nome* para se referir ao nome completo, ora especifica *prenome* e *nome*, este último com o significado de nome de família", como acentua, com propriedade, Maria Celina Bodin de Moraes.[293]

Pois bem, o nome civil da pessoa natural é formado pelo *nome individual*, também chamado de *prenome*, e pelo *sobrenome*, também chamado de *nome patronímico* ou *nome de família*, além de, eventualmente, contar com um *agnome*. Esses, portanto, são os elementos componentes do nome.

O *prenome* é o primeiro elemento componente do nome, servindo para a designação individual de cada pessoa. Pode ser *simples* (Felipe, Hannah ou Nicholas) ou *composto* (João Gabriel e Pedro Henrique), devendo ser indicado livremente pelos pais, no momento do registro civil da pessoa natural. Como visto alhures, porém, essa liberdade de escolha não é ilimitada e arbitrária, pois, coerentemente, o art. 55 da Lei de Registros Públicos permite ao Oficial do Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais recusar o registro de nomes que exponham ao ridículo os seus portadores ou atentem contra a ordem pública. Aliás, o registro civil serve como fonte aquisitiva do prenome.

Vale lembrar que será, necessariamente, composto o prenome no caso de gêmeos com idêntico nome, consoante exigência do art. 63 da Lei nº 6.015/73 – LRP. Assim, caso os pais atribuam aos gêmeos o mesmo prenome, impõe-se que seja duplo e diferenciado. Exemplificativamente, caso queiram nominar os gêmeos como *José*, deverão ter prenomes duplos com diferenciações – *José Carlos* e *José Luiz*, por exemplo.

O *sobrenome*, também chamado de *nome patronímico* ou *nome de família*, é o indicativo da origem ancestral, da procedência familiar.[294] Igualmente, o patronímico pode ser simples (Almeida) ou composto (Vilas Boas). Serve como elemento identificador da estirpe da pessoa, sendo adquirido *ipso iure*, com o simples nascimento. Assim, até mesmo o filho adulterino ou incestuoso faz jus ao patronímico de seu genitor e de sua genitora, em razão da vedação constitucional de qualquer designação discriminatória (CF/88, art. 227, § 6º). Outrossim, a igualdade constitucional entre o homem e a mulher autoriza que a ordem indicativa do sobrenome é aleatória,

293. MORAES, Maria Celina Bodin de. "Sobre o nome da pessoa humana", op. cit., p. 51.

294. No direito brasileiro não se faz qualquer distinção, sequem em sede doutrinária, à distinção entre *patronímico* e *sobrenome*. No sistema português, no entanto, utiliza-se a expressão *patronímico* para indicar a origem paterna, enquanto o *sobrenome* tem o condão de aludir à ancestralidade materna.

estando ao sabor e vontade das próprias partes. Podem inserir primeiramente o do pai ou da mãe, sem qualquer obrigatoriedade.

Não se pode deixar de sublinhar, no ponto, que no caso de *multiparentalidade*, o filho disporá do sobrenome de todos os pais. Isso porque a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao deliberar sobre a possibilidade de pluriparentalidade (permitindo que uma pessoa tenha, eventualmente, dois, ou mais, pais ou mães, concomitantemente à outra filiação), foi de clareza solar ao asseverar a produção de todos os *"efeitos jurídicos próprios"*.[295] Ora, um dos efeitos da filiação é a identificação familiar. Em sendo assim, no caso de multiparentalidade, reconhecida judicialmente, o filho ostentará o sobrenome de todos os pais (dois pais e uma mãe, duas mães e um pai...), na medida em que mantém relação de parentesco (paterno-filial) com todos eles.

É possível, ainda, a existência de um terceiro elemento componente do nome. É o chamado *agnome*, que é uma partícula diferenciadora, destinada a servir de complemento ao nome, indicando o grau de parentesco ou o grau de geração, como nos conhecidos exemplos de *Filho*, *Júnior* ou *Neto*.[296] *Cuida-se de um elemento distintivo, destinado, apenas, a pessoas que possuem o mesmo nome e pertencem a uma mesma família e, por isso, é visivelmente ocasional.*

Menção há de se fazer, outrossim, ao *hipocorístico*, que, por seu turno, "são aqueles (nomes) em que se retira parte do nome original, de modo a reduzi-lo, mantendo-se a sílaba mais forte ou diminutivos, utilizados para exprimir carinho (Chico, Beto, Toninho)" ou para indicação da "sílaba preponderante" (Tião, Fafá, Lu, Zé), como ensina José Roberto Neves Amorim.[297] Se, eventualmente, um hipocorístico (apelido) se tornar notório, passando a identificar a pessoa individual e socialmente, autoriza-se que seja acrescido ou, até mesmo, que venha a substituir o nome, por força de decisão judicial.

Por derradeiro, é importante fazer referência ao *pseudônimo* ou *heterônimo*. Com origens etimológicas na expressão grega *pseudos*, que indica mentira, serve o pseudônimo para a ocultação da identidade civil do titular, de modo a impedir seu reconhecimento pelo público em geral, sendo utilizado, normalmente, por artistas, escritores e jornalistas. É expressão que identifica alguém em sua atividade profissional apenas, através de nome diverso do seu. Pessoalmente, o indivíduo continua a ser conhecido pelo seu prenome, uma vez que o pseudônimo o identificará, tão somente, no âmbito de suas atividades profissionais, desde que lícitas (CC, art. 19). Pondera José Roberto Neves Amorim que, "normalmente, os pseudônimos são adotados por pessoas ilustres e autoridades constituídas, como o então Presidente da República José Ribamar Ferreira de Araújo, que governou o País com o pseudônimo

295. *"A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios"*. (STF, Ac. Tribunal Pleno, RE 898.060/SC, rel. Min. Luiz Fux, Repercussão geral 622, j. 22.9.2016).

296. CARVALHO NETO, Inácio; FUGIE, Érika Harumi. *Novo Código Civil Comparado e Comentado*, op. cit., p. 48.

297. AMORIM, José Roberto Neves. *Direito ao nome da pessoa física*, op. cit., p. 16.

de José Sarney".[298] Outros famosos exemplos de pseudônimo são Zezé di Camarg Sílvio Santos, Susana Vieira e, em terras lusitanas, o poeta Fernando Pessoa, q utilizava, além do próprio nome, três pseudônimos (Ricardo Reis, Álvaro de Camp e Bernardo Soares) para os seus escritos, variando de acordo com o conteúdo d textos, conferindo verdadeira personalidade a cada pseudônimo.

O pseudônimo, naturalmente, é de uso exclusivo do seu titular, em razão de s caráter personalíssimo, e tem de ser escolhido nos limites da ordem pública e d bons costumes, gozando de proteção jurídica, por constituir sinal de identidade pr fissional pessoal, como, aliás, reconhece literalmente o art. 19 da norma substanti

Registre-se, ademais, que não se admite no Direito brasileiro "o uso de títul nobiliárquicos (ou honoríficos) que em outros países podem compor o nome",[299] t como Duque, Condessa etc., conforme a advertência de Pedro Henrique de Miran Rosa, muito embora se admita o uso dos *cognomes*, aqui entendidos como pseudônim

5.3 O princípio da inalterabilidade relativa e as hipóteses de alteração d nome civil

Considerando que o nome é direito da personalidade, o sistema jurídico brasile abraça a regra da sua *inalterabilidade relativa* (LRP, art. 58), com a visível intenç de proteger a pessoa humana.

Em sendo assim, em linha de princípio, o nome será alterável, tão somen em situações excepcionais, previstas expressamente em lei ou por decisão judici quando evidenciada uma justa causa. A opção normativa é justificável. Isso porq o nome civil gera um registro público no cartório de pessoas naturais e, via de co sequência, tangencia, ainda que obliquamente, certo interesse público na veracidad segurança e continuidade dos registros. Assim, "o que se pretende com o nome ci é a real individualização da pessoa perante a família e a sociedade", como já disse em sede pretoriana.[300]

Desse modo, é fácil perceber que a possibilidade de modificação do nome há ser excepcional, restrita às hipóteses previstas em norma legal ou decorrentes de u justa motivação, reconhecida pelo magistrado, em uma específica ação de retificaç de registro civil, prevista no art. 109 da Lei de Registros Públicos, e submetida procedimento de jurisdição voluntária – que admite decisão baseada em equida (CPC, art. 723, Parágrafo Único).

A título ilustrativo, é possível apresentar o rol das mais frequentes hipóteses mudança de nome civil (prenome e sobrenome) na sociedade brasileira, permitid pela norma legal, conforme os dispositivos mencionados a seguir:

298. AMORIM, José Roberto Neves. *Direito ao nome da pessoa física*, op. cit., p. 17.

299. ROSA, Pedro Henrique de Miranda. *Direito Civil*: parte Geral e Teoria Geral das Obrigações, op. cit., p. 4

300. TJ/PR, Ap. Cív. 74.503-3, Ac. 6ª Câm. Cív., *DJ*/PR 14.6.99, *COAD/ADV* 13, mar. 00, p. 202.

1. *hipóteses de alteração do prenome*

a) quando expuser o titular ao ridículo ou a situação vexatória,[301] bem como se tratando de nome exótico[302] (LRP, art. 55, parágrafo único);

b) havendo erro gráfico evidente, caracterizado, *e. g.*, por equívocos de grafia;[303]

c) para inclusão ou modificação de apelido público notório, também chamado de *hipocorístico* (LRP, art. 58 e parágrafo único). Ou seja, para o acréscimo de alcunha designativa da pessoa, pela qual se tornou conhecida socialmente, dês que não exista proibição em lei. É o conhecido exemplo do ex-Presidente da República Luiz Inácio *Lula* da Silva e do boxeador baiano Acelino *Popó* Freitas, além dos também conhecidos acréscimos nos nomes de *Xuxa* e *Pelé*. No ponto, convém registrar que o titular pode optar por acrescer ou modificar o seu prenome;[304]

d) pela adoção (ECA, art. 47, § 5º);

e) pelo uso prolongado e constante de nome diverso (é o caso de alguém que ficou conhecido por Márcia, em vez de Mércia,[305] seu nome registral);[306]

f) quando ocorrer homonímia depreciativa, gerando embaraços profissionais ou sociais;

g) pela tradução (nessa hipótese, uma transliteração), nos casos em que o nome foi grafado em língua estrangeira. É o exemplo do estrangeiro que se naturaliza brasileiro, podendo pleitear a retificação do seu nome, através de uma espécie de adaptação ou tradução, como lhe faculta o Estatuto

301. Exemplifica Maria Helena Diniz. *Curso de Direito Civil Brasileiro*, op. cit., p. 188, com os casos de Neide NavindaNavolta Pereira, Sum Tim Na, Céu Azul do Sol Poente, Pedrinha Bonitinha Silva e Graciosa Rodela d'Alho, dentre outros.

302. Recentemente, um programa de televisão apresentou interessante rol de nomes exóticos registrados em diferentes lugares do país: Açafrão Fagundes, Brilhantino Muratori, Himalaia Virgulino, Benvindo o Dia do Meu Nascimento Cardoso, Oceano Atlântico Linhares, Safira Azul Esverdeada, Sandália de Oliveira Silva, dentre outros.

303. É a hipótese de Osvaldo, que foi registrado como "Osvardo", ou Ulisses, que teve em seu registro o nome grafado como "Ulice", conforme anota Maria Helena Diniz.*Curso de Direito Civil Brasileiro*,op. cit., p. 188.

304. Marcos Ehrhardt Júnior, analisando a possibilidade de mudança do nome nesse caso, lembra que o "jogador de futebol Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu, se quisesse, poderia optar por se chamar Marcos Cafu Evangelista de Moraes, ou, simplesmente, Cafu Evangelista de Moraes" (*Direito Civil*: LICC e Parte Geral, op. cit., p. 224-225).

305. Veja-se interessante aresto do Tribunal de Justiça bandeirante: "Prenome. Substituição por apelido, autorizada pelo art. 58 da Lei no. 6.015/73, não é privilégio de artistas e políticos e sim tutela a dignidade humana de todos que, famosos ou não, ricos ou pobres, passam a ser vistos, chamados e respeitados por nome diverso daquele que consta do registro civil. Hipótese de mulher que não aceita o prenome, muito difundido, e que provocou, pela associação dos apelidos de família, uma homonímia gigantesca. Provimento para que prevaleça o apelido notório que lhe molda a personalidade" (TJ/SP, Ac. 3ª Câm. Direito Privado, Ap. Civ. 150.963-4/Taubaté, Rel. Des. Enio Santarelli Zuliani, v. u., j. 6.6.00).

306. Maria Helena Diniz noticia que já se teve oportunidade de autorizar a modificação do nome de Maria Aparecida que era conhecida no meio social como Maria Luciana (*RT* 532: 86). Cf. *Curso de Direito Civil Brasileiro*, op. cit., p. 191.

do Estrangeiro Em razão disso, Michael (do original germânico ou inglês) termina sendo transliterado para Miguel, enquanto William se converte em Guilherme.

2. *hipóteses de alteração do sobrenome*

a) pela adoção (ECA, art. 47, § 5º), valendo a lembrança que a legislação permite a alteração, além do sobrenome, também do prenome do adotado. Em relação à mudança de prenome, se o adotado tiver mais de 12 anos de idade, exige-se o seu consentimento. Contando com menos de 12 anos de idade, deve ser ouvido, sempre que possível, mas a sua manifestação não vincula o magistrado;

b) pelo casamento, hétero ou homoafetivo, quando é facultado a qualquer dos nubentes acrescer o nome do outro (CC, art. 1.565, § 1º),[307] inclusive podendo ambos modificar o nome, acrescentando o sobrenome de seu consorte;

c) pelo divórcio, uma vez que o(s) cônjuge(s) que alterou (alteraram) o seu nome patronímico pelo casamento poderá (poderão) voltar a utilizar o nome que possuía (possuíam) antes do matrimônio (CC, arts. 1.571, § 2º, e 1.578);

d) para a inclusão de sobrenome de ascendente (inclusive abarcando a chamada inclusão de sobrenome avoengo na hipótese de acréscimo do patronímico dos avós), desde que não prejudique o patronímico dos demais ascendentes;[308]

e) pela união estável, hétero ou homoafetiva;

f) pela anulação ou declaração de nulidade do casamento (quando os ex-cônjuges voltam a ter o nome que dispunham antes de casar, exceto se se tratar de casamento putativo e optar o cônjuge de boa-fé por permanecer com o nome de casado).

Também vale lembrar que o estrangeiro domiciliado no país poderá alterar o seu nome nas mesmas hipóteses dos nacionais, de acordo com os arts. 30 e 43 da Lei

307. Art. 1.565, § 1º, Código Civil: "Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro". Já se entendia, no entanto, desde o advento da *Lex Fundamentallis* que "a Carta Magna de 1988 equiparou direitos e deveres dos homens e mulheres. É juridicamente possível o pedido do marido de adotar o patronímico de família de sua futura esposa" (TJ/SP, Ac. 1ª Câm. Cív., Ap. Cív. 198.349-1/7, Rel. Des. Guimarães e Souza, j. 3.8.93, *BolAASP* 1839/90).

308. Colhe-se na jurisprudência interessante exemplo de acréscimo de sobrenome de ascendente: "Pela leitura de todo o processado, nota-se que a apelante pretende acrescentar nome, de origem japonesa, tendo em vista sua filiação. A pretensão exposta pelo recorrente, preservado o entendimento do ilustre prolator da sentença hostilizada, merece acolhida. Isto porque o nome da pessoa, composto pelo sobrenome e pelo prenome, é um sinal de que a identifica perante a sociedade em que vive e como tal transforma-se num modo de ser do indivíduo [...] A retificação neste momento da vida da menor lhe é vantajosa, na medida em que ainda não pratica atos identificadores da vida civil, passível de alterações no futuro" (TJ/SP, Ap. Cív. 88.603-4/0, Ac. 7ª Câm. de Direito Privado, j. 28.7.99, *COAD/ADV* 52, dez. 99, p. 826).

nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro (lembrando que se aplicam as regras do seu estatuto pessoal, isto é, da lei de seu domicílio, consoante a previsão do art. 7º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).

É mister fazer referência, ainda, à possibilidade de modificação do nome (prenome e sobrenome) instituída pela Lei nº 9.807/99, que regulamenta o programa de proteção à testemunha que houver colaborado em processo penal ou inquérito policial. A norma permite, em seu art. 9º, a alteração judicial do nome da própria testemunha e do seu cônjuge ou companheiro, ascendentes e descendentes, com o intuito de resguardar a sua própria integridade familiar. Saliente-se que a referida mudança de nome pode ser definitiva ou temporária, sendo permitido ao titular retomar, posteriormente, o seu nome originário. Nesse caso, caberá ao juiz da Vara Criminal determinar a mudança em cartório.

Outra situação ensejadora da mudança de sobrenome está contemplada na Lei nº 11.924/09 – apelidada de Lei Clodovil Hernández, em homenagem ao Deputado que apresentou o projeto do qual resultou a citada norma legal – autorizando o acréscimo de sobrenome do padrasto ou madrasta pelo enteado ou enteada. Acolhendo a orientação de nossa jurisprudência,[309] a citada lei acrescentou o § 8º ao art. 57 da Lei nº 6.015/73 – Lei de Registros Públicos, esclarecendo, expressamente, que "o enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família". Por evidente, exige-se autorização judicial, através de procedimento de jurisdição voluntária, na vara de registros públicos, com a intervenção do Promotor de Justiça, para o acréscimo do sobrenome do padrasto ou da madrasta. Isso sem esquecer a necessidade de prévio e expresso consentimento deles. É claro que o acréscimo de sobrenome não implica em efeitos jurídicos, sequer decorrendo direito sucessório ou alimentar. A pessoa que modificou o seu nome, para acrescer o do padrasto ou madrasta, continua a ser filho de seus pais, de quem irá suceder e reclamar alimentos e demais efeitos jurídicos, apenas passando a ter, em seu nome (que é direito da personalidade), a referência ao parente por afinidade. Dúvida não há de que o fundamento dessa possibilidade é o *afeto existente entre as partes*. E, por óbvio, poderá, no futuro, voltar a ter o nome originário, retirando o acréscimo, justificadamente, por nova decisão judicial. Questão de relevo diz respeito à necessidade, ou não, de anuência do pai ou mãe para o acréscimo de sobrenome do padrasto ou madrasta. Verificando se tratar de questão personalíssima, entendemos desnecessária a anuência dos pais, como bem

309. Já reconheciam os Tribunais: "O nome pode ser alterado mesmo depois de esgotado o prazo de um ano, contado da maioridade, desde que presente razão suficiente para excepcionar a regra temporal prevista no art. 56 da Lei 6.015/73, assim reconhecido em sentença (art. 57). Caracteriza essa hipótese o fato de *a pessoa ter sido criada desde tenra idade pelo padrasto, querendo por isso se apresentar com o mesmo nome usado pela mãe e pelo marido dela*" (STJ, Ac. 2ªSeção, REsp. 220.059/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar Jr., j. 22.11.00, *DJU* 12.2.01, p. 92, *RSTJ* 145: 255).

pontuou o próprio texto legal. Todávia, em se tratando de filho menor de idade e de consequência, sujeito ao poder familiar, sustentamos a necessidade de citação pais, dando-lhes conhecimento do pedido, em respeito, inclusive, ao que dispõ art. 1.105 do Código de Processo Civil e oportunizando prazo para a impugnaçã pedido de acréscimo do sobrenome do padrasto ou madrasta. É certo que a even impugnação do pai ou mãe biológico não impede uma decisão judicial deferin acréscimo quando restarem insubsistentes os motivos impugnatórios. Observe-se pais devem ser citados, para ter conhecimento do pedido, mas não será preciso venham a anuir a ele, podendo o juiz determinar o acréscimo de nome patroním ouvido o Ministério Público, mesmo com a eventual objeção dos pais.

Para além das aludidas hipóteses de modificação de nome autorizadas norma legal, convém registrar uma possibilidade especial modificativa do nome. possibilidade de alteração *imotivada* do nome durante o primeiro ano a parti maioridade civil – ou seja, dos dezoito aos dezenove anos de idade ou a parti data da emancipação. Nesse lapso temporal de um ano, o titular pode, exercen seu direito personalíssimo à identificação, escolher o prenome que deseja oste e o sobrenome identificador da origem familiar, dês que não prejudique a indic da família de ambos os pais (LRP, art. 56). Trata-se de uma *especial hipótes mudança de nome* e que merece atenção, por ser o único caso de alteração im vada de nome,[310] bastando a vontade do titular. Como se vê, esse permissivo a mudança imotivada do nome, durante o primeiro ano após a aquisição da p capacidade, é completamente justificável. Isso porque, em se tratando de um d to da personalidade, é natural que o nome civil da pessoa humana seja escol livremente por ela, garantindo-lhe o exercício pleno de sua personalidade e de identificação social. Em nome da segurança social, porém, o pedido imotivado ser formulado no prazo decadencial de um ano, antes aludido. Ultrapassado prazo e adquirida a plena capacidade, somente será tolerada a mudança de n nas hipóteses elencadas em lei.[311]

A outro giro, reafirmando a natureza personalíssima do nome como um asp integrante da dignidade do seu titular no seio social e familiar, é preciso reiter admissibilidade de modificação do nome em situações não previstas expressam em lei.

Assim, *reclama-se uma interpretação não exaustiva das hipóteses modificat do nome*, permitida a sua alteração justificadamente para salvaguardar a dignid da pessoa humana, de acordo com o caso concreto, por deliberação do juiz – atr

310. Com esse pensar, Rodolfo Pamplona Filho e Pablo Stolze Gagliano afirmam que "para o exercício direito potestativo (alteração do nome no primeiro ano após a maioridade civil), não exige realme lei uma motivação peculiar para a pretensão" (*Novo Curso de Direito Civil*, op. cit., p. 123).

311. "Após o decurso do primeiro ano da maioridade, só se admitem modificações do nome em caráter e cional e mediante comprovação do justo motivo." (STJ, Ac. 4ª T., REsp. 52.106, rel. Min. Barros Montei u., j. 17.8.1999, *DOU* 29.11.99, p. 164).

de um procedimento de jurisdição voluntária (LRP, art. 109), de competência da vara de registros públicos.

Frise-se, nessa linha de ideias, que razões de ordem psicológica (íntima) e de ordem social devem confluir para averiguar, na situação concreta, se a alteração é necessária para assegurar a dignidade humana. É postura que "abre perspectivas para uma corrente liberal"[312] na alteração do nome, apesar da regra geral da inalterabilidade.

Não foi por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça, patrocinando esse entendimento, permitiu que um filho, abandonado pelo seu genitor, apesar de reconhecida a paternidade, alterasse seu nome patronímico, excluindo o sobrenome paterno – mesmo não havendo expressa autorização de lei. Veja-se:

> "O nome pode ser modificado desde que motivadamente justificado. No caso, além do abandono do pai, o autor sempre foi conhecido por outro patronímico. A jurisprudência, como registrou Benedito Silvério Ribeiro, ao buscar a correta inteligência da lei, afinada com a 'lógica do razoável', tem sido sensível ao entendimento de que o que se pretende com o nome civil é a real individualização da pessoa perante a família e a sociedade" (STJ, Ac. 4ª T., REsp. 66.643/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 21.10.97, *DJU* 9.12.97, p. 64707).

Também a Corte paulista já afirmou a possibilidade de alterar o sobrenome da viúva quando ela contrair um novo casamento, apesar da falta de previsão legal expressa:

> "Registro civil. Assento de casamento. Alteração de nome. Pretensão de viúva nubente de acrescentar o apelido de família do segundo marido ao nome de solteira, suprimindo o do primeiro cônjuge. Admissibilidade. Ação julgada procedente. Sentença confirmada" (TJ/SP, Ap. Cív. 21.360-1, Rel. Des. Alves Barbosa, *RJTJSP* 81: 211).

Realmente, um entendimento mais contemporâneo e sintonizado com o princípio da dignidade da pessoa humana vem soprando no sentido de admitir que o cônjuge ou companheiro viúvo possa retirar o nome patronímico do falecido consorte ou companheiro, independentemente de convolar novas núpcias. Assim, com o fim do casamento ou da união estável, por conta do óbito, nada impede que o viúvo exclua o sobrenome do *de cujus*, refletindo um novo tempo nas decisões de família, mais flexíveis e humanas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (na Ap. Cív. 70003313384) teve oportunidade de confirmar a possibilidade de "alteração do nome, como decorrência do fim do casamento".

Pelo fio do exposto, é possível, então, asseverar que o princípio da *inalterabilidade relativa do nome* implica na possibilidade de o juiz modificar, a requerimento do interessado, o nome civil (seja o prenome, seja o sobrenome) em casos justificáveis,

312. Com esse espírito e referência, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já assentou entendimento no julgamento da Ap. Cív. 7000.6600092 – Comarca de Planalto, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 3.9.03.

na defesa da proteção integral da personalidade humana, independentemente expressa previsão legal.

Efetivada a mudança do nome por requerimento do titular (nos casos previ em lei ou demonstrada a justa causa), parece-nos que o retorno ao estado ante voltando ao nome originário, somente é possível se evidenciada uma situação s veniente, motivadora da restituição do titular ao status quo ante. Fora disso, a r geral é que o novo nome incorpora-se à personalidade, identificando-o dali em dia sob pena, inclusive, de se permitir um comportamento contraditório e incoerent

5.4 Hipóteses controvertidas de mudança do nome civil

Ainda em relação ao nome, parece-nos importante trazer a lume alguns po controvertidos relativamente à alteração do nome em determinadas situações e cíficas no que tange à manutenção, ou não, do nome após a ruptura do casam ou da união estável, à alteração do nome dos filhos após a mudança de nome pais, em face do divórcio ou da dissolução de união estável, à mudança do nome conta da cirurgia de mudança de sexo (transgenitalização) e, finalmente, ao n da pessoa inserida em programa de proteção à testemunha.

Primus, vale o destaque de que o casamento, bem como a união estável, per a mudança do nome, com o acréscimo do sobrenome de um cônjuge, com companh pelo outro (CC, art. 1.565). Advindo, entretanto, a dissolução da relação matrimo ou de união estável, surge uma indagação palpitante: aquele que acresceu o patronímico do outro deve perdê-lo? A resposta é no sentido de que a regra ge a *deliberação pelo titular*. Assim, quem modificou o nome - quando do casament da união estável - podendo mantê-lo ou excluí-lo, de acordo com o seu interesse seja, adquirido o sobrenome pelo casamento ou união estável, ele estará incorpor inexoravelmente, à personalidade do titular, somente podendo lhe ser retirado c sua anuência. Assim, não é despiciendo registrar a necessária desvinculação da c pela dissolução do matrimônio com a manutenção do nome de casado.

Com efeito, conforme vem preconizando Silmara Juny de A. Chinelato e Al da, em obra sensível e bem fundamentada, "o ponto fundamental a ser discutid questão do nome da mulher casada é reconhecer-lhe a natureza jurídica inequí de direito da personalidade".[314] A orientação do Superior Tribunal de Justiça já tava assentada nessa direção, compreendendo que o nome de casado incorpora-

313. É o que vem sendo afirmado em sede jurisprudencial: "(...) Uma vez que foram os próprios recorrent ação anterior, que pediram a alteração de seus nomes, com o objetivo de obter a nacionalidade portu e tiveram seu pedido atendido na integralidade, não podem, agora, simplesmente pretender o re lecimento do *statu quo ante*, alegando que houve equívoco no pedido e que os custos de alteraç todos os seus documentos são muito elevados." (STJ, Ac. 3ª T., REsp. 1.412.260/SP, rel. Min. Nancy An j. 15.5.2014, DJe 22.5.2014).

314. ALMEIDA, Silmara Juny de A. Chinelato e. *Do nome da mulher casada*, op. cit., p. 130.

personalidade, não podendo ser retirado sem anuência do interessado.[315] Nessa linha de intelecção, a Emenda Constitucional nº 66/10, que facilitou a dissolução do casamento, eliminou a possibilidade de discussão de culpa pela ruptura do casamento, deixando claro que somente o titular delibera sobre a manutenção, ou não, do nome patronímico adquirido pelo casamento.

Secundus, mas ainda no âmbito das relações familiares, exsurge um outro ponto controvertido: a possibilidade de mudança do nome da genitora (ou do genitor, embora menos comum na prática) que voltou a ter o nome de solteira, no registro civil de nascimento do filho, após a eventual dissolução do casamento. Cuida-se de hipótese de grande ocorrência cotidiana. A pessoa muda o nome por ocasião do casamento, acrescendo o sobrenome do cônjuge, tem filhos durante a convivência afetiva, mas o casamento se dissolve, voltando, então, a ter o nome civil anterior às núpcias. Nesse caso, porém, o filho tem em seu registro o nome que a mãe teve durante o casamento. Seria um caso de retificação do registro civil do nascimento do filho, para fazer constar o sobrenome que a genitora voltou a ter após a dissolução nupcial? Pois bem, a resposta somente pode ser afirmativa. É que o direito à individualidade e à identificação integra a personalidade humana, plasmando a sua dignidade. Assim, a documentação pessoal deve refletir a identidade do seu titular, contendo as informações precisas e atuais de seus genitores. Por isso, é direito do filho ter, em seu registro de nascimento, o correto nome civil de seus pais. É possível imaginar o volume de contratempos que são impostos a alguém por conta dessa situação. Por isso, mostra-se justo e razoável retificar o registro civil de nascimento de uma pessoa para fazer constar o novo nome do genitor, decorrente de dissolução conjugal.

A orientação da jurisprudência superior, inclusive, se firmou nesse diapasão:

> "Civil. Alteração do registro de nascimento para nele fazer constar o nome de solteira da genitora, adotado após o divórcio. Possibilidade.
>
> I – A dificuldade de identificação em virtude de a genitora haver optado pelo nome de solteira após a separação judicial enseja a concessão de tutela judicial a fim de que o novo patronímico materno seja averbado no assento de nascimento, quando existente justo motivo e ausentes prejuízos a terceiros, ofensa à ordem pública e aos bons costumes. II – É inerente à dignidade da pessoa humana a necessidade de que os documentos oficiais de identificação reflitam a veracidade dos fatos da vida" (STJ, Ac. Unân., 3ª T., REsp. 1.041.751/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.8.09).

315 Há interessante precedente que vale ser lembrado: "Acórdão recorrido que conclui acarretar a supressão do nome da ex-mulher prejuízo à sua identificação. Matéria de fato. Incidência da Súmula 7 do STJ. Preservação, ademais, do direito à identidade do ex-cônjuge. Distinção manifesta entre o sobrenome da mãe e o dos filhos havidos da união dissolvida, não importando que hoje já tenham estes atingido a maioridade" (STJ, Ac. unân., 4a T., REsp. 358.598/PR, rel. Min. Barros Monteiro, j. 17.9.02, *Revista de Direito Privado* 15: 324).Do voto condutor proferido no julgamento acima indicado, colhe-se importante fundamento, a evidenciar a necessidade de analisar o caso sob a ótica do direito da personalidade à identidade: "Ainda que a manutenção pela ex-mulher do nome de casada possa criar uma situação de desconforto e de constrangimento ao varão, há de prevalecer a disposição legal que preserva o direito à identidade da mulher".

Tertius, há outro problema, também de grande relevância, dizendo re alteração do nome por conta da cirurgia de mudança de sexo realizada pelo xual, também chamada cirurgia emasculatória, de redesignação do estado s de transgenitalização. Com efeito, a Resolução nº 1.957/10 do Conselho Fe Medicina – CFM, dispensando autorização judicial para a referida intervenção c estabelece condições e requisitos para que o profissional médico realize a cir alteração do estado sexual. Ora, levada a efeito a cirurgia médica, com a a física e psíquica adequadas e conformadas, o (ex) transexual, seguramente, f junto ao Judiciário a alteração do estado sexual e do seu nome. Surge, questionamento: é possível mudar o nome? Maria Berenice Dias, profunda e da matéria, esclarece, com rara proficiência e precisão, que "o direito à id tem assento constitucional, pois está inserido na sua norma de maior relevâ proclama o princípio do respeito à dignidade humana", motivo pelo qual "r justificativa é cabível para negar a mudança, não se fazendo necessária alteração de dispositivos legais para chancelar a pretensão".[316]

Pacificando históricas controvérsias, o Superior Tribunal de Justiça co entendimento no sentido da viabilidade de mudança do nome e do estad do transexual submetido a procedimento cirúrgico de transgenitalização, percebe:

> "Direito Civil. Recurso especial. Transexual submetido à cirurgia de redesignação sexual. Alteração do prenome e designativo de sexo. Princípio da dignidade da pessoa humana. Sob a perspectiva dos princípios da Bioética – de beneficência, autonomia e justiça –, a dignidade da pessoa humana deve ser resguardada, em um âmbito de tolerância, para que a mitigação do sofrimento humano possa ser o sustentáculo de decisões judiciais, no sentido de salvaguardar o bem supremo e foco principal do Direito: o ser humano em sua integridade física, psicológica, socioambiental e ético-espiritual.
>
> A afirmação da identidade sexual, compreendida pela identidade humana, encerra a realização da dignidade, no que tange à possibilidade de expressar todos os atributos e características do gênero imanente a cada pessoa. Para o transexual, ter uma vida digna importa em ver reconhecida a sua identidade sexual, sob a ótica psicossocial, a refletir a verdade real por ele vivenciada e que se reflete na sociedade...
>
> Conservar o "sexo masculino" no assento de nascimento do recorrente, em favor da realidade biológica e em detrimento das realidades psicológica e social, bem como morfológica, pois a aparência do transexual redesignado, em tudo se assemelha ao sexo feminino, equivaleria a manter o recorrente em estado de anomalia, deixando de reconhecer seu direito de viver dignamente.
>
> Assim, tendo o recorrente se submetido à cirurgia de redesignação sexual, nos termos do acórdão recorrido, existindo, portanto, motivo apto a ensejar a alteração para a mudança de sexo no registro civil, e a fim de que os assentos sejam capazes de cumprir sua verdadeira função, qual seja, a de dar publicidade aos fatos relevantes da vida social do indivíduo, forçosa se mostra a admissibilidade

316. DIAS, Maria Berenice. *União homossexual*: o preconceito e a justiça, op. cit., p. 127-128. Também esse entendimento, José Roberto Neves Amorim. *Direito ao nome da pessoa física*, op. cit., p. 6

> da pretensão do recorrente, devendo ser alterado seu assento de nascimento a fim de que nele conste o sexo feminino, pelo qual é socialmente reconhecido.
>
> Vetar a alteração do prenome do transexual redesignado corresponderia a mantê-lo em uma insustentável posição de angústia, incerteza e conflitos, que inegavelmente atinge a dignidade da pessoa humana assegurada pela Constituição Federal. No caso, a possibilidade de uma vida digna para o recorrente depende da alteração solicitada. E, tendo em vista que o autor vem utilizando o prenome feminino constante da inicial, para se identificar, razoável a sua adoção no assento de nascimento, seguido do sobrenome familiar, conforme dispõe o art. 58 da Lei nº 6.015/73.
>
> Assegurar ao transexual o exercício pleno de sua verdadeira identidade sexual consolida, sobretudo, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, cuja tutela consiste em promover o desenvolvimento do ser humano sob todos os aspectos, garantindo que ele não seja desrespeitado tampouco violentado em sua integridade psicofísica. Poderá, dessa forma, o redesignado exercer, em amplitude, seus direitos civis, sem restrições de cunho discriminatório ou de intolerância, alçando sua autonomia privada em patamar de igualdade para com os demais integrantes da vida civil. A liberdade se refletirá na seara doméstica, profissional e social do recorrente, que terá, após longos anos de sofrimentos, constrangimentos, frustrações e dissabores, enfim, uma vida plena e digna" (STJ, Ac. Unân., 3ª T., REsp. 1.008.398/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.10.09, *DJU* 18.11.09).

É possível, pois, a modificação do nome da pessoa que se submeteu à cirurgia de mudança de sexo, como, aliás, aludido alhures, ao tratar do direito à integridade física como expressão dos direitos da personalidade.

No ponto, inclusive, vaticinamos uma discussão que se apresentará com importante eficácia prática. O transexual não operado também pode reclamar o direito de modificação de seu nome e estado sexual? O tema já se põe na agenda do dia da ciência jurídica.[317] De nossa parte, entendemos possível a alteração do nome mesmo não tendo se realizado procedimento cirúrgico de transgenitalização, uma vez que o assunto deve ser refletido à luz da dignidade humana e de prova efetiva da situação fática do transexual. Afinal de contas não se pode reduzir o estado sexual de uma pessoa a um aspecto meramente genital.

Pontue-se, ainda, que a via processual adequada para a obtenção da redesignação de estado sexual não é a ação de retificação de registro civil, contemplada no art. 109 da Lei de Registros Públicos, mas sim um procedimento especial de jurisdição voluntária, com pedido de mudança de estado sexual da pessoa. É a chamada *ação de redesignação do estado sexual*, que será processada no juízo da vara de família,

317. Há um precedente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negando o pleito de mudança de nome e de estado sexual formulado por um transexual não operado: "o Apelante pleiteia alteração do nome e de sexo no registro civil, afirmando que desde tenra idade, apesar da conformação genital masculina, psicologicamente se sente mulher, fazendo-se tornar conhecido pelo prenome de Milena. Todavia, o recorrente ainda não se submeteu à cirurgia de mudança de sexo, o que não permite alteração do nome e do sexo em seu registro civil." (TJ/BA, Ac. 4a Câm. Cív., Ap. Cív. 03683226420128050001, rel. Des. José Olegário Monção Caldas, j. 15.10.13).

por se tratar de ação de estado,[318] e não na vara de registros públicos. Cuida inclusive, de regra de competência absoluta, podendo (aliás, devendo ser control de ofício pelo juiz).

5.5 O uso de nome social

Caminhando pela trilha de inclusão social e cidadania desbravada pela Co tituição da República, o Decreto nº 8.727/16 autorizou o uso do *nome socia* reconhecimento de identidade de gênero, por travestis e transexuais no âmb da Administração Pública Federal. Trata-se de hipótese autorizadora de utiliza de nome social nos atos e procedimentos do Poder Público, a partir de requ mento administrativo do interessado, sendo vedadas expressões discriminató ou pejorativas.

Segundo a dicção do Parágrafo Único do art. 1º do aludido Decreto, o n social é a "designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifi é socialmente reconhecida".

Sob o ponto de vista prático, significa que, nos órgãos do Poder Púb Federal (como, por exemplo, universidades, autarquias, ministérios, empr públicas etc.), uma pessoa, servidora pública, ou não, tenha o direito de identificada em todas os documentos, atos e procedimentos pelo nome iner à sua identidade de gênero. É o caso dos travestis e dos transexuais, oper ou não, que ainda não alteraram os seus registros civis de nascimento.

Considerando o evidente fundamento do nome social, que é o respei dignidade humana no que tange à identificação de gênero, entendemos qu demais esferas do Poder Público, estadual e municipal, e as pessoas jurídica direito privado (como, por exemplo, estabelecimentos comerciais em relação seus empregados) devem respeitar a opção de uso do nome social. Isso po se trata, em última análise, de aplicação da tese da *eficácia horizontal dos d tos fundamentais*, conferindo aplicação direta do direito à identidade sexual âmbitos público e privado, independentemente da existência de norma especí Não se olvide, a propósito, que a Corte Suprema brasileira já asseverou a efi direta dos direitos fundamentais nas relações privadas, independentement lei expressa (STF, Ac. Tribunal Pleno, RE 201.819/RJ, rel. Min. Gilmar Mend

Vale o registro de que a possibilidade de uso de nome social não imp em alteração no registro civil em cartório, onde permanecerá o nome origin até que se obtenha autorização do juiz para a modificação do nome junt Registro Público. Exatamente por isso, nos registros da Administração Pú devem constar, expressamente, o nome social e o nome originário do titular 3º do Decreto).

318. Com esse pensar, Maria Berenice Dias. *União homossexual*: o preconceito e a justiça, op. cit., p. 128

5.6 O nome comercial

Nome comercial é o critério de identificação da pessoa jurídica ou do comerciante individual, podendo se consubstanciar através de *firma comercial* ou *denominação social*.

Como ensina Francisco Amaral, "*firma ou razão comercial* é o nome sob o qual o comerciante ou a sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes", enquanto "*denominação* é apenas o nome da sociedade". E, então, conclui: "exemplo de firma – M. Santos & Cia. Ltda.; exemplo de denominação – Petrobras".[319]

Além disso, a pessoa jurídica pode assumir uma marca de fantasia (ou nome de fantasia), dizendo respeito à expressão pela qual é conhecida. É o exemplo da "*Coca-Cola*".

A proteção do nome comercial e da marca (assim como a tutela do nome de domínio na Internet, que também conta com a tutela legal) é relativa, abrangendo a área empresarial em que atua o titular, não se podendo impedir que empresas que atuam em outros ramos do mercado se valham do mesmo nome. Imagine-se que a tutela dispensada ao *Sistema Globo de Comunicações* não pode impedir a utilização da marca "*Globo*" por uma farmácia ou por uma transportadora.[320] É conveniente ressalvar, porém, que o art. 126 da Lei nº 9.279/96 reconhece, expressamente, que *a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade "goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil"*, consolidando hipótese típica de concretização do princípio da confiança. Dessa maneira, se um nome comercial vem sendo utilizado notoriamente, inclusive com a sua respectiva marca, outro não poderá registrá-lo, em razão da consolidação ocorrida no seio social.

Ressalte-se que todas as formas de identificação da pessoa jurídica encontram-se protegidas por lei, gozando de tutela preventiva e repressiva, inclusive com esteio na Lei nº 9.279/96 – que regulamenta a proteção à propriedade industrial (marcas industriais).

5.7 A tutela jurídica do nome civil

Optou o legislador de 2002 por estampar, expressamente, a proteção jurídica do nome civil, estabelecendo, nos arts. 17 e 18:

---

319. AMARAL, Francisco. *Direito Civil*: introdução, op. cit., p. 273.

320. Nesse sentido, há interessante precedente: "Medida cautelar visando à proteção de nome comercial (Curitiba OnLine Ltda.), marca (Curitiba OnLine) e nome de domínio ("curitibaonline.com.br"). Presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora. [...] Acrescente-se que esta Câmara tem assentado o entendimento de que é relativa a proteção conferida ao nome comercial e à marca, não incidindo quando as empresas atuam em ramos do mercado diferentes e visando consumidores distintos. A possibilidade de confusão ou associação das marcas pelo consumidor importa a vedação do registro da marca, consoante prescrito no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96" (TJ/PR, Ac. 1ª Câm. Cív., Agr. Instr. 96.683-0 e 98.295-8 – Comarca de Curitiba, rel. Des. Ulysses Lopes, j. 28.11.00, *DJ* 12.2.01).

> Art. 17, Código Civil:
>
> "O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória."
>
> Art. 18, Código Civil:
>
> "Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial".

Na verdade, trata-se da própria tutela jurídica dos direitos da perso garantida a proteção preventiva e repressiva ao uso indevido do nome po (seja nome de pessoa natural ou de pessoa jurídica). Nessa linha de intel de se concluir que é possível a utilização de ações de proibição de uso de de reclamação pelo indevido uso do nome (como formas de prevenir o dano propagação), além da ação reparatória de danos. Tudo isso sem prejuízo da das providências contempladas no art. 497 do Código de Processo Civil c através de tutela específica.[321]

Aliás, do uso indevido do nome (da pessoa natural ou jurídica) é poss decorram prejuízos de ordem patrimonial ou extrapatrimonial,[322] reparáveis de ação indenizatória. A hipótese é de responsabilidade objetiva, na medida não se discute a culpa pela indevida utilização do nome alheio. De fato, a rização do ilícito, nesse caso, decorre do puro e simples uso de nome alh fins comerciais, caracterizado o dano pelo próprio ato – é o que se denomi prova *in re ipsa* do dano.

Ademais, ampliou o Texto Codificado a proteção jurídica do nome para a também, o *pseudônimo* (utilizado para atividades lícitas), como reza o ar Estatuto Substantivo.[323]

In fine, cumpre destacar que a Lei nº 10.695/03, abraçando ideais ga e de intervenção mínima do Estado, revogou o tipo penal do art. 185 do Có pressivo, deixando de caracterizar delito a usurpação de nome ou pseudônim

321. Art. 497, Código de Processo Civil: "na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de n juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que as obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente."

322. Nesse sentido, José Roberto Neves Amorim. *Direito ao nome da pessoa física*, op. cit., p. 94 ss.

323. A jurisprudência já tinha firmado posição nesse sentido: "A utilização de pseudônimo notório s zação do legítimo titular implica perdas e danos" (TJ/SP, *RJTJSP-Lex* 98: 232-4).